

Alexandre Teixeira

**CURSO DE
PRÁTICA TRABALHISTA
2ª FASE DA OAB**

**VOLUME I – TEORIA
27ª Edição**

SATE

SISTEMA ALEXANDRE TEIXEIRA DE ENSINO

2026

CURSO DE PRÁTICA TRABALHISTA 2ª FASE DA OAB

VOLUME I – TEORIA

27ª Edição

SATE

SISTEMA ALEXANDRE TEIXEIRA DE ENSINO

2026

Curso de Prática Trabalhista – 2ª Fase da OAB – Volume I – Teoria

Copyright© 2026 – TEIXEIRA, Alexandre.

Conselho editorial: Alexandre Teixeira / Aline Barbosa Mesquita/ Andressa Portes / Carolina Gondim Rocha Alves

Central de atendimento: Tel.: (85) 99681-5000

Fortaleza/CE

Revisão e organização: Andressa Portes

Capa e Diagramação: Gilderley (Gil)

TEIXEIRA, Alexandre. Curso de Prática Trabalhista – 2ª Fase da OAB – Volume I – Teoria, Alexandre Teixeira – Fortaleza – Ceará: Eu Vou Passar na OAB, 2026. 261p., 27ª Edição Revista, Atualizada e Ampliada.

SATE Editora/ 2026 – CNPJ: 21.802.828/0001-33

ISBN: 978-65-987215-3-4

1. Direito do Trabalho. I. Teoria 2. Ordem dos Advogados do Brasil - Exames, questão etc. I. Título. II. Série.

25-271323 CDU – 34:331

Todos os direitos reservados. Nenhum excerto desta obra pode ser reproduzido ou transmitido, por quaisquer formas ou meios, ou arquivado em sistema ou banco de dados, sem a autorização do autor.

NOTA DA EDITORA

As informações e opiniões apresentadas nesta obra são de inteira responsabilidade do(s) autor (es).

A SATE Editora se responsabiliza apenas pelos vícios do produto no que se refere à sua edição, considerando a impressão e apresentação. Vícios de atualização, opiniões, revisão, citações, referências ou textos compilados são de responsabilidade de seu(s) idealizador (es).

Impresso no Brasil

Impressão gráfica: SATE Editora

Índice

Capítulo 1 – Reclamação Trabalhista.....	06
Capítulo 2 – Vínculo Empregatício	14
Capítulo 3 – Contrato de Trabalho	19
Capítulo 4 – Rescisão do contrato de trabalho.....	34
Capítulo 5 - Verbas Trabalhistas Rescisórias e Indenizatórias.....	50
Capítulo 6 - Alteração Contratual.....	77
Capítulo 7– Jornada de trabalho.....	85
Capítulo 8– Remuneração e salário	101
Capítulo 9 – Estabilidade, Reintegração e Antecipação de Tutela	121
Capítulo 10 – Inquérito Judicial para Apuração de Falta Grave	150
Capítulo 11– Dano e sua indenização.....	155
Capítulo 12– Defesa Trabalhista.....	158
Capítulo 13 – Ação de Consignação em Pagamento.....	200
Capítulo 14 – Ação de Cumprimento.....	204
Capítulo 15 – Recursos no Processo Trabalhista.....	206
Capítulo 16– Pressupostos Recursais.....	210
Capítulo 17 – Recurso Ordinário.....	220
Capítulo 18 – Recurso Adesivo.....	231
Capítulo 19– Recurso de Revista.....	232
Capítulo 20 – Embargos de Divergência.....	241
Capítulo 21– Recurso Ordinário Constitucional.....	242
Capítulo 22 – Ações Possessórias.....	246
Capítulo 23– Agravo de Instrumento.....	251
Capítulo 24 – Execução.....	254

Capítulo 1

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA

1. PARA QUE SERVE UMA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA?

A petição inicial de reclamação trabalhista é um dos meios através dos quais se pode dar início a uma ação trabalhista em que, por exemplo, o empregado requer que o Poder Judiciário condene o empregador a dar, fazer, deixar de fazer ou pagar alguma coisa.

Existem outras petições que também podem dar início a um processo judicial, tais como as ações possessórias, consignação em pagamento, mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, ação rescisória, ações cautelares, ação de cumprimento, inquérito judicial para apuração de falta grave, ações ordinárias etc. Todas serão estudadas nos próximos capítulos.

2. REQUISITOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA

Os requisitos da Reclamação Trabalhista estão descritos no **§1º do art. 840 da CLT**, e, de forma simplificada, são: endereçamento, qualificação das partes, uma breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, data e assinatura.

Art. 840, CLT- A reclamação poderá ser escrita ou verbal.

§ 1º - Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do Presidente da Junta, ou do juiz de direito a quem for dirigida, a qualificação do reclamante e do reclamado, uma breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante.

Endereçamento

1 ou 2 linhas

Qualificação

Fatos

Entre os fatos e o pedido deve haver uma correlação lógica, sob pena de inépcia.

Pedidos

(incluindo o de notificação da reclamada e de produção de provas)

Valor da causa

Data

Nome do Advogado

OAB

2.1. Qualificação das partes

Na petição de reclamação trabalhista, ambas as partes devem ser qualificadas. A CLT apenas prevê a qualificação, mas não delimita o que vem a ser a qualificação. Dada à omissão, por força do **art. 769 da CLT**, aplica-se ao caso o **artigo 319, do CPC/15** que dispõe que qualificar é identificar o reclamante e reclamado através dos nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência. Qualquer outra informação é desnecessária¹.

O item 3.5.9 do edital de abertura do Exame de Ordem Unificado² veda que o candidato identifique a prova na qualificação, de modo que esta deverá ser feita levando-se em conta as informações que estejam efetivamente no caderno de provas. Por exemplo, se o caderno de provas informou que o reclamante é PEDRO DA SILVA e que ele é mecânico, a qualificação ficará assim, de acordo com o edital: PEDRO DA SILVA, estado civil..., mecânico, domicílio..., residência ... (...).

Na parte da qualificação, o examinando deverá, ainda, indicar a peça processual correta com a devida menção ao dispositivo legal, nos termos do item 4.2.6.1. do Edital³.

2.2. Fundamentação Fática e Jurídica (Fórmula mágica)

¹ Vide espelhos de prova de todos os exames de ordem unificados OAB/FGV que podem ser obtidos em <http://oab.fgv.br>

² “Na elaboração dos textos da peça profissional e das respostas às questões práticas, o examinando deverá incluir todos os dados que se façam necessários, sem, contudo, produzir qualquer identificação além daquelas fornecidas e permitidas no caderno de prova. Assim, o examinando deverá escrever o nome do dado seguido de reticências (exemplo: “Município...”, “Data...”, “Advogado...”, “OAB...”, etc.). A omissão de dados que forem legalmente exigidos ou necessários para a correta solução do problema proposto acarretará em descontos na pontuação atribuída ao examinando nesta fase”.

³ “A indicação correta da peça prática é verificada no *nomem iuris* da peça concomitantemente com o correto e completo fundamento legal usado para justificar tecnicamente a escolha feita.

Todo pedido feito numa inicial de Reclamação Trabalhista deve ter sua fundamentação fática, que são os motivos, as razões, as circunstâncias e os porquês de cada pedido.



Dessa forma, para que a tese fique nos exatos padrões da OAB/FGV, basta aplicar a fórmula mágica:

É que ... (O que o empregador fez de errado)

E daí? (Diga o direito e explique)

Pelo que requer ... (Faça o pedido)

Nos termos de ... (Súm, OJ, Lei)

ATENÇÃO! De acordo com exames anteriores, a menção correta ao dispositivo de Lei, Constituição, Súmula ou OJ, sem a respectiva fundamentação jurídica, é considerada como mera menção ao dispositivo pela OAB e não é devida qualquer pontuação. Assim, a menção ao dispositivo, para pontuar, deve ser precedida por uma consistente fundamentação jurídica (causa de pedir).

2.2.1. Posso inventar fatos?

É proibido inventar informações na prova, devendo-se colocar apenas aquelas que a questão trouxer.

Ex.: Se a questão disser que o reclamante é operador de telemarketing, coloque essa informação na qualificação, porém, caso a questão não se manifeste sobre sua ocupação, coloque apenas “ocupação”, nos termos do item 3.5.8 do Edital.

2.2.2. Devo abrir um tópico para cada item pedido na reclamação trabalhista?

Sim. É importante (não obrigatório) que, para cada tese a ser discutida na Reclamação Trabalhista, exista um tópico correspondente, de modo a deixar a peça redigida bem organizada, o que facilitará a compreensão e correção da mesma pelo examinador.

EXEMPLO: caso faça pedido de pagamento de horas extras, seria interessante abrir um tópico **I – DAS HORAS EXTRAS** ou se o pedido é o de vínculo empregatício: **II – DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO** e assim por diante.

Cada tópico deverá conter sua própria fundamentação fática e jurídica, acompanhada da menção ao dispositivo da Constituição Federal, da Consolidação das Leis do Trabalho, da legislação esparsa, das Súmulas do STF, STJ e TST, e nas Orientações Jurisprudenciais do TST. **O conteúdo de cada desses tópicos deverá obrigatoriamente constar no pedido.**

2.3. Data e assinatura

Ao final de sua petição reclamação trabalhista, nos termos do **§ 1º do art. 840 da CLT**, o candidato deverá datar e assinar. No entanto, os itens 3.5.7⁴ e 3.5.8 do Edital de Abertura vedam qualquer tipo de identificação, assim, quando da elaboração da peça profissional, o candidato deverá utilizar apenas a expressão “CIDADE de DIA de MÊS de ANO” e a palavra “ADVOGADO...”. Ao texto que contenha outra assinatura, será atribuída nota 0 (zero), por se tratar de identificação do examinando em local indevido.

2.4. Pedido

O primeiro pedido que deve ser feito numa reclamação trabalhista é o **JULGAMENTO TOTALMENTE PROCEDENTE DA RECLAMAÇÃO** que vale, em média 0,40 (quarenta décimos).

Em segundo, deve-se atentar que dos fatos narrados deve decorrer logicamente a conclusão, essa é a exigência, *contrario sensu*, do **inc. III, §1º, art. 330, CPC/15**. Assim, se nos fatos foi narrada uma situação em que o empregado prestou serviços extraordinários sem o devido pagamento, o pedido lógico é o pagamento destas horas com o adicional de 50% sobre o valor da hora normal, integração ao salário e reflexo nas demais verbas trabalhistas.

Com a reforma trabalhista, a redação do **§ 1º do art. 840 da CLT** passou a exigir a liquidação dos pedidos, ou seja, além de o pedido dever ser certo ou determinado, o reclamante deve indicar o seu valor. No entanto, para a prova da segunda fase da OAB, a Fundação Getúlio Vargas – e nem o CESPE (2006 a 2010) – exigirá cálculos com valores, devendo o aluno, em sua peça de reclamação

⁴ Quando da realização das provas prático-profissionais, caso a peça profissional e/ou as respostas das questões práticas exijam assinatura, o examinando deverá utilizar apenas a palavra ADVOGADO...”. Ao texto que contenha outra assinatura, será atribuída nota 0 (zero), por se tratar de identificação do examinando em local indevido.

trabalhista, apenas sinalizar uma liquidação com a utilização do R\$ _____ (erre, cifrão e tracinho), na seguinte forma: “(...) requer a condenação do reclamado ao pagamento de duas horas extras por dia, de 22.06.2015 a 03.03.2018, de segunda à sexta-feira, no valor de R\$ _____.”

2.4.1. Cumulação de pedidos: sucessivos a alternativos

No processo do trabalho também se admite a cumulação de pedidos, por aplicação subsidiária do processo civil (**art. 769, CLT**). Na verdade, o **art. 327 do CPC/15** admite a cumulação de pedidos num único processo contra o mesmo réu, ainda que entre os pedidos não haja conexão:

***Art. 327, CPC/15.** É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.*

§ 1º São requisitos de admissibilidade da cumulação que:

I - os pedidos sejam compatíveis entre si;

II - seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;

III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.

§ 2º Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a cumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum.

§ 3º O inciso I do § 1º não se aplica às cumulações de pedidos de que trata o art. 326.

A cumulação de pedidos pode se dividir em: pedidos sucessivos e alternativos.

O caso clássico de alternatividade de pedidos é, por exemplo, quando se postula a reintegração do empregado estável. No entanto, não sendo possível a reintegração dada à incompatibilidade entre empregado e empregador resultante do dissídio, a condenação ao pagamento da indenização do período estável, nos termos do **art. 496 da CLT**.

Numa reclamação trabalhista, pedidos alternativos podem ser feitos desta maneira: “Diante do exposto, reclamante requer o julgamento totalmente procedente da presente ação para condenar o empregador a reintegrar o empregado. Não sendo possível (a reintegração), dada a incompatibilidade, seja o reclamado condenado a indenizar o período estável (...).”

3. DEVO PEDIR A NOTIFICAÇÃO OU CITAÇÃO DA RECLAMADA?

Sim. Apesar de a notificação da reclamada no processo do trabalho ser automática e de responsabilidade da Vara do Trabalho (**art. 841, caput, CLT**), em exames anteriores, nos termos do **art. 319, CPC/15**, foi exigido o pedido de notificação sob pena de não pontuação.

4. DEVO PROTESTAR PELA PRODUÇÃO DE PROVAS?

Sim. Ainda que no processo do trabalho não haja a exigência de produção de provas pelas partes (**arts. 825 e 845, CLT**), uma vez que as partes comparecerão à audiência acompanhadas de suas testemunhas, sendo este o momento em que produzirão as demais provas (**art. 845, CLT**).

5. DEVO MENCIONAR O VALOR DA CAUSA?

Sim. Muito embora na hipótese de à causa não ter sido atribuído qualquer valor, devendo o juiz atribuir o valor para efeito de alçada (**art. 2º, Lei 5.584/70**), como já exigido em exames anteriores, deve-se atribuir à causa um valor, conforme **art. 292, VI, CPC**. Note, porém, que não se deve criar valores, devendo o candidato, conforme edital, fazer a seguinte menção: “Dá-se à causa o valor de R\$...”.

6. DEVO PEDIR OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA?

Sim. Existe uma presunção de pobreza quando se trata do empregado, uma vez que quase sempre este empregado deixa para entrar com sua Reclamação Trabalhista quando já perdeu o emprego, o que perfaz o requisito do **§ 3º do art. 790, CLT**.

7. DEVO FAZER PEDIDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS?

SIM. Com a reforma trabalhista, serão devidos pela parte vencida ao advogado da parte vencedora, honorários advocatícios de sucumbência entre 5% (cinco por cento) e 15% (quinze por cento) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Assim, ao final da petição inicial, deverá o aluno pedir a condenação do

reclamado ao pagamento dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação liquidada.

8. VERBAS TRABALHISTAS RESCISÓRIAS E INDENIZATÓRIAS

As verbas trabalhistas rescisórias e indenizatórias são aquelas devidas, geralmente, na rescisão do contrato de trabalho e que deveriam ter sido pagas no fim do contrato de trabalho.

- Aviso Prévio / Saldo de salários / 13º proporcional / 13º vencido
- Férias proporcionais + 1/3 / Férias vencidas simples + 1/3 / Férias vencidas dobradas + 1/3
- Levantamento depósitos FGTS
- Indenização 40% FGTS

9. TESES TRABALHISTAS

- Vínculo empregatício
- Assédio moral/rescisão indireta
- Estabilidade/Reintegração
- Dano material/moral/estético/existencial
- Nulidade do contrato/alteração/dispensa Retificação da CTPS
- Terceirização
- Horas extras
- Horas noturnas
- Insalubridade
- Periculosidade
- Comissões/Gratificações legais/Gorjetas
- Adicional de transferência

- Repouso e feriados
- Equiparação salarial
- Indenização do art. 9º, lei 7238/84

10. VERBAS SECUNDÁRIAS OU ACESSÓRIAS

Verbas secundárias ou acessórias são aquelas devidas em decorrência da inadimplência do empregador.

- Multa § 8º do art. 477 da CLT
- Multa do art. 467 da CLT
- Guias seguro-desemprego
- Guias levantamento FGTS
- Justiça gratuita
- Honorários advocatícios

Capítulo 2

VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1. INTRODUÇÃO

A tese de reconhecimento de vínculo empregatício é usada quando o empregador não tiver assinado nem anotado a CTPS do empregado, não reconhecendo a existência de sua condição de empregado, portanto, o pedido principal da reclamação trabalhista será o reconhecimento do vínculo, anotação e baixa na CTPS do empregado. Baixar a CTPS do empregado significa anotar a data de rescisão do contrato de trabalho e, caso o empregador não faça isso de forma espontânea, deve-se requerer judicialmente.

Existem três categorias de empregados: empregado urbano, empregado doméstico e empregado rural.

2. CATEGORIAS DE EMPREGADOS

2.1. Empregado Urbano

2.1.1. Definição legal

Para que um trabalhador seja caracterizado como empregado, deve prestar serviços **não-eventuais com pessoalidade, subordinação e com a intenção de receber salários**. A ausência de qualquer um desses elementos retira do trabalhador sua qualidade de empregado, podendo aparecer figuras diversas tais como os autônomos, eventuais, avulsos, diaristas etc..

A pessoalidade significa que somente o empregado contratado é quem poderá prestar o serviço, pois o empregador ao contratar o empregado leva em consideração a pessoa do empregado.

2.1.2.3. Não-eventualidade (habitualidade ou permanência)

Habitualidade ou permanência é a prestação de serviços nas atividades normais ou permanentes da empresa.

Toda empresa tem as suas chamadas atividades ou necessidades normais ou permanentes. Ela desenvolve certas atividades, atividades-fim e atividades-meio.

**Necessidades normais
ou permanentes**

Atividade-fim: São as atividades normais da empresa sem as quais a empresa deixa de existir.

Atividade-meio: São as atividades secundárias, mas que viabilizam dando apoio e suporte à atividade-fim.

O trabalhador que presta serviços nas necessidades normais/permanentes de uma empresa, presta serviços **não-eventuais**, portanto é um trabalhador não-eventual.

A não-eventualidade **não está relacionada à quantidade de dias trabalhados**. Pode-se trabalhar um dia só na semana e ser empregado, desde que a prestação de serviços daquele empregado seja necessária com habitualidade à determinada empresa ou empregador.

2.1.2.4. Subordinação

É quando o empregador determina ao empregado os horários de trabalho, o modo de realizar o trabalho em sua quantidade e qualidade, por exemplo.

2.1.2.5. Onerosidade/intenção de receber salários

O empregado, ao prestar serviços de natureza não eventual e subordinado, o faz com a **intenção de receber salário**.

TESE DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA NA RECLAMAÇÃO:

OBS: Grifar as palavras destacadas na CLT!

As teses da peça são basicamente a junção das palavras destacadas nos artigos com as informações que a peça traz, observe:

***Art. 2º, CLT.** Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.*

Art. 3º, CLT - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza **não eventual** a empregador, sob a **dependência deste e mediante salário**.

Art. 13, CLT - A Carteira de Trabalho e Previdência Social é obrigatória para o exercício de qualquer emprego, inclusive de natureza rural, ainda que em caráter temporário, e para o exercício por conta própria de atividade profissional remunerada.

Art. 29, CLT. O empregador terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para **anotar na CTPS**, em relação aos trabalhadores que admitir, a data de admissão, a remuneração e as condições especiais, se houver, facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério da Economia.

O reclamante tem direito ao reconhecimento do vínculo empregatício, com **anotação e baixa na CTPS**, pois trabalhava com **habitualidade** (X dias na semana), com subordinação (dados que caracterizam subordinação), e com onerosidade, (mediante salário, recebendo a quantia de R\$___), nos termos dos

2.2. Empregado Doméstico

O **artigo 1º da Lei Complementar n. 150/2015** conceitua empregado doméstico como sendo *aquele que presta serviços de natureza **contínua, subordinada, onerosa, pessoal**, de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas, por **mais que 02 (dois) dias na semana***.

Primeiramente, é válido destacar a diferença entre continuidade e não eventualidade:

CONTINUIDADE	NÃO-EVENTUALIDADE
Está diretamente ligada à quantidade de dias da semana em que o empregado presta serviço.	Não guarda relação com a quantidade de dias em que o empregado presta serviços.

Dito isso, o empregado doméstico é aquele que presta serviços de natureza contínua **por mais de 02 vezes por semana**. Dessa forma, a continuidade é a prestação de serviço superior a 02 vezes por semana ou a partir de 03 vezes por semana, sendo este o atual entendimento do TST.

2.2.1. Diarista Doméstico

O diarista doméstico é aquele que presta serviços no âmbito residencial à pessoa ou família, sem finalidade lucrativa, por **até 02 vezes por semana** (art. 1º da LC 150). Ele não tem vínculo empregatício, tendo direito tão somente à remuneração pactuada, sendo esta paga ao final do dia – daí o nome diarista. Logo, o pagamento da remuneração do diarista não pode ser acumulado para cada 15 dias ou para o fim do mês.

É doméstico o caseiro de sítio de veraneio do empregador, desde que não se realize na propriedade, produção para fins de comercialização. Caso exista exploração agro econômica com venda a terceiros, restará descaracterizado o vínculo de trabalho doméstico com o caseiro e este será empregado rural.

TESE DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DOMÉSTICO NA RECLAMAÇÃO:

OBS: Grifar as palavras destacadas na CLT!

As teses da peça são basicamente a junção das palavras destacadas nos artigos com as informações que o caso traz, observe:

*Art. 1º, LC 150/2015 - Ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviços de forma **contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa** à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas, por **mais de 2 (dois) dias por semana**, aplica-se o disposto nesta Lei.*

Art. 13, CLT - A Carteira de Trabalho e Previdência Social é obrigatória para o exercício de qualquer emprego, inclusive de natureza rural, ainda que em caráter temporário, e para o exercício por conta própria de atividade profissional remunerada.

*Art. 29, CLT. O empregador terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para **anotar na CTPS**, em relação aos trabalhadores que admitir, a data de admissão, a remuneração e as condições especiais, se houver, facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério da Economia.*

A reclamante tem direito ao reconhecimento do vínculo empregatício como doméstica, com **anotação e baixa na CTPS**, pois trabalhava com **continuidade, por mais de 2 (dois) dias na semana**, com **subordinação** (dados que caracterizam subordinação), e com **onerosidade**, (mediante salário, recebendo a quantia de R\$__ mensais), nos termos do Art. 1º da LC 150/2015, e Arts. 13 e 29 da

2.3. Empregado rural

Com o advento da **Lei 5889/73**, o empregado rural passou a ser definido por seu **art. 2º** da seguinte maneira: *empregado rural é toda pessoa física que, em propriedade rural ou prédio rústico, preste serviços de natureza não eventual a empregador rural, mediante dependência e salário.*

2.3.1. Prestação de serviços a empregador rural: não importa se o empregado exerce atividade tipicamente urbana como os administradores de fazenda, os almoxarifes, os datilógrafos, os motoristas, se estes prestam serviços não-eventuais a empregador rural serão considerados empregados rurais⁵. O que define o empregado rural não é o tipo de função que exerce, se tipicamente urbana ou rural, mas, sim, a **atividade exercida pelo empregador**. Se eminentemente rural, seus empregados serão todos rurais, inclusive os datilógrafos, gerentes, almoxarifes, motoristas do estabelecimento rural.

Assim, empregado rural é quem presta serviços a empregador rural.

2.3.2. Prestação de serviços em propriedade rural: Entende-se por *propriedade rural* aquela localizada geograficamente na zona rural, em que nela é explorada uma atividade agroeconômica rural.

2.3.3. Prestação de serviços em prédio rústico: Prédio rústico é o destinado à exploração agrícola, pecuária ou extrativa vegetal. No entanto, está localizado geograficamente no espaço urbano.

⁵Súmula 196 STF: “Ainda que exerça atividade rural, o empregado de empresa industrial e comercial é classificado de acordo com a categoria do empregador”.

Capítulo 3

CONTRATO DE TRABALHO

1. CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO (art. 442 da CLT)

Ante a nova redação do **art. 114, CF**, necessário se faz realizar a distinção entre Relação de Trabalho e Relação de Emprego.

1.1. Relação de Trabalho versus Relação de Emprego: Relação de trabalho compreende as relações entre todos os tipos de trabalhadores e seus tomadores de serviços, tais como os trabalhadores autônomos, eventuais, empregados, avulsos etc. **Relação de emprego** diz respeito à relação jurídica entre empregado e empregador. Relação de trabalho é gênero donde relação de emprego é espécie.

1.2. Definição legal (art. 442, CLT): “Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego.”.

Toda relação jurídica de emprego decorrerá, necessariamente, de um contrato de emprego. Assim, não existe relação de emprego sem contrato de emprego. Muito embora esse contrato possa ser escrito ou verbal, sempre terá de haver o contrato de emprego.

É importante deixar claro que a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) não é o contrato de trabalho, mas sim só mais uma prova da relação de trabalho.

ATENÇÃO!!! **GRIFAR** AS PALAVRAS DESTACADAS NA CLT:

Art. 456, CLT. A prova do contrato individual do trabalho será feita pelas **anotações** constantes da carteira profissional ou por instrumento escrito e suprida por todos os meios permitidos em direito.

Na CTPS devem ser anotadas as condições especiais e os elementos principais da relação havida, tal como determina o **art. 29, caput da CLT**:

Art. 29 - O empregador terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para **anotar na CTPS**, em relação aos trabalhadores que admitir, a data de admissão, a remuneração e as condições especiais, se houver, facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério da Economia.

O fato de o empregador não ter assinado a carteira de trabalho não quer dizer que não haja contrato entre empregado e empregador, pois o vínculo de emprego decorre do contrato de trabalho, inclusive se esse contrato for verbal.

Logo, se a CTPS fosse o próprio contrato, a ausência de anotação implicaria a inexistência de vínculo empregatício entre as partes.

Art. 13, CLT - A Carteira de Trabalho e Previdência Social é **obrigatória para o exercício de qualquer emprego** temporário, e para o exercício por conta própria de atividade profissional remunerada.

Há casos em que as anotações na carteira de trabalho não refletem a realidade, como acontece muito no comércio, onde um empregado tem a CTPS assinada como vendedor e ganhando salário mínimo, quando na verdade desempenha as funções de gerente e recebe bem mais que o salário mínimo. Isso acontece porque o empregado precisa trabalhar e acaba se submetendo às ilegalidades do empregador.

Súmula 12 do TST. As anotações apostas pelo empregador na carteira profissional do empregado não geram presunção *juris et de jure*, mas apenas *juris tantum* (aditem prova em contrário).

É princípio do Direito do Trabalho e do Processo do Trabalho a *primazia da realidade sobre as formas*, que quer dizer que muito mais vale a realidade dos fatos do que a prova documental, pois esta muitas vezes não reflete a realidade.

Súmula 225 do STF. Não é absoluto o valor probatório das anotações de Carteira Profissional.

O contrato pode ser expresso ou tácito, sendo **expresso** aquele em que as partes manifestam expressamente a intenção de contratar, já o contrato **tácito**, tem manifestação de vontade, mas não de maneira expressa.

1.3. Condições do contrato individual de trabalho (art. 104, CC/2002):

Um contrato válido gera uma relação de emprego existente. Os elementos fático/jurídicos da relação de emprego estão previstos no **art. 3º da CLT**. Além dos elementos fático/jurídicos, existem também os elementos formais, constantes do **art. 104 do CC**.

O contrato de trabalho, como todo ato jurídico, seja bilateral seja unilateral, para ser efetivamente válido, exige 03 requisitos:

Art. 104, CC. A validade do negócio jurídico requer:

I- agente capaz;

II- objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III – forma prescrita ou não defesa em lei.

Assim, podemos concluir que, por mais que um trabalhador seja pessoa física, preste serviços com personalidade, que a prestação de serviços seja não-eventual, que os seus serviços estejam subordinados e que preste os serviços com intenção de receber salários (possuindo os cinco elementos fático-jurídicos), esse trabalhador será considerado empregado só e somente se o contrato de trabalho for válido.

5 ELEMENTOS FÁTICO-JURÍDICOS		3 REQUISITOS DE VALIDADE DO ATO JURÍDICO
- Pessoa física - personalidade - não-eventualidade - subordinação - onerosidade	+	- capacidade das partes - licitude do objeto - forma prescrita ou não defesa em lei

a) Capacidade das Partes

Algumas coisas no direito do trabalho são um tanto quanto diferentes do direito civil. Enquanto a capacidade civil começa aos 16 anos (dos 16 aos 18 anos há capacidade relativa) e aos 18 anos o sujeito é absolutamente capaz; a capacidade no direito do trabalho começa a partir dos **14 anos**, quando já se pode celebrar um contrato de trabalho, desde que, nesse caso, seja um contrato de aprendizagem. O aprendiz não precisa de autorização dos pais para celebrar um contrato de trabalho, basta que ele tenha 14 anos e uma CTPS (para que seja feita a devida anotação).

Art. 7º, XXXIII, CF - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

Art. 428, CLT. *Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 (quatorze) e menor de 24 (vinte e quatro) anos inscrito em programa de aprendizagem formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz, a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação.*

Art. 402, CLT. *Considera-se menor para os efeitos desta Consolidação o trabalhador de quatorze até dezoito anos.*

Art. 406, CLT - O Juiz de Menores poderá autorizar ao menor o trabalho a que se referem as letras "a" e "b" do § 3º do art.405

Os contratos de trabalho celebrados com menores de 14 anos são **contratos de trabalho nulos de pleno direito**, pois, por mais que a pessoa possua os cinco elementos fático-jurídicos, se não for agente capaz, o contrato de trabalho é nulo, e sendo nulo não se é empregado, porque além dos elementos fático-jurídicos, são precisos os elementos jurídicos formais.

De acordo com o entendimento do TST, no caso de nulidade do contrato de trabalho por incapacidade do agente, a relação de emprego é inexistente, mas **acaba gerando efeitos**, como o pagamento de salários e demais direitos trabalhistas. Esses efeitos são gerados até o juiz declarar o contrato como nulo (efeito *ex nunc* da sentença).

b) Licitude do objeto

Quando se fala na licitude do objeto, fala-se efetivamente da prestação de serviços, isso porque o objeto do contrato de trabalho é a prestação de serviços. A própria atividade realizada pelo empregado deve ser lícita.

Quando a própria prestação de serviços for ilícita, o contrato de trabalho será ilícito, pois o objeto é ilícito. Nessa situação o contrato será nulo e não gerará efeitos.

No jogo do bicho, por exemplo, tanto o banqueiro como o ‘apontador’ é contraventor. Nesse caso, o contrato de trabalho será nulo porque o objeto é ilícito, e nesses casos, o trabalhador não tem nenhum direito. Pode até ter várias verbas trabalhistas a receber, mas não terá nenhum direito a elas.

OJ 199, SDI-1, TST. É nulo o contrato de trabalho celebrado para o desempenho de atividade inerente à prática do jogo do bicho, ante a ilicitude de seu objeto, o que subtrai o requisito de validade para a formação do ato jurídico.

Manter casa de prostituição é crime, no entanto, não há tipo penal prevendo como ilícito penal as atividades desenvolvidas por manobrista em casa de prostituição, dançarinas e outros. Logo, o contrato desses trabalhadores é válido e gera todos os efeitos.

Em relação à prostituta em casa de prostituição, existe bastante divergência. Para os que entendem ser crime, o contrato de trabalho é nulo, não gerando quaisquer efeitos e para aqueles que entendem não ser crime, o contrato é válido.

Em se tratando de policial militar que trabalha como segurança particular, não há se falar em ilicitude (inexistência de previsão como contravenção ou crime) da prestação de serviços, logo o vínculo existe e o contrato válido gera todos os

efeitos.

Assim, consoante a Súmula 386, TST já consolidou esse entendimento:

Súmula nº 386 - TST - Preenchidos os requisitos do art. 3º da CLT, é **legítimo** o reconhecimento de relação de emprego entre **policia militar e empresa privada**, independentemente do eventual cabimento de penalidade disciplinar prevista no Estatuto do Policial Militar.

c) Forma prescrita ou não defesa em lei

A regra geral é que os contratos de trabalho não tenham formalidades. Eles são informais, não solenes. Mas alguns contratos de trabalho têm solenidade, como, por exemplo, o contrato de aprendizagem.

Se o empregador não obedecer às formalidades, o contrato é nulo. Esse contrato deixa de ser um contrato de aprendizagem e passa a ser um contrato por prazo indeterminado.

Na área pública, para manter-se com a administração pública, seja ela direta ou indireta, vínculo empregatício, é preciso que a formalidade do concurso público tenha sido respeitada, porque se não houver concurso público, esse contrato é nulo.

Mesmo com a decretação de nulidade do contrato por descumprimento da formalidade, esse contrato gera dois efeitos, que são: os direitos de receber os salários pelo tempo efetivamente trabalhado e os depósitos do FGTS.

Súmula Nº 363 do TST. A contratação de servidor público, após a CF/1988, **sem prévia aprovação em concurso público**, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.

Se uma pessoa assume um cargo público e após 02 anos seu concurso foi declarado nulo, com trânsito em julgado, esse concurso equivale a uma contratação sem concurso, ou seja, essa pessoa só terá direito de receber salários pelas horas efetivamente trabalhadas e os depósitos do FGTS.

O.J. 128, SDI-2. O certame público posteriormente anulado equivale à contratação realizada sem a observância da exigência contida no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988. Assim sendo, aplicam-se à hipótese os efeitos previstos no Enunciado nº 363 do TST.

A decisão que declara o concurso nulo tem efeitos *ex tunc*, assim, o concurso era nulo desde a data da sua realização, razão pela qual se aplica a **Súmula 363, TST**.

1.4. Duração do contrato de trabalho

1.4.1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.

Pelo *princípio da continuidade da relação de emprego*, os contratos de trabalho são, em regra, por prazo indeterminado. A relação de emprego surge para se perpetuar no tempo. Não há que se confundir continuidade com estabilidade.

O contrato por prazo determinado é uma exceção, sendo mais barato para o empregador e assegurando menos direitos aos trabalhadores. Por esse prisma é possível notar a incidência do *princípio da proteção*.

O contrato por prazo determinado extinto não gera, em regra, indenização, assim como, também em regra, não é compatível com as estabilidades provisórias.

Art. 443, CLT - *O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito e por prazo determinado ou indeterminado.*

1.4.2. Contrato de trabalho por prazo determinado

É a exceção, justificando seu aparecimento apenas em casos excepcionais, como estabelecido pelos **§§ 1º e 2º do artigo 443 da CLT**:

§ 1º. *Considera-se como de **prazo determinado** o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo prefixado ou da execução de serviços especificados ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada.*

§ 2º. *O contrato por prazo determinado **só será válido** em se tratando:*

- a) de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo (contratação de pessoal extra em época de natal);*
- b) de atividades empresariais de caráter transitório (feiras de negócios);*
- c) de contrato de experiência (qualquer atividade);*

Para que os contratos por prazo determinado sejam considerados válidos, deve haver um motivo especial, transitório, temporário que justifique a contratação por prazo determinado.

Se o empregador não preencher os legais requisitos para a contratação por prazo determinado, esse contrato passará a valer como contrato de trabalho por prazo indeterminado.

Vejam os cada uma das condições para a contratação por prazo determinado:

a) De serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do

prazo

Neste caso, a atividade empresarial não é transitória. A atividade empresarial é permanente, mas a necessidade de mais empregados é que é transitória e temporária.

No final de cada ano, por exemplo, abrem-se no comércio muitas vagas para contratação temporária em decorrência do aumento extraordinário no volume de vendas e as empresas precisam contratar mais empregados para atenderem o volume de vendas daquele período. Assim, quando houver aumento extraordinário de serviços e esse aumento justifique a contratação de mais empregados, esses contratos poderão ser por prazo determinado.

Também poderá haver contratação por prazo determinado nos casos de substituição provisória de pessoal permanente na empresa, como por exemplo, para substituir empregada que entrará em licença maternidade por 120 dias ou empregado aposentado por invalidez.

***Art. 475, CLT** - O empregado que for aposentado por invalidez terá **suspenso o seu contrato de trabalho** durante o prazo fixado pelas leis de previdência social para a efetivação do benefício.*

***§2º** - Se o empregador houver admitido substituto para o aposentado, poderá rescindir, com este, o respectivo contrato de trabalho **sem indenização**, desde que tenha havido ciência inequívoca da interinidade ao ser celebrado o contrato.*

b) De atividades empresariais de caráter transitório;

Nos contratos cuja natureza da atividade justifique a predeterminação do prazo do contrato.

É a atividade empresarial de caráter transitório do empregador que justifica a celebração de um contrato por prazo determinado. Não só a necessidade é transitória, mas a própria atividade do empregador é transitória.

Exemplo fácil é o caso dos carnavais fora de época.

c) Do contrato de experiência

A lei dispôs que o contrato de experiência fosse um contrato de trabalho por prazo determinado. Num país como o Brasil, em que a maioria dos profissionais não possui qualificação técnica, o empregador não tem como saber se o empregado corresponderá às necessidades do cargo, então a norma possibilitou que o empregador pudesse contratar por um período de experiência e avaliar o

empregado.

O contrato de experiência é um contrato por prazo determinado, em que, como qualquer outro, o empregado tem todos os direitos trabalhistas garantidos, e, portanto, deve ser anotado na CTPS, conforme o **artigo 13 da CLT**.

Art. 13, CLT - A Carteira de Trabalho e Previdência Social é **obrigatória para o exercício de qualquer emprego**, inclusive de natureza rural, ainda que em caráter temporário, e para o exercício por conta própria de atividade profissional remunerada.

O contrato de experiência, por **ausência de previsão legal, não precisa ser escrito**, pode ser, como qualquer outro contrato de trabalho, implícito ou explícito, mas sua natureza se demonstra incompatível com a pactuação implícita.

A anotação do contrato de experiência se faz necessária para provar a existência do contrato especial, mas não consiste em contrato de trabalho.

O contrato de experiência é um contrato de trabalho por prazo determinado que tem **validade máxima de 90 dias**. A prorrogação se dá dentro do prazo de 90 dias. Por exemplo, o tempo contratado inicialmente é de 45 dias e poderá ser prorrogado por mais 45 dias, não excedendo o limite de 90 dias.

Art. 445, Parágrafo único, CLT. O contrato de experiência **não poderá exceder de 90 (noventa) dias**.

Súmula Nº 188 do TST. O contrato de experiência pode ser prorrogado, respeitado o limite máximo de 90 (noventa) dias.

É importante ainda lembrar que a prorrogação não precisa necessariamente se dar por igual período (pode o prazo inicial ser de 30 dias e haver prorrogação por mais 60 dias), mas só poderá haver uma única prorrogação e não pode exceder os 90 dias.

1.4.2.1. Duração e prorrogação: de maneira geral, segundo a regra celetista, os contratos por prazo determinado não podem exceder a dois anos (**art. 445 CLT, caput**), sendo que o de experiência não poderá exceder a **90 dias** (parágrafo único, art. 445 CLT). Ambos prorrogáveis apenas uma **única vez**, desde que não ultrapassem os períodos do art. 445 (90 dias), sob pena de se consubstanciarem em contratos por prazo indeterminado, prorrogação esta que pode ser expressa ou tácita, porém deve constar do conteúdo contratual originário.

Na prorrogação não há extinção do contrato, somente houve aumento do

contrato já existente e está prevista no **art. 451, CLT**:

Art. 451. *O contrato de trabalho por prazo determinado que tácita ou expressamente, for prorrogado mais de uma vez, **passará a vigorar sem determinação de prazo.***

1.4.2.2. Sucessividade (sucessão de contratos): consiste na celebração de novo contrato a termo após a extinção próxima de um contrato anterior da mesma natureza. Segundo o **art. 452 CLT**, um contrato a termo somente pode ser lícitamente sucedido por outro, entre as mesmas partes, se transcorridos seis meses do contrato anterior. Desobedecida a regra, o segundo contrato transmudar-se-á para indeterminado (art.451, CLT)

Art. 452. *Considera-se por **prazo indeterminado** todo contrato que suceder, dentro de **seis meses**, a outro contrato por prazo determinado, **salvo se a expiração deste dependeu da execução de serviços especializados ou realização de certos acontecimentos.***

Os contratos por prazo determinado têm suas condições de validade (**art. 443, §2º, CLT**) e de existência (**Art. 443, §1º, CLT**).

§1º. *Considera-se como de **prazo determinado** o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo prefixado ou da execução de serviços especificados ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada.*

Essa existência está adstrita ao termo prefixado, à execução de serviços especificados ou à realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada.

Se o contrato por prazo determinado (CPD) para existir foi condicionado a uma data exata, o segundo CPD só vai ter validade como CPD se feito depois de *seis meses*.

No entanto, se a expiração do CPD dependeu da execução de serviços especializados ou realização de certos acontecimentos, o prazo de seis meses não precisa ser respeitado, consoante informa a parte final do art. 452 da CLT (***salvo se a expiração deste dependeu da execução de serviços especializados ou realização de certos acontecimentos***).

1.4.2.3. Contrato de Safra: é pacto empregatício rural a prazo certo, cujo termo final é fixado em função das variações estacionais da atividade agrária. A lei não exige solenidade para sua formação, apenas se recomenda forma escrita.

Previsto na **Lei 5.889/73, art. 14**, tem duração de – no máximo – 02 anos (porque o art. 1º da Lei do rural afirma que na omissão dela aplica-se a CLT).

O **art. 14-A, caput, §§1º e 3º da Lei 5.889/73** criou o contrato a **pequeno prazo** ou pequena safra. Este contrato é do meio rural, mas, diferentemente do de safra, ele dura – no máximo – dois meses dentro do período de um ano.

Exemplo: nos três primeiros meses do ano, uma Fazenda trabalha com feijão verde e, nos três seguintes, a mesma fazenda cultiva caju, podendo, então, fazer o contrato de pequeno prazo com trabalhadores para prestar seus serviços por no máximo dois meses dentro de um ano. Vale ressaltar que esse contrato a pequeno prazo **só pode ser celebrado por empregador pessoa física**, exigindo-se, sempre, que **o empregado seja inscrito na GFIP** (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social).

A anotação da CTPS do empregado rural contratado a pequeno prazo pode ser dispensada, na forma do **art. 14-A, §3º, I e II, da Lei 5.889/73**:

Mediante contrato escrito, em duas vias, uma para cada parte, onde conste, no mínimo:

- a) expressa autorização em acordo ou convenção coletiva;*
- b) identificação do produtor rural e do imóvel rural onde o trabalho será realizado e indicação da respectiva matrícula;*
- c) identificação do trabalhador, com indicação do respectivo Número de Inscrição do Trabalhador –NIT.*

Esse é o único caso de dispensa de anotação na CTPS de empregado.

1.4.2.4. Contrato por Obra Certa: é pacto empregatício urbano a prazo, qualificado pela presença de um construtor em caráter permanente no pólo empresarial e pela execução de obra (art. 1º, Lei nº 2.959/56). São três os requisitos: qualidade empresarial do empregador (deve ser este um construtor), motivo justificado da predeterminação do prazo e previsão de indenização por ruptura contratual. Os demais requisitos são os da CLT para os contratos por prazo determinado. A jurisprudência tem descartado esse contrato, prevalecendo a sua indeterminação.

1.4.2.5. Trabalho a Tempo Parcial: artigo **58-A, CLT**: “considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração **não exceda a trinta horas semanais**, sem a possibilidade de horas suplementares semanais, ou, ainda, aquele cuja duração não exceda a vinte e seis horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até seis horas suplementares semanais.”.

- 1.4.2.6. Contrato de Locação de Serviços:** prestação de serviços que tem por objeto a prestação de serviços de forma autônoma, isto é, não subordinada (regulado pelos **artigos 593 à 609 do CC/02**).
- 1.4.2.7. Contrato de Empreitada:** tem por objeto não a prestação de serviços, mas uma determinada obra, sem que haja o requisito empregatício da subordinação (regulado pelos **artigos 610 à 626 do CC/02**).
- 1.4.2.8. Subempreitada:** nos contratos de subempreitada responderá subempreiteiro pelas obrigações derivadas dos contratos de trabalho que celebrar, cabendo, todavia, aos empregados, o direito de reclamação, contra o empreiteiro principal pelo inadimplemento daquelas obrigações por parte do primeiro (**art.455, CLT**).
- 1.4.2.9. Dono da obra:** diante da inexistência de previsão legal, o contrato de empreitada entre o dono da obra e o empreiteiro não enseja responsabilidade solidária ou subsidiária nas obrigações contraídas pelo empreiteiro, salvo sendo o dono da obra uma construtora ou incorporadora⁶.
- 1.4.2.10. Contrato por Temporada:** pactos empregatícios direcionados à prestação do trabalho em lapsos temporais específicos e delimitados em função da atividade empresarial. **Exemplo tradicional:** contrato de trabalhador de hotel de veraneio, firmado, sucessivamente, ao longo de vários anos apenas com relação à prestação de serviços na respectiva temporada anual de verão.
- 1.4.2.11. Contrato de Pequena Empreitada:** é o pacto em que uma das partes é um trabalhador que realiza seus serviços só ou com, no máximo, um ou dois ajudantes na empreitada de obras de pequeno vulto, **artigo 652, “a”, inc. III CLT:** competência imprópria da Justiça do Trabalho.

⁶ Orientação Jurisprudencial 191 SDI-1: *“Dono da obra. Responsabilidade. Diante da inexistência de previsão legal, o contrato de empreitada entre o dono da obra e o empreiteiro não enseja responsabilidade solidária ou subsidiária nas obrigações contraídas pelo empreiteiro, salvo sendo o dono da obra uma construtora ou incorporadora”*.

2. TERCEIRIZAÇÃO

Ocorre terceirização quando existem relações entre pessoas jurídicas que envolvem prestações de serviços, sendo uma relação triangular, angularizada. Ao invés vez de contratar o empregado de forma direta, contrata-se uma empresa interposta, ou seja, contrata-se o empregado mediante terceiros.

SUM-331, TST - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação do item IV e inseridos os itens V e VI à redação) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011

I – (redação prejudicada).

II – A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, **não gera vínculo de emprego com os órgãos da Administração Pública** direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988).

III – (redação prejudicada).

IV – O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a **responsabilidade subsidiária** do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial.

V – Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta **respondem subsidiariamente**, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade **não decorre de mero inadimplemento** das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.

VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange **todas as verbas** decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral.

2.1. HIPÓTESES EM QUE A TERCEIRIZAÇÃO PODE SER REALIZADA

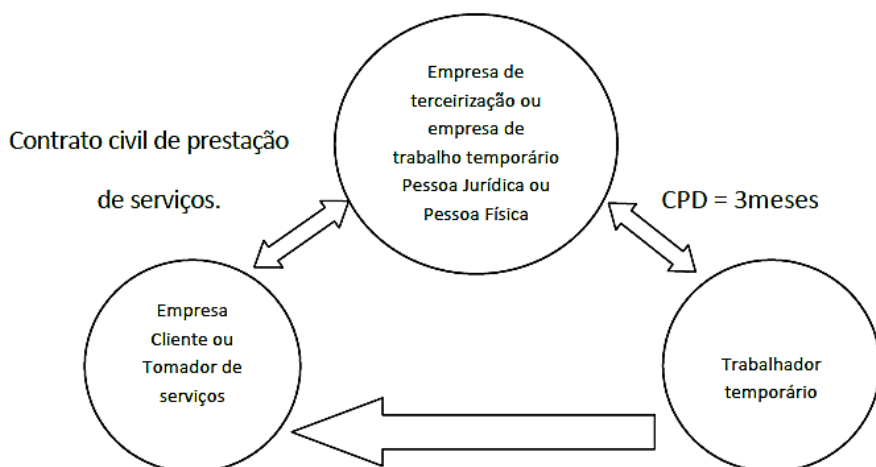
Existem exceções ao *princípio da contratação direta*, conforme prevê a parte final do **inciso I**, da Súmula transcrita, que trata dos trabalhadores contratados temporariamente (**Lei 13.429/17**), bem como seu **inciso III**, que trata da contratação por prazo indeterminado de serviços de vigilância, conservação e limpeza e serviços especializados ligados a atividade-meio do tomador, desde que ausentes os elementos caracterizadores da relação de emprego.

Pode haver contratação temporária nos casos de aumento extraordinário de trabalho ou substituição provisória de pessoal permanente, como está previsto no **art. 2º da Lei nº Lei 13.429/17**:

Lei nº 13.429/17, Art. 2º - Trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física contratada por uma empresa de trabalho temporário que a coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviços, para atender à **necessidade de substituição transitória** de pessoal permanente ou à **demand**

complementar de serviços.

A lei exige que o contrato entre a empresa cliente e a empresa de trabalho temporário seja realizado por escrito, e que o contrato entre a empresa de trabalho temporário e os trabalhadores temporários seja por prazo determinado, por escrito, e por no máximo por 180 dias, prorrogáveis por mais 90 dias.



A lei não permite a prorrogação do prazo de 90 dias por simples manifestação de vontade por parte de contratante e contratado, exceto se houver manutenção das condições que ensejaram a contratação pelo primeiro período, conforme dispõe o **art. 10, § 2º da Lei 13.429/17**.

2.2. Terceirização por prazo indeterminado

É possível, ainda, a terceirização nas atividades fim e meio através de contrato por prazo indeterminado.

O **inciso IV da Súmula 331, do TST**, prevê a responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços no caso de inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora, tendo em vista a incidência da culpa *in eligendo* e *in vigilando*.

Na terceirização, a empresa cliente, tomadora de serviços, paga a empresa prestadora de serviços, e esta, por sua vez, deve pagar aos empregados. Se a empresa terceirizadora não pagar aos empregados, este pagamento poderá ser

reclamado à empresa cliente, visto que esta sempre será responsável subsidiária pelos créditos dos empregados (por mais que a empresa cliente tenha honrado o contrato de forma absoluta).

Se a empresa de trabalho temporário não assumir os créditos trabalhistas dos empregados, em regra, a responsabilidade da empresa tomadora de serviços é subsidiária, **salvo nos casos de falência**, em que a responsabilidade será **solidária**.

*Art. 16, Lei nº 6.019/74. No caso de **falência** da empresa de trabalho temporário, a empresa tomadora ou cliente é **solidariamente responsável** pelo recolhimento das contribuições previdenciárias, no tocante ao tempo em que o trabalhador esteve sob suas ordens, assim como em referência ao mesmo período, pela remuneração e indenização previstas nesta Lei.*

A **responsabilidade é subsidiária** quando, na execução, primeiro atinge os bens do devedor principal e se não forem suficientes é que os bens da empresa cliente serão atingidos. Já se a **responsabilidade for solidária**, a execução poderá incidir sobre qualquer das empresas, não havendo benefício de ordem.



ATENÇÃO! A empresa tomadora de serviços pode ser a Administração Pública, mas nunca para terceirizar a atividade fim, salvo nos casos da **Lei 6.019/74**.

Mesmo que a Administração Pública celebre terceirização ilícita, portanto, ilegal, a formação de vínculo diretamente com o tomador de serviços é juridicamente impossível, pois, como não houve a realização de concurso público, violaria a norma constitucional prevista no **art. 37, II, CF**:

Art. 37, CF/88

*II - a investidura em cargo ou emprego público **depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos**, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;*

O empregado terceirizado que não tenha recebido suas verbas trabalhistas, indenizatórias e rescisórias deverá ajuizar reclamação em face da prestadora e da tomadora, só valendo como título executivo contra a tomadora a sentença em que conste seu nome.

Súmula 331, TST, inciso IV- O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a **responsabilidade subsidiária** do tomador de serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja **participação da relação processual e conste também do título executivo judicial**.

Assim, a responsabilidade da Administração não decorre simplesmente do não pagamento das verbas trabalhistas pela empresa prestadora.

Súmula 331, TST, inciso V- Os entes integrantes da administração pública direta e indireta **respondem subsidiariamente**, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua **conduta culposa** no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/93, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade **não decorre de mero inadimplemento** das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.

Súmula 331, TST, inciso VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços **abrange todas as verbas** decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral.

2.3. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA TERCEIRIZAÇÃO

A responsabilidade solidária na terceirização encontra-se calcada no **art. 942** e seu parágrafo único do código civil na medida em que o tomador de serviços concorra para o dano moral, material, estético ou existencial sofrido pelo trabalhador, tal como ocorre nos casos de acidente de trabalho sofrido pelo empregado em que haja dolo ou culpa tanto do empregador (empresa prestadora de serviços) e do tomador de serviços.

Capítulo 4

RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

A rescisão do contrato de trabalho é o rompimento da relação contratual existente entre empregado e empregador. A rescisão pode se dar por diversas causas, listadas a seguir.

1. SEM JUSTA CAUSA

1.1. Conceito

Ocorre rescisão do contrato de trabalho sem justa causa, quando o empregador rescinde o contrato de trabalho do empregado sem qualquer motivo justo ou aparente, não havendo razão para a despedida, a não ser o ato unilateral sem motivação do empregador.

1.2. Verbas devidas

Assim como na **rescisão indireta, na despedida sem justa causa**, tem o empregado direito a todas as verbas trabalhistas, inclusive ao adicional do **art. 9º da lei 7.238/84**, caso a rescisão ocorra em até 30 dias antes da data-base.

O empregado recebe:	
AVISO PRÉVIO	✓
SALDO DE SALÁRIOS	✓
13º PROPORCIONAL	✓
FÉRIAS PROPORCIONAIS + 1/3	✓
FÉRIAS VENCIDAS SIMPLES + 1/3, SE HOUVER	✓
FÉRIAS VENCIDAS DOBRADAS + 1/3, SE HOUVER	✓
LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS DO FGTS	✓
INDENIZAÇÃO DE 40% SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	✓
INDENIZAÇÃO ADICIONAL ART. 9º LEI 7.238/84	✓

2. JUSTA CAUSA DO EMPREGADO

2.1. Conceito

A justa causa ocorre quando do cometimento de uma falta grave, listadas no **art. 482 da CLT**. A rescisão por justa causa do empregado ocorre, então, quando este comete uma falta grave.

2.2. Verbas devidas

Na **rescisão por justa causa**, tem o empregado direito a saldo de salários e férias vencidas, se houver, por serem direito adquirido. Importante ressaltar que as férias proporcionais não são devidas por serem mera expectativa de direito.

O empregado recebe:	
AVISO PRÉVIO	X
SALDO DE SALÁRIOS	✓
13ª PROPORCIONAL	X
FÉRIAS PROPORCIONAIS + 1/3	X
FÉRIAS VENCIDAS SIMPLES + 1/3	✓
FÉRIAS VENCIDAS DOBRADAS + 1/3	✓
LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS DO FGTS	X
INDENIZAÇÃO DE 40% SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	X
INDENIZAÇÃO ADICIONAL ART. 9º LEI 7.238/84	X

Quanto ao FGTS do empregado, este não perde o valor depositado, mas tão somente o direito de levá-lo. Isso porque os depósitos propriamente ditos são direito adquirido do empregado.

Lei 8.036/90, Art. 15. *Para os fins previstos nesta Lei, todos os empregadores ficam obrigados a depositar, até o vigésimo dia de cada mês, em conta vinculada, a importância correspondente a 8% (oito por cento) da remuneração paga ou devida, no mês anterior, a cada trabalhador, incluídas na remuneração as parcelas de que tratam os arts. 457 e 458 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Gratificação de Natal de que trata a Lei nº 4.090, de 13 de julho de 1962. (Redação dada pela Lei nº 14.438, de 2022) Produção de efeitos*

Art. 20. *A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações:*

VIII - VIII - *quando o trabalhador permanecer três anos ininterruptos fora do regime do FGTS; (Redação dada pela Lei nº 13.932, de 2019)*

3. Das faltas graves do empregado

As faltas graves que justificam a rescisão por justa causa do empregado encontram-se previstas no **art. 482 da CLT**:

- a) **ato de improbidade**: a improbidade revela o mau caráter do empregado, sua perversidade, desonestidade. O ato ensejador pode ser o furto ou roubo de mercadorias da empresa.
- b) **incontinência de conduta**: a incontinência de conduta está ligada ao desregramento do empregado no tocante à vida sexual. São obscenidades praticadas, a libertinagem, a pornografia, o assédio sexual (**Lei 10.224/2001**). **OU mau procedimento**: é o desrespeito às normas padrão de convívio em grupo social, como aquele que vive de fazer intrigas entre os colegas de trabalho ou até quando o empregado dolosa ou culposamente causa um dano ao empregador.
- c) **negociação habitual**: diz respeito aos atos de empresa praticados pelo empregado que negocia habitualmente dentro do local de trabalho sem a permissão do empregador.
- d) **condenação criminal**: para haver justa causa é preciso que o empregado seja condenado criminalmente com sentença transitada em julgado.
- e) **desídia**: o empregado labora com desídia no desempenho de suas funções quando o faz com negligência, preguiça, má vontade, displicência, desleixo. A desídia também pode ser caracterizada como um conjunto de pequenas faltas que mostram a omissão do empregado no serviço, **desde que** haja repetição de atos faltosos.
- f) **embriaguez**: pode ser esta por uso de álcool ou de drogas. Deve-se distinguir entre embriaguez habitual e embriaguez no serviço. Aquela é caracterizada pelo alcoolismo, trazendo em seu conteúdo a habitualidade. Esta é o fato único de se estar embriagado no serviço, ainda que uma única vez, ensejando a justa causa.
- g) **violação de segredo de empresa**: é cometida pelo empregado que divulga marcas e patentes, fórmulas do empregador, sem seu consentimento, o que não deveria ser tornado público, configurando prejuízo.
- h) **Ato de indisciplina**: é o descumprimento de ordens gerais de serviço. **OU insubordinação**: está ligada ao descumprimento de ordens pessoais de serviço.
- i) **abandono de emprego**: é largar, deixar o emprego ou posto de trabalho, desistir o operário de trabalhar na empresa.

- j) **ato lesivo a honra e a boa fama:** calúnia, injúria e difamação praticadas no serviço contra qualquer pessoa, salvo em legítima defesa própria ou de outrem. **OU ofensa física:** é a agressão do empregado praticada no serviço contra qualquer pessoa, salvo em legítima defesa, própria ou de outrem.
- k) **ato lesivo a honra e a boa fama:** calúnia, injúria e difamação com relação à pessoa do empregador ou superiores hierárquicos, salvo em legítima defesa própria ou de outrem. **OU ofensa física:** é a agressão do empregado contra empregador ou superiores hierárquicos, salvo em legítima defesa, própria ou de outrem.
- l) **prática constante de jogos de azar:** se a prática é isolada, uma única vez, ou poucas vezes, não há justa causa. Para ser justa a ruptura do contrato, deve haver a habitualidade.
- m) **Perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado.**

Outras hipóteses: O não uso dos EPIs (art. 158, parágrafo único, “b” CLT); empregados de estrada de ferro que se recusarem a executar serviços extraordinários em caso de urgência e acidentes (art. 240 e parágrafo único da CLT) e ainda o movimento paredista (greve) sem a observância das disposições da Lei 7.783/89.

3.1 Assédio Moral

Assédio moral é quando o empregador comete de forma repetida e intencional qualquer das faltas previstas em lei como graves. No entanto, nesta modalidade, o elemento subjetivo “*vontade*” de cometer a falta grave é essencial para sua caracterização, sob pena de não se poder distinguir da falta grave simples (sem assédio), até porque todo assédio moral é uma falta grave, mas nem toda falta grave é assédio moral.

No assédio, o empregador não tem mais intenção em permanecer com determinado empregado, mas não quer simplesmente despedi-lo, pois ao fazê-lo, teria que pagar a indenização⁷, o que torna a rescisão mais cara. Ao invés disso, começa a praticar de forma proposital, reiterada e constante, faltas graves contra o empregado, com o intuito de fazê-lo sentir-se constrangido no ambiente de trabalho para que este empregado, não mais suportando a situação, peça demissão.

⁷ Indenização de 40% sobre os depósitos do FGTS, nos termos do art. 10, inc. I, ADCT e art. 15, § 1º da Lei 8.036/90.

3.2 O QUE SE DEVE PEDIR NUMA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA?

No caso de falta simples **sem** constrangimento:

Reconhecimento da falta grave + rescisão indireta + verbas rescisórias e indenizatórias

No caso de falta simples **com** constrangimento:

Reconhecimento da falta grave + rescisão indireta + verbas rescisórias e indenizatórias + indenização por dano moral
--

No caso de **assédio moral** o constrangimento é **presumido**:

Reconhecimento da falta grave + rescisão indireta + verbas rescisórias e indenizatórias + indenização por dano moral
--

4. JUSTA CAUSA DO EMPREGADOR OU RESCISÃO INDIRETA OU DESPEDIDA INDIRETA

4.1. Conceito

O cometimento de falta grave por parte do empregador causa a rescisão do contrato de trabalho por justa causa, também chamada de rescisão indireta.

4.2. Verbas devidas

Assim como na **rescisão sem justa causa**, na **despedida indireta** tem o empregado direito a todas as verbas trabalhistas, inclusive ao adicional do **art. 9º da lei 7.238/84**, caso a rescisão ocorra em até 30 dias antes da data-base.

O empregado recebe:	
AVISO PRÉVIO	✓
SALDO DE SALÁRIOS	✓
13º PROPORCIONAL	✓
FÉRIAS PROPORCIONAIS + 1/3	✓
FÉRIAS VENCIDAS SIMPLES + 1/3, SE HOUVER	✓
FÉRIAS VENCIDAS DOBRADAS + 1/3, SE HOUVER	✓
LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS DO FGTS	✓
INDENIZAÇÃO DE 40% SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	✓
INDENIZAÇÃO ADICIONAL ART. 9º LEI 7.238/84	✓

4.3. Das faltas graves do empregador

As faltas graves que justificam a rescisão por justa causa do empregador encontram-se previstas no **art. 483 da CLT**:

OBS: Grifar as palavras destacadas na CLT!

As teses da peça são basicamente a junção das palavras destacadas nos artigos com as informações que a peça traz, observe:

Art. 483, CLT. *O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando:*

- a) forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes, ou alheios ao contrato;*
- b) For tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo;*
- c) correr perigo manifesto de mal considerável;*
- d) não cumprir o empregador as obrigações do contrato;*
- e) praticar o empregador ou seus prepostos, contra ele ou pessoas de sua família, ato lesivo da honra e boa fama;*
- f) o empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;*
- g) o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários.*

TESE DE RECONHECIMENTO DE RESCISÃO INDIRETA

NA RECLAMAÇÃO:

A reclamante TEM DIREITO a nulidade da dispensa com justa causa OU ao reconhecimento da dispensa sem justa causa porque NÃO COMETEU falta grave de (DIGA A FALTA GRAVE) porque (DIGA A SITUAÇÃO), nos termos do art. 482,

NA CONTESTAÇÃO:

A reclamante NÃO TEM direito a nulidade da dispensa com justa causa OU ao reconhecimento da dispensa sem justa causa porque COMETEU falta grave de (DIGA A FALTA GRAVE) porque (DIGA A SITUAÇÃO), nos termos do art. 482,

4.3.1. Serviços Superiores às Forças do Empregado

Os serviços “superiores à força”, previstos na alínea “a” do dispositivo legal supramencionado, podem ser entendidos tanto como força física quanto intelectual.

Exs:- Mulheres

Art. 390, CLT - Ao empregador é vedado empregar a mulher em serviço que demande o emprego de força muscular superior a 20 (vinte) quilos para o trabalho contínuo, ou 25 (vinte e cinco) quilos para o trabalho ocasional.

Parágrafo único - *Não está compreendida* na determinação deste artigo a remoção de material feita por impulsão ou tração de vagonetes sobre trilhos, de carros de mão ou quaisquer aparelhos mecânicos.

-Homens

Art. 198, CLT - É de 60 kg (sessenta quilogramas) o peso máximo que um empregado pode remover individualmente, ressalvadas as disposições especiais relativas ao trabalho do menor e da mulher.

Parágrafo único - *Não está compreendida* na proibição deste artigo a remoção de material feita por impulsão ou tração de vagonetes sobre trilhos, carros de mão ou quaisquer outros aparelhos mecânicos, podendo o Ministério do Trabalho, em tais casos, fixar limites diversos, que evitem sejam exigidos do empregado serviços superiores às suas forças.

- Menores de idade

Art. 405, CLT - Ao menor **não será permitido** o trabalho:

§ 5º Aplica-se ao menor o disposto no art. 390 e seu parágrafo único.

4.3.2. Rigor Excessivo

O empregador pode advertir o empregado de forma verbal ou escrita, sempre dentro da razoabilidade, podendo ser as punições de advertência, suspensão ou dispensa por justa causa.

Art. 483, CLT. O empregado poderá **considerar rescindido** o contrato e pleitear a devida indenização quando:

For tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo;

O **art. 474 da CLT** traz um exemplo do rigor excessivo previsto na alínea “b” do art. 483 da CLT:

Art. 474, CLT. A **suspensão** do empregado por mais de trinta dias consecutivos importa na rescisão injusta do contrato de trabalho.

4.3.3. Perigo Manifesto de Mal Considerável

Não se trata de trabalho perigoso, pois é possível exercê-lo. O que não se admite é que o empregador agrave o perigo, por exemplo, não fornecendo o EPI (equipamento de proteção individual).

*Art. 483, CLT. O empregado poderá **considerar rescindido** o contrato e pleitear a devida indenização quando:*

c) correr perigo manifesto de mal considerável;

4.3.4. Descumprimento das Obrigações Contratuais

Todas as hipóteses de falta grave do empregador estão englobadas pela hipótese prevista na **alínea “d” do art. 483 da CLT**:

*Art. 483, CLT. O empregado poderá **considerar rescindido** o contrato e pleitear a devida indenização quando:*

d) não cumprir o empregador as obrigações do contrato;

Isso porque no Brasil há o chamado “conteúdo mínimo do contrato de trabalho”, que determina que o contrato de trabalho, mesmo verbal ou tácito, deve observar as leis, os contratos coletivos e as decisões de autoridades, em conformidade com o **art. 444 da CLT**:

*Art. 444, CLT. As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de **livre estipulação das partes** interessadas em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes.*

4.3.5. Ato Lesivo da Honra e Boa Fama do Empregado

Essa hipótese está prevista na **alínea “e” do art. 483 da CLT** e ocorre quando o empregador toma atitudes com o objetivo de suscitar dúvidas acerca da probidade (caráter) do empregado ou de sua família.

*Art. 483, CLT. O empregado poderá **considerar rescindido** o contrato e pleitear a devida indenização quando:*

*e) Praticar o empregador ou seus prepostos, contra ele ou pessoas de sua família, ato lesivo da **honra e boa fama**;*

4.3.6. Ofensa Física

A previsão da alínea “f” do art. 483 da CLT é de que o empregador não pode ofender moralmente nem o empregado nem a sua família. A alínea “f” do mesmo artigo já prevê que a ofensa física só não pode ser ao empregado, de modo que ofensa física às pessoas de sua família não constitui falta grave.

Art. 483, CLT. O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando:

f) o empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;

4.3.7. Redução de Tarefa

Diferentemente do disposto na alínea “d”, em que há alteração no salário, independentemente da quantidade do serviço, a **alínea “g” do art. 483 da CLT** prevê como causa de rescisão indireta a alteração na quantidade de serviço que altere consideravelmente o salário, de forma a prejudicar o empregado.

Observe que o §3º do art. 483 da CLT concede ao empregado a escolha de permanecer ou não trabalhando no curso do processo pelo qual pleiteia a rescisão indireta do contrato de trabalho.

Art. 483, CLT. O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando:

g) o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários.

§3º Nas hipóteses das letras d e g, poderá o empregado pleitear a rescisão de seu contrato de trabalho e o pagamento das respectivas indenizações, permanecendo ou não no serviço até final decisão do processo.



ATENÇÃO! De acordo com o TST, o **atraso de salários por mais de 30 dias** corridos é considerado falta grave do empregador.

Art. 472, CLT. O afastamento do empregado em virtude das exigências do serviço militar, ou de outro encargo público, não constituirá motivo para alteração ou rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador.

5. PEDIDO DE DEMISSÃO

5.1. Conceito

O pedido de demissão ocorre quando o empregado voluntariamente e, sem justa causa, quer se desligar do contrato de trabalho.

5.2. Verbas devidas

Empregado que pede demissão nem levanta FGTS e nem tem direito à indenização, recebendo as demais verbas. No caso do aviso prévio, este é devido pelo empregado ao empregador, nos termos do **§ 2º do art. 487 da CLT**.

O empregado recebe:	
AVISO PRÉVIO – dado pelo empregado ao empregador	✓
SALDO DE SALÁRIOS	✓
13º PROPORCIONAL	✓
FÉRIAS PROPORCIONAIS + 1/3	✓
FÉRIAS VENCIDAS SIMPLES + 1/3, SE HOUVER	✓
FÉRIAS VENCIDAS DOBRADAS + 1/3, SE HOUVER	✓
LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS DO FGTS	X
INDENIZAÇÃO DE 40% SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	X
INDENIZAÇÃO ADICIONAL ART. 9º LEI 7.238/84	X

6. CULPA RECÍPROCA

6.1. Conceito

Há culpa recíproca quando o empregado e o empregador cometem, ao mesmo tempo, falta grave.

Art. 484, CLT- *Havendo culpa recíproca no ato que determinou a rescisão do contrato de trabalho, o tribunal de trabalho reduzirá a indenização à que seria devida em caso de culpa exclusiva do empregador, por metade.*

SUM-14, TST. CULPA RECÍPROCA (nova redação) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 *Reconhecida a culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho (art. 484 da CLT), o empregado tem direito a 50% (cinquenta por cento) do valor do aviso prévio, do décimo terceiro salário e das férias proporcionais.*

Lei 8.036/199, Art. 18. *Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, por parte do empregador, ficará este obrigado a depositar na conta vinculada do trabalhador*

no FGTS os valores relativos aos depósitos referentes ao mês da rescisão e ao imediatamente anterior, que ainda não houver sido recolhido, sem prejuízo das cominações legais.

§1º Na hipótese de despedida pelo empregador sem justa causa, depositará este, na conta vinculada do trabalhador no FGTS, importância igual a quarenta por cento do montante de todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho, atualizados monetariamente e acrescidos dos respectivos juros.

§2º Quando ocorrer despedida por culpa recíproca ou força maior, reconhecida pela Justiça do Trabalho, o percentual de que trata o § 1º **será de 20 (vinte) por cento.**

6.2. Verbas devidas

Conforme o **art. 484 da CLT** e a **Súmula 14 do TST**, transcritos anteriormente, na culpa recíproca, as verbas indenizatórias são devidas pela metade. Apenas o saldo de salários e as férias são devidos integralmente, tendo o empregado, ainda, direito a levantar os depósitos de FGTS.

O empregado recebe:	
AVISO PRÉVIO	✓½
SALDO DE SALÁRIOS	✓
13º PROPORCIONAL	✓½
FÉRIAS PROPORCIONAIS + 1/3	✓½
FÉRIAS VENCIDAS SIMPLES + 1/3	✓
FÉRIAS VENCIDAS DOBRADAS + 1/3	✓
LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS DO FGTS	✓
INDENIZAÇÃO DE 40% SOBRE OS DEPÓSITOS DO FGTS	✓½
INDENIZAÇÃO ADICIONAL ART. 9º LEI 7.238/84	✓



ATENÇÃO!

Verbas rescisórias propriamente ditas: são aquelas cujo direito o empregado já adquiriu e, regra geral, são devidas tanto na rescisão, quanto na vigência do contrato de trabalho, tais como: saldo de salários, férias vencidas simples e dobradas, e depósitos de FGTS.

Verbas indenizatórias: são aquelas cujo direito o empregado ainda não adquiriu e são devidas, regra geral, apenas na rescisão contratual, tais como: aviso prévio, 13º salário proporcional, férias proporcionais e indenização de 40% sobre os depósitos de FGTS.

Esses conceitos são confirmados pelas **Súmulas 73 e 14 do TST:**

SUM-73, TST. *A ocorrência de justa causa, salvo a de abandono de emprego, no decurso do prazo do aviso prévio dado pelo empregador, **retira do empregado qualquer direito** às verbas rescisórias de natureza indenizatória.*

SUM-14, TST. CULPA RECÍPROCA - *Reconhecida a culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho (art. 484 da CLT), o empregado tem direito a 50% (cinquenta por cento) do valor do aviso prévio, do décimo terceiro salário e das férias proporcionais.*

7. FORÇA MAIOR

7.1. Conceito

Art. 501, CLT. *Entende-se como força maior todo **acontecimento inevitável**, em relação à vontade do empregador, e para a realização do qual este não concorreu, direta ou indiretamente.*

§1º *A **imprevidência do empregador** exclui a razão de força maior.*

§2º *À ocorrência do motivo de força maior que não afetar substancialmente, nem for suscetível de afetar, em tais condições, a situação econômica e financeira da empresa **não se aplica as restrições** desta Lei referentes ao disposto neste Capítulo.*

Art. 502. *Ocorrendo motivo de força maior que determine a **extinção da empresa**, ou de um dos estabelecimentos em que trabalhe o empregado, é assegurada a este, quando despedido, uma indenização na forma seguinte:*

I – sendo estável, nos termos dos artigos 477 e 478;

II – não tendo direito à estabilidade, metade da que seria devida em caso de rescisão sem justa causa;

III – havendo contrato por prazo determinado, aquela a que se refere o artigo 479 desta Lei, reduzida igualmente à metade.

7.2. Verbas devidas

Em caso de força maior, somente a indenização de 40% sobre os depósitos do FGTS será pela metade, sendo o restante das verbas devidas de forma integral. Assim, a indenização será de 20% sobre os depósitos do FGTS. É assim, porque antes do FGTS, a indenização correspondia a um mês de salário por cada ano ou fração superior a seis meses.

O empregado recebe:	
AVISO PRÉVIO	✓
SALDO DE SALÁRIOS	✓
13º PROPORCIONAL	✓
FÉRIAS PROPORCIONAIS + 1/3	✓
FÉRIAS VENCIDAS SIMPLES + 1/3	✓
FÉRIAS VENCIDAS DOBRADAS + 1/3	✓
LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS DO FGTS	✓
INDENIZAÇÃO DE 40% SOBRE OS DEPÓSITOS DO FGTS	✓ ½
INDENIZAÇÃO ADICIONAL ART. 9º LEI 7.238/84	X

Nesse caso, não há a indenização adicional do art. 9º da Lei 7.238 por não ter o evento ocorrido por culpa do empregador.

Haverá, porém, aviso prévio, por força da **Súmula 44 do TST**, que se refere à “cessação da atividade da empresa” de forma genérica, incluindo-se, portanto, a cessação por motivo de força maior.

SUM-44, TST. A cessação da atividade da empresa, com o pagamento da indenização, simples ou em dobro, **não exclui**, por si só, o direito do empregado ao **aviso prévio**.

8. FACTUM PRINCIPIS

8.1. Conceito

O *factum principis* é uma espécie de força maior em que há o fato “de um homem especial”. É, então, um ato, legislativo ou administrativo, de autoridade, capaz de extinguir a empresa e, consequentemente, os contratos de trabalho dela decorrentes. Esse tipo de rescisão encontra previsão legal no **art. 486 da CLT**:

Art. 486, CLT - No caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, **motivada por ato** de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização, que ficará a cargo do governo responsável.

TESE DE RECONHECIMENTO DE RESCISÃO

NA RECLAMAÇÃO:

A reclamante tem direito ao pagamento da indenização de 40% paga pelo empregador por não **se tratar de rescisão por factum principis**, pois teve o contrato rescindido sem justa causa, porque o **empregador deu causa** à interdição do estabelecimento pela autoridade pública uma vez que (DADOS DA PEÇA), nos

Observe, então, que a indenização a que se refere o **artigo 486 da CLT** corresponde às verbas rescisórias indenizatórias.

O empregado recebe:	
AVISO PRÉVIO	Empregador
SALDO DE SALÁRIOS	Empregador
13º PROPORCIONAL	Empregador
FÉRIAS PROPORCIONAIS + 1/3	Empregador
FÉRIAS VENCIDAS SIMPLES + 1/3	Empregador
FÉRIAS VENCIDAS DOBRADAS + 1/3	Empregador
LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS DO FGTS	Empregador
INDENIZAÇÃO DE 40% SOBRE OS DEPÓSITOS DO FGTS	Autoridade
INDENIZAÇÃO ADICIONAL ART. 9º LEI 7.238/84	X

9. MORTE DO EMPREGADO

9.1. Conceito

Ocorre a caducidade ou morte natural do contrato de trabalho.

9.2. Verbas devidas

Nesse caso, só não há direito ao aviso prévio e à indenização de 40% sobre os depósitos do FGTS, pois **“empregado que morre e vai pro caixão, nem recebe aviso prévio nem indenização”**.

O empregado recebe:	
AVISO PRÉVIO	X
SALDO DE SALÁRIOS	✓
13º PROPORCIONAL	✓
FÉRIAS PROPORCIONAIS + 1/3	✓
FÉRIAS VENCIDAS SIMPLES + 1/3	✓
FÉRIAS VENCIDAS DOBRADAS + 1/3	✓
LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS DO FGTS	✓
INDENIZAÇÃO DE 40% SOBRE OS DEPÓSITOS DO FGTS	X
INDENIZAÇÃO ADICIONAL ART. 9º LEI 7.238/84	X

10. MORTE DO EMPREGADOR PESSOA FÍSICA

10.1. Conceito

Os direitos adquiridos pelos empregados em decorrência do contrato de trabalho, continuam intactos mesmo após mudanças na estrutura jurídica da

empresa (empregador).

Art. 483, CLT. O empregado **poderá considerar rescindido** o contrato e pleitear a devida indenização quando:

§2º No caso de **morte do empregador** constituído em empresa individual, é facultado ao empregado rescindir o contrato de trabalho.

10.2. Verbas devidas

Conforme o entendimento do TST, a rescisão por morte do empregador pessoa física, empresa individual ou empresa unipessoal, equipara-se à *rescisão indireta* por falta grave do empregador, em que são devidos inclusive o aviso prévio e a indenização de 40% sobre os depósitos do FGTS.

O empregado recebe:	TST
AVISO PRÉVIO	✓
SALDO DE SALÁRIOS	✓
13º PROPORCIONAL	✓
FÉRIAS PROPORCIONAIS + 1/3	✓
FÉRIAS VENCIDAS SIMPLES + 1/3	✓
FÉRIAS VENCIDAS DOBRADAS + 1/3	✓
LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS DO FGTS	✓
INDENIZAÇÃO DE 40% SOBRE OS DEPÓSITOS DO FGTS	✓
INDENIZAÇÃO ADICIONAL ART. 9º LEI 7.238/84	x

11. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA DO EMPREGADO

Na verdade, a aposentadoria espontânea do empregado não é causa de rescisão do contrato de trabalho, tendo em vista que ele tem a opção de continuar no emprego.

Anteriormente, a aposentadoria era considerada rescisão do contrato de trabalho, mas, com o julgamento das **ADIN's 1.770-4 e 1.721-3** pelo STF, foi declarada a inconstitucionalidade dos **§§1º e 2º do art. 453 da CLT**.

Art. 453, CLT. No tempo de serviço do empregado, quando readmitido, serão computados os períodos, **ainda que não contínuos**, em que tiver trabalhado anteriormente na empresa, **salvo** se houver sido despedido por falta grave, recebido indenização legal ou se aposentado espontaneamente.

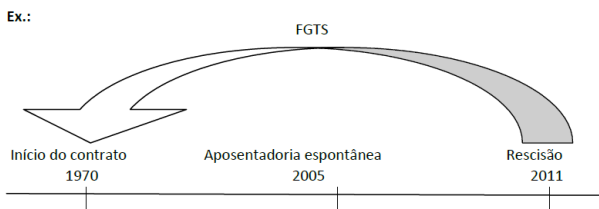
§1º Na aposentadoria espontânea de empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista é permitida sua readmissão desde que atendidos aos requisitos constantes do artigo 37, inciso XVI, da Constituição, e condicionada à prestação de concurso público.

§2º O ato de concessão de benefício de aposentadoria a empregado que não tiver completado trinta e cinco anos de serviço, se homem, ou trinta, se mulher, importa em extinção de vínculo empregatício.

Atualmente, a aposentadoria espontânea não extingue o contrato de trabalho e, caso o empregado opte por continuar trabalhando, será pelo mesmo contrato de trabalho. É o entendimento da **OJ 361 da SDI-1 do TST**.

OJ-361, SDI-1, TST. A aposentadoria espontânea **não é causa** de extinção do contrato de trabalho se o empregado **permanece prestando serviços** ao empregador após a jubilação. Assim, por ocasião da sua dispensa imotivada, o empregado tem direito à multa de 40% do FGTS sobre a totalidade dos depósitos efetuados no curso do pacto laboral.

Isso significa que, se o empregado for demitido sem justa causa após a aposentadoria, a indenização de 40% sobre os depósitos de FGTS será relativa *a todo o período de trabalho*, ou seja, desde a contratação, não havendo que se falar em novo contrato após a aposentadoria.



Isto ocorre mesmo que o empregado tenha levantado todo o valor depositado no FGTS quando da ocasião da aposentadoria, o que é permitido por força do **art.20, inciso III, da Lei 8.036/1990**.

Lei 8.036/1990, Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações:

III - aposentadoria concedida pela Previdência Social;

Se o empregado, ao aposentar-se, quiser rescindir o contrato de trabalho, incorrerá na hipótese do **pedido de demissão**, havendo uma única diferença em relação às verbas rescisórias e indenizatória, qual seja o fato de que ele, na condição de aposentado, poderá levantar seu FGTS.

Capítulo 5

VERBAS TRABALHISTAS RESCISÓRIAS E INDENIZATÓRIAS

1. AVISO PRÉVIO

1.1. Conceito

Em síntese, significa avisar com antecedência que o contrato de trabalho vai acabar.

Apesar de o aviso prévio, por ser ato unilateral, depender da vontade de apenas uma das partes, é necessário, para surtir efeitos no mundo jurídico, que ele seja comunicado à outra parte.

O aviso prévio tanto pode figurar como direito do empregado e dever do empregador, como direito do empregador e dever do empregado. Isso porque o **art. 487, caput, da CLT**, dispõe que “[...] a parte que, sem justo motivo, quiser rescindir o contrato deverá avisar a outra da sua resolução [...]”. Observe-se que “a parte” a que se refere o dispositivo legal mencionado pode ser tanto o empregado como o empregador.

Ademais, o **§1º** e o **§2º do art. 487, CLT** trazem as consequências da falta do aviso prévio por parte do empregador e do empregado:

ATENÇÃO!!! **GRIFAR** AS PALAVRAS DESTACADAS NA CLT:

Art. 487, CLT:

§1º A falta do aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço.

§2º A falta de aviso prévio por parte do empregado dá ao empregador o direito de descontar os salários correspondentes ao prazo respectivo.

Observe que o **§2º** estabelece claramente a possibilidade de o empregador, no caso de o empregado não conceder o aviso prévio, descontar, quando do pagamento das verbas rescisórias, o equivalente à remuneração de um mês de trabalho.

1.1.1. Prazo

O prazo mínimo será **SEMPRE** de 30 dias.

art. 7º, CF. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que

visem à melhoria de sua condição social:

...

*XXI – aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo **no mínimo de trinta dias**, nos termos da lei;*

É possível a criação de uma norma coletiva que traga um prazo maior de aviso prévio e, nesse caso, todo o período será computado como de tempo de serviço efetivo, conforme determina a **OJ 367 da SDI-1**:

***OJ-367, SDI-1, TST.** O prazo de aviso prévio de 60 dias, concedido por meio de norma coletiva que silencia sobre alcance de seus efeitos jurídicos, computa-se integralmente como tempo de serviço, nos termos do § 1º do art. 487 da CLT, repercutindo nas verbas rescisórias.*

1.1.2. Hipóteses de Cabimento

Cabe aviso prévio quando, não havendo prazo estipulado, ou seja, quando o contrato for por prazo indeterminado, o empregador quiser rescindir o contrato sem justo motivo, ocorrendo o mesmo quando o desejo de rescindir o contrato partir do empregado.

Observa-se, assim, que, de acordo com o **caput do art. 487, CLT** em regra, o aviso prévio só é devido no contrato por prazo indeterminado:

***Art. 487, CLT. Não havendo prazo estipulado**, a parte que, sem justo motivo, quiser rescindir o contrato deverá avisar a outra da sua resolução com a antecedência mínima de:*



ATENÇÃO! HÁ EXCEÇÃO. Trata-se da **CLÁUSULA ASSECURATÓRIA DO DIREITO RECÍPROCO DE RESCISÃO ANTECIPADA**.

Se o Contrato de Trabalho por Prazo Determinado contiver uma cláusula que permita a rescisão antecipada e o empregador quiser rescindir antecipadamente o contrato, poderá fazê-lo, ficando, no entanto, obrigado ao pagamento da indenização de 40% sobre os depósitos do FGTS e à concessão de aviso prévio (**Art. 481 da CLT e Súmula 163 do TST**).

***Art. 481, CLT.** Aos contratos por prazo determinado, que contiverem cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão, antes de expirado o termo ajustado, aplicam-se, caso seja exercido tal direito por qualquer das partes, os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado.*

***SUM-163, TST:** Cabe aviso prévio nas rescisões antecipadas dos contratos de experiência, na forma do art. 481 da CLT (ex-Prejulgado nº 42).*

O aviso prévio é devido integralmente também no caso de cessação das atividades da empresa, por força da **Súmula 44 do TST**:

SUM-44, TST: A cessação da atividade da empresa, com o pagamento da indenização, simples ou em dobro, **não exclui**, por si só, o direito do empregado ao aviso prévio.

É devido aviso prévio, ainda, no caso de rescisão do contrato de trabalho por justa causa do empregador, conforme **§4º do art. 487, CLT**:

Art. 487, CLT:

§4º É devido o aviso prévio na despedida indireta.

A lei assim não estabelece expressamente, mas por questões fáticas, o aviso prévio, nesse caso, será indenizado.

Na hipótese de o empregado, no curso do aviso prévio, cometer qualquer das faltas autorizadas da rescisão contratual por justa causa, perderá ele o direito não só ao restante do respectivo período, conforme prevê o **art. 491 da CLT**, como também às indenizações que lhes seriam devidas no caso da não ocorrência da justa causa, por força da **Súmula 73 do TST**.

SUM-73, TST. A ocorrência de justa causa, **salvo** a de abandono de emprego, no decurso do prazo do aviso prévio dado pelo empregador, **retira do empregado** qualquer direito às verbas rescisórias de natureza indenizatória.

Art. 491, CLT - O empregado que, durante o prazo do aviso prévio, cometer qualquer das faltas consideradas pela lei como justas para a rescisão, **perde o direito** ao restante do respectivo prazo.

1.1.3. Espécies de Aviso Prévio

No ordenamento jurídico pátrio, temos dois tipos de aviso prévio: o aviso prévio trabalhado e o aviso prévio indenizado, também conhecido como *aviso prévio não trabalhado*.

Aviso prévio	
Trabalhado	Aquele em que o empregado presta serviços no período
Indenizado	Não há prestação de serviços, mas há o recebimento do salário correspondente

Art. 487, CLT, § 1º A falta do aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida **sempre a integração desse período no seu tempo de serviço**.

Ambos os tipos de aviso prévio **integram o tempo de serviço do empregado**, projetando o contrato de trabalho para o futuro por, no mínimo, mais 30 dias.

Isso significa que haverá no mínimo, mais um mês de salário, mais 1/12 de férias, mais 1/12 de 13º salário, mais um mês de FGTS e a data a ser anotada como de saída do empregado em sua CTPS será a do último dia do aviso prévio, **ainda que ele seja indenizado (OJ 82, SDI-1, TST)**.

O aviso prévio é **SEMPRE** tempo de serviço para todos os efeitos, pois o aviso prévio **indenizado** tem natureza salarial e não indenizatória, a despeito do nome.

1.1.4. Redução dos horários durante o aviso prévio

Sendo o aviso prévio trabalhado, o empregado pode escolher entre faltar sete dias consecutivos ou reduzir seus horários em duas horas todos os dias, **mantendo-se a remuneração**, durante o prazo do aviso prévio, isto com o intuito de o empregado ter a chance de procurar um novo emprego, já que acabou de perder o atual, nos termos do **art. 488, caput, e parágrafo único da CLT**.

No entanto, é muito comum o empregador propor a substituição da redução de duas horas pelo pagamento das mesmas como extraordinárias. O TST através de sua **Súmula 230** entende ser o ato ilegal uma vez que impede que o trabalhador procure novo emprego durante o prazo do aviso.

***SUM-230, TST.** É ilegal substituir o período que se reduz da jornada de trabalho, no aviso prévio, pelo pagamento das horas correspondentes.*

Caso isso aconteça, mesmo com a anuência expressa do trabalhador, a pactuação é nula e o TST vem entendendo que o empregador deverá pagar ao empregado um valor equivalente a um novo aviso, cuja natureza será meramente indenizatória, sem qualquer projeção do contrato de trabalho para o futuro, por não se tratar de novo aviso, mas apenas de um valor equivalente a um novo aviso.

1.1.5. Valor do Aviso Prévio

O valor do aviso prévio está previsto no **art. 487, §3º da CLT**. Não havendo valor fixo, é feita a média dos 12 últimos meses de remuneração.

Art: 487, CLT, §3º Em se tratando de salário pago na base de tarefa, o cálculo, para os efeitos dos parágrafos anteriores, será feito de acordo com a média dos últimos doze meses de serviço.

Como se verifica através do **§1º e §2º do art. 487 da CLT**, o aviso prévio é calculado **sobre os salários** e não sobre a remuneração. Logo, se o empregado recebe gorjetas e tem seu aviso prévio **indenizado**, o valor do aviso não será calculado sobre a remuneração, não sendo levadas em conta as gorjetas. Já se o aviso prévio for **trabalhado**, a remuneração é devida e o empregado tem direito às gorjetas.

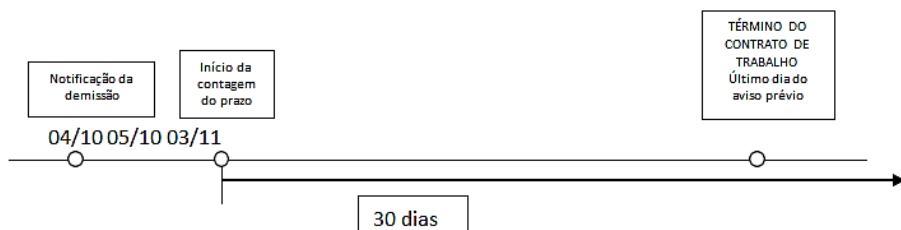
1.1.6. Contagem do Aviso Prévio

A contagem do aviso prévio obedece à regra de contagem dos prazos civis prevista no **art. 132 do Código Civil**, ou seja, com a exclusão do dia do início (que é o dia da notificação da demissão) e a inclusão do dia final ou do vencimento, nos termos da **Súmula 380 do TST**.

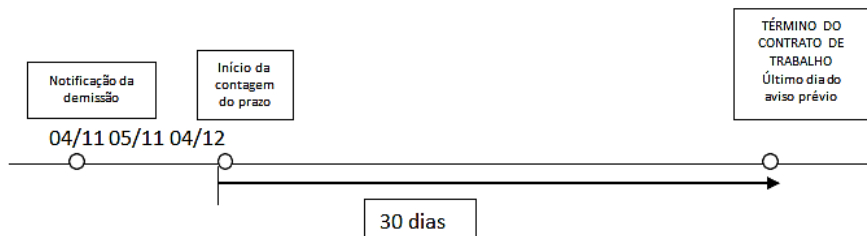
SUM-380, TST. Aplica-se a regra prevista no "caput" do art. 132 do Código Civil de 2002 à contagem do prazo do aviso prévio, **excluindo-se o dia do começo e incluindo o do vencimento**.

Art. 132, CC. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, **excluído o dia do começo, e incluí o do vencimento**.

O aviso prévio é contado dia a dia, levando-se em consideração os meses que tem 30 dias e os meses com 31 dias e o mês de fevereiro com 28 dias e, quando o ano for bissexto, 29 dias. Assim, se o empregado for notificado da demissão no dia 04 de outubro, o prazo inicia-se no dia 05 de outubro, projetando-se o contrato até 03 de novembro, tendo em vista o mês de outubro ter 31 dias.



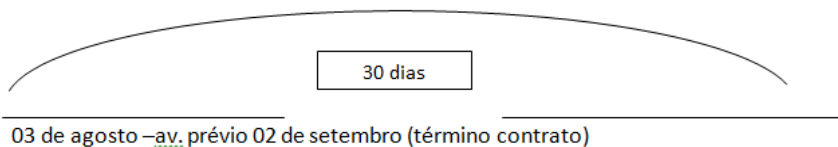
Caso a notificação da demissão se dê, por exemplo, no dia 04/11, já que novembro tem 30 dias, começaria o prazo no dia 05/11, findando em 04/12.



Seja o aviso prévio trabalhado ou indenizado, o período de 30 dias integra o contrato de trabalho do empregado, motivo pelo qual incide normalmente sobre esse período: depósito de FGTS, 1/12 de férias e 1/12 de décimo terceiro salário.



ATENÇÃO! O contrato de trabalho só termina quando acaba o aviso prévio!



Por isso, a data a ser anotada na CTPS do empregado como data de saída (fim do contrato) é a do último dia do aviso prévio, ainda que indenizado, conforme **OJ-82 da SDI1**:

OJ-82, SDI-1, TST. A data de saída a ser anotada na CTPS deve corresponder à do término do prazo do aviso prévio, ainda que indenizado.

Quando o empregado não concede aviso ao empregador, e somente neste caso, não há que se falar em prorrogação do contrato de trabalho.

1.1.7. Irrenunciabilidade

Em regra, o aviso prévio é direito irrenunciável do empregado, havendo exceção no caso de ter ele obtido novo emprego, conforme determina a **Súmula 276 do TST**.

SUM-276, TST. O direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado. O pedido de dispensa de cumprimento não exime o empregador de pagar o respectivo valor, **salvo** comprovação de haver o prestador dos serviços **obtido novo emprego**.

1.1.8. Falta Grave durante o Aviso Prévio

Se o empregador cometer falta grave durante o aviso prévio, ainda que o aviso tenha sido dado pelo empregado (pedido de demissão), o empregador fica obrigado ao pagamento do restante do aviso, além das verbas rescisórias de natureza indenizatória.

Art. 490, CLT. O empregador que, durante o prazo do aviso prévio dado ao empregado, praticar ato que justifique a rescisão imediata do contrato, sujeita-se ao pagamento da remuneração correspondente ao prazo do referido aviso, sem prejuízo da indenização que for devida.

Caso o empregado cometa qualquer falta grave durante o aviso, perde o direito ao restante dele, além das verbas rescisórias de natureza indenizatória, salvo, neste último caso, se a falta for por abandono de emprego.

Art. 491, CLT. O empregado que, durante o prazo do aviso prévio, cometer qualquer das faltas consideradas pela lei como justas para a rescisão, perde o direito ao restante do respectivo prazo.

SUM-73, TST. A ocorrência de justa causa, salvo a de abandono de emprego, no decurso do prazo do aviso prévio dado pelo empregador, retira do empregado qualquer direito às verbas rescisórias de natureza indenizatória.

Justifica-se a exclusão da justa causa por abandono de emprego por haver, neste caso, presunção de que o empregado tenha conseguido novo emprego, tendo sido necessário o seu afastamento imediato.

1.1.9. Reconsideração

O art. 489 da CLT estabelece que é perfeitamente possível a *reconsideração* durante o período de aviso prévio. De acordo com o art. 489 da CLT, pode a parte que avisou à outra da sua intenção de rescindir o contrato, arrependendo-se, voltar atrás na sua decisão e solicitar a manutenção do vínculo. À outra parte caberá decidir se desconsidera ou não o aviso prévio.

Art. 489, CLT- Dado o aviso prévio, a rescisão torna-se efetiva depois de expirado o respectivo prazo, mas, se a parte notificante reconsiderar o ato, antes de seu termo, à outra parte é facultado aceitar a reconsideração. Assim, a reconsideração é ato bilateral, devendo a parte que recebeu o aviso com ela anuir.

Existe, no entanto, a *reconsideração tácita*, prevista no **art. 489, parágrafo único da CLT**, que ocorre quando as partes não manifestam expressamente a sua vontade, mas agem em conformidade com a reconsideração e em desconformidade com a intenção de rescindir o contrato.

Art. 489, CLT, Parágrafo único - *Caso seja aceita a reconsideração ou continuando a prestação depois de expirado o prazo, o contrato continuará a vigorar, como se o aviso prévio não tivesse sido dado.*

Visualiza-se mais claramente essa hipótese com o aviso prévio trabalhado, podendo ocorrer de o empregado trabalhar os 30 dias do aviso prévio e ao invés de findar a prestação de serviços, no dia seguinte ele retomar o trabalho normalmente, prosseguindo com seu labor, pelo que o empregador não se insurge, aceitando que o empregado continue trabalhando como se o aviso prévio não tivesse sido dado.

1.1.10. Forma do Aviso Prévio

A lei não exige que o aviso prévio seja escrito, podendo também ser verbal.

1.1.11. Término do Aviso Prévio no Mês da Data-Base da Categoria Profissional do Empregado

Data-base é o dia e mês, variável de acordo com a categoria profissional, em que os sindicatos de empregados incitam os sindicatos de empregadores com o objetivo de reajustar os termos dos seus contratos coletivos de trabalho, ou seja, é o mês em que a categoria profissional provoca a categoria econômica para negociação coletiva.

Ex.: bancário (data-base em setembro)

Aviso prévio



Sendo notificado o empregado em 03 de agosto, o seu contrato prorroga-se até 02 de setembro, independentemente de ser trabalhado ou indenizado. Logo, no caso do bancário, sendo em setembro a data-base, havendo reajuste coletivo, este incidirá no aviso prévio ainda que tenha sido indenizado, quando o pagamento é

feito até 10 dias contados a partir do término do contrato.

Isso ocorre mesmo se o reajuste for realizado após a data-base, ou seja, se ultrapassar o mês da data-base, tendo, nesse caso, efeito retroativo, conforme determinado no **art. 487, §6º, da CLT**:

Art. 487, § 6º, CLT O reajustamento salarial coletivo determinado no curso do aviso prévio, beneficia o empregado pré-avisado da despedida, mesmo que tenha recebido antecipadamente os salários correspondentes ao período do aviso, que integra seu tempo de serviço para todos os efeitos legais.

1.1.12. Aviso Prévio Proporcional

Após ter entrado em vigor no dia 13.10.2011, a alteração realizada pela **Lei 12.506/11** trouxe o tão sonhado aviso prévio proporcional. Após 23 anos e oito dias, finalmente o **inc. XXI do art. 7º da Constituição Federal** foi regulamentado e o aviso prévio proporcional passou a existir, disciplinado da seguinte forma:

Lei n. 12.506/11, Art. 1º O aviso prévio, de que trata o Capítulo VI do Título IV da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943, será concedido na proporção de 30 (trinta) dias aos empregados que contem até 1 (um) ano de serviço na mesma empresa”.

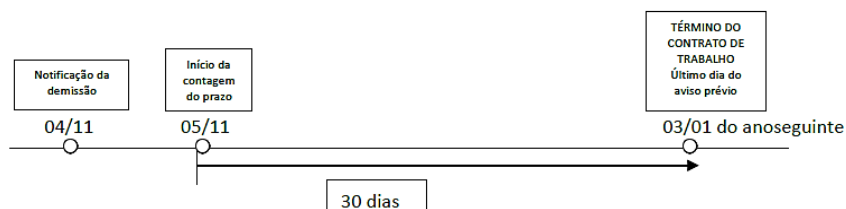
Parágrafo único. Ao aviso prévio previsto neste artigo serão acrescidos 3 (três) dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 (sessenta) dias, perfazendo um total de até 90 (noventa) dias.

Assim, de acordo com a redação literal da lei, ao ser o empregado despedido sem justa causa no primeiro ano de contrato, terá no mínimo aviso prévio de 30 dias (**art. 487, caput, CLT**), aos quais serão acrescidos 03 dias por cada ano de serviço (**Lei 12.506/11**). No entanto, após a edição da **Nota Técnica 184, MTbE** foram acrescidos mais 3 dias ao cálculo acima especificado. Assim sendo, o empregado com menos de um ano de emprego terá 30 dias de aviso e o empregado com um ano de emprego terá 33 dias de aviso prévio, nos termos da tabela abaixo:

Tempo de serviço (anos completos)	Aviso Prévio proporcional ao tempo de serviço (Nº de dias)
0	30
1	33
2	36
3	39
4	42
5	45
6	48

7	51
8	54
9	57
10	60
11	63
12	66
13	69
14	72
15	75
16	78
17	81
18	84
19	87
20	90

Utilizando-se a NT 184 MTbE, o empregado que conta com 10 anos de empresa e demitido sem justa causa, terá aviso prévio proporcional de 60 dias. Caso a notificação da demissão se dê, por exemplo, no dia 04/11 (mês com 30 dias), o início da contagem do prazo será no dia 05/11 e o final do aviso prévio será 03/01 do ano seguinte.



ATENÇÃO: Apesar da interpretação ser equivocada, para a prova da OAB deverá ser utilizada a nota técnica, como ocorreu no **X Exame de Ordem** na Ação de Consignação em Pagamento.

2. FÉRIAS

2.1. Conceito

As férias constituem o período de descanso a que o empregado tem direito após 12 meses de trabalho. A Constituição Federal garante esse direito aos

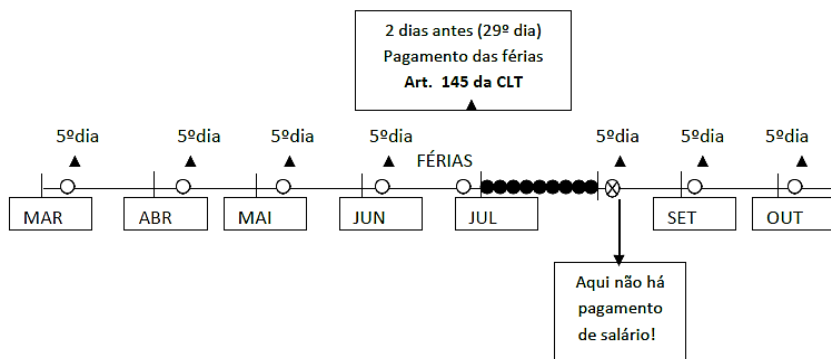
empregados urbanos e rurais, domésticos e aos avulsos, em seu **art. 7º, inciso XVII**:

Art. 7º, CF/88. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XVII - gozo de **férias anuais remuneradas** com, pelo menos, **um terço a mais** do que o salário normal;

2.2. Pagamento

A remuneração de férias é paga de forma antecipada até dois dias antes do início do gozo das férias. Normalmente, a remuneração relativa ao mês trabalhado (mês da prestação de serviços) é paga, no máximo, até o quinto dia útil do mês subsequente ao mês vencido (prestação de serviços). No entanto, caso o empregado goze férias a partir do dia primeiro de julho, sua remuneração de julho, que poderia ser paga até o quinto dia útil do mês de agosto, deverá ser paga até o dia vinte e nove de junho. Vejamos:



De acordo com o **§1º do Art. 459 da CLT**, o pagamento do salário deve ser feito até o 5º dia útil do mês subsequente ao da prestação do serviço:

Art. 459, §1º, CLT - Quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado, o mais tardar, até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido.

Já em se tratando de férias, o pagamento deve ser feito até dois dias antes do início do seu gozo, conforme determinado no **art. 145 da CLT**:

Art. 145, CLT. O pagamento da remuneração das férias e, se for o caso, o do abono referido no artigo 143 serão efetuados até dois dias antes do início do respectivo período.

Caso o empregador descumpra o prazo previsto no art. 145 da CLT, pagando a remuneração de férias do empregado depois do dia 30 de junho, por exemplo, deverá pagar referida remuneração em dobro, nos termos da **Súmula 450 do TST**.

SÚMULA Nº 450, TST. *É devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no art. 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no art. 145 do mesmo diploma legal.*

2.3. Período Aquisitivo e Período Concessivo

As férias são adquiridas e concedidas em dois períodos:

Período aquisitivo: São os doze primeiros meses do contrato de trabalho. No período aquisitivo, o empregado está *adquirindo* o seu direito às férias. Tal direito é adquirido de forma gradativa, na razão de 1/12 (um doze avos) por mês trabalhado. Assim, concluído o período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho do empregado, este terá adquirido o período completo de férias, o que resulta no seu *direito adquirido* às férias.

Período concessivo: É o período equivalente aos 12 meses *subsequentes* ao período aquisitivo. As férias devem ser concedidas ao empregado pelo empregador no período concessivo e o empregado deve gozá-las também neste período. Se o empregado gozar as férias fora do período concessivo terá as férias pagas em dobro. Trata-se das chamadas *férias vencidas dobradas* ou *férias indenizáveis*. Ressalte-se que não se trata de conceder o dobro do período para gozo das férias, mas de remunerar de forma dobrada o valor equivalente ao período.

O **art. 136 da CLT** dispõe que ao empregador cabe escolher o período em que o empregado gozará as férias. Esse ato de concessão das férias pelo empregador é semelhante ao ato administrativo discricionário, pois ele fará a escolha de acordo com sua conveniência e oportunidade e dentro da lei, nesse caso, dentro do período concessivo.

Art. 136, CLT. *A época da concessão das férias será a que melhor consulte os interesses do empregador.*

Assim, se, por exemplo, o empregado recebe o aviso prévio de férias para gozá-las no mês de julho, devendo tal aviso estar em conformidade com o **art. 135 da CLT**, que estabelece a necessidade de o empregador informar a concessão das férias por escrito e com antecedência mínima de 30 dias, o pagamento de seus salários se

dará da seguinte forma:

JUNHO	Mês trabalhado
JULHO	Mês de férias O empregado recebe a remuneração referente ao mês de junho até o 5º dia útil de julho + Remuneração de julho adiantada, correspondente à remuneração de férias + 1/3 do salário
AGOSTO	Mês subsequente ao gozo das férias, que será trabalhado. Neste mês o empregado não recebe salário, visto que o pagamento de salários é feito sempre em relação ao mês anteriormente trabalhado, e no mês de julho o empregado gozou férias e recebeu os salários do mês de forma adiantada.
SETEMBRO	Recebe até o 5º dia útil o salário referente ao mês de Agosto.

É possível ainda, que o empregado receba nas férias a metade do seu 13º salário, desde que comunique ao empregador, até o dia *31 de janeiro* do ano em que vai tirar as férias, que deseja receber desta forma. Quando o empregado comunica ao empregador até a data limite, o empregador é obrigado a pagar a parcela do 13º salário por ocasião das férias. Se o comunicado for feito fora do prazo, cabe ao empregador decidir se pagará ou não dessa forma.

Lei 4.749/65.

Art. 2º - Entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano, o empregador pagará como adiantamento da gratificação referida no artigo precedente, de uma só vez, metade do salário recebido pelo respectivo empregado no mês anterior.

§ 1º - O empregador **não estará obrigado** a pagar o adiantamento, no mesmo mês, a todos os seus empregados.

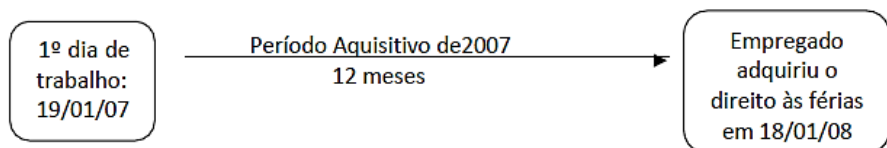
§ 2º - O adiantamento será pago ao ensejo das férias do empregado, sempre que este o requerer no mês de janeiro do correspondente ano.



ATENÇÃO: Se numa prova de 2ª fase da OAB a questão disser que o contrato foi rescindido numa data ou que o empregado foi despedido sem justa causa, sempre prorrogue o contrato de trabalho por, **no mínimo**, mais 30 dias, em virtude do aviso prévio.

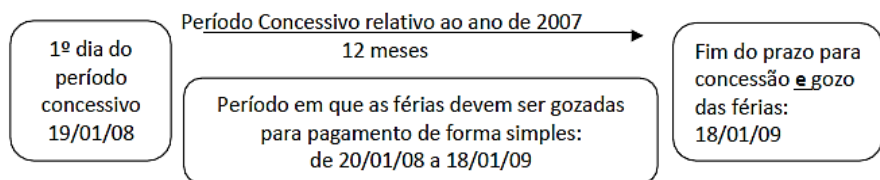
Ex.: Empregado admitido em 19 de janeiro de 2007.

Demissão em 04 de outubro de 2010 (já com aviso prévio projetado)



O primeiro dia de trabalho conta como primeiro dia do período aquisitivo.

Se o primeiro dia não contasse, no exemplo dado, o período aquisitivo seria de 19/01/07 a 19/01/08; mas conta, findando o período aquisitivo em 18 de janeiro de 2008.



Para que o empregador não seja punido com o pagamento das férias em dobro, deverá conceder e o empregado deverá gozar as férias dentro do período concessivo. Logo, o último dia de férias deverá coincidir com o último dia do período concessivo. Esse é o limite para o empregador não ser punido com o pagamento em dobro.

Art. 137, CLT. Sempre que as férias forem concedidas após o prazo de que trata o artigo 134, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração.

§1º Vencido o mencionado prazo sem que o empregador tenha concedido às férias, o empregado poderá ajuizar reclamação pedindo a fixação, por sentença, da época de gozo das mesmas.

§2º A sentença cominará pena diária de cinco por cento do salário mínimo, devida ao empregado até que seja cumprida.

§3º Cópia da decisão judicial transitada em julgado será remetida ao órgão local do Ministério do Trabalho, para fins de aplicação da multa de caráter administrativo.

Se as férias forem concedidas ou gozadas após 18/01/09, no exemplo dado, sua remuneração será paga em dobro. Ainda que apenas um dia das férias seja gozado fora do período, este dia deverá ser pago em dobro. Logo, muito embora o empregador conceda as férias dentro do período concessivo, se elas não forem

gozadas em sua integralidade dentro deste período, haverá pagamento dos dias correspondentes em dobro, ou seja, os dias que ultrapassarem o período serão pagos em dobro. É o que nos diz a **Súmula 81 do TST**:

SUM-81, TST. *Os dias de férias gozados após o período legal de concessão deverão ser remunerados em dobro.*

Sendo assim, de acordo com o entendimento do TST, se o empregador conceder as férias e não pagá-las na época oportuna (**art. 145 da CLT**), esta remuneração será dobrada. Caso o empregado receba a remuneração e não goze o período, o pagamento é também dobrado.



ATENÇÃO! No caso de férias dobradas, estas serão calculadas com base na remuneração percebida pelo empregado quando da extinção do contrato ou da interposição da reclamação trabalhista.

SUM-7, TST. *Indenização pelo não-deferimento das férias no tempo oportuno será calculada com base na remuneração devida ao empregado na época da reclamação ou, se for o caso, na da extinção do contrato.*

Ex.: Imagine que o empregador concedeu as férias do empregado no dia 09/01/09. Neste caso, do dia 09 ao dia 18 de janeiro temos dez dias, e tais dias serão pagos de forma simples, já que dentro do período concessivo. No entanto, os vinte dias subsequentes e complementares às férias, serão pagos em dobro, pois já ultrapassaram o limite máximo que tinha o empregador para concessão das férias do empregado.

Extinção do contrato de trabalho 04/10/2010			
19/01/07 a 18/01/08	19/01/08 a 18/01/09	19/01/09 a 18/01/10	19/01/10 a 04/10/10
P. aquisitivo 07	P. aquisitivo 08	P. aquisitivo 09	P. aquisitivo 10
	19/01/08a18/01/09	19/01/09a18/01/10	19/01/10 a18/01/11
	P.Concessivo 07	P.Concessivo08	P. Concessivo09

Assim, no exemplo dado, se o empregado nunca houver gozado férias, as férias de 2007 e 2008 serão dobradas, as férias de 2009 serão simples e as de 2010 serão proporcionais.

No caso de o empregado demitir-se antes de completar os 12 meses do período aquisitivo, terá ele direito a férias proporcionais, de acordo com a **Súmula 261 do TST**:

SUM-261, TST. *O empregado que se demite antes de complementar 12 (doze)*

meses de serviço tem direito a férias proporcionais.

2.4. Férias Proporcionais

As férias proporcionais são o último período do contrato de trabalho. Neste caso, o empregado ainda não adquiriu o seu direito a um período completo de férias, pois o contrato de trabalho terminou antes de o último período completar doze meses. As férias proporcionais são adquiridas a razão de 1/12 avos por mês trabalhado ou fração superior a 14 dias, nos termos do **art. 146, caput, e parágrafo único da CLT**.

Art. 146, Parágrafo único, CLT. Na cessação do contrato de trabalho, após doze meses de serviço, o empregado, desde que não haja sido demitido por justa causa, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias, de acordo com o artigo 130, na proporção de um doze avos por mês de serviço ou fração superior a quatorze dias.

Tomando-se como base o exemplo do item 2.3 supra, em que o último período do contrato de trabalho foi de **19.01.2010 a 04.10.2010** (data da extinção do contrato de trabalho já com a projeção do aviso prévio), note que este período deveria ter ido de **19.01.2010 a 18.01.2011**, mas houve a extinção do contrato sem justa causa em **04.10.2010**, devendo ser feito até esse dia o cálculo das férias proporcionais, já que o período aquisitivo das férias do ano de 2010 nem chegou a se completar.

A título de ilustração, o cálculo de férias, tendo o empregado remuneração de R\$ 1.200,00:

	<u>Salário</u>		<u>1/3 Constitucional</u>	
	▲		▲	
*Férias vencidas simples:	R\$1.200,00	+	R\$400,00	= R\$1.600,00
	<u>Férias simples (já com 1/3 constitucional)</u>			
	▲			
*Férias dobradas:	R\$1.600,00	(x 2)	=	R\$ 3.200,00
			<u>Cálculo de 9/12</u>	<u>1/3 Constitucional</u>
			▶	◀
*Férias proporcionais:	(R\$1.200,00x9/12)+1/3=R\$900,00+R\$300,00=R\$1.200,00			

Em suma, temos que:

Férias vencidas dobradas: são aquelas cujo período aquisitivo se completou, o concessivo acabou, mas o empregado não gozou.

Férias vencidas simples: são aquelas cujo período aquisitivo se completou, mas o concessivo não acabou.

Férias proporcionais: são aquelas cujo período aquisitivo sequer se completou.

2.5. Exceções

2.5.1. Forma de Concessão

A regra geral é que as férias sejam concedidas de uma só vez:

***Art. 134** - As férias serão concedidas por ato do empregador, em um só período, nos 12 (doze) meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito*

No entanto, desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até três períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a quatorze dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a cinco dias corridos, cada um, nos termos do art. 134, § 1º da CLT.

2.6. Faltas durante o Período Aquisitivo

As faltas durante o período aquisitivo e suas consequências no período concessivo de férias do empregado encontram-se previstas no **art. 130 da CLT**, da seguinte forma:

Faltas injustificadas no período aquisitivo	Período de gozo de férias
Até 5	30 dias corridos
De 6 a 14	24 dias corridos
De 15 a 23	18 dias corridos
De 24 a 32	12 dias corridos
Acima de 32	Perda do direito às férias

2.7. Abono de Férias

Abono de férias é a faculdade que o empregado tem de converter um terço (1/3) de suas férias em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria correspondente (**art. 143 da CLT**). O abono pecuniário deve ser calculado sobre a remuneração das férias já acrescida de um terço.

***Art. 143, CLT.** É facultado ao empregado converter um terço do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes.*

***§1º** O abono de férias deverá ser requerido até quinze dias antes do término do período aquisitivo.*

Com a reforma trabalhista, os empregados submetidos ao regime de tempo parcial serão regidos pelo art. 130 da CLT.

3. SALDO DE SALÁRIOS

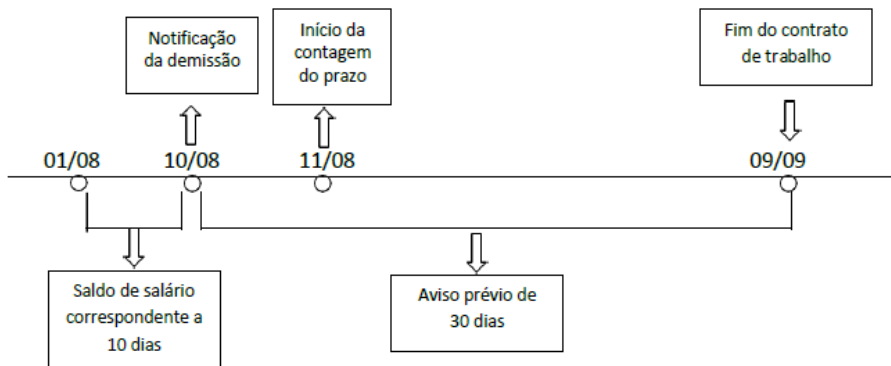
3.1. Conceito

Saldo de salários são os salários pelos dias trabalhados no mês da notificação da demissão, até o dia da notificação da demissão. Assim, se o empregado for demitido, com ou sem justa causa, no dia 22 de junho de 2014, o saldo de salários são os salários do dia 01 de junho até o dia 22 de junho, então, 22 dias de saldo de salários. Caso o empregado tenha sido demitido sem justa causa, o aviso prévio começará a contar a partir do dia 23 de junho. Caso tenha sido demitido com justa causa, o contrato será rescindido no próprio dia 22 de junho, pois não haverá aviso prévio em dispensa com justa causa.

3.2. Saldo de Salário e Aviso Prévio

Importante ressaltar que o saldo de salário e o aviso prévio são direitos compatíveis e cumulativos entre si, de forma que, se a dispensa for sem justa causa, são devidos tanto um como o outro.

Assim, se o empregado for demitido dia 10 de agosto, o saldo de salários será de 10 dias, iniciando-se a contagem do aviso prévio no dia 11 de agosto e terminando o contrato dia 09 de setembro, caso o aviso prévio seja de 30 dias.



4. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

4.1. Conceito

Originariamente denominado de **gratificação natalina**, era concedido por mera liberalidade do empregador aos empregados do comércio, ante o aumento das vendas e, conseqüentemente, dos lucros em virtude das festas de fim de ano.

Após o surgimento da **Lei 4.090/62**, a gratificação natalina tornou-se compulsória e passou a denominar-se **décimo terceiro salário**. Atualmente, é devido por força do **inciso VIII do art. 7º, da CF/88**:

Art. 7º, CF: São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

VIII – décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos IV, VI, **VIII**, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI e XXIV, bem como a sua integração à previdência social.



ATENÇÃO! O 13º salário é calculado com base na REMUNERAÇÃO do empregado e não no salário.

4.2. Forma de Pagamento

O 13º salário é pago, no máximo, em duas metades, desde que a 1ª seja paga até o dia 30 de novembro e a 2ª até o dia 20 de dezembro de cada ano.

O valor pode ser pago de forma integral em novembro, mas nunca de uma só vez em dezembro, pois é obrigatório o adiantamento entre os meses de fevereiro

e novembro, não havendo obrigatoriedade de o empregador pagar de uma só vez a todos os seus empregados. Daí a possibilidade de o adiantamento ocorrer em meses diversos, a fim de que o empregador possa efetuar-lo gradativamente aos seus empregados. É o que dispõem os **arts. 1º e 2º da Lei 4.749/65**:

***Art. 1º** A gratificação salarial instituída pela Lei no 4.090, de 13 de julho de 1962, será paga pelo empregador até o dia 20 de dezembro de cada ano, compensada a importância que, a título de adiantamento, o empregado houver recebido na forma do artigo seguinte.*

***Art. 2º** Entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano, o empregador pagará, como adiantamento da gratificação referida no artigo precedente, de uma só vez, metade do salário recebido pelo respectivo empregado no mês anterior.*

***§1º** O empregador não estará obrigado a pagar o adiantamento, no mesmo mês, a todos os seus empregados.*

Enquanto as férias são calculadas de um ano para o outro, o 13º salário é calculado sempre dentro do mesmo ano, sendo garantido na razão de 1/12 avos por mês trabalhado ou fração igual ou superior a 15 dias.

O **§2º do art. 2º da Lei 4.749/65** traz a possibilidade de o empregado requerer a primeira metade do 13º juntamente com o pagamento das férias:

***Lei 4.749/65, Art. 2º, §2º** O adiantamento será pago ao ensejo das férias do empregado, sempre que este o requerer no mês de janeiro do correspondente ano.*

Para os empregados que percebem salário variável, o adiantamento será calculado na base da média aritmética das importâncias devidas nos meses trabalhados até o anterior àquele que se realizar o adiantamento.

5. LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS DO FGTS

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, previsto no **art. 7º, III, da CF/88** e regulamentado na **Lei 8.036/90**, é uma espécie de poupança forçada do empregado, pois é composto por depósitos mensais correspondentes a 8% sobre a sua remuneração (**art. 15 da Lei 8.036/1990**), os quais devem ser feitos pelo EMPREGADOR. Esses depósitos vão para uma conta da Caixa Econômica Federal vinculada ao contrato de trabalho.

***Art. 7º, CF/88.** São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:*

III - fundo de garantia do tempo de serviço;

***Lei 8.036/1990, Art. 15.** Para os fins previstos nesta Lei, todos os empregadores*

ficam obrigados a depositar, até o vigésimo dia de cada mês, em conta vinculada, a importância correspondente a 8% (oito por cento) da remuneração paga ou devida, no mês anterior, a cada trabalhador, incluídas na remuneração as parcelas de que tratam os arts. 457 e 458 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Gratificação de Natal de que trata a Lei nº 4.090, de 13 de julho de 1962. (Redação dada pela Lei nº 14.438, de 2022).

De acordo com **art. 20, inciso I, da Lei 8.036/1990**, o FGTS poderá ser movimentado quando da rescisão sem justa causa, culpa recíproca e força maior, motivo pelo qual deverá ser sempre solicitado o seu levantamento quando a peça for reclamação trabalhista.

Lei 8.036/1990, Art. 20. *A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações:*

I - Despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de culpa recíproca e de força maior;

6. INDENIZAÇÃO DE 40% SOBRE OS DEPÓSITOS DO FGTS

6.1. Conceito

Trata-se de uma indenização, um percentual, que é pago a mais quando da rescisão injusta do contrato de trabalho. Encontra previsão no art. 7º, inciso I, da CF/88:

Art. 7º, CF/88. *São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:*

I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;

A indenização de 40% sobre os depósitos de FGTS encontra-se prevista também no **art. 10, inciso I, da ADCT e no art. 18 da Lei 8.036/90**:

Art. 10, ADCT. *Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o Art. 7º, I, da Constituição:*

I - fica limitada a proteção nele referida ao aumento, para quatro vezes, da porcentagem prevista no Art. 6º, caput e §1º, da Lei nº 5.107, de 13 de setembro de 1966;

Lei 8.036/1990, Art. 18. *Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, por parte do empregador, ficará este obrigado a depositar na conta vinculada do trabalhador no FGTS os valores relativos aos depósitos referentes ao mês da rescisão e ao imediatamente anterior, que ainda não houver sido recolhido, sem prejuízo das cominações legais.*

§1º *Na hipótese de despedida pelo empregador sem justa causa, depositará este, na conta vinculada do trabalhador no FGTS, importância igual a quarenta*

por cento do montante de todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho, atualizados monetariamente e acrescidos dos respectivos juros.

§2º *Quando ocorrer despedida por culpa recíproca ou força maior, reconhecida pela Justiça do Trabalho, o percentual de que trata o § 1º será de 20 (vinte) por cento.*

§3º *As importâncias de que trata este artigo deverão constar da documentação comprobatória do recolhimento dos valores devidos a título de rescisão do contrato de trabalho, observado o disposto no art. 477 da CLT, eximindo o empregador, exclusivamente, quanto aos valores discriminados.*

6.1.1. Hipóteses de Cabimento

A indenização, regra geral, é devida nos contratos por prazo indeterminado e **NÃO** devida nos contratos por prazo determinado. Isso porque nos contratos por prazo determinado, como o próprio nome demonstra, a data de término é previamente ajustada entre as partes, inexistindo surpresa por parte do empregado quanto a sua dispensa.



ATENÇÃO! O art. 445, *caput*, da CLT estabelece que o prazo dos contratos por prazo determinado não pode ser superior a dois anos.

Art. 445, CLT. *O contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais de 2 (dois) anos, observada a regra do Art. 451.*

Observe-se, nesse sentido, o disposto no **art. 475, caput e §1º, da CLT:**

Art. 475, CLT. *O empregado que for aposentado por invalidez terá **suspensão** o seu contrato de trabalho durante o prazo fixado pelas leis de previdência social para a efetivação do benefício.*

§1º *Recuperando o empregado a capacidade de trabalho e sendo a aposentadoria cancelada, ser-lhe-á assegurado o direito à **função que ocupava** ao tempo da aposentadoria, facultado, porém, ao empregador, o direito de **indenizá-lo** por rescisão do contrato de trabalho, nos termos dos arts. 477 e 478, **salvo** na hipótese de ser ele portador de estabilidade, quando a indenização deverá ser paga na forma do Art. 497.*

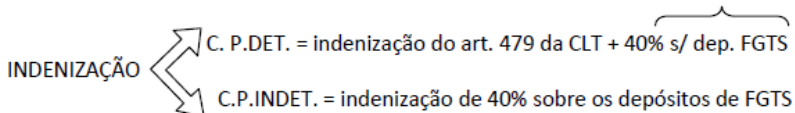
§2º *Se o empregador houver **admitido substituto** para o aposentado, **poderá rescindir**, com este, o respectivo contrato de trabalho sem indenização, **desde que** tenha havido ciência inequívoca da interinidade ao ser celebrado o contrato.*

Fica bem claro, pelo **§2º** do dispositivo legal exposto, que, regra geral, não há indenização quando do término dos contratos por prazo determinado, desde que a sua provisoriedade tenha sido indubitavelmente informada ao empregado. O

cabimento de indenização compensatória nesse tipo de contrato constitui uma exceção.

Vejamos, então, as diferenças existentes entre a indenização compensatória nos contratos por prazo indeterminado e nos contratos por prazo determinado:

Art. 18 da Lei 8.036/90



- * FGTS é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, previsto no art. 7º, III, da CF/88 e regulamentado na Lei 8.036/90.
- * É uma espécie de poupança forçada do empregado, pois é composto por depósitos mensais correspondentes a 8% sobre a sua remuneração, os quais devem ser feitos pelo EMPREGADOR. Esses depósitos vão para uma conta da Caixa Econômica Federal vinculada ao contrato de trabalho.
- * De acordo com o entendimento do STF, o FGTS possui natureza previdenciária.

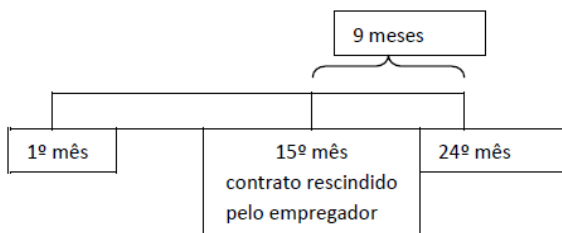
Ex.: Caso o empregado possua R\$10.000,00 em sua conta de FGTS, quando da rescisão sem justa causa do contrato de trabalho ele poderá levantar (sacar) 100% desse valor. Além disso, o empregador deverá pagar ao empregado, a título de indenização compensatória, valor correspondente a 40% sobre R\$10.000,00, ou seja, R\$4.000,00. Os R\$10.000,00 servirão, então, apenas como base de cálculo para a multa.

Apesar de a regra geral ser o não cabimento de indenização nos contratos por prazo determinado, a mesma é devida quando da rescisão antecipada do contrato, sem justa causa, por parte do empregador. Nesse caso, é devida indenização equivalente à metade da remuneração a que o empregado teria direito até o fim do contrato, conforme o **art. 479 da CLT** e entendimento da **Súmula 125 do TST**:

Art. 479, CLT. *Nos contratos que tenham termo estipulado, o empregador que, sem justa causa, despedir o empregado será obrigado a pagar-lhe, a título de indenização, e por metade, a remuneração a que teria feito até o termo do contrato.*

TST. SUM-125. O art. 479 da CLT aplica-se ao trabalhador optante pelo FGTS admitido mediante contrato por prazo determinado, nos termos do art. 30, §3º, do Decreto nº 59.820, de 20.12.1966.

Ex.: Contrato de 24 meses. Salário de R\$1.000,00. Se o contrato for rescindido no 15º mês, o empregador deverá pagar **50%** do valor de remuneração a que o empregado teria direito até o fim do contrato, ou seja: $(R\$1.000,00 \times 9) \div 2 = R\$4.500,00$.



Se a rescisão antecipada do contrato de trabalho por prazo determinado partir do empregado, também **cabereá indenização** deste para o empregador, conforme o disposto no **art. 480 da CLT**, sendo seu valor de no máximo de 50% da remuneração do restante do período em que deveria prestar serviço, sendo necessário que o empregador comprove que sofreu prejuízos.

Art. 480, CLT. Havendo **termo estipulado**, o empregado **não se poderá** desligar do contrato, sem justa causa, sob pena de ser **obrigado a indenizar o empregador** dos prejuízos que desse fato lhe resultarem.

§1º A indenização, porém, não poderá exceder àquela a que teria direito o empregado em idênticas condições.



ATENÇÃO! De acordo com o **art. 481 da CLT**, os CTPD podem conter a chamada **CLÁUSULA ASSECURATÓRIA DO DIREITO RECÍPROCO DE RESCISÃO ANTECIPADA**, que permite às partes rescindirem o contrato de forma antecipada. Neste caso, a indenização se dará nos moldes e princípios dos contratos por prazo indeterminado, ou seja, incidirá a indenização de **40% sobre os depósitos de FGTS** e o **aviso prévio**.

Art. 481, CLT. Aos contratos por prazo determinado, que contiverem cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão, antes de expirado o termo ajustado, aplicam-se, caso seja exercido tal direito por qualquer das partes, os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado.

O contrato de experiência é uma espécie de contrato por prazo determinado

que não pode ultrapassar o prazo de *90 dias* e cujo objetivo é verificar a aptidão do empregado para certa função. Nesse tipo de contrato, conforme o enunciado **da Súmula 163 do TST**, também poderá haver a *cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão*, cabendo AVISO PRÉVIO quando da rescisão antecipada, AINDA QUE A INICIATIVA TENHA SIDO DO EMPREGADO.

SUM-163, TST - Cabe aviso prévio nas rescisões antecipadas dos contratos de experiência, na forma do art. 481 da CLT.

7. INDENIZAÇÃO ADICIONAL DO ART. 9º DA LEI 7.238/84

7.1. Conceito

Essa indenização, também conhecida como indenização complementar, é pouco difundida no Direito do Trabalho e possui relação intrínseca com a *data-base*, que é um mês e dia do ano escolhidos pelas categorias organizadas em sindicatos para se obter melhores condições de trabalho.

Essas melhores condições de trabalho surgem através de negociações que começam antes mesmo da data-base e culminam na elaboração de Acordo Coletivo ou Convenção Coletiva de Trabalho.



ATENÇÃO! Se a questão não informar, presume-se que a data-base é no 1º dia do mês.

Um exemplo das tão almejadas melhores condições de trabalho buscadas pelas categorias profissionais é o valor atual das horas extras da categoria de jornalistas, pois, para eles, a partir da segunda hora extra prestada, incide o adicional de 100% sobre o valor da hora normal.

7.2. Cabimento

Se o empregado for demitido nos 30 dias que antecedem a data-base, terá ele direito à indenização do **art. 9º da Lei 7.238/84**:

Lei 7.238/84, Art. 9º O empregado dispensado, sem justa causa, no período de 30 (trinta) dias que antecede a data de sua correção salarial, terá direito à indenização adicional equivalente a 1 (um) salário mensal, seja ele optante ou não pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Considera-se a expressão “dispensado”, contida no dispositivo legal mencionado, como sendo a efetiva rescisão (término) do contrato de trabalho. Sendo assim, tem-se como base para análise de cabimento da indenização adicional

a data após os 30 dias de aviso prévio (e não a data da notificação da demissão).

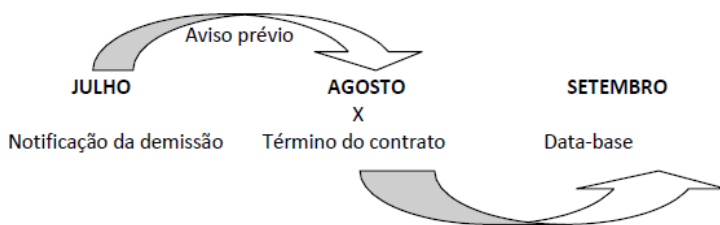
Importante lembrar, que, de acordo com a **Súmula 182 do TST**, o aviso prévio, seja trabalhado ou indenizado, é levado em consideração para efeitos da indenização ora estudada.

SUM-182, TST. O tempo do aviso prévio, **mesmo indenizado**, conta-se para efeito da indenização adicional prevista no art. 9º da Lei nº 6.708, de 30.10.1979.



ATENÇÃO! Considerando que você não pode “inventar” informações na prova, só peça a indenização adicional do art. 9º da Lei 7.238/84 se a questão trouxer a data-base da categoria profissional.

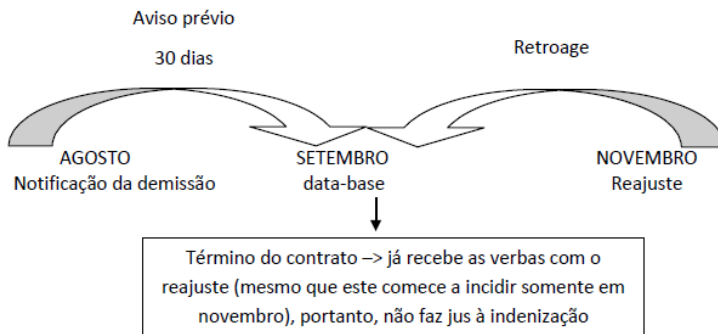
Ex.: Se a notificação da demissão ocorrer em julho e a data-base for em setembro, o término do contrato de trabalho se dará em agosto (por conta do aviso prévio), 30 dias antes da data-base, incidindo, nesse caso, a indenização do art. 9º da Lei 7.238/84.



Se o empregado for demitido em um mês, e, prorrogando-se mais 30 dias em virtude do aviso prévio, o contrato findar-se justamente na *data-base*, não há que se falar em indenização, tendo em vista que as verbas rescisórias já serão calculadas com o novo salário, conforme **§6º do Art. 487 da CLT**:

Art. 487, § 6º, CLT. O reajustamento salarial coletivo determinado no curso do aviso prévio, **beneficia o empregado pré-avisado** da despedida, **mesmo que tenha recebido antecipadamente os salários correspondentes ao período do aviso, que integra seu tempo de serviço para todos os efeitos legais.**

Ex.: Se a notificação for em agosto, com data-base em setembro, não há que se falar em indenização, visto que a rescisão não antecedeu 30 dias da data-base e o empregado já recebe com o reajuste.



Ainda que o empregado já tenha recebido as verbas rescisórias, havendo reajuste no curso do aviso prévio, o empregado terá direito a receber a diferença entre o valor recebido e o reajustado.

Atente para o fato de que, mesmo tendo o empregador pago a rescisão com o reajuste, o simples fato de ter sido a rescisão nos 30 dias que antecedem a data-base, de acordo com a **Súmula 314 do TST**, torna devido o adicional do **art. 9º da lei 7.238/84**.

SUM-314, TST. Se ocorrer a rescisão contratual no período de 30 (trinta) dias que antecede à data-base, observado a Súmula nº 182 do TST, o pagamento das verbas rescisórias com o salário já corrigido **não afasta o direito à indenização adicional** prevista nas Leis nºs 6.708, de 30.10.1979 e 7.238, de 28.10.1984.

7.3. Base de Cálculo

Conforme o entendimento previsto na **Súmula 242 do TST**, se o empregado for dispensado sem justa causa no mês da data-base (contando com a projeção do aviso prévio indenizado ou trabalhado), a base de cálculo das verbas rescisórias e da indenização adicional será o **salário já reajustado** e não o salário que antecede o dissídio, não havendo direito do empregado à percepção da indenização adicional.

Caso, porém, o término do contrato de trabalho (após a projeção do aviso prévio) recaia sobre o mês que antecede a data-base, cabendo a indenização adicional, a base de cálculo desta e das demais verbas rescisórias será o **salário que antecede o dissídio coletivo**. É o entendimento da Súmula 242 do TST.

SUM-242, TST. A indenização adicional, prevista no art. 9º da Lei nº 6.708, de 30.10.1979 e no art. 9º da Lei nº 7.238 de 28.10.1984, corresponde ao salário mensal, no valor devido na data da comunicação do despedimento, **integrado pelos adicionais legais ou convencionados**, ligados à unidade de tempo mês, não sendo computável a gratificação natalina.

Capítulo 6

ALTERAÇÃO CONTRATUAL

1. INTRODUÇÃO

A alteração objetiva do contrato de trabalho é regida pelo *princípio da inalterabilidade contratual lesiva*, previsto no **art. 468, caput, da CLT**, princípio segundo o qual os contratos não podem ser alterados de forma a prejudicar direta ou indireta o empregado. Aliás, nos termos do referido art. 468 da CLT, dois são os requisitos para que o contrato de trabalho possa ser alterado: **1)** anuência das partes, tanto do empregado, quanto do empregador; **2)** desde que a alteração não traga prejuízos diretos ou indiretos ao empregado.

ATENÇÃO!!! **GRIFAR** AS PALAVRAS **DESTACADAS** NA CLT:

As teses da peça são basicamente a junção das palavras destacadas nos artigos com as informações que o caso traz, observe:

Art. 468, CLT – *Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por **mútuo consentimento**, e ainda assim desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia.*

Art. 469 - *Ao empregador é vedado transferir o empregado, **sem a sua anuência**, para localidade diversa da que resultar do contrato, **não se considerando** transferência a que não acarretar **necessariamente a mudança do seu domicílio**.*

§ 1º - *Não estão compreendidos na proibição deste artigo: os empregados que exerçam **cargo de confiança** e aqueles cujos contratos tenham como **condição**, implícita ou explícita, a transferência, quando esta decorra de **real necessidade de serviço**.*

§ 2º - *É **lícita** a transferência quando ocorrer **extinção do estabelecimento** em que trabalhar o empregado.*

§ 3º - *Em caso de **necessidade de serviço** o empregador poderá transferir o empregado para localidade diversa da que resultar do contrato, não obstante as restrições do artigo anterior, mas, nesse caso, ficará obrigado a um pagamento suplementar, nunca inferior a **25% (vinte e cinco por cento)** dos salários que o empregado percebia naquela localidade, enquanto durar essa situação.*

A reclamante tem direito ao **adicional de transferência**, pois a **transferência foi provisória** porque (explique com os dados do caso), nos termos do art. 469, parágrafo único, §3º da CLT e art. 300, §2º CPC.

Todo empregado que é admitido aos serviços de uma empresa é enquadrado numa função. Entenda-se por função o conjunto de tarefas desenvolvidas pelo empregado na empresa. O enquadramento funcional é a função que ele passa a ocupar, sua posição na empresa.

Assim, se alguém é contratado para ministrar aulas em um cursinho, nesta empresa ele foi enquadrado como professor ou na função de professor e desempenhará as tarefas relativas ao ministério de aulas.

2.2. Reenquadramento Funcional

Reenquadramento funcional é a volta a uma função anterior, ao antigo enquadramento, de modo que o empregado ao ser admitido numa empresa é enquadrado numa função e, por determinação expressa e formal da empresa, é enquadrado numa outra função. Ao retornar à primeira função, está sendo reenquadrado.

Em regra, a necessidade ou o pedido de reenquadramento funcional ocorre quando, por exemplo, o empregado é contratado e enquadrado numa função com determinadas vantagens salariais ou contratuais e, depois, é remanejado (enquadrado) para outra função com menores vantagens salariais ou contratuais. Dada à alteração contratual lesiva (**art. 468, CLT**), o empregado pede para ser reenquadrado na primeira função que lhe era mais vantajosa e receber as diferenças salariais do período.

2.2.1. O que se deve pedir numa Reclamação Trabalhista?

Nulidade da alteração contratual + reenquadramento na função anterior + diferenças salariais + reflexos nas verbas rescisórias e indenizatórias

2.3. Desvio de função

Desvio de função é o fato de um empregado enquadrado numa função passar a desempenhar as tarefas relativas a uma outra função, informalmente, sem que tenha havido enquadramento na nova função. Em regra, a nova função é superior a primeira tanto hierárquica quanto financeiramente, mas na CTPS do empregado ainda consta a primeira função e ele continua percebendo o salário da primeira.

2.3.1. O que se deve pedir numa Reclamação Trabalhista?

Nulidade da alteração contratual + enquadramento na função superior + diferenças salariais + reflexos nas verbas rescisórias e indenizatórias

2.4. Acúmulo de funções

Acúmulo de funções se dá quando o empregado, enquadrado numa função, além das tarefas relativas às suas funções, desempenha outras para as quais não foi contratado.

Art. 456. A prova do contrato individual do trabalho será feita pelas anotações constantes da carteira profissional ou por instrumento escrito e suprida por todos os meios permitidos em direito.

Parágrafo único. A falta de prova ou inexistindo cláusula expressa e tal respeito, entender-se-á que o empregado se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal.

2.4.1. O que se deve pedir numa Reclamação Trabalhista?

Caso o acúmulo esteja dentro das condições pessoais e profissionais do empregado:

Acúmulo de funções + enquadramento também na função acumulada + diferenças salariais + reflexos nas verbas rescisórias e indenizatórias

A reclamante tem direito às **diferenças salariais OU plus salarial**, pois **acumulava as funções** de (dados do caso), nos termos do art. 456, parágrafo

Caso o acúmulo **não** esteja dentro das condições pessoais e profissionais do empregado:

Nulidade da alteração contratual + rescisão indireta + verbas rescisórias e indenizatórias + indenização por dano moral

2.5. Rebaixamento

Rebaixamento é o “downgrade”, ou seja, o empregado é enquadrado numa função com determinada vantagem salarial, depois o empregador o enquadra numa função hierarquicamente inferior com salário inferior.

2.5.1. O que se deve pedir numa Reclamação Trabalhista?

Caso o contrato já tenha sido extinto:

Nulidade da alteração contratual + reenquadramento na função anterior + diferenças salariais + reflexos nas verbas rescisórias e indenizatórias + indenização por dano moral

Caso o contrato ainda esteja em vigor:

Nulidade da alteração contratual + rescisão indireta + reenquadramento na função anterior + diferenças salariais + reflexos + verbas rescisórias e indenizatórias + indenização por dano moral

2.6. Reversão:

Reversão significa volta, retorno, e só se pode voltar ou retornar caso se tenha ido ou sido e está prevista no **§ 1º do art. 468 da CLT**. A reversão tem a ver com a assunção de um cargo provisório, temporário, interino como o de confiança, a exemplo de gerente, coordenador, chefe, diretor.

Art. 468, § 1º Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança.

§ 2º A alteração de que trata o § 1o deste artigo, com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada, independentemente do tempo de exercício da respectiva função.

Normalmente, usamos os artigos aqui mencionados na contestação.

TESE DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL

NA CONTESTAÇÃO:

O reclamante **não tem direito** a manutenção do pagamento da gratificação de função, pois o valor **não é incorporado a remuneração, não constituindo direito adquirido** do empregado, nos termos do Art.468, §1º e §2º da CLT.

3. TRANSFERÊNCIA DO EMPREGADO

A transferência do empregado é a típica alteração contratual lesiva, porque traz evidentes prejuízos ao empregado²⁰, mas que não é considerada nula caso haja o preenchimento dos requisitos previstos em lei para que o empregador possa transferir o empregado.

Para que o empregado seja transferido são necessários três requisitos:

- a) A anuência do empregado – Exceções: **a)** empregados ocupantes de cargos de confiança; **b)** contratos com cláusula implícita ou explícita de transferência; **c)** extinção do estabelecimento.
- b) Necessária mudança de domicílio;
- c) Real necessidade de serviços.

3.1. Empregados ocupantes de cargos de confiança/ cláusula explícita de transferência

Os empregados ocupantes de cargo de confiança já têm cláusula implícita (presumida) de transferência (**§1º do art. 469, CLT**) dada a relação de fidúcia existente entre o gerente, por exemplo, e o empregador. Assim, desde que o empregado realmente tenha encargo de gestão, exercendo função de confiança, sua transferência prescindirá de sua anuência, mesmo assim o empregador deverá comprovar real necessidade de serviço, a fim de se evitar uma transferência abusiva.

No caso de contratos com cláusula explícita de transferência, o empregador também deverá comprovar real necessidade de serviço, nos termos da **súmula 43 do TST**.

***Súmula nº 43, TST** - Presume-se abusiva a transferência de que trata o §1º do Art. 469 da CLT, sem comprovação da necessidade do serviço.*

3.1.1.1. Extinção do estabelecimento

O **§2º do art. 469 da CLT** não deixa dúvidas quanto a possibilidade de transferência sem a anuência do empregado, ao estabelecer que, no caso de extinção do estabelecimento em que trabalha o empregado, é lícita a transferência dele.

Nesta hipótese, a real necessidade de serviço não precisa ser comprovada, pois já é presumida e necessariamente definitiva.

3.1.1.2. Necessária mudança de domicílio

Se o local da prestação for alterado, mas não for alterado o domicílio, não se trata de transferência. Se o empregado, em razão da alteração do local da prestação, alterar seu domicílio, isso, por si só, não consiste na transferência, pois necessária mudança de domicílio significa que ou o empregado se muda ou não haverá possibilidade física de os serviços serem prestados na nova localidade.

Apesar de a **súmula 29 do TST** estabelecer que empregado **transferido** por ato unilateral do empregador para local mais distante de sua residência tem direito a suplemento salarial correspondente ao acréscimo da despesa de transporte, não se trata propriamente de transferência, mas de mera remoção ou simples mudança do local da prestação de serviços que, pela alteridade, havendo aumento com as despesas do transporte estas serão arcadas pelo empregador.

3.1.1.3. Real necessidade de serviços

O **§3º, art. 469, CLT** estabelece que em caso de necessidade de serviço, o empregador poderá transferir o empregado para localidade diversa da que resultar do contrato, não obstante as restrições do **artigo 468, CLT**, mas, nesse caso, ficará obrigado a um pagamento suplementar, nunca inferior a 25% (vinte e cinco por cento) dos salários que o empregado percebia naquela localidade, **enquanto durar essa situação**.

Se o empregador não provar a real necessidade de serviços a transferência é ilícita e, conseqüentemente, nula de pleno direito (**arts. 9º e 468 da CLT**).

4. ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA

É possível que a transferência do empregado para localidade diversa da que resultou o contrato original seja definitiva ou provisória. A transferência é definitiva quando o empregado é designado para prestar serviços em outra cidade⁸ sem a intenção de voltar, mas a de se instalar e criar raízes no novo local da prestação de serviços.

Provisória é a transferência do empregado que é levada a efeito para que preste determinados serviços no novo local de trabalho, sem a intenção de ficar, pois tão logo os serviços sejam prestados o empregado retorna ao local de origem.

Nos termos do **§3º do art. 469 da CLT**, quando a transferência é provisória,

⁸ A transferência é lesiva pelo fato de que o empregado terá de se adaptar ao novo local de prestação de serviços, distante de sua terra natal, longe de sua família e amigos, tendo que conhecer e se familiarizar pouco a pouco com novos e estranhos colegas de trabalho. Muitas vezes tem dificuldades de locomoção por não conhecer as ruas da nova cidade ou por não ter a facilidade do transporte próprio.

ela enseja o pagamento pelo empregador ao empregado de um adicional de transferência de pelo menos 25% sobre os salários percebidos pelo empregado na localidade de origem (e não da nova localidade), pois o adicional, de acordo com a lei, só é devido enquanto durar a condição do empregado de transferido.

Retornando o empregado ao local de origem ou transformando-se em transferência definitiva, perderia o direito de perceber o adicional, que é pago mês a mês e tem natureza salarial, refletindo nos direitos trabalhistas do empregado para todos os efeitos.

Mesmo em se tratando de empregados que exercem a função de confiança ou que tenham cláusula implícita ou explícita de transferência, o adicional é devido desde que a transferência seja provisória, nos termos da **OJ 113 da SDI-1 do TST**.

***OJ 113 SDI-I, TST.** O fato de o empregado exercer cargo de confiança ou a existência de previsão de transferência no contrato de trabalho **não exclui o direito ao adicional**, sempre que a transferência **for provisória**.*

TESE DE RECONHECIMENTO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL

NA RECLAMAÇÃO:

A reclamante tem direito ao adicional de transferência, pois **a transferência foi provisória** (EXPLIQUE, dados do caso), nos termos do art. 469, parágrafo único, §3º da CLT e art. 300. §2º CPC.

5. PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A TRANSFERÊNCIA

Não se deve confundir o adicional de transferência com o fato de que as despesas com a transferência são suportadas pelo empregador. É que o adicional de transferência é pago ao empregado mês a mês, tem natureza salarial e *só é devido quando a transferência for provisória*. Já a rubrica das despesas com transferência, significa passagens, mudança e hospedagem provisória ou até o empregado se estabelecer definitivamente no novo local de trabalho. Estas despesas têm natureza indenizatória e são devidas tanto na transferência provisória quanto na definitiva.

***Art. 470, CLT.** As despesas resultantes da transferência correrão **por conta do empregador**.*

6. O QUE SE DEVE PEDIR NUMA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA NO CASO DE TRANSFERÊNCIA ILÍCITA?

No caso de transferência ilícita, por se tratar de alteração contratual, primeiro pede-se a nulidade da alteração contratual e, conseqüentemente, a nulidade da transferência. No entanto, duas são as possibilidades: **1)** Se a transferência ilícita já foi efetivada; **2)** Se a transferência ilícita ainda está na iminência de acontecer.

Caso a transferência ilícita já tenha sido efetivada e o empregado já se encontre no novo local da prestação de serviços:

Nulidade da alteração contratual + nulidade da transferência + liminar em antecipação de tutela para o empregado retornar ao local de origem

A reclamante tem direito de **retornar à cidade de origem**, pois a **transferência é nula** porque (explique com os dados do caso), **PELO QUE REQUER O SEU RETORNO A CIDADE DE ORIGEM POR LIMINAR EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA (PROVISÓRIA)**, nos termos do art. 469 da CLT e art. 300, §2º CPC.

Caso a transferência ilícita esteja apenas na iminência de acontecer, mas ainda não aconteceu:

Nulidade da alteração contratual + nulidade da transferência + liminar em antecipação de tutela para evitar a transferência do empregado

Capítulo 7

JORNADA DE TRABALHO

1. TEMPO DE SERVIÇO

O art. 4º da CLT entende que a jornada de trabalho é o tempo de serviço efetivo, ou seja, é o tempo em que o empregado está à disposição do empregador:

ATENÇÃO!!! **GRIFAR** AS PALAVRAS DESTACADAS NA CLT:

Art. 4º - Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja **à disposição do empregador**, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada.

§ 1º **Computar-se-ão, na contagem de tempo de serviço**, para efeito de indenização e estabilidade, os períodos em que o empregado estiver afastado do trabalho prestando **serviço militar** e por motivo de **acidente do trabalho**.

§ 2º Por **não se considerar** tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário o que **exceder a jornada normal**, ainda que ultrapasse o limite de cinco minutos previsto no § 1º do art. 58 desta Consolidação, quando o empregado, por **escolha própria**, buscar proteção pessoal, em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, entre outras:

I - práticas religiosas;

II - descanso;

III - lazer;

IV - estudo;

V - alimentação;

VI - atividades de relacionamento social;

VII - higiene pessoal;

VIII - troca de roupa ou uniforme, quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa.

1.1. Tempo de serviço em sobreaviso

Empregado em casa aguardando ordens de serviço por no máximo 24 horas. As horas de sobreaviso são remuneradas a 1/3 do salário normal. O mero uso de aparelho de comunicação, como BIP, CELULAR não caracteriza o regime de sobreaviso.

SUM-428, TST.

I - O uso de instrumentos telemáticos ou informatizados fornecidos pela empresa ao empregado, por si só, **não caracteriza o regime de sobreaviso**.

II - Considera-se em sobreaviso o empregado que, à distância e submetido a controle patronal por instrumentos telemáticos ou informatizados, **permanecer**

em regime de plantão ou equivalente, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço durante o período de descanso.

1.2. Tempo de serviço de prontidão

Empregado no local de trabalho aguardando ordens, por no máximo 12 horas. As horas de prontidão serão remuneradas a razão de 2/3 do salário normal.

- **Memorex 1:** Em casa o empregado “aguenta” esperar mais tempo e no alfabeto o **P (prontidão)** vem antes do **S (sobreaviso)**, logo, 12 vem antes de 24.
- **Memorex 2:** Prontidão lembra plantão e o médico dá plantão no local de trabalho.
- **Memorex 3:** Em casa não gasta dinheiro com almoço, com ônibus, não gasta roupa, logo, ganha menos que ficando no trabalho.

2. HORAS EXTRAORDINÁRIAS (art. 7º, XVI, CF/88)

A CF/88 assegura o pagamento das horas extraordinárias com adicional de no mínimo 50% sobre o valor da hora normal de trabalho, sendo, pois, completamente possível que acordos Coletivos tragam previsão de percentual maior.

A despeito da prática cotidiana, é preciso lembrar que os empregados não estão obrigados a prestar horas extraordinárias, logo, os empregadores não podem obrigar a prestação de horas extras, tampouco dispensar o empregado que se negue a prestá-las, conforme se depreende da breve análise do **caput do art. 59 da CLT**:

Art. 59 – A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras, em número não excedente de duas, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho.

Para a prestação de horas extraordinárias a Lei exige:

- a) acordo escrito individual **OU** coletivo

E

- b) máximo de duas horas extras diárias.

Apesar da limitação legal da quantidade de horas extras por dia, as horas extras ilegais (acima das duas permitidas pela CLT ou aquelas que não forem previstas em acordo escrito) devem ser remuneradas, assim como as legais e se forem habituais, deverão integrar o salário, cabendo, ainda, autuação do Ministério

do Trabalho pela infração.

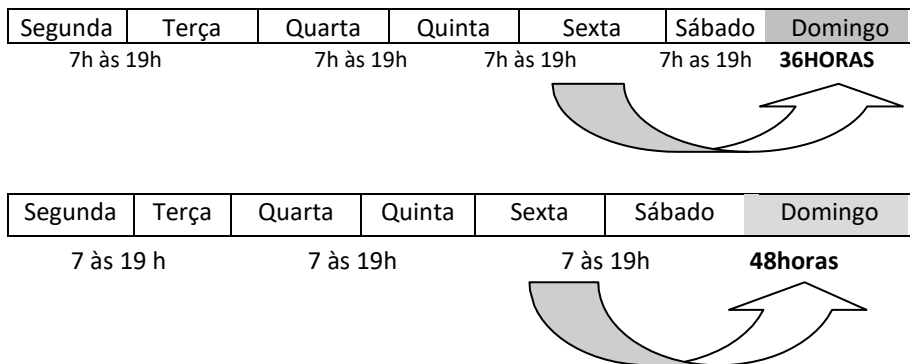
3. SISTEMAS DE COMPENSAÇÃO DE JORNADA (Art. 7º, XIII, CF/88)

3.1. Semana Espanhola (12hx36h)

É sistema de compensação semanal do empregado que trabalha no máximo 48 horas por semana e por no máximo 40 horas na semana seguinte. Pode ser trabalhando num sábado e no seguinte, não ou sistema 12hx36h. O sistema de compensação de jornada 12hx36h somente poderá ser feito mediante convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho, os quais exigem a participação obrigatória dos sindicatos (art. 8º, inc. VI da CF).

Com a reforma trabalhista, quando se tratar de emprego doméstico (LC 150/15, art. 10) ou contratação de profissionais na área da saúde, o sistema de compensação 12hx36h poderá ser celebrado mediante **acordo individual escrito entre empregado e empregador**. Nos demais casos, somente mediante Convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho.

3.2. Escala 12x36:



Com a Reforma Trabalhista, a remuneração mensal pactuada para o trabalho em regime de compensação 12hx36h **abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados** e serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno, quando houver,

de que tratam o art. 70 e o § 5º do art. 73, nos termos do § 1º do art. 59-A da CLT.

Assim, quando a escala de trabalho do empregado em regime de compensação 12x36h coincidir com o trabalho em domingos e feriados, as trinta e seis horas de descanso já compensarão tais períodos, pelo que são indevidas quaisquer folgas compensatórias ou indenizações dobradas.

Dentro das doze horas de trabalho, o intervalo intrajornada será concedido ao empregado, ou indenizado com pagamento de adicional de 50% sobre o valor da hora normal. Tal valor, no entanto, terá natureza meramente indenizatória, e, não, salarial, nos termos do § 4º do art. 71 da CLT:

Art. 71 (...) CLT

§ 4º A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, de **natureza indenizatória**, apenas do **período suprimido**, com **acréscimo de 50%** (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho.

3.4. Semana Inglesa

Sistema de compensação semanal onde a compensação ocorre dentro da própria semana. Por força da reforma trabalhista, o sistema de compensação inglês tornou-se mais fácil, uma vez que pode ser feito mediante acordo individual, tácito ou escrito desde que a compensação ocorra dentro do mesmo mês da prestação de serviços extraordinários, nos termos do §6º do art. 59 da

Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
8h	8h	8h	8h	8h	4h	x = 44h/S

OU

Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
9h	9h	9h	9h	8h	x	x = 44h/S

OU

Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
10h	8h	8h	10h	8h	x	x = 44h/S

CLT.

Em todos os casos, o empregado trabalha 44 horas semanais, respeitando-se, pois, o limite legal de horas laboradas numa mesma semana. Esse sistema permite que o empregador divida as 44 horas semanais do empregado dentro da

semana, respeitando, no entanto, o limite de horas extras permitido por dia, qual seja: 2 horas.

3.5. Semana Francesa

É a compensação semanal na qual o empregado trabalha 7 dias consecutivos e folga dois dias. Não admitida pelo TST para a compensação de horas extras no Brasil, pois entende que fere o **art. 7º, V, CF/88** e o **art. 67 da CLT**. A rechaça a essa modalidade de compensação semanal está presente no entendimento contido na **OJ 410, SDI-1, TST**.

Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
8h	8h	8h	8h	8h	8h	8h

Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
8h	8h	8h	8h	8h	8h	

OJ 410, SDI-1, TST - Viola o art. 7º, XV, da CF a concessão de repouso semanal remunerado após o sétimo dia consecutivo de trabalho, importando no seu pagamento em dobro.

Ocorre que a Lei 605/49 informa que o repouso semanal se refere à semana anterior e não à própria semana, no entanto, para provas de concurso o entendimento deverá ser que o repouso semanal deve ser concedido dentro da mesma semana, vedada a concessão após o sétimo dia consecutivo. Neste mesmo sentido é a **súmula 146 TST**.

TST SÚMULA nº 146 - O trabalho prestado em domingos e feriados, **não compensado**, deve ser **pago em dobro**, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal.

Assim, pela aplicação da **OJ 410, SDI-1- TST**, a semana francesa é inaplicável à compensação de jornada no Brasil.

3.6. Banco de Horas

É um sistema de compensação de jornada em que as horas extras prestadas podem ser compensadas dentro de um período de até um ano. Em regra, o sistema de compensação pelo banco de horas só pode ser celebrado mediante instrumento

de negociação coletiva e seu período máximo de compensação é de um ano. Como é estipulado por convenção ou acordo coletivo, deverá obedecer ao prazo constante no instrumento coletivo, nos termos do § 2º do art. 59 da CLT:

Art. 59 (...)

*§ 2º Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for **compensado pela correspondente diminuição em outro dia**, de maneira que não exceda, no período máximo de um ano, à soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias.*

No entanto, com a reforma trabalhista, abriu-se a possibilidade de o sistema de compensação pelo banco de horas ser celebrado mediante **contrato individual escrito entre empregado e empregador**, desde que a compensação das horas extras prestadas ocorra dentro do período máximo de seis meses, nos termos do § 5º do art. 59 da CLT:

Art. 59 CLT (...)

*§ 5º O banco de horas de que trata o § 2º deste artigo poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no **período máximo de seis meses**.*

4. INTERVALO INTERJORNADA (art. 66, CLT)

Concedido fora da jornada, entre uma jornada e outra. É de, no mínimo, 11 horas. Esse intervalo não é contabilizado na jornada, logo, também não é remunerado. Assim, se o empregado finaliza sua jornada na segunda-feira às 22 horas, o empregador somente poderá exigir seus serviços a partir das 9 horas da manhã da terça-feira. Se o empregador desprezar o intervalo Interjornada deverá pagar horas extraordinárias, consoante **OJ 355, SDI-1, TST**.

Art. 66. *Entre 2 (duas) jornadas de trabalho haverá um período mínimo de **11 (onze) horas consecutivas** para descanso.*

OJ-SDI1-355 - *O desprezo ao intervalo mínimo interjornadas previsto no art. 66 da CLT acarreta, por analogia, os mesmos efeitos previstos no §4º do art. 71 da CLT e na Súmula nº 110 do TST, devendo-se **pagar a integralidade das horas que foram subtraídas do intervalo, acrescidas do respectivo adicional**.*

No caso de haver repouso semanal remunerado entre uma jornada e outra, há que se somar às 24 horas do repouso, as 11 horas do intervalo intrajornada.

Exemplo: Um empregado que trabalha até às 24 horas do sábado e tem seu repouso semanal remunerado aos domingos, só poderá prestar serviços a partir das

11 horas da segunda-feira.

O **art. 67 da CLT** traz a previsão de concessão do repouso semanal remunerado obrigatoriamente aos domingos, no entanto, a partir da entrada em vigor da CF/88, essa coincidência com o domingo passou a ser preferencial e não mais obrigatória.

Há, ainda, obrigação de manutenção pelo empregador de quadro organizando a escala mensal dos repouso semanais, com exceção dos elencos teatrais.

Ainda sobre o repouso semanal preferencialmente aos domingos, pela análise do **art. 386 da CLT** depreende-se que ao homem é assegurado pelo menos um repouso semanal coincidente com o domingo e às mulheres a escala de revezamento será quinzenal.

***Art. 67, CLT.** Será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domingo, no todo ou em parte.*

***Parágrafo único.** Nos serviços que exijam trabalho aos domingos, com exceção quanto aos elencos teatrais, será estabelecida escala de revezamento, mensalmente organizada e constando de quadro sujeito à fiscalização.*

***Art. 386, CLT.** Havendo trabalho aos domingos, será organizada uma escala de revezamento quinzenal, que favoreça o repouso dominical.*

A remuneração do repouso semanal remunerado só é devida se o empregado laborar durante toda a semana, cumprindo integralmente seus horários. Se de forma injustificada o empregado faltar algum dia da semana, ou seja, se não cumprir integralmente a semana do repouso, perderá além da remuneração do dia da falta, a remuneração do repouso semanal, mas gozará o repouso.

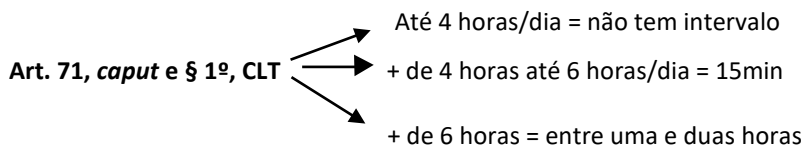
Os empregados domésticos também têm direito aos feriados e ao repouso semanal remunerado.

Se for exigido labor no domingo ou nos feriados e não for dado o repouso compensatório, o dia deverá ser pago de forma dobrada, sem prejuízo do pagamento do repouso semanal remunerado, essa é a inteligência da **Súmula 146, TST**.

5. INTERVALO INTRAJORNADA

É o intervalo dentro da jornada, para repouso e alimentação. Previsto no **art. 71 e em seu §1º, da CLT**.

O §2º do art. 71, CLT é categórico ao afirmar que os intervalos intrajornada, em regra, não são computados na jornada de trabalho e, por isso mesmo, não são remunerados.



É possível, no entanto, que o intervalo intrajornada seja reduzido para menos de uma hora, desde que obedecidas às condições impostas pelo § 3º, art. 71, CLT desde que haja autorização do Ministro do Trabalho (ou Ministério ou o órgão do trabalho competente), empresa organizada em refeitórios e desde que os empregados não estejam prestando horas extras. Com a reforma trabalhista, é possível a redução do intervalo mínimo de uma hora para trinta minutos, mediante convenção ou acordo coletivo de trabalho, nos termos do art. 611-A inciso III da CLT:

Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho, têm **prevalência sobre a lei** quando, entre outros, dispuserem sobre:

I - pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais;

II - banco de horas anual;

III - intervalo intrajornada, **respeitado o limite mínimo de trinta minutos** para jornadas superiores a seis horas;

6. REDUÇÃO OU SUPRESSÃO DO INTERVALO INTRAJORNADA

Os intervalos intrajornada suprimidos ou reduzidos deverão ser remunerados com adicional de 50% sobre o valor da hora normal de trabalho, mas apenas do tempo suprimido ou reduzido, cuja natureza será meramente indenizatória, nos termos do art. 71 § 4º da CLT.

7. INTERVALOS ESPECIAIS PARA DESCANSO

São considerados tempo de serviço (tempo à disposição) para todos os efeitos e, por isso mesmo, são remunerados. Assim, diferentemente dos intervalos ordinários, os intervalos especiais são interrupção do contrato de trabalho e não suspensão. Vejamos algumas modalidades de intervalos especiais:

7.1. Intervalo para repouso do médico/odontólogo (art. 8º, §1º, Lei 3.999/61)

A cada noventa minutos de trabalho é assegurado à classe dos médicos e dos odontólogos um repouso intrajornada de 10 minutos. Não sendo demais lembrar que esses dez minutos fazem parte da jornada, ou seja, são computados na jornada e, por isso, remunerados.

Art. 8º A duração normal do trabalho, salvo acordo escrito que não fira de modo algum o disposto no artigo 12, será:

§1º Para cada noventa minutos de trabalho gozará o médico de um repouso de dez minutos.

7.2. Intervalo para repouso do empregado em atividade de mecanografia/escrituração/datilografia/cálculo (equiparação em relação aos digitadores, Súmula 346 TST), art. 72, CLT.

A cada noventa minutos trabalhados, esses empregados têm assegurado 10 minutos de intervalo intrajornada destinado ao repouso. A **Súmula 346, do TST** atualizou a previsão contida no **art. 72 da CLT**, tendo em vista que equiparou os digitadores aos trabalhadores que trabalham em serviço de mecanografia.

*Art. 72, CLT– Nos serviços permanentes de mecanografia (datilografia, escrituração ou cálculo), a cada período de **90 (noventa) minutos de trabalho consecutivo** corresponderá um repouso de **10 (dez) minutos** não deduzidos da duração normal de trabalho.*

*Súmula nº 346, TST - Os digitadores, por aplicação analógica do Art. 72 da CLT, **equiparam-se** aos trabalhadores nos serviços de mecanografia (datilografia, escrituração ou cálculo), razão pela qual têm direito a intervalos de descanso de dez (10) minutos a cada noventa (90) de trabalho consecutivo.*

7.3. Empregados em minas de subsolo, art. 298, CLT.

A cada três horas ininterruptas de trabalho é assegurado um intervalo de 15 minutos para repouso.

*Art. 298, CLT- Em cada período de **3 (três) horas consecutivas** de trabalho, será obrigatória uma pausa de **15 (quinze) minutos** para repouso, a qual será computada na duração normal de trabalho efetivo.*

7.4. Empregados em câmaras frigoríficas

A cada uma hora e quarenta minutos de trabalho o empregado tem direito a um intervalo de 20 minutos.

Art. 253 - Para os empregados que trabalham no interior das câmaras frigoríficas e para os que movimentam mercadorias do ambiente quente ou normal para o frio e vice-versa, depois de **1 (uma) hora e 40 (quarenta) minutos** de trabalho contínuo, será assegurado um período de **20 (vinte) minutos de repouso**, computado esse intervalo como de trabalho efetivo.

7.5. Empregada em fase de amamentação, art. 396, CLT.

Até o sexto mês de vida da criança, a lactante tem direito a dois intervalos de 30 minutos no decorrer da jornada. Válida a ressalva acerca da possibilidade de concessão dos intervalos seguidos e ao final da jornada, ou seja, ao invés de parar duas vezes durante a jornada, a empregada encerra seu labor uma hora antes. Não há qualquer vedação legal à concessão dos intervalos seguidos, até porque a finalidade (amamentação e contato materno com a criança recém-nascida) é atingida também nessa forma de concessão dos intervalos.

7.6. Tolerância

A CLT prevê tolerância em relação ao início e ao final da jornada, não sendo computados como jornada extraordinária possíveis variações de horário que não excedam de cinco minutos no início ou no final da jornada, limitando a variação a 10 minutos diários. No entanto, se os 10 minutos forem ultrapassados, toda a extrapolação será considerada jornada extraordinária. Esse entendimento é depreendido da breve análise do **art. 58, §1º, CLT e da Súmula 366 do TST**.

Art. 58, CLT- A duração normal do trabalho, para os empregados em qualquer atividade privada, **não excederá de 8 horas diárias**, desde que não seja fixado expressamente outro limite.

§1º - Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto não excedentes de 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diários.

SUM-366, TST. Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário do registro de ponto não excedentes de cinco minutos, observado o **limite máximo de dez minutos diários**. Se ultrapassado esse limite, será considerada como extra a totalidade do tempo que exceder a jornada normal. (ex-Ojs da SBDI-1 nºs 23- inserida em 03.06.1996 - e 326 - DJ 09.12.2003).

8. EMPREGADOS EXCLUÍDOS DO CONTROLE DE JORNADA

8.1. Empregado externo que exerça atividade incompatível com a fixação de jornada (art. 62, I, CLT)

A condição de empregado externo deve ser anotada na Carteira de

Trabalho do empregado e no registro de empregados, pois como situação especial que é, merece registro.

Art. 62 - Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo:

*I - os empregados que exercem **atividade externa incompatível** com a fixação de horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social e no registro de empregados;*

8.2. Gerente (art. 62, II e parágrafo único da CLT)

O simples fato de ser o empregado gerente não o exclui do controle de jornada, pois somente será excluído se cumulados os requisitos contidos no **art. 62, II e parágrafo único**, quais sejam, ocupar cargo de gestão (tem, além do contrato de trabalho, um contrato de mandato, contrato acessório ao de trabalho) e remuneração do cargo ou em decorrência da percepção de gratificação de função pelo menos 40% maior que a remuneração do cargo efetivo.

Art. 62 - Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo:

*I - os empregados que exercem **atividade externa incompatível** com a fixação de horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social e no registro de empregados;*

*II - os **gerentes**, assim considerados os exercentes de cargos de gestão, aos quais se equiparam, para efeito do disposto neste artigo, os diretores e chefes de departamento ou filial.*

*III - os empregados em regime de **teletrabalho**.*

*Parágrafo único - O regime previsto neste capítulo **será aplicável** aos empregados mencionados no inciso II deste artigo, quando o salário do cargo de confiança, compreendendo a gratificação de função, se houver, for **inferior ao valor** do respectivo salário efetivo acrescido de 40% (quarenta por cento).*

Necessário compreender que não existe garantia de percepção de gratificação de função para ocupantes de cargo de gestão, sendo faculdade do empregador, também não existindo obrigação de remunerar o gerente melhor que a função originária, mas é certo que o gerente só será excluído do controle da jornada se sua remuneração (com ou sem a gratificação) superar em, pelo menos, 40% a remuneração referente ao cargo originário.

Exemplos para fixação:

R\$ 1000,00 (sem gratificação): tem controle de jornada.

R\$ 1.300,00 (sem gratificação): tem controle de jornada.

função original: GERENTE R\$ 1.400,00 (sem gratificação): não tem controle de jornada.

R\$ 1.000,00

R\$1.000,00 + R\$ 300 gratificação: tem controle de jornada.

R\$ 1.000,00 + R\$ 400 gratificação: não tem controle de jornada.

8.3. Gerente bancário “gerentinho” (art. 224, §2º, CLT)

É o bancário que exerce cargo de confiança e recebe gratificação de função de pelo menos 1/3 do valor da remuneração do cargo efetivo. A norma deve ser observada com cautela, pois a redação do **§2º do art. 224, CLT** afirma que se o gerente bancário receber gratificação de função de pelo menos 1/3 do valor da remuneração a ele não se aplicará a disposição contida no **caput do art. 224, CLT**, ou seja, a ele não se aplica a limitação de jornada de 6 horas e a vedação de labor aos sábados, logo, poderá laborar até 8 horas diárias, de segunda a sábado, sendo tutelado pela regra geral do controle de jornada e não pela exceção prevista no *caput*.

Assim, o que está previsto, na verdade, não é uma inexistência total de limitação de jornada, mas o alargamento da jornada, ou seja, o que ultrapassar a oitava hora será remunerado com adicional de horas extraordinárias, pois hora extra será. Neste sentido, dispõe a **súmula 102, II, III, IV, TST**.

Art. 224, CLT. A duração normal do trabalho dos empregados em bancos, casas bancárias e Caixa Econômica Federal será de **6 horas contínuas nos dias úteis**, com exceção dos sábados, perfazendo um total de trinta horas de trabalho por semana.

(...)

§ 2º As disposições deste artigo **não se aplicam** aos que exercem funções de direção, fiscalização, Chefia e equivalentes, ou que desempenham outros cargos de confiança, desde que o valor da gratificação não seja inferior a um terço do salário do cargo efetivo.

Súmula nº 102, TST-Bancário - Caixa - Cargo de Confiança

II- O bancário que exerce a função a que se refere o § 2º do art. 224 da CLT e recebe gratificação não inferior a um terço de seu salário **já tem remuneradas** as duas horas extraordinárias excedentes de seis.

III- Ao bancário exercente de **cargo de confiança** previsto no artigo 224, § 2º, da

CLT são devidas as 7ª e 8ª horas, como extras, no período em que se verificar o pagamento a menor da gratificação de 1/3.

*IV- O bancário sujeito à regra do art. 224, § 2º, da CLT cumpre jornada de trabalho de 8 (oito) horas, sendo **extraordinárias as trabalhadas além da oitava.***

8.4. Gerente geral de agência “gerentão” (art. 62, §2º, CLT)

É o gerente superior da agência. Somente existe um por agência, sendo todos os outros gerentes (gerentinhos) a ele subordinados. A exclusão do controle de jornada, no caso dele, é total, podendo, portanto, ultrapassar o limite das 8 horas diárias e laborar independente da percepção de horas extraordinárias.

É regulamentado pela mesma norma aplicável aos ocupantes de cargo de gestão em empresas que não desempenhem atividades bancárias, mas para sua caracterização precisa, além da percepção de pelo menos 40% acima da remuneração do cargo originário, ser o gerente da agência e não apenas de contas ou de relacionamento ou qualquer outra “coisa menor”.

A **Súmula 287 do TST** reitera a inexistência de direito à percepção de horas extraordinárias:

***SÚM. 287, TST** - A jornada de trabalho do empregado de banco gerente de agência é regida pelo art. 224, § 2º, da CLT. Quanto ao gerente-geral de agência bancária, **presume-se o exercício de encargo de gestão**, aplicando-se-lhe o art. 62 da CLT.*

8.5. TELETRABALHADORES

Com a aprovação da Reforma Trabalhista, esse regime de trabalho passa a possuir regulamentação própria, que dá maior segurança a empregados e empregadores e permite que seja mais utilizado. A Reforma utiliza a nomenclatura teletrabalho para se referir ao *home office*, e define o modelo de trabalho, nos termos do art. 75-B da CLT:

***Art. 75-B.** Considera-se teletrabalho ou trabalho remoto a prestação de serviços fora das dependências do empregador, de maneira preponderante ou não, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que, por sua natureza, não configure trabalho externo. (Redação dada pela Lei nº 14.442, de 2022)*

*§ 1º O comparecimento, ainda que de modo habitual, às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento **não descaracteriza o regime de teletrabalho ou trabalho remoto.** (Incluído pela Lei nº 14.442, de 2022)*

Portanto, teletrabalho e trabalho externo não se confundem, este é aquele também realizado fora das dependências do empregador porque sua própria natureza o obriga, por exemplo: instaladores de antenas de TV, leitores de relógios de energia, etc. Já o teletrabalho, embora pudesse ser realizado na empresa, por opção de empregado e empregador, passa a ser realizado de fora das suas dependências.

O primeiro ponto da Reforma que merece destaque é quanto à jornada de trabalho, pois, segundo a Reforma, suas regras não se aplicam aos empregados no regime de teletrabalho. Isto implica dizer, em tese, que o empregado não estaria sujeito ao controle de ponto e, se por um lado deixaria de receber o adicional pelas horas extras, por outro, não haveria mais que se falar em descontos, advertências ou suspensões por atrasos, no regime de teletrabalho.

9. PRÉ CONTRATAÇÃO DE HORAS EXTRAS (Súmula 199, TST)

Nada obsta que no momento da contratação já seja pactuada a prestação de horas extraordinárias, no entanto, no caso de empregado bancário é vedada a pré-contratação de horas extraordinárias, sendo nula essa previsão, pois o **art. 225 da CLT** diz que as horas extras dos empregados bancários só serão prestadas excepcionalmente, logo incompatível com a pré-contratação.

TST Enunciado nº 199 - Serviço Suplementar - Bancário - Pré-Contratação de Horas Extras

I- A contratação do serviço suplementar, quando da admissão do trabalhador bancário, é nula. Os valores assim ajustados apenas remuneram a jornada normal, sendo devidas as horas extras com o adicional de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento), as quais não configuram pré-contratação, se pactuadas após a admissão do bancário. (ex-Súmula nº 199 – alterada pela Res. 41/1995, DJ21.02.1995 e ex-OJ nº 48 da SBDI-1 – inserida em 25.11.1996)

II- Em se tratando de horas extras pré-contratadas, opera-se a prescrição total se a ação não for ajuizada no prazo de cinco anos, a partir da data em que foram suprimidas. (ex-OJ nº 63 da SBDI-1 – inserida em 14.03.1994)

10. JORNADA NOTURNA

Para compensar as alterações do ciclo normal, o empregado é remunerado de forma especial, através do adicional noturno, previsto no **art. 7º, IX, CF e art. 73 da CLT**.

A **hora noturna é paga em valor superior à hora diurna**, tendo os domésticos direito a tal diferença, a partir da entrada em vigor da LC 150/15. Assim,

somente os empregados urbanos e rurais têm direito ao adicional noturno, mas existindo entre eles diferenças, sendo verdadeira hipótese de incidência do brocardo direitos iguais na essência e não na existência.

O horário noturno do empregado urbano se encontra previsto no **artigo 73, §2º, CLT** e é das 22 horas às 5 horas, sendo, no entanto, reduzida a hora noturna, pois uma hora diurna equivale a 60 minutos e uma hora noturna a 52 minutos e 30 segundos. Trata-se de ficção jurídica (fato reconhecidamente falso que a lei reputa verdadeiro).

Logo, das 22 horas às 5 horas se tem 8 horas noturnas.

Há que se ressaltar que, por se tratar de jornada especial, o obreiro não gozará de intervalo intrajornada. A hora extra noturna do empregado urbano é acrescida de 20% da hora diurna.

11. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO

O novo entendimento do TST (**OJ 360 TST**), afirma que para caracterização dos turnos ininterruptos de revezamento, a empresa não precisa operar durante 24 horas do dia e 7 dias da semana, nem os empregados não precisam operar durante 24 horas do dia e 7 dias da semana, bastando que a empresa funcione em apenas dois turnos, um diurno e um noturno, ainda que parcialmente, e os empregados se revezem nesses horários.

Só é revezamento se houver permuta entre os turnos da noite e do dia, dado o caráter prejudicial do labor noturno.

Novo quadro de revezamento em turnos ininterruptos:

TURNOS	1ª SEMANA	2ª SEMANA	3ª SEMANA	4ª SEMANA
12H – 18H	Empregado A	Empregado B	Empregado A	Empregado B
18H – 24H	Empregado B	Empregado A	Empregado B	Empregado A

De acordo com o **artigo 7º, XIV, CF**, a jornada dos turnos ininterruptos de revezamento é de 6 horas, salvo negociação coletiva, pois a Convenção Coletiva e o Acordo Coletivo de Trabalho podem aumentar o limite das 6 horas para 08, sendo, no entanto, nula a previsão através de contrato individual, consoante **Súmula 423 TST**.

Súmula nº 423 - TST - Estabelecida jornada superior a seis horas e limitada a oito horas por meio de regular negociação coletiva, os empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento **não tem direito** ao pagamento da 7ª e 8ª horas como extras.

O art. 73, caput, CLT autoriza o revezamento semanal ou quinzenal, mas não pode ser mensal.

Art. 73 – Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá **remuneração superior à do diurno** e, para esse efeito, sua remuneração terá um **acréscimo de 20% (vinte por cento)**, pelo menos, sobre a hora diurna.

Há que se ressaltar, no entanto, que a exceção contida no **caput, do art. 73, da CLT** não foi recepcionada pela Constituição de 1967, pois até os empregados que trabalhem em turnos ininterruptos de revezamento têm direito ao adicional noturno (em relação às horas noturnas que vier a laborar). Esse também é o entendimento da **Súmula 213 do STF**, observe-se:

STF Súmula nº 213 - Adicional de Serviço Noturno - Regime de Revezamento. É devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento.

Há que se compreender, ainda, que a concessão do intervalo intrajornada não descaracteriza o turno ininterrupto de revezamento, sendo esse o entendimento contido na Súmula 360, TST.

TST Enunciado nº 360 - Repouso e Alimentação Dentro de Cada Turno - Repouso Semanal - Turno de Revezamento

A interrupção do trabalho destinada a repouso e alimentação, dentro de cada turno, ou o intervalo para repouso semanal, **não descaracteriza o turno de revezamento** com jornada de 6 (seis) horas previsto no art. 7º, XIV, da CF/1988.

Capítulo 8

REMUNERAÇÃO E SALÁRIO

1. REMUNERAÇÃO

De acordo com o entendimento jurisprudencial, a remuneração é a composição de salário, adicionais eventuais e gorjetas, porém, o **art. 457, caput, da CLT**, define remuneração como sendo composta apenas por salário e gorjetas.

ATENÇÃO!!! **GRIFAR** AS PALAVRAS DESTACADAS NA CLT:

*Art. 457, CLT. Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do **salário** devido e pago diretamente pelo empregador, como **contraprestação do serviço**, as **gorjetas que receber**.*

Assim, temos duas definições para remuneração:

- **Definição jurisprudencial:** compreendem-se na remuneração do empregado, além do salário, as gorjetas e os adicionais eventuais.
- **Definição legal:** compreendem-se na remuneração do empregado o salário e as gorjetas.

2. GORJETAS

Gorjeta é a **importância em pecúnia** paga direta e separadamente ao prestador do serviço, sendo, por isso, uma espécie de remuneração *sui generis*. Essa parcela **não integra o salário** pelo fato de ser paga por terceiros e não pelo empregador. É o entendimento do **art. 457, caput, da CLT e da Súmula 354 do TST**:

*Art. 457, CLT - Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do **salário** devido e pago diretamente pelo empregador, como **contraprestação do serviço**, as **gorjetas que receber**.*

*SUM-354, TST. As gorjetas, cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos clientes, **integram a remuneração do empregado, não servindo de base de cálculo** para as parcelas de aviso-prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado.*



ATENÇÃO! Quando não há gorjetas, o salário é quantitativamente igual à remuneração. Essa distinção é extremamente importante por existirem direitos trabalhistas que são calculados sobre a remuneração e direitos que são calculados só sobre o salário.

Observe que o **art. 457, §3º, da CLT**, também considera como gorjeta o valor adicional na conta que a empresa cobra sob a alegação de que ele será posteriormente distribuído entre os seus empregados.

Art. 457, CLT,
(...)

*§ 3º. Considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente dada pelo cliente ao empregado, como também o **valor cobrado pela empresa**, como serviço ou adicional, a qualquer título, e destinado à distribuição aos empregados.*

Pelo dispositivo legal mencionado, depreende-se que há duas espécies de gorjeta:

- **Gorjeta direta:** Aquela que o cliente dá espontaneamente ao empregado (não há nenhum tipo de cobrança, sendo oferecida pelo cliente).
- **Gorjeta indireta:** Aquela que se cobra do cliente na nota de serviço (conta) e destinada à distribuição aos empregados.



ATENÇÃO! A remuneração não pode ser composta só de gorjetas, haja vista que estas são valores “a mais” pagos diretamente pelo cliente ao empregado, não substituindo o salário, que é toda contraprestação devida e paga diretamente pelo empregador ao empregado. O direito à percepção de salário encontra-se previsto no **art. 7º, inciso IV, da Carta Magna**:

Art. 7º, CF/88: São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

Sendo assim, se uma questão de 2ª fase da OAB trouxer a informação de, por exemplo, um garçom que sempre recebeu somente gorjetas, é necessário

requerer na peça os salários de todo o período do contrato de trabalho, com base no **art. 7º, inciso IV, da CF/88 e art. 457, §3º, da CLT.**

3. SALÁRIO

O SALÁRIO é definido pela jurisprudência como sendo o complexo de parcelas contra prestativas devidas e pagas diretamente ao empregado pelo empregador em decorrência do contrato de trabalho. **Ex.:** Professor não recebe gorjeta, então, o valor de sua remuneração é igual ao valor de seu salário.

O **SALÁRIO INTEGRA A REMUNERAÇÃO** e não o contrário. Assim, encaixam-se no conceito de salário apenas e tão somente aquelas parcelas devidas e pagas diretamente pelo empregador ao empregado, ficando de fora as gorjetas, que são devidas e pagas pelos clientes dos empregadores, servindo estes, muitas vezes, apenas como repassadores de referidas verbas que comporão a remuneração, mas nunca o salário.

Existem direitos trabalhistas que são calculados sobre o salário e direitos trabalhistas que são calculados sobre a remuneração. Se o direito trabalhista é calculado sobre a remuneração, entram no seu cálculo o salário e as gorjetas. Se o direito trabalhista é calculado só sobre o salário, as gorjetas ficam de fora.

Alguns autores afirmam que remuneração é igual a salário, porém, essa afirmação contraria o disposto na CLT e o entendimento do TST.

2.4. Salário por força de lei

Existem créditos trabalhistas que, por força de lei, integram o salário. São eles os previstos no **§1º do art. 457, da CLT**:

Art. 457, CLT, §1º Integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador.

2.5. Salário fixo

Entende-se por salário fixo o valor acordado entre as partes a ser recebido mensalmente pelo empregado em decorrência do serviço prestado.

3. COMISSÕES E PERCENTAGENS

Cumprir destacar, inicialmente, as diferenças existentes entre comissões e percentagens.

As **comissões** constituem um valor fixo sobre a produção. **Ex.:** Um vendedor de carros ganha R\$ 100,00 a mais na venda de carro de luxo e R\$ 50,00 a mais na venda de carro popular e somente as comissões são salário, as percentagens, não.

Já as **percentagens** são valores percentuais calculados sobre a produção, venda ou prestação do serviço. Logo, o percentual é fixo, mas o resultado é variável. **Ex.:** Um vendedor de roupas que ganha 5% sobre suas vendas, caso venda R\$1.000,00 em um mês, receberá R\$50,00 referente à percentagem.

Não é permitido que a remuneração seja composta somente por gorjetas, mas é possível que seja composta só por comissões e percentagens, haja vista que, de acordo com o **art. 457, §1º, da CLT**, essas parcelas integram o salário, sendo devidas de forma direta pelo empregador ao empregado.

Como a Constituição Federal garante, em seu **art. 7º, inciso VII**, que o empregado que recebe remuneração variável não pode ter seu salário inferior ao mínimo, se o vendedor não atingir, através de suas comissões, o salário mínimo, ainda assim este lhe será devido.

Não pode o empregador, ainda, sob a justificativa de que o empregado não atingiu o mínimo no mês anterior, descontar no mês subsequente o que pagou a mais, caso o empregado ultrapassasse o mínimo pelas comissões a que fizer jus (**art. 7º, parágrafo único, da CF/1988**).

Art. 7º, CF/88

*VII – garantia de salário, **nunca inferior ao mínimo**, para os que percebem remuneração variável;*

Art. 78, CLT - Quando o salário for ajustado por empreitada, ou convencionado por tarefa ou peça, será garantida ao trabalhador uma remuneração diária nunca inferior à do salário-mínimo por dia normal da região, zona ou subzona.

Parágrafo único. Quando o salário-mínimo mensal do empregado a comissão ou que tenha direito a percentagem for integrado por parte fixa e parte variável, ser-lhe-á sempre garantido o salário-mínimo, vedado qualquer desconto em mês subsequente a título de compensação.

4. GRATIFICAÇÕES LEGAIS

No Direito do Trabalho as gratificações podem ser dadas pelo empregador ao empregado pela realização de uma tarefa ou tarefas a mais ou diferentes das habitualmente realizadas, desenvolvidas ou contratadas, podendo envolver, inclusive, uma maior responsabilidade na empresa como as gratificações de função previstas em lei.

Um empregado regularmente contratado para atender alunos que se

matriculam para o curso de segunda fase da OAB de determinada empresa, no dia da prova participa do evento em que há distribuição de água mineral, pipocas, bombons e afins a esses mesmos alunos no local de prova. Esse valor dado a mais seria uma gratificação contratual (não prevista em lei).

As gratificações legais são, por definição, aquelas gratificações previstas em lei como, por exemplo, as gratificações de função do gerente de 40% sobre o salário normal – parágrafo único do art. 62 da CLT – e a gratificação de função do gerente bancário de 1/3 sobre o salário, nos termos do §2º do art. 224 da CLT.

Essas gratificações legais integram o salário do empregado e acabarão por refletir, isto é, integrar a base de cálculo de outros direitos trabalhistas.

As demais gratificações previstas em regulamento interno de empresa (normas internas da empresa), contatos individuais de trabalho, convenções coletivas ou acordos coletivos não tem natureza salarial e não integram o salário do empregado para qualquer fim.

5. AJUDAS DE CUSTO

As ajudas de custo são importâncias dadas pelo empregador ao empregado para prestação de serviço no local da contratação e **não tem natureza salarial**.

Vale ressaltar que há diferença entre ajuda de custo e **diárias para viagem**: as diárias para viagem são dadas para custear a prestação do serviço em viagens, enquanto as ajudas de custo são concedidas para custear as despesas com a prestação do serviço no próprio local da prestação.

6. PRÊMIOS

Os prêmios, de acordo com o §4º do art. 457 da CLT, são meras liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados, em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades e, por força do disposto no § 2º do art. 457 da CLT, não tem natureza salarial:

Art. 457, CLT, § 2º** As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos **não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.

Não se deve confundir prêmios, gratificações e comissões. Apenas as comissões têm natureza salarial. As gratificações com natureza salarial são apenas as previstas em lei (legais) e os prêmios não têm natureza salarial.

O QUE NÃO É MAIS CONSIDERADO SALÁRIO

Por força da reforma trabalhista, a redação do §1º do art. 457 da CLT foi alterada e integram o salário do empregado apenas a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. O que não estiver elencado no § 1º do art. 457 da CLT não terá natureza salarial, mas meramente indenizatória ou compensatória.

Assim, as horas extras, as horas noturnas, os adicionais de insalubridade, periculosidade e os de transferência **não mais terão natureza salarial**. Na verdade, mesmo antes da reforma trabalhista, nunca houve qualquer lei no sentido de que tais parcelas acima descritas teriam natureza salarial. Apenas o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, sem qualquer base legal, concedia a tais direitos a natureza salarial, como se podia ver das súmulas 376, 60, 80 e 139 do TST.

Tais adicionais desde a sua criação sempre visaram à compensação por trabalhos em situações mais gravosas tais como o além da jornada, o noturno, o insalubre, o perigoso e aquele realizado com a necessária mudança de domicílio do empregado. Assim, caso um empregado tenha prestado serviço extraordinário, noturno, insalubre, perigoso ou transferido sem o pagamento de qualquer adicional, em reclamação trabalhista deve-se **pedir o simples pagamento dos adicionais** de 50%, 20%, 10% ou 20% ou 40%, 30% e 25% sem qualquer reflexo nos demais direitos trabalhistas dos empregados.

7. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

O adicional de insalubridade encontra-se previsto no **art. 7º, XXIII, da CF/88**, e definido no **art. 189, da CLT**, sendo a atividade insalubre aquela que expõe o empregado a substâncias capazes de gerar prejuízos a sua saúde, em grau superior ao permitido.

***Art. 7º, CF/88.** São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:*

***XXIII** - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;*

***Art. 189, CLT.** Serão consideradas atividades ou operações **insalubres** aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados*

em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.

O art. 7º, inciso XXXIII da CF/88, delegou, então, à lei, a tarefa de classificar os agentes insalubres, perigosos e penosos, seu percentual e sua base de cálculo. Porém, a lei, no caso, a CLT, em seu **art. 190**, delegou essa tarefa de classificação e determinação de percentual ao Poder Público, de forma que só geram direito ao adicional as atividades classificadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego como insalubres.

Art. 190, CLT- *O Ministério do Trabalho aprovará o quadro das atividades e operações insalubres e adotará normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes.*

Parágrafo único - *As normas referidas neste artigo incluirão medidas de proteção do organismo do trabalhador nas operações que produzem aerodispersóides tóxicos, irritantes, alérgicos ou incômodos.*

Esse posicionamento é confirmado pela **súmula 448 incisos I e II, do TST**:

*I - Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na **relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho**.*

*II – A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por **não se equiparar à limpeza em residências e escritórios**, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.*

A eliminação, neutralização ou desclassificação da insalubridade no ambiente de trabalho retira do empregado o direito ao recebimento do adicional, conforme o disposto na **Súmula 248 do TST**, não ofendendo o direito adquirido (**art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88**):

SUM-248, TST. *A reclassificação ou a descaracterização da insalubridade, por ato da autoridade competente, **repercuta na satisfação do respectivo adicional.***

A insalubridade é eliminada quando o agente nocivo deixa de existir no ambiente de trabalho, e neutralizada quando, apesar de o agente nocivo ainda existir, seus efeitos são anulados através do uso de Equipamentos de Proteção Individual. Percebe-se, então, uma atecnia na **Súmula 80, do TST**, haja vista que o uso de EPI apenas neutraliza a insalubridade, não a eliminando.

SUM-80, TST. *A **eliminação da insalubridade** mediante fornecimento de*

aparelhos protetores aprovados pelo órgão competente do Poder Executivo exclui a percepção do respectivo adicional.

O **art. 191, da CLT**, prevê as medidas de eliminação ou neutralização da insalubridade, entendendo-se que seu inciso I trata de eliminação e seu inciso II de neutralização.

Art. 191, CLT. *A eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá:*

I – com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância;

II – com a utilização de equipamentos de proteção individual ao trabalhador, que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância.

Parágrafo único. *Caberá às Delegacias Regionais do Trabalho, comprovada a insalubridade, notificar as empresas, estipulando prazos para sua eliminação ou neutralização, na forma deste artigo.*

É possível, ainda, que a utilização de EPI não seja suficiente para neutralizar a insalubridade (**Súmula 289, do TST**), mas tão somente diminuí-la, sendo, nesse caso, devido o respectivo adicional, podendo haver diminuição em seu grau pelo Ministério do Trabalho.

SUM-289, TST. *O simples fornecimento do aparelho de proteção pelo empregador não o exime do pagamento do adicional de insalubridade. Cabe-lhe tomar as medidas que conduzam à diminuição ou eliminação da nocividade, entre as quais as relativas ao uso efetivo do equipamento pelo empregado.*

A exposição **INTERMITENTE** também gera direito ao adicional (e não apenas a permanente).

SUM-47, TST. *O trabalho executado em condições insalubres, em caráter intermitente, não afasta, só por essa circunstância, o direito à percepção do respectivo adicional.*

No ambiente insalubre, quanto maior a exposição do empregado, maior o prejuízo a sua saúde e maior a percentagem do adicional devido, existindo, por isso, três graus de risco, conforme dispõe o **art. 192, da CLT**.

Art. 192, CLT - *O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário-mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.*

A despeito do **art. 7º, inciso IV, da CF/88**, e da **Súmula Vinculante nº4**, o STF

entende que, enquanto não houver nova lei regulamentando a matéria, a **base de cálculo do adicional de insalubridade continuará a ser o salário-mínimo**, que não mais é regional, como menciona o artigo supratranscrito, mas nacional, conforme determinado na Constituição Federal.

Art. 7º, CF/88. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

IV – Salário-mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

Súmula Vinculante 4, STF. Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

Assim, a **Súmula 228, do TST**, encontra-se **suspensa**.

*SUM-228, TST. A partir de 9 de maio de 2008, data da publicação da Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal, o adicional de insalubridade será calculado **sobre o salário básico**, **salvo** critério mais vantajoso fixado em instrumento coletivo.*

8. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Assim como o adicional de insalubridade, o adicional de periculosidade também se encontra previsto no **inciso XXIII do art. 7º, da CF/88**. Sua definição, por sua vez, está prevista no **art. 193 da CLT** (com a nova redação dada pela **Lei 12.740/12**), sendo perigosa a atividade que oferece risco instantâneo e permanente ao trabalhador:

*Art. 193. São consideradas **atividades ou operações perigosas**, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a:*

I - inflamáveis, explosivos ou energia elétrica;

II - roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

*§ 1º - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um **adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário sem os acréscimos** resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.*

*§ 2º - O empregado **poderá optar** pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido.*

§ 3º - Serão descontados ou compensados do adicional outros da mesma natureza eventualmente já concedidos ao vigilante por meio de acordo coletivo.

§ 4º - São também consideradas perigosas as atividades de trabalhador **em motocicleta**.

São ainda consideradas perigosas:

SUM-39, TST. empregados que operam **em bomba de gasolina** têm direito ao adicional de periculosidade (Lei nº 2.573, de 15.08.1955)

OJ SDI-1 345. A exposição do empregado à **radiação ionizante ou à substância radioativa** enseja a percepção do adicional de periculosidade, pois a regulamentação ministerial (Portarias do Ministério do Trabalho nºs 3.393, de 17.12.1987, e 518, de 07.04.2003), ao reputar perigosa a atividade, reveste-se de plena eficácia, porquanto expedida por força de delegação legislativa contida no art. 200, "caput", e inciso VI, da CLT. No período de 12.12.2002 a 06.04.2003, enquanto vigeu a Portaria nº 496 do Ministério do Trabalho, o empregado faz jus ao adicional de insalubridade.

OJ SDI-1 324. É assegurado o adicional de periculosidade apenas aos empregados que trabalham em **sistema elétrico** de potência em condições de risco, ou que o façam com equipamentos e instalações elétricas similares, que ofereçam risco equivalente, ainda que em unidade consumidora de energia elétrica.

OJ SDI-1 347. É devido o adicional de periculosidade aos empregados cabistas, **instaladores e reparadores de linhas e aparelhos de empresas de telefonia, desde que**, no exercício de suas funções, fiquem expostos a condições de risco equivalente ao do trabalho exercido em contato com sistema elétrico de potência.

A periculosidade é integralmente devida quando a exposição é permanente ou intermitente:

SUM 364 TST. I - Tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto **permanentemente** ou que, de **forma intermitente**, sujeita-se a condições de risco. **Indevido**, apenas, quando o contato dá-se de **forma eventual**, assim considerado o fortuito, ou o que, sendo habitual, dá-se por tempo **extremamente reduzido**.

9. CARACTERÍSTICAS DA REMUNERAÇÃO E DO SALÁRIO

9.1. Essencialidade

Remuneração encontra-se tanto no conceito de empregado como no de empregador. É essencial à manutenção e sobrevivência do trabalhador.

9.2. Forfetividade

Os salários são pagos *a forfer*, (natureza forfetária), ou seja, independente de lucro ou prejuízo do empregador. O **art. 7º da CF** garante o salário mínimo ao trabalhador que perceba remuneração variável, sendo vedado o desconto, conforme parágrafo único do **Art. 78 da CLT**:

***Art. 78, CLT, Parágrafo único.** Quando o salário-mínimo mensal do empregado a comissão ou que tenha direito a percentagem for integrado por parte fixa e parte variável, ser-lhe-á **sempre garantido** o salário-mínimo, **vedado qualquer desconto** em mês subsequente a título de compensação.*

9.3. Periodicidade

A CLT garante a periodicidade máxima mensal.

***Art. 459, CLT.** O pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do trabalho, **não deve ser estipulado por período superior a um mês**, **salvo** no que concerne a comissões, percentagens e gratificações.*

Quando a CLT fala em periodicidade mensal, deve ser fechado o mês, devendo o salário ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido, em que foi prestado o serviço.



ATENÇÃO! O sábado é dia útil para efeito de pagamento de salários.

***Art. 224, CLT.** A duração normal do trabalho dos empregados em bancos, casas bancárias e Caixa Econômica Federal será de **seis horas contínuas nos dias úteis**, com exceção dos sábados, perfazendo um total de trinta horas de trabalho por semana.*

***SUM-113, TST.** O sábado do bancário é **dia útil não trabalhado**, não dia de repouso remunerado. **Não cabe** a repercussão do pagamento de horas extras habituais em sua remuneração.*

O pagamento do salário fora do prazo legal acarreta juros e correção monetária.

Em se tratando das comissões, percentagens e gratificações, podem ser pagas após a periodicidade mensal e ao 5º dia útil do mês subsequente ao vencido.

***Art. 466, CLT.** O pagamento de comissões e percentagens só é exigível depois de ultimada a transação a que se referem.*

***§ 1º** - Nas transações realizadas por prestações sucessivas, **é exigível o pagamento das percentagens e comissões** que lhes disserem respeito proporcionalmente à respectiva liquidação.*

*§ 2º - A cessação das relações de trabalho **não prejudica** a percepção das comissões e percentagens devidas na forma estabelecida por este artigo.*

No entanto, de acordo com o entendimento atual do TST (maio/2010), a ultimação da *transação* a que se refere o **Art. 466, caput da CLT**, significa a simples conclusão do contrato ou fechamento do negócio, independentemente do pagamento do preço pelo cliente.

Em relação ao §1º, somente após o vencimento pode ser cobrada a comissão, independente do pagamento do preço. Mesmo que haja rescisão antes do vencimento das parcelas, devida é a comissão.

Art. 766, CLT. *Nos dissídios sobre estipulação de salários, serão estabelecidas condições que, assegurando justos salários aos trabalhadores, permitam também justa retribuição às empresas interessadas.*

9.4. Formalidade

O ato jurídico de pagamento dos salários é ato solene, devendo obedecer à forma prescrita em lei.

De acordo com o entendimento dominante do TST é juridicamente impossível à comprovação de pagamentos de salários de empregado urbano ou rural mediante prova exclusivamente testemunhal.

Em se tratando de empregado doméstico, a partir da entrada em vigor da LC 150/15, a comprovação de pagamento de salários se dá mediante contrarrecibo.

É perfeitamente possível que o **comprovante de depósito** em conta bancária seja recibo suficiente para comprovar o pagamento de salários, desde que:

- a) o empregado concorde,
- b) a conta seja aberta para esse fim, e
- c) a agência seja próxima ao local de trabalho.

Art. 464, CLT. Parágrafo único. *Terá **força de recibo** o comprovante de depósito em conta bancária, aberta para esse fim em nome de cada empregado, com o consentimento deste, em estabelecimento de crédito próximo ao local de trabalho.*

Art. 465, CLT. *O pagamento dos salários será efetuado em **dia útil e no local do trabalho**, dentro do horário do serviço ou imediatamente após o encerramento deste, **salvo quando** efetuado por depósito em conta bancária, observado o disposto no artigo anterior.*

9.5. Complexidade

Os salários são complexos porque não são compostos de uma parcela só.

Art. 457, CLT, § 1º *Integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador.*

Salário complessivo ou recibo complessivo é aquele que engloba vários direitos trabalhistas num só. Não é permitido.

SUM-91, TST. *Nula é a cláusula contratual que fixa determinada importância ou percentagem para atender englobadamente vários direitos legais ou contratuais do trabalhador.*

9.6. Nacionalidade

O salário deve ser pago em moeda nacional e corrente no país.

Art. 463, CLT. *A prestação, em espécie, do salário será paga em moeda corrente do País.*

Parágrafo único. *O pagamento do salário realizado com inobservância deste artigo considera-se como não feito.*

O técnico estrangeiro, contratado no estrangeiro para prestar serviço no Brasil, pode receber em moeda estrangeira, no todo ou em parte, se assim optar, conforme **Dec. 691/69 e Art. 7º, XXX/CF**. Esse é o único caso em que se permite o recebimento de salários em moeda estrangeira. Nesse caso, os direitos que terá garantidos serão exclusivamente os do contrato.

Art. 7º, CF/88.

XXX – proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;

Por origem, pode haver diferenciação.

Sum. 201 TST e art. 3º, II, da Lei 7.064/82 – Empregado contratado no Brasil para prestar serviço no estrangeiro.

SUM-207, TST. *A relação jurídica trabalhista é regida pelas leis vigentes no país da prestação de serviço e não por aquelas do local da contratação.*

9.7. Irredutibilidade

Art. 503, CLT. *É lícita, em caso de força maior ou prejuízos devidamente comprovados, a redução geral dos salários dos empregados da empresa, proporcionalmente aos salários de cada um, não podendo, entretanto, ser*

superior a vinte e cinco por cento, respeitado, em qualquer caso, o salário mínimo da região.

Tal dispositivo não foi recepcionado pela CF, somente sendo possível a redução salarial conforme **Art. 7º, IV e VI, da CF**, que unificou o salário mínimo em todo o território nacional e proíbe a redução salarial, **salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo**, respectivamente.

De acordo com a **Lei 4923/65**, em seu **art. 2º**, a redução dos salários só pode ocorrer por, no máximo três meses, prorrogáveis. A lei exige, no entanto, a redução da jornada (não exigível pelo **art. 503 da CLT**).

9.8. Intangibilidade

Art. 462, CLT. *Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, salvo quando este resultar de adiantamentos, de dispositivos de lei ou de contrato coletivo.*

Contrato Coletivo = Acordo ou Convenção Coletiva.

Não há disposição legal tratando do adiantamento, mas pode ser feito desde que o empregador concorde.

OJ-251, SDI-1, TST. *É lícito o desconto salarial referente à devolução de cheques sem fundos, quando o frentista não observar as recomendações previstas em instrumento coletivo.*

Art. 462, CLT, §1º *Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito, desde que esta possibilidade tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo do empregado.*

- **CULPA:** se houver expressa previsão contratual;
- **DOLO:** sempre.

O Salário tanto pode ser pago em espécie como em natura.

Art. 82, CLT. *Quando o empregador fornecer, in natura, uma ou mais das parcelas do salário mínimo, o salário em dinheiro será determinado pela fórmula $S_d = S_m - P$, em que S_d representa o salário em dinheiro, S_m o salário mínimo e P a soma dos valores daquelas parcelas na região, zona ou subzona.*

Parágrafo único. *O salário mínimo pago em dinheiro não será inferior a trinta por cento do salário mínimo fixado para a região, zona ou subzona.*

SUM-258, TST. *Os percentuais fixados em lei relativos ao salário "in natura" apenas se referem às hipóteses em que o empregado percebe salário mínimo,*

apurando-se, nas demais, o real valor da utilidade.

➤ **Utilidades:** são bens ou serviços que o empregador, por força de lei, contrato ou costume, fornece ao empregado de forma habitual, como alimentação, moradia, lazer, higiene, vestuário etc.

As utilidades fornecidas de forma habitual e gratuita **integram o salário** (logo, refletem nas verbas). Assim, o ideal para o empregador é descontar um valor (por menor que seja) para que a utilidade não integre o salário.

Exemplo:

R\$ 540,00	R\$ 540,00	
R\$ 100,00 – Alimentação	- R\$ 20,00	100,00 (-) 20,00
R\$ 60,00 – Higiene	- R\$ 6,00 higiene	60,00 (-) 6,00
R\$700,00	R\$514,00	

Caso o empregador seja integrante do PAT - programa de alimentação do trabalhador (**Lei 6321/76**), mesmo que o empregador não efetue qualquer desconto salarial, a concessão do vale refeição ou ticket alimentação não integrará o salário do empregado.

SUM-241, TST. O vale para refeição, fornecido **por força do contrato de trabalho**, tem **caráter salarial**, integrando a remuneração do empregado, para todos os efeitos legais.

OJ-133, SDI-1, TST. A ajuda alimentação fornecida por empresa participante do **programa de alimentação ao trabalhador**, instituído pela Lei nº 6.321/76, **não tem caráter salarial**. Portanto, não integra o salário para nenhum efeito legal.

	URBANO	RURAL
ALIMENTAÇÃO	20%	25%
HABITAÇÃO	25%	20%

SUM-258, TST. Os percentuais fixados em lei relativos ao salário "in natura" apenas se referem às hipóteses em que o empregado percebe salário mínimo, apurando-se, nas demais, o real valor da utilidade.

Lei 5889/73, Art. 9º **Salvo** as hipóteses de autorização legal ou decisão judiciária, **só poderão ser descontadas do empregado rural** as seguintes parcelas, calculadas sobre o salário mínimo:

- até o limite de vinte por cento pela ocupação da morada;
- até vinte e cinco por cento pelo fornecimento de alimentação sadia e farta, atendidos os preços vigentes na região;
- adiantamentos em dinheiro.

Existem utilidades que mesmo que o empregador as forneça de forma habitual e gratuita, elas não integram o salário.

Art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, **compreende-se no salário**, para todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.

§ 1º Os valores atribuídos às prestações "in natura" deverão ser justos e razoáveis, não podendo exceder, em cada caso, os dos percentuais das parcelas componentes do salário-mínimo (arts. 81 e 82).

§ 2º Para os efeitos previstos neste artigo, **não serão consideradas** como salário as seguintes utilidades concedidas pelo empregador:

I – vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados no local de trabalho, **para a prestação do serviço**;

II – educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os valores relativos a matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático;

III – transporte **destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno**, em percurso servido ou não por transporte público;

IV – assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou mediante seguro-saúde;

V – seguros de vida e de acidentes pessoais;

VI – previdência privada;

VII – (VETADO)

VIII – o valor correspondente ao vale-cultura.

(...)

§ 5º O valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio ou não, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras similares, mesmo quando concedido em diferentes modalidades de planos e coberturas, **não integram o salário do empregado para qualquer efeito nem o salário de contribuição**, para efeitos do previsto na alínea g do § 9º do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Salvo se houver convenção e acordo coletivo, **não é permitido** desconto do vestuário utilizado como fardamento.



CUIDADO! O desconto será permitido se houver convenção ou acordo coletivo nesse sentido.

De acordo com o STF, caso o empregador forneça o dinheiro para o transporte ao invés do vale, **o valor não pode ser considerado salário**.

Em tese, não seriam possíveis descontos referentes à assistência médica. No entanto, de acordo com a **súmula 342**, é possível, visto que representa um benefício ao empregado.

SUM-342, TST. Descontos salariais efetuados pelo empregador, com a **autorização prévia e por escrito do empregado**, para ser integrado em planos de assistência odontológica, médico-hospitalar, de seguro, de previdência privada, ou de entidade cooperativa, cultural ou recreativo-associativa de seus trabalhadores, em seu benefício e de seus dependentes, não afrontam o disposto no art. 462 da CLT, **salvo se ficar demonstrada a existência de coação ou de outro defeito que vicie o ato jurídico.**

SUM-367, TST. I- A habitação, a energia elétrica e veículo fornecidos pelo empregador ao empregado, quando indispensáveis **para a realização do trabalho, não têm natureza salarial**, ainda que, no caso de veículo, seja ele utilizado pelo empregado também em atividades particulares.

I - O cigarro **não se considera** salário utilidade em face de sua nocividade à saúde.

Nas férias, o empregado é proibido de prestar serviços. Logo, se a utilidade é fornecida durante as férias, pelo menos durante o seu período ela será considerada salário.

10. DESCONTO SALARIAL

No ordenamento jurídico trabalhista brasileiro, a remuneração do empregado goza de proteção especial, sendo a regra geral a intangibilidade salarial. Ou seja, o salário deve ser pago integralmente, sendo vedados descontos, salvo em hipóteses legalmente autorizadas ou mediante acordo expresso com o trabalhador. Essa proteção está prevista no art. 462 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que estabelece que:

"Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, salvo quando este resultar de adiantamentos, de dispositivos de lei ou de contrato coletivo."

(Como visto em Intangibilidade)

10.1. Descontos Sindicais Indevidos

Com a reforma trabalhista (Lei nº 13.467/2017), os descontos de natureza sindical (contribuição sindical, confederativa, assistencial ou mensalidade) passaram a depender de autorização expressa e prévia do empregado. Isso foi reforçado pelo art. 579 da CLT, que dispõe:

"As contribuições facultativas previstas nesta Consolidação só poderão ser

exigidas dos empregados que autorizarem expressamente o seu recolhimento."

Além disso, o TST (OJ 17 da SDC) e o STF (Súmula 666) reforçam que empregado não sindicalizado não pode ser compelido a contribuir com o sindicato, salvo consentimento expresse. Logo, é indevido qualquer desconto sem autorização por escrito, devendo os valores ser devolvidos.

10.2. Desconto por Dano Material ao Empregador

Segundo o art. 462, §1º da CLT, descontos por danos causados pelo empregado só são lícitos se houver culpa do trabalhador e previsão contratual:

"Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito, desde que esta possibilidade tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo do empregado."

Portanto, em casos de culpa sem previsão contratual, o desconto é indevido. Aplica-se aos casos nos quais os empregados sofreram descontos por danos materiais sem dolo e sem previsão contratual, violando o dispositivo acima.

Exemplo 01: um frentista teve desconto por cheque sem fundo, mesmo tendo cumprido as normas da CCT, o que também configura desconto indevido, conforme a OJ 251 da SDI-1 do TST, que diz:

"É inválido o desconto salarial referente a prejuízo com cheque sem provisão de fundos quando o empregado observa rigorosamente as normas da empresa ou da CCT quanto à sua aceitação."

10.3. Desconto por Faltas Justificadas

O art. 473 da CLT estabelece situações em que o empregado pode faltar justificadamente, sem prejuízo de salário. Entre elas, destacam-se:

Inciso II: até 9 dias consecutivos em caso de casamento.

(...)

Inciso IV: 1 dia por ano para doação voluntária de sangue.

Exemplo 01: um professor teve descontados seis dias de sua remuneração por ausência após casamento, o que é ilegal, pois o art. 320, §3º da CLT assegura ao professor o direito de faltar por 9 dias consecutivos por gala.

Exemplo 02: a empregada foi descontada por doar sangue, o que contraria o art. 473, IV, da CLT, sendo também desconto indevido.

Todos os casos apresentados se referem a descontos salariais indevidos, por violarem dispositivos legais claros da CLT, entendimentos sumulados do TST e do STF, e jurisprudência consolidada. Em todos os exemplos, o empregado faz jus à devolução integral dos valores descontados, acrescidos de correção monetária e juros, conforme previsão legal e entendimento dominante da Justiça do Trabalho.

10.4. Descontos Salariais devidos/lícitos/válidos

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em seu **art. 462, caput**, estabelece como regra geral a **intangibilidade salarial**, ou seja, **vedação de descontos**, salvo em hipóteses **expressamente autorizadas por lei, instrumento coletivo ou acordo contratual**.

Contudo, o mesmo artigo prevê **exceções**, autorizando o desconto em casos específicos:

Art. 462, §1º, CLT: Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito, **desde que esta possibilidade tenha sido acordada** ou na ocorrência de **dolo do empregado**.

Além disso, o desconto é permitido também em situações como:

- Adiantamentos salariais;
- Descumprimento de normas internas ou coletivas;
- Erros procedimentais imputáveis ao empregado.

Abaixo, a aplicação a alguns casos específicos:

Exemplo 01. Dano Culposos com Previsão Contratual

Situação: Empregado causou dano culposamente ao deixar torneira aberta, encharcando piso; há previsão contratual expressa.

Lícito – O desconto é válido, pois houve culpa do empregado e previsão contratual, conforme o art. 462, §1º da CLT.

Exemplo 02. Dano Doloso

Situação: Empregado desobedeceu ordem expressa ("não abrir a porta"), causando quebra de móveis.

Lícito – O desconto é válido, pois houve dolo, ou seja, conduta intencional. Nessa

hipótese, a previsão contratual é dispensada, bastando a comprovação do dolo (art. 462, §1º da CLT).

Exemplo 03. Descumprimento de Normas de CCT

Situação: Frentista aceitou cheque sem verificar cadastro do cliente, contrariando normas da CCT da categoria.

Lícito – O desconto é válido, pois o empregado descumpriu norma coletiva, o que configura falha imputável ao trabalhador. Fundamento adicional: OJ 251 da SDI-1 do TST, que condiciona a ilicitude do desconto à observância rigorosa das normas da empresa ou CCT. Aqui, isso não ocorreu.

Exemplo 04. Adiantamento Salarial

Situação: Reclamante quer a devolução de desconto feito a título de adiantamento.

Lícito – O desconto é permitido por lei, nos termos do art. 462, caput, da CLT, que expressamente autoriza descontos referentes a adiantamentos feitos ao empregado.

Os descontos examinados nos exemplos acima são devidos e válidos, por estarem amparados nas exceções previstas no art. 462 da CLT e em jurisprudência consolidada do TST. Nessas hipóteses, o empregado não tem direito à restituição, já que o desconto decorreu de:

- Culpa com previsão contratual;
- Dolo comprovado;
- Inobservância de normas coletivas;
- Adiantamento salarial válido.

Capítulo 9

ESTABILIDADE, REINTEGRAÇÃO & ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

1. ESTABILIDADE OU GARANTIA DE EMPREGO

De início, importante entender como se deu o surgimento do instituto do FGTS, bem como sua relação com a estabilidade decenal. Observe os três períodos distintos dessa evolução, desde o período da estabilidade decenal até hoje:

Período de 1923 a 1966	Período de 1967 a 04.10.88	Período de 05.10.88 até hoje
Não havia FGTS.	Surgimento da Lei 5.107/66 , que cria o FGTS.	FGTS obrigatório, conforme art. 7º, inciso III, da CF/1988 .
Nessa época, era devida a todo empregado com mais de um ano de tempo de serviço, que fosse demitido sem justa causa, <i>uma indenização por tempo de serviço (art. 477 e art. 478, da CLT)</i> correspondente a um mês da maior remuneração do empregado por cada ano ou fração igual ou superior a 06 meses.	<u>OPTANTE:</u> A indenização correspondia a 10% sobre os depósitos do FGTS.	
Era detentor, porém, de <i>estabilidade decenal</i> , (art. 492, da CLT), o empregado que possuía mais de 10 anos de efetivo serviço, só podendo ser dispensado se cometesse falta grave, sendo esta apurada mediante inquérito (art. 494 e art. 853, da CLT). Nesses casos, a indenização seria dobrada,	<u>NÃO OPTANTE:</u> Indenização do tempo de serviço com possibilidade de adquirir a estabilidade decenal.	

conforme art. 496 e art. 497, da CLT.		
--	--	--

A estabilidade por tempo de serviço era garantida pelo **artigo 492, da CLT**, ao empregado que contasse com mais de dez anos de serviço na mesma empresa ou grupo de empresas, não podendo ser dispensado a não ser por motivo de falta grave ou força maior, devidamente comprovados através de inquérito judicial para apuração de falta grave (**art. 498 e art. 853, da CLT**).

ATENÇÃO!!! **GRIFAR** AS PALAVRAS DESTACADAS NA CLT:

Art. 498, CLT - Em caso de fechamento do estabelecimento, filial ou agência, ou supressão necessária de atividade, **sem ocorrência de motivo de força maior**, é assegurado aos empregados estáveis, que ali exerçam suas funções, direito à **indenização**, na forma do artigo anterior.

Art. 853, CLT - Para a instauração do inquérito para apuração de falta grave contra empregado garantido com estabilidade, o empregador apresentará reclamação por escrito à Junta ou Juízo de Direito, dentro de 30 (trinta) dias, contados da data da suspensão do empregado.

Reconhecida a inexistência de falta grave ou não comprovada a circunstância de força maior capaz de ensejar a ruptura justificada do contrato de trabalho do estável, caberia reintegração no primeiro caso e, no segundo, indenização equivalente a um mês de remuneração por cada ano ou fração igual ou superior a seis meses de serviço, paga na forma dobrada (**art. 478, da CLT**).

Art. 478, CLT - A indenização devida pela rescisão de contrato por prazo indeterminado será de 1 (um) mês de remuneração por ano de serviço efetivo, ou por ano e fração igual ou superior a 6 (seis) meses.

§1º - O primeiro ano de duração do contrato por prazo indeterminado é considerado como período de experiência, e, antes que se complete, nenhuma indenização será devida.

§2º - Se o salário for pago por dia, o cálculo da indenização terá por base 25 (vinte e cinco) dias.

§3º - Se pago por hora, a indenização apurar-se-á na base de 200 (duzentas) horas por mês.

§4º - Para os empregados que trabalhem a comissão ou que tenham direito a percentagens, a indenização será calculada pela média das comissões ou percentagens percebidas nos últimos 12 (doze) meses de serviço.

§5º - Para os empregados que trabalhem por tarefa ou serviço feito, a indenização será calculada na base média do tempo costumeiramente gasto pelo interessado para realização de seu serviço, calculando-se o valor do que seria feito durante 30 (trinta) dias.

Muitas vezes, porém, a reintegração era desaconselhável em virtude do grau de incompatibilidade gerada pelo dissídio entre empregado e empregador, sendo devido, nesse caso, também indenização equivalente a um mês de remuneração por cada ano ou fração igual ou superior a seis meses de serviço, paga na forma dobrada.

A doutrina e a jurisprudência construíram a figura da despedida obstativa da estabilidade decenal, reduzindo, jurisprudencialmente, o prazo de 10 (dez) para 09 (nove) anos na medida em que presumia impeditiva de estabilidade a despedida, sem justo motivo, do empregado que alcançasse nove anos de serviço na empresa⁹.

Em 1967, com o surgimento da **Lei 5.107/66 (hoje Lei 8.036/90)**, criou-se o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A partir de então, coexistiram o instituto da estabilidade decenal e o FGTS, cabendo ao empregado optar por um ou outro (origem das expressões “optante” e “não optante”).

A **estabilidade decenal** tacitamente **desapareceu** com a promulgação da **atual Constituição Federal**, que previu a obrigatoriedade do sistema do FGTS para todos os empregados, (*inclusive aos empregados domésticos, que estão incluídos no sistema do FGTS pelo art. 21 da LC n. 150/2015*), e a consequente indenização compensatória de 40% sobre os depósitos da conta vinculada (**art. 10, inciso I, ADCT**), que veio a substituir as indenizações previstas no **art. 478** e no **art. 497, da CLT** (*indenização por tempo de serviço*).

Art. 10, ADCT- *Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o Art. 7º, I, da Constituição:*

I - fica limitada a proteção nele referida ao aumento, para quatro vezes, da porcentagem prevista no Art. 6º, caput e §1º, da Lei nº 5.107, de 13 de setembro de 1966;

LC n. 150/2015, Art. 21. É devida a inclusão do empregado doméstico no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), na forma do regulamento a ser editado pelo Conselho Curador e pelo agente operador do FGTS, no âmbito de suas competências, conforme disposto nos arts. 5º e 7º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, inclusive no que tange aos aspectos técnicos de depósitos, saques, devolução de valores e emissão de extratos, entre outros determinados na forma da lei.

Para que o empregador possa demitir um empregado estável, além de necessária a ocorrência de falta grave, ainda se faz necessário que tal falta seja comprovada.

⁹**SUM-26 ESTABILIDADE (cancelada) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003** *Presume-se obstativa à estabilidade a despedida, sem justo motivo, do empregado que alcançar nove anos de serviço na empresa.*

SUM-212, TST. O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o despedimento, **é do empregador**, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado.

Quando o juiz percebe no curso do inquérito, que há incompatibilidade entre empregado e empregador, não sendo aconselhável a reintegração, converte a mesma em indenização, nos termos do **art. 496, da CLT**:

Art. 496, CLT. Quando a reintegração do empregado estável for desaconselhável, dado o grau de incompatibilidade resultante do dissídio, especialmente quando for o empregador pessoa física, o tribunal do trabalho poderá **converter aquela obrigação em indenização** devida nos termos do artigo seguinte.

a. Espécies de Estabilidade

i. Estabilidade do art. 41, da CF/1988

Outra situação estável é a do servidor público civil regulada pelo **art. 41, da CF/1988** que ingressa nos quadros da administração pública, obrigatoriamente, através de concurso de provas ou de provas e títulos (**art. 37, inciso II, §2º, da CF/88**).

Adquirida a estabilidade, o empregado público somente perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado (**art. 41, §1º, inciso I, da CF/88**), ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada a ampla defesa (**art. 41, §1º, inciso II, da CF/88**) ou ainda mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho (**art. 41, §1º, inciso III, da CF/88**).

Já quanto aos servidores públicos de empresas estatais, assim entendidas as empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades controladas pelo Estado, que se organizam conforme os modelos da iniciativa privada, explorando atividade econômica na forma do **art. 170, da CF/88**, a eles não se aplica a estabilidade do art. 41, da CF/88¹⁰ que, conseqüentemente, viabiliza sua dispensa arbitrária pelo empregador estatal¹¹, prescindindo, inclusive, de motivação do ato

¹⁰Idem

¹¹**OJ-SDI1-247** “SERVIDOR PÚBLICO. CELETISTA CONCURSADO. DESPEDIDA IMOTIVADA. EMPRESA PÚBLICA OU SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE

I - A despedida de empregados de empresa pública e de sociedade de economia mista, mesmo admitidos por concurso público, independe de ato motivado para **sua validade**;

II - A validade do ato de despedida do empregado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) está

administrativo.

1.1.1. Dirigente Sindical

O dirigente sindical tem garantia de emprego desde o registro de candidatura ao cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Há entendimento do TST no sentido de ser estável também o empregado eleito para representação patronal sindical¹².

O mandato é de 03 anos (**inciso VIII art. 8º, CF c/c §3º art. 543 CLT**), não podendo o dirigente, nem seu suplente, serem transferidos de seu local originário de trabalho de modo a afetar ou tornar impossível o desempenho de suas funções sindicais, salvo expressa anuência obreira, com a consequente renúncia à estabilidade.

O **art. 522 CLT** limita a **sete**, o número de dirigentes sindicais por sindicato, com seus respectivos suplentes. Para a dispensa motivada do dirigente sindical e de seus suplentes, há necessidade de abertura de inquérito judicial para apuração de falta grave (**art. 853, CLT**).

Súmula nº 369 - TST - Dirigente Sindical - Estabilidade Provisória

II - O art. 522 da CLT, que limita a sete o número de dirigentes sindicais, foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. (ex-OJ nº 266 - Inserida em 27.09.2002)

O empregado de categoria diferenciada, eleito dirigente sindical, só goza de estabilidade se exercer na empresa atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para o qual foi eleito. Assim, não goza de garantia de emprego, o vigilante de rede bancária que é eleito dirigente sindical do sindicato dos bancários.

Súmula nº 369 - TST - Dirigente Sindical - Estabilidade Provisória

III - O empregado de categoria diferenciada eleito dirigente sindical só goza de estabilidade se exercer na empresa atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para o qual foi eleito dirigente. (ex-OJ nº 145 - Inserida em 27.11.1998)

Ademais, funções de direção sindical que não acarretam enfrentamento com o empregador não garantem a estabilidade, consoante o TST já pacificou

*condicionada à motivação, por gozar a empresa do mesmo tratamento destinado à Fazenda Pública em relação à imunidade tributária e à execução por precatório, além das prerrogativas de foro, prazos e **custas processuais**”.*

¹² Precedente STF RE 217.355-5-MG, Ac. 2ª T., 29.08.2000, Rel. Min. Maurício Corrêa, LTr 65-02/180).

entendimento a respeito dos membros do conselho fiscal e dos delegados sindicais, observe-se:

OJ – SDI 1 - Nº 365, TST – ESTABILIDADE PROVISÓRIA. MEMBRO DE CONSELHO FISCAL DE SINDICATO. INEXISTÊNCIA. DJ 20, 21 e 23.05.2008. Membro de conselho fiscal de sindicato não tem direito à estabilidade prevista nos arts. 543, § 3º, da CLT e 8º, VIII, da CF/1988, porquanto não representa ou atua na defesa de direitos da categoria respectiva, tendo sua competência limitada à fiscalização da gestão financeira do sindicato (art. 522, §2º, da CLT).

OJ- SDI 1 - Nº 369, TST, DE 03.12.08 – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – Delegado sindical: inaplicabilidade. A Orientação Jurisprudencial nº 369 TST/SBDI-I, de 03.12.08, dispõe que o **delegado sindical não é beneficiário da estabilidade provisória** prevista no art. 8º, VIII, da CF/88, a qual é dirigida, exclusivamente, àqueles que exerçam ou ocupem cargos de direção nos sindicatos, submetidos a processo seletivo.

O pedido de demissão do dirigente sindical e seu suplente, mesmo que estes estejam há menos de um ano na empresa, terá de ser assistido pelo sindicato da categoria, na sua falta, pela autoridade do Ministério do Trabalho ou, ainda, pela Justiça do Trabalho (**art. 500, CLT**).

Não é garantida a estabilidade ao empregado que registra sua candidatura à dirigente sindical ou suplente no curso do aviso prévio (**Súmula 369, V, TST e Súmula 348, TST**). Também não é garantida estabilidade se há extinção da empresa ou filial na qual trabalhava o empregado estável, não sendo devida qualquer indenização.

Súmula nº 369 - TST - Dirigente Sindical - Estabilidade Provisória

V - O registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período de aviso prévio, ainda que indenizado, não lhe assegura a estabilidade, visto que inaplicável a regra do § 3º do art. 543 da Consolidação das Leis do Trabalho. (ex-OJ nº 35 - Inserida em 14.03.1994).

Súmula nº 348 - TST- Aviso Prévio - Garantia de Emprego. É inválida a concessão do Aviso Prévio na fluência da garantia de emprego, ante a incompatibilidade dos dois institutos.

Os empregados que forem contratados por prazo determinado que se candidatarem a dirigente ou a suplente, não poderão ter seus contratos a prazo rescindidos antecipadamente.

No entanto, adquirindo estabilidade como dirigentes sindicais no curso do contrato, não poderão ser dispensados até o término normal do contrato, quando, então, este se extinguirá e consequentemente, a estabilidade adquirida.

Caso o sindicato não comunique por escrito à empresa, no prazo de 24h, acerca do registro de candidatura de empregado ao cargo de dirigente sindical, não

poderá este alegar estabilidade caso o empregador resolva exercer seu direito de dispensá-lo imotivadamente (§3º art. 543, CLT).

O TST já sumulou entendimento segundo o qual é indispensável a comunicação do registro da candidatura à empresa para que se opere a aquisição da estabilidade, vejamos:

Súmula nº 369 - TST - Dirigente Sindical - Estabilidade Provisória

I - É assegurada a estabilidade provisória ao empregado dirigente sindical, ainda que a comunicação do registro da candidatura ou da eleição e da posse seja realizada fora do prazo previsto no art. 543, § 5º, da CLT, desde que a ciência ao empregador, por qualquer meio, ocorra na vigência do contrato de trabalho.

IV - Havendo extinção da atividade empresarial no âmbito da base territorial do sindicato, não há razão para subsistir a estabilidade.

1.1.2. Estabilidade do Empregado Representante de Empresa

Novidade introduzida pela reforma trabalhista foi a regulamentação do art. 11 da Constituição Federal pelo art. 510-A da CLT, pois desde 05.10.88 já previa a Constituição a eleição de representante dos empregados nas empresas com mais de 200 empregados, a fim de promover o entendimento entre empregados e empregadores:

CF. Art. 11. *Nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores.*

O membro da comissão de representantes dos empregados não poderá sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro, desde o registro da candidatura até um ano após o fim do mandato, nos termos do § 3º do art. 510-D, CLT.

Por **falta de previsão legal**, a falta grave porventura cometida pelo representante de empresa não precisará ser comprovada mediante inquérito judicial.

1.1.3. Membro da CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

A CIPA é órgão interno e paritário de prevenção de acidentes, formado por representantes dos empregados e do empregador.

É estável o empregado eleito para cargo de direção da CIPA, desde o registro

da candidatura até um ano após o término do mandato. **O suplente da CIPA goza da garantia de emprego prevista no art. 10, II, a, do ADCT da CF/88.** Os mandatos são de 01 ano, permitida a reeleição. Note-se que a estabilidade provisória se dirige apenas aos trabalhadores eleitos representantes dos empregados na direção da CIPA, titulares e suplentes (**Súmula 339, I, TST e 676, STF**). Não se dirige, pois, aos representantes designados pelo empregador, que não são eleitos pelos demais obreiros. Caso haja eleição destes, a estabilidade lhes será garantida.

Art. 10, ADCT - *Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o Art. 7º, I, da Constituição:*

II - fica **vedada** a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

- a) do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato;

Súmula nº 339 - TST - Suplente da CIPA (Comissões Internas de Prevenção de Acidentes) - Garantia de Emprego

- I** - O suplente da CIPA goza da garantia de emprego prevista no art. 10, II, "a", do ADCT a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988.

Súmula nº 676 - STF - Garantia da Estabilidade Provisória - Aplicabilidade - Suplente do Cargo de Direção de CIPA. A garantia da estabilidade provisória prevista no art. 10, II, a, do ADCT, também se aplica ao suplente do cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes (CIPA).

A súmula 339, II, TST, revela o caráter eminentemente funcional da estabilidade do cipeiro, rechaçando qualquer pretensão de interpretá-la como estabilidade pessoal, observe-se:

Súmula nº 339 - TST - A estabilidade provisória do cipeiro não constitui vantagem pessoal, mas garantia para as atividades dos membros da CIPA, que somente tem razão de ser quando em atividade a empresa. **Extinto o estabelecimento**, não se verifica a despedida arbitrária, sendo **impossível a reintegração e indevida a indenização** do período estável. (ex-OJ nº 329 da SBDI-1 - DJ 09.12.2003)

A dispensa **imotivada e irregular do cipeiro**, titular ou suplente, garante sua **imediata reintegração** ao emprego. No caso de a reintegração ser impossível, ou porque o período estável se exauriu ou porque o dissídio criado entre patrão e empregado desaconselhe à reintegração, o Tribunal do Trabalho poderá **converter aquela obrigação em indenização**, que corresponde aos salários desde a data da despedida até o final da estabilidade.

Art. 165, CLT - Os titulares da representação dos empregados nas CIPA (s) **não poderão sofrer despedida arbitrária**, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro.

O registro da candidatura do cipeiro, titular ou suplente, **durante o curso do aviso prévio**, trabalhado ou indenizado, **NÃO garantirá sua estabilidade**, uma vez que a projeção do contrato de trabalho para o futuro, pela concessão do aviso prévio indenizado, tem efeitos limitados às vantagens econômicas obtidas no período de pré-aviso, ou seja, salários, reflexos e verbas rescisórias.

1.1.4. Empregada Gestante

Art. 10 - Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o Art. 7º, I, da Constituição:

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

*b) da empregada gestante, desde a **confirmação da gravidez** até **cinco meses** após o parto.*

Desde a edição de referida norma, ficou muito difícil precisar o momento exato da confirmação da gravidez, pois não se sabia se essa confirmação se daria perante a própria empregada ou perante o empregador.

Assim, a jurisprudência do TST manteve-se firme e unânime no sentido de que a confirmação da gravidez se dá com a concepção, ou seja, com a fecundação.

O empregador pode exigir exame de gravidez quando da oportunidade de realização de exames necessários, com exceção do exame de admissão e com a ressalva de que o exame de gravidez durante o exame periódico não pode ter por finalidade diferenciar as gestantes das empregadas que não estejam grávidas.

Há que se ressaltar que os **arts. 1º e 2º, da Lei 9.029/95** vedam a exigência de declaração da empregada no sentido de atestar que não se encontra grávida.

Art. 1º É proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de trabalho, ou de sua manutenção, por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade, entre outros, ressalvadas, nesse caso, as hipóteses de proteção à criança e ao adolescente previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

Art. 2º Constituem crime as seguintes práticas discriminatórias:

I - a exigência de teste, exame, perícia, laudo, atestado, declaração ou qualquer outro procedimento relativo à esterilização ou a estado de gravidez;

*Súmula 244, item III, TST - A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no art. 10, inciso II, alínea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, mesmo na hipótese de **admissão mediante contrato por tempo determinado**.*

Atualmente, nos termos do **art. 391-A da CLT**, ainda que a gravidez tenha se dado no curso do aviso prévio trabalhado ou indenizado, a empregada gestante terá direito à estabilidade.

Art. 391-A. *A confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato de trabalho, **ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado**, garante à empregada gestante a estabilidade provisória prevista na alínea b do inciso II do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.*

Enquanto durar o pagamento do salário-maternidade não poderá ser a empregada despedida, pois seu contrato estará suspenso, **salvo se** o empregador indenizar todo o período em que a empregada permanecer afastada do trabalho, sem prejuízo do restante do período estável e do aviso prévio.

A dispensa imotivada e irregular da gestante só autoriza a reintegração se esta se der **durante o período da estabilidade**. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade.

Se a decisão que reconhece a ilegalidade da dispensa for prolatada após o fim do período estável, será devida a indenização do período estável (e não a reintegração) acrescida de aviso prévio, nos termos da **Súmula 348, TST**:

Súmula nº 348 - TST - *É inválida a concessão do Aviso Prévio na fluência da garantia de emprego, ante a incompatibilidade dos dois institutos.*

TESE DE ESTABILIDADE DA GESTANTE NA RECLAMAÇÃO

A reclamante tem direito de ser reintegrada por ter **estabilidade da gestante**, pois à **época de sua dispensa estava grávida (dados do caso)**, pelo que requer a REINTEGRAÇÃO LIMINAR EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA (URGÊNCIA), nos

1.1.5. Estabilidade do empregado adotante

Novidade introduzida pela reforma trabalhista, a mãe adotante ou que possua a guarda provisória para fins de adoção, desde a obtenção da guarda, ainda que provisória, até cinco meses após a adoção, nos termos do parágrafo único do art. 391-A da CLT.

Art. 391-A. Parágrafo único. *O disposto no caput deste artigo aplica-se ao empregado adotante ao qual tenha sido concedida guarda provisória para fins de adoção.*

No caso de casal heterossexual em que a genitora vier a falecer, por exemplo, no parto e o cônjuge sobrevivente ou outra pessoa detiver a guarda da criança, o detentor da guarda fará jus à licença maternidade, nos termos do art. 1º da LC 146/14:

“O direito prescrito na alínea b do inciso II do art. 10 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias, nos casos em que ocorrer o **falecimento da genitora**, será assegurado a quem **detiver a guarda do seu filho**”

1.1.6. Estabilidade decorrente de acidente de trabalho.

O segurado que sofreu acidente de trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de doze meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença-acidentário, independentemente da percepção de auxílio-acidente.

Art. 118 da Lei 82.13/91. *O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo **prazo mínimo de doze meses**, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, **independentemente** de percepção de auxílio-acidente.*

O simples fato de ter sofrido acidente não garante ao obreiro a estabilidade acidentária, sendo, segundo o TST (**reflexo do art. 118, da Lei 82.13/91 e Súmula 378, TST**), necessária a presença concomitante de dois requisitos: *afastamento superior a 15 dias e percepção de benefício auxílio acidentário*.

Há sensível diferença entre doença do trabalho e doença profissional (ocupacional), sendo que a primeira é adquirida no trabalho, mas não decorrente dele e a segunda é decorrente da prestação de serviços.

Ressaltando-se que o acidente e a doença comum não garantem ao empregado a estabilidade e que a estabilidade do acidentado do trabalho é fraca, ou seja, não precisa de inquérito judicial para apuração de falta grave para romper o contrato de trabalho.

Quando do retorno ao trabalho, a lei garante estabilidade complementar de 12 meses não na mesma função, mas apenas no mesmo emprego, pois poderá ser o empregado reabilitado e assumir uma outra função, sem prejuízo dos salários e das vantagens já incorporadas (**art. 468, CLT**).

Art. 468, CLT– *Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por **mútuo consentimento**, e ainda assim desde que **não resultem**, direta ou indiretamente, **prejuízos ao empregado**, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia.*

Enquanto durar o pagamento do auxílio-doença acidentário não poderá ser o empregado despedido, pois seu contrato estará suspenso (**art. 476, CLT**), salvo, se o empregador indenizar todo o período em que o empregado permanecer afastado do trabalho, sem prejuízo dos 12 meses complementares quando da cessação do auxílio-doença acidentário e do aviso prévio.

Art. 476, CLT. *Em caso de seguro-doença ou auxílio-enfermidade, o empregado é considerado em **licença não remunerada** durante o prazo desse benefício.*

Registre-se, por pertinente, que o acidentado comum **não tem direito à estabilidade**, mas apenas e tão somente à suspensão de seu contrato de trabalho quando o afastamento do empregado no emprego se der por mais de quinze dias consecutivos, ainda que no curso do aviso prévio, uma vez que os efeitos da dispensa só irão se operar depois de expirado o recebimento do benefício previdenciário, qual seja, o auxílio-doença comum, não-acidentário.

Por fim, cabe assinalar que no contrato de trabalho **por prazo determinado, ainda que de experiência**, o acidentado terá garantia de emprego, nos exatos termos do **item III da súmula 378, TST**:

Súmula 378, inciso III TST – *O empregado submetido a contrato de trabalho por tempo determinado **goza da garantia provisória de emprego** decorrente de acidente de trabalho prevista no art. 118 da Lei nº 8.213/91.*

1.1.7. Empregados eleitos Diretores de Sociedades Cooperativas

É indispensável que o empregador tome conhecimento do registro da candidatura do empregado ao cargo de diretor para que a garantia de emprego possa se operar, obedecendo, assim, ao prazo estabelecido pelo **§5º art. 543, CLT** e se utilizando das regras aplicadas ao dirigente sindical.

Art. 543 - *O empregado eleito para cargo de administração sindical ou representação profissional, inclusive junto a órgão de deliberação coletiva, **não poderá** ser impedido do exercício de suas funções, nem transferido para lugar ou mister que lhe dificulte ou torne impossível o desempenho das suas atribuições sindicais.*

§ 5º - *Para os fins deste artigo, a entidade sindical comunicará por escrito à empresa, **dentro de 24 (vinte e quatro) horas**, o dia e a hora do registro da candidatura do seu empregado e, em igual prazo, sua eleição e posse, fornecendo, outrossim, a este, comprovante no mesmo sentido. O Ministério do Trabalho e Previdência Social fará no mesmo prazo a comunicação no caso da designação referida no final do §4º.*

A garantia de emprego é conferida apenas ao empregado eleito para cargo de direção, não se estendendo aos suplentes. A estabilidade é para quem ocupa cargo de direção, pouco importando sua denominação como *diretor* ou *conselheiro administrativo*, pois embora o **art. 55 da Lei nº 5764/71** aluda ao termo "*diretor*", não se pode afastar o direito à estabilidade no caso em que a cooperativa é dirigida, de fato e mediante delegação estatutária, por um conselho administrativo que

exerce típicas funções de uma diretoria¹³.

Orientação jurisprudencial 253 SDI-1: O art. 55 da Lei 5764/71 assegurada a garantia de emprego apenas aos empregados eleitos **diretores de Cooperativas, não abrangendo os membros suplentes.**

O **art. 522 da CLT** é aplicado, por força do **art. 55 Lei 5764/71**, aos empregados diretores de cooperativas, de modo que fica limitado a apenas 07 (sete) o número de diretores com garantia de emprego¹⁴. O pedido de demissão de diretor empregado com menos de um ano de empresa só terá validade com a assistência do sindicato da categoria, na sua falta, pela autoridade do Ministério do Trabalho ou, ainda, pela Justiça do Trabalho (**art. 500, CLT**).

Para a dispensa motivada do empregado eleito para ocupar cargo de direção de sociedade cooperativa, há necessidade de abertura de inquérito judicial para apuração de falta grave (**art. 853 CLT**), consoante aplicação por analogia da **orientação jurisprudencial nº 114 SDI¹⁵**, uma vez que o art. 55 do referido diploma legal (Lei 5764/71) estendeu as garantias asseguradas pelo **art. 543 da CLT**.

Não é garantida a estabilidade ao empregado que registra sua candidatura no curso do aviso prévio¹⁶. Também **não é garantida estabilidade** se há extinção da empresa ou filial na qual trabalhava o empregado estável¹⁷, não sendo devida qualquer indenização¹⁸, mas se resguarda o direito do empregado ao aviso prévio¹⁹.

A dispensa imotivada e irregular do empregado eleito para cargo de direção de sociedade cooperativa, garante sua imediata reintegração ao emprego. No caso de a reintegração ser impossível, ou porque o período estável se esgotou ou

¹³ Precedente TST – RR 27312 – 3ª T. – Relª Min. Conv. Wilma Nogueira de A. Vaz da Silva – DJU 21.03.2003.

¹⁴ Precedente TST – RR 488066 – 5ª T. – Rel. Min. Conv. Waldir Oliveira da Costa – DJU 09.11.2001 – p. 886.

¹⁵ Orientação jurisprudencial nº 114 SDI-1: “*Dirigente sindical. Despedida. Falta grave. Inquérito judicial. Necessidade*”.

¹⁶ Orientação Jurisprudencial nº 35 SDI-1: “*Dirigente sindical. Registro de candidatura no curso do aviso prévio. Não tem direito à estabilidade provisória*”.

¹⁷ Orientação Jurisprudencial nº 86 SDI-1: “*Dirigente sindical. Extinção da atividade empresarial no âmbito da base territorial do sindicato. Insubistência da estabilidade*”.

¹⁸ Enunciado 173: “*Extinto, automaticamente, o vínculo empregatício com a cessação das atividades da empresa, os salários só são devidos até a data da extinção*”.

¹⁹ Enunciado 44: “*A cessação da atividade da empresa, com o pagamento da indenização, simples ou em dobro, não exclui, por si só, o direito do empregado ao aviso prévio*”.

porque o dissídio criado entre patrão e empregado desaconselhe a reintegração²⁰, o Tribunal do Trabalho poderá converter aquela obrigação em indenização²¹ que corresponde aos salários desde a data da despedida até o final da estabilidade.

1.1.8. Estabilidade dos Membros da Comissão de Conciliação Prévia

É vedada a dispensa dos representantes dos empregados membros das comissões de conciliação prévia, sejam titulares ou suplentes até um ano após o final do mandato que é de um ano permitida uma recondução (**art. 625-B, III, CLT**). Será composta de 2 a 10 membros, sendo a metade indicada pelos empregados e a outra pelo empregador.

Não é garantida a estabilidade ao empregado que registra sua candidatura **no curso do aviso prévio ou se o contrato é por prazo determinado**. Também não é garantida estabilidade se **há extinção da empresa ou filial na qual trabalhava o empregado estável, não sendo devida qualquer indenização**²².

A dispensa imotivada e irregular do empregado indicado para membro de comissão de conciliação prévia, titular ou suplente, garante sua imediata reintegração ao emprego. No caso de a reintegração ser impossível, ou porque o período estável se esgotou ou porque o dissídio criado entre patrão e empregado desaconselhe a reintegração²³, o Tribunal do Trabalho poderá converter aquela obrigação em indenização²⁴ que corresponde aos salários desde a data da despedida até o final da estabilidade.

A extinção do contrato de trabalho do estável membro da C.C.P. só se dará mediante Inquérito Judicial para Apuração de Falta Grave, consoante a interpretação conjunta dos **arts 543, §3º, CLT e art. 8º, VIII, CF**:

Art. 543, §3º, CLT - Fica vedada a dispensa do **empregado sindicalizado ou associado**, a partir do momento do registro de sua candidatura a cargo de direção ou representação de entidade sindical ou de associação profissional, até 1 (um) ano após o final do seu mandato, caso seja eleito **inclusive como suplente**, salvo se cometer falta grave devidamente apurada nos termos desta Consolidação.

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

²⁰ Aplicação, em parte, do art. 496 CLT.

²¹ Orientação Jurisprudencial nº 116 SDI-1: “Estabilidade provisória. Período estável exaurido. Reintegração não assegurada. Devidos.

²² Enunciado 173: “Extinto, automaticamente, o vínculo empregatício com a cessação das atividades da empresa, os salários só são devidos até a data da extinção”.

²³ Aplicação, em parte, do art. 496 CLT.

²⁴ Orientação Jurisprudencial nº 116 SDI-1: “Estabilidade provisória. Período estável exaurido. Reintegração não assegurada. Devidos.

*VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a **partir do registro da candidatura** a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, **ainda que suplente, até um ano após o final do mandato**, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.*

Ressalte-se que segundo o entendimento do TST e do STF, “nos termos da Lei” significa dizer que se faz necessária a apuração da falta grave por meio de inquérito judicial, consoante as **Súmulas 197 do STF e 379 do TST**, tratando, pois, de forma igual os que se encontram em situação igual.

***Súmula nº 197 - STF** - O empregado **com representação sindical** só pode ser despedido mediante inquérito em que se apure falta grave.*

***Súmula nº 379 - TST** - O **dirigente sindical** somente poderá ser dispensado por falta grave mediante a apuração em inquérito judicial, inteligência dos arts. 494 e 543, §3º, da CLT.*

1.1.9. Membros do Conselho Nacional da Previdência Social – CNPS

Os representantes dos trabalhadores do CNPS, efetivos e suplentes, têm direito à garantia de emprego estabilidade desde a nomeação até um ano após o término do mandato, somente podendo ser dispensados por motivos de falta grave, regularmente comprovada por intermédio de processo judicial, ou seja, inquérito judicial para apuração de falta grave (**§7º art. 3º Lei 8213/91**).

Não é garantida a estabilidade ao empregado que registra sua candidatura no curso do aviso prévio²⁵ ou se o contrato é por prazo determinado. Também não é garantida estabilidade se há extinção da empresa ou filial na qual trabalhava o empregado estável, não sendo devida qualquer indenização (**Enunciado 173, TST**).

A dispensa imotivada e irregular do empregado nomeado para membro, titular ou suplente do Conselho Nacional da Previdência Social, garante sua imediata reintegração ao emprego. No caso de a reintegração ser impossível, ou porque o período estável se esgotou ou porque o dissídio criado entre patrão e empregado desaconselhe a reintegração, o Tribunal do Trabalho poderá converter aquela obrigação em indenização que corresponde aos salários desde a data da despedida até o final da estabilidade.

1.1.10. Membros do Conselho Curador do FGTS

Os membros do Conselho Curador do FGTS, titulares e suplentes, têm direito à garantia de emprego desde a nomeação até um ano após o término do

²⁵ Súmula 369, TST: “Dirigente sindical. Registro de candidatura no curso do aviso prévio. Não tem direito à estabilidade provisória”.

mandato de representação, somente podendo ser dispensados por motivo de falta grave, devidamente apurada por meio de processo sindical (§9º art. 3º lei 8.036/90).

Não é garantida a estabilidade ao empregado que registra sua candidatura no curso do aviso prévio ou se o contrato é por prazo determinado. Também não é garantida estabilidade se há extinção da empresa ou filial na qual trabalhava o empregado estável, não sendo devida qualquer indenização.

A dispensa imotivada e irregular do empregado nomeado para membro, titular ou suplente do Conselho Curador do FGTS, garante sua imediata reintegração ao emprego.

No caso de a reintegração ser impossível, ou porque o período estável se esgotou ou porque o dissídio criado entre patrão e empregado desaconselhe a reintegração, o Tribunal do Trabalho poderá converter aquela obrigação em indenização que corresponde aos salários desde a data da despedida até o final da estabilidade.

Há que se ressaltar, no entanto, que a estabilidade do empregado nomeado membro representante dos empregados no Conselho Curador do FGTS não tem a estabilidade forte, mas também não tem a fraca, sendo uma espécie de estabilidade “média”, pois para o encerramento do contrato de trabalho não se faz necessário o inquérito judicial para apuração de falta grave, mas é preciso procedimento administrativo (sindicância) para a dispensa do empregado detentor dessa modalidade estável.

1.1.11. Estabilidade do art. 41 da CF/88

Outra situação estável é a do servidor público civil regulada pelo **art. 41, CF/88** que ingressa nos quadros da administração pública obrigatoriamente através de concurso de provas ou de provas e títulos (**art. 37, inc. II, §2º, CF/88**).

Atualmente, é obrigatória a contratação, pela Administração Pública direta, autárquica e fundacional de servidores públicos para a ocupação de cargo efetivo mediante o regime jurídico único. No entanto, antes de declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 19 foram contratados servidores públicos sob o regime celetista, estes últimos denominados de empregados públicos.

***Art. 41, CF/88.** São estáveis **após três anos de efetivo exercício** os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.*

***Art. 37, CF/88** - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá*

aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

§2º - A não-observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

O texto refere-se à estabilidade após 03 (três) anos de efetivo exercício aos servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Assim, os empregados públicos da administração direta, autárquica e fundacional da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, uma vez ultrapassado o estágio probatório, com a obrigatória avaliação de desempenho por comissão especialmente instituída para esse fim, são beneficiários da estabilidade prevista no **art. 41 CF/88**.

Adquirida a estabilidade, somente poderá o empregado público perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado (**art. 41, § 1º, I CF/88**) ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada a ampla defesa (**art. 41, §1º, II CF/88**) ou ainda mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho (**art. 41, §1º, III CF/88**).

Já os servidores públicos de empresas estatais, assim entendidas as empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades controladas pelo Estado, que se organizam conforme os modelos da iniciativa privada, explorando atividade econômica na forma do art. 170 CF/88, a eles não se aplica a estabilidade do **art. 41, CF/88** o que, consequentemente, viabiliza sua dispensa arbitrária pelo empregador estatal, prescindindo, inclusive, de motivação do ato administrativo, sendo esse, inclusive, o raciocínio da **Súmula 390, II, TST; da OJ 247, I, TST; e do art. 173, §1º, II, CF/88**:

Súmula nº 390 - TST - Estabilidade - Celetista - Administração Direta, Autárquica ou Fundacional - Empregado de Empresa Pública e Sociedade de Economia Mista

II - Ao empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, ainda que admitido mediante aprovação em concurso público, não é garantida a estabilidade prevista no art. 41 da CF/1988. (ex-OJ nº 229 - Inserida em 20.06.2001)

OJ 247 SDI1 TST. ESTABILIDADE. EMPRESA PÚBLICA E SOC. ECON. MISTA. SERVIDOR PÚBLICO. CELETISTA CONCURSADO. DESPEDIDA IMOTIVADA. EMPRESA PÚBLICA OU SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE.

I - A despedida de empregados de empresa pública e de sociedade de

economia mista, mesmo admitidos por concurso público, independe de ato motivado para sua validade;

Art. 173, CF/88 - Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.

§1º - A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre:

II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários;

No entanto, em se tratando de empregado público da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), por força da **OJ 247, II, TST**, só podem ser dispensados se houver motivação do ato da dispensa.

***OJ 247 SDI1 TST. II** - A validade do ato de despedida do empregado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) está **condicionada à motivação**, por gozar a empresa do mesmo tratamento destinado à Fazenda Pública em relação à imunidade tributária e à execução por precatório, além das prerrogativas de foro, prazos e custas processuais.*

1.1.12. Trabalhadores Habilitados e Reabilitados

Trabalhadores habilitados são deficientes físicos e mentais que adquiriram capacidade física para o trabalho. Trabalhadores reabilitados são aqueles que perderam sua capacidade para o trabalho em virtude de um acidente comum ou do trabalho (aí inseridas as moléstias profissionais e comuns) e depois a adquiriram novamente.

Caso o empregador demita o empregado portador de deficiência sem que tenha contratado um substituto nas mesmas condições, a **dispensa será nula** e o empregado deverá ser **reintegrado até a contratação de outro nas mesmas condições**.

1.1.13. Portador de HIV

Caracteriza-se atitude discriminatória²⁶ ato de empresa que, a pretexto de motivação de ordem técnica, dispensa empregado portador soropositivo sem a ocorrência de justa causa e já ciente, à época, do estado de saúde em que se

²⁶ Pesquisa minuciosa a respeito dessa discriminação encontra-se em FURTADO, Emmanuel Teófilo. Preconceito no Trabalho e a Discriminação por Idade. São Paulo. LTr, 2004 p. 236-248.

encontrava o empregado, devendo o mesmo ser reintegrado.

SÚM-443, TST. *Presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à reintegração no emprego.*

A questão é que poderá ser dispensado o empregado portador da SIDA que cometer falta grave ou cuja dispensa embasar-se em motivos comprovadamente técnicos, econômicos ou financeiros.

TESE DE ESTABILIDADE DO PORTADOR DE HIV NA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA:

O reclamante tem direito de ser **reintegrado**, pois sua dispensa foi **presumidamente discriminatória** por ser o empregado **portador do vírus do HIV** que é doença grave e incurável e que causa **estigma e preconceito**, pelo que requer a **REINTEGRAÇÃO LIMINAR EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA (URGÊNCIA)**, nos termos do arts. 1º e 4º da Lei 9.029/95, súmula 443 TST e art. 300 § 2º do CPC.

1.1.14. Estabilidade por acordo de vontade das partes

O Tribunal Superior do Trabalho, através de seu **Enunciado 355**, já considerou inválida garantia de emprego concedida a empregado de empresa estatal, mesmo explorando atividade econômica, porque não aprovada a norma individual pelo Ministério ao qual a entidade se subordinava.

Súmula nº 355 - TST - *O aviso DIREH nº 2, de 12.12.1984, que concedia estabilidade aos empregados da CONAB, não tem eficácia, porque não aprovado pelo Ministério ao qual a empresa se subordinava.*

Por outro lado, atendidos os requisitos legais, a jurisprudência tem aceitado como válida, **norma coletiva que confere estabilidade suplementar a acidentado**, prorrogando-se no tempo mesmo após a vigência do instrumento normativo que previu a garantia de emprego.

OJ n. 41, TST. *Inserida em 25.11.96. Preenchidos todos os pressupostos para a aquisição de estabilidade decorrente de acidente ou doença profissional, ainda durante a vigência do instrumento normativo, goza o empregado de estabilidade mesmo após o término da vigência deste.*

2. PARA QUE SERVE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA?

A antecipação dos efeitos da tutela é, simplesmente, a possibilidade jurídica de se antecipar o resultado da sentença, antes de o processo ser sentenciado. O normal é que o provimento jurisdicional final – a sentença – seja concedido, apenas, depois de exaurido o processo de conhecimento, depois de praticados todos os atos processuais que convençam o juiz de que o momento de julgar chegou.

Partindo do pressuposto de que todos têm direito a uma efetiva tutela jurisdicional prestada pelo Estado através do Poder Judiciário, e esta tutela é prestada com o exaurimento do processo, casos há em que, se esperado o tempo normal de duração de um processo, o direito que se quer tutelar através dele pode se perder e a sentença final será ineficaz.

Por exemplo, determinado empregado, por força do contrato de trabalho mantido com seu empregador, está acobertado por plano de saúde privado. No entanto, ao sofrer acidente de trabalho e permanecer por mais de 15 dias afastado, seu contrato de trabalho foi suspenso para percepção do benefício auxílio-doença acidentário. Suspenso o contrato de trabalho, o empregador suspendeu o plano de saúde do empregado – por estar ligado a seu contrato – justamente quando o empregado mais precisa de seu plano de saúde.

O empregado apresenta reclamação trabalhista e requer ao juiz que o plano seja mantido. Caso espere a prática de todos os atos processuais até a sentença final, que lhe garanta a tutela jurisdicional pretendida, qual seja, a manutenção do plano de saúde, é possível que este empregado, não tendo condições financeiras de pagar tratamento particular, venha a ter lesões psicológicas, físicas ou fisiológicas irreversíveis decorrentes do acidente de trabalho.

Ao invés de esperar pela sentença final, cujo efeito seria a determinação da manutenção do plano de saúde, a reclamação trabalhista requer que os efeitos desta sentença sejam antecipados, ou seja, seja garantida, mediante antecipação de tutela, a manutenção do plano de saúde. O juiz não precisaria nem mesmo esperar a instrução e, desde que o reclamante demonstre a verossimilhança de suas alegações e a irreversibilidade do dano, a manutenção do plano de saúde seria garantida no início da lide e sem a oitiva da parte contrária²⁷.

²⁷*Initio litis et inaudita altera pars.*

2.1. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NA SENTENÇA E ANTES DA SENTENÇA

Quando se antecipa os efeitos da tutela antes da sentença, que é o mais comum, o provimento jurisdicional que só seria possível com a decisão final do processo é antecipado para que o direito que se quer proteger não pereça, não desapareça. Uma vez conseguida liminarmente (preliminarmente) a antecipação da tutela (antes da sentença final), dá-se o seu cumprimento com, por exemplo, a reintegração provisória do empregado.

Com a sentença final, haverá a confirmação da tutela antecipada e a reintegração em definitivo do trabalhador.

Entretanto, existe a possibilidade de o juiz não antecipar os efeitos da tutela antes da sentença porque, por exemplo, não se convenceu da verossimilhança das alegações e entendeu que conceder a tutela agora poderia causar um prejuízo irreversível ao réu, nos termos do **art. 300 do CPC**.

3. QUAIS CASOS DEPENDEM DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA?

É faticamente impossível determinar quais casos dependem ou em que casos a antecipação de tutela caberá, dada a grande quantidade de situações que dependeriam de cada caso a ser analisado.

Entretanto, há, basicamente, quatro situações em que o pedido de antecipação de tutela é certo: **a) reintegração de empregado garantido com estabilidade; b) reintegração de empregado dispensado por discriminação, vingança ou outro motivo vil ou torpe; c) transferência abusiva de empregado; d) manutenção de benefícios urgentes do empregado.**

3.1. Reintegração de empregado garantido com estabilidade

O uso mais comum do instituto da antecipação de tutela é no caso de reintegração de empregado garantido com estabilidade. Os empregados garantidos com estabilidade têm direito de permanecer em seus empregos pelo tempo determinado por lei, somente perdendo a estabilidade e, consequentemente seus empregos, caso cometam falta grave^{28 29}.

Note que o empregado nomeado membro representante dos

²⁸ ...

²⁹ Vide capítulo sobre estabilidade no emprego.

trabalhadores no Conselho Curador do FGTS, nos termos do **§ 9º do art. 3º da Lei 8.036/90** tem a perda de sua estabilidade ligada não a processo judicial (**inquérito, art. 853 da CLT**), mas a *processo sindical*, de natureza administrativa e, portanto, diferente do inquérito judicial.

Assim, caso o empregado garantido com estabilidade não cometa falta grave ou, dependendo do caso, mesmo que a cometa, esta não for apurada mediante inquérito judicial ou processo sindical, o empregado terá direito de ser reintegrado no emprego com o pagamento dos salários do período do afastamento.

Contudo, ao pedir a reintegração no emprego de empregado garantido com estabilidade, deve-se ter em mente que a reintegração só é direito do empregado se esta se der dentro do período estabilitário. Caso o período estabilitário já tenha se esgotado, terminado, o empregado não terá direito à reintegração, mas, apenas e tão somente, à indenização do período estabilitário, ou seja, salários e demais vantagens desde o afastamento até o último dia de estabilidade (**súmula 244, item II e súmula 396, item I, ambas do TST**), de forma simples e não dobrada como nos termos do **art. 497 da CLT**, aplicável somente ao estável decenal, de acordo com entendimento dominante do TST³⁰.

Caso 1. Apresentação de reclamação trabalhista e sentença dentro do período estabilitário:

Determinada empregada gestante, que tem estabilidade desde a confirmação da gravidez até o quinto mês após o parto (**art. 10, II, b do ADCT**), em seu segundo mês de gestação, quando nem mesmo sabia que estava grávida, é dispensada sem justa causa por seu empregador. Pouco tempo depois, descobre que está grávida e dada a nulidade de sua dispensa, ingressa com reclamação trabalhista com pedido de reintegração, ainda dentro do período estabilitário.

Como a ação foi proposta dentro do período estabilitário, a empregada pode, perfeitamente, requerer sua reintegração. Caso defira a antecipação de tutela antes da sentença ou na sentença, mas dentro do período estabilitário, o juiz poderá determinar a reintegração da empregada.

Caso 2. Apresentação de reclamação trabalhista dentro do período estabilitário e sentença fora do período:

Tomando por base o caso do item **a.1.**, a empregada ingressa com

³⁰ DECISÕES DO TST SOBRE O ASSUNTO.

reclamação dentro do período estável e pede corretamente sua reintegração no emprego. No entanto, o juiz ao antecipar os efeitos da tutela antes da sentença ou na sentença, o faz quando já acabado, exaurido ou terminado o período estável.

Neste caso, o juiz não poderá determinar a reintegração da empregada, mas, apenas, o pagamento da indenização do período estável que são os salários e demais vantagens até o final da estabilidade, uma vez que a reintegração somente pode ocorrer dentro do período de estabilidade, nos termos das **súmulas 244, item II e 396, item I do TST**.

Caso o juiz defira a reintegração em decisão interlocutória ou de mérito, o fará de modo incorreto, merecendo a decisão ser atacada mediante recurso ordinário (**art. 895, I da CLT**).

Caso 3. Apresentação da reclamação trabalhista e sentença fora do período estável:

Caso a empregada gestante dispensada sem justa causa no segundo mês de gestação deixe para ingressar com reclamação trabalhista somente após o período estável, não poderá pedir a reintegração e, se o fizer, o pedido estará totalmente equivocado, de modo que o examinando perderá pontos no exame de ordem. Ela deve pedir em sua reclamação trabalhista, apenas, a indenização do período estável. O juiz que, certamente, decidir fora do período estável também garantirá somente a indenização.

Muito se discutiu sobre o fato de a empregada deixar para ingressar com ação trabalhista após o período de estabilidade, se não seria um abuso ao exercício do direito de ação por parte da trabalhadora. No entanto, o TST através da **OJ 399 da SDI-1**, decidiu que:

“O ajuizamento de ação trabalhista após decorrido o período de garantia de emprego não configura abuso do exercício do direito de ação, pois este está submetido apenas ao prazo prescricional inscrito no **art. 7º, XXIX, da CF/1988**, sendo devida a indenização desde a dispensa até a data do término do período estável.”.

3.2. Reintegração de empregado dispensado por discriminação, vingança ou outro motivo vil ou torpe.

Um equívoco muito comum no mundo jurídico é o de se pensar que reintegração de empregado só tem a ver com estabilidade. Não. A reintegração de empregado não tem a ver apenas com estabilidade, mas com a nulidade da dispensa

do empregado. Se por algum motivo o ato demissional do empregado for nulo, sua reintegração se faz necessária.

Nunca é demais lembrar que, muito embora o **inc. I do art. 7º da CF** proteja a relação de emprego contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa mediante pagamento de uma indenização prevista em lei complementar - dentre outros direitos, no momento, enquanto a lei complementar de que trata o **inc. I do art. 7º da CF** não vier, essa proteção fica limitada ao pagamento de uma indenização equivalente a 40% sobre os depósitos de FGTS feitos, ou que deveriam ter sido feitos, na conta do empregado, nos termos do **art. 10, inc. I do ADCT**.

Deste modo, o mesmo dispositivo que protege a relação de emprego contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa, garante que o empregador dispense o empregado quando lhe aprouver, sabendo, contudo, que ficará sujeito ao pagamento de uma indenização. Esta é toda a proteção. Assim, o empregador tem o direito *potestativo* – contra o qual ninguém pode se opor – de despedir o empregado com ou sem justa causa.

Mas seu direito tem limites. Um deles, como já foi visto, é a estabilidade que subordina a demissão ao cometimento de falta grave pelo empregado ou, dependendo do caso, à apuração da falta grave mediante inquérito em que se verifique a procedência da acusação. Outro limite é o abuso de direito. Por mais que o empregador tenha o direito de despedir o empregado, não poderá exercê-lo de forma abusiva, sob pena de anular o ato demissional (**art. 9º da CLT**) e cometer ato ilícito passível de indenização (**arts. 186, 187 e 927 do C.C e art. 4º, caput, da Lei 9.029/95**).

3.3. Dispensa por ato discriminatório

O **art. 1º da Lei 9.029/95** estabelece que fica proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de emprego, ou sua manutenção, por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar ou idade, ressalvadas, neste caso, as hipóteses de proteção ao menor, previstas no **inciso XXXIII do artigo 7º da CF**.

Caso o empregado seja, por exemplo, portador do vírus do HIV, sua dispensa é presumidamente discriminatória (**súmula 443 do TST**) e, portanto, nula de pleno direito (**art. 9º da CLT**), devendo ser reintegrado no emprego e pedir o pagamento dos salários do período do afastamento (**art. 4º, inc. I da Lei 9.029/95**) sem prejuízo, é claro, de indenização por dano moral, nos termos do **art. 4º, caput,**

da mesma lei e **art. 1º inc. II da CF**, pois sua dignidade foi ferida pelo fato de sua doença, por causar estigma e preconceito, foi decisiva para sua não manutenção no emprego, sentindo-se o empregado diminuído perante terceiros e perante si mesmo.

No entanto, existe a possibilidade de o empregado não pretender retornar ao emprego com receio de que o ambiente de trabalho, por força da discriminação, lhe seja absolutamente hostil e insuportável. Neste caso, o empregado ofendido, ao invés de ser reintegrado, poderá escolher uma indenização equivalente aos salários e demais vantagens de todo o período de afastamento, paga em dobro (**inc.II do art. 4º da Lei 9.029/95**).

3.4. Dispensa Retaliativa

Como dito acima, o empregador tem garantido constitucionalmente (**art. 7º, inc. I da CF**) o direito de despedir com ou sem justa causa o empregado, bastando para isso que pague a indenização correspondente (**art. 10, inc. I ADCT**). O empregador pode despedir o empregado até sem motivo (sem justa causa), mas nunca por motivo vil ou torpe como, por exemplo, a vingança.

É muito comum que durante o contrato de trabalho o empregador não respeite os direitos trabalhistas previstos em lei ou no contrato. O empregado ao questionar o empregador sobre, por exemplo, a não concessão de suas férias no prazo (**art. 137 da CLT**), não pagamento de horas extras, não pagamento de gratificação, enfim, é despedido “sem justa causa” aparente. No entanto, esta aparência é falsa, pois o que motivou sua dispensa foi ter indagado acerca de seus direitos. Por mais que o empregador possa despedir livremente o empregado, o exercício regular de seu direito não pode ser praticado de forma abusiva, de modo a exceder os limites impostos pela boa fé, bons costumes, fim social ou econômico.

Ao despedir o empregado como retaliação a suas indagações, o empregador excedeu os limites da boa-fé, o que tornou a dispensa abusiva (**art. 187 do C.C.**), nula de pleno direito (**art. 9º da CLT**) e carecedora de reparação por dano material ou moral (**art. 97 do C.C.**). Nula a dispensa, impõe-se sua reintegração no emprego com o pagamento dos salários do período de afastamento e indenização por dano.

3.4.1. Qual a diferença entre empregado estável e discriminado quanto à impossibilidade de reintegração?

No caso de empregado estável em que sua reintegração seja desaconselhada, a opção pela conversão em indenização não é do empregado, mas do juiz, em que este escolherá diante do caso concreto se converte em indenização ou não. Assim, o reclamante tem que fazer o pedido de reintegração e, só alternativamente, o de indenização.

3.5. Transferência abusiva de empregado:

A concessão de liminar para tornar sem efeito transferência³¹³²³³³⁴ abusiva está dentre as faculdades atribuídas ao juiz do trabalho por força do **inc. IX do art. 659 da CLT**:

Art. 659, CLT - Competem privativamente aos Presidentes das Juntas, além das que lhes forem conferidas neste Título e das decorrentes de seu cargo, as seguintes atribuições:

(...)

IX - conceder **medida liminar**, até decisão final do processo, em reclamações trabalhistas que visem a tornar sem efeito transferência disciplinada pelos parágrafos do artigo 469 desta Consolidação.

Caso o empregado já tenha sido transferido e o ato de transferência não tenha preenchido os requisitos previstos no **art. 469 da CLT e seus parágrafos**, há lesividade da alteração contratual (**art. 468 da CLT**), podendo o empregado ingressar com reclamação trabalhista requerendo nulidade da alteração e liminar que torne a transferência sem efeito, com seu imediato retorno à cidade de origem, com a demonstração da fumaça do bom direito e do perigo na demora.

No entanto, existe a possibilidade de a transferência abusiva ainda não ter sido levada a efeito, mas esteja na iminência de acontecer. Então, o empregado, a fim de não sofrer o prejuízo, pode se antecipar e requerer liminar obstativa da sua transferência, nos termos da **OJ 67 da SDI-2 do TST**. A reclamação trabalhista, neste caso, teria como objeto uma obrigação de não fazer, ou seja, de não transferir abusivamente o empregado.

Tanto no caso de nulidade de transferência já efetivada quanto no caso de

³¹

³²

³³ ...

³⁴Vide capítulo sobre alteração do contrato de trabalho, mais precisamente a parte sobre transferência de empregados.

impedimento de transferência futura, o empregado pode se utilizar tanto da medida liminar, prevista no **inc. IX do art. 659 da CLT** quanto da antecipação de tutela, prevista no **art. 300 do CPC/15**³⁵.

A diferença, como já explicado neste capítulo, é que: utilizando-se o empregado da reclamação trabalhista com pedido liminar, demonstraria como requisitos para sua concessão o *fumus boni iuris* e o *periculum in mora*, fundamentando o pedido no **inc. IX do art. 659 da CLT**. No caso de antecipação de tutela, os requisitos seriam a *verossimilhança das alegações* e a *irreversibilidade do dano*, com fundamento no **art. 300 CPC/15**.

3.6. Manutenção de benefícios urgentes do empregado:

Apesar de alguns processualistas sustentarem que a antecipação de tutela no processo do trabalho restringe-se, basicamente, aos casos de reintegração e/ou transferência, quando não pedida apenas a medida liminar, razão não lhes assiste. Há, na verdade, uma infinidade de possibilidades de o instituto da antecipação de tutela ser utilizado no Processo do Trabalho. Longe de se tentar esgotar as possibilidades, deseja-se, apenas, mostrar que os casos de manutenção de benefícios urgentes são um prato cheio para a antecipação.

Cite-se como exemplo, mais uma vez, o caso de determinado empregado que, por força do contrato de trabalho mantido com seu empregador, está coberto por plano de saúde privado, pago pelo empregador. No entanto, ao sofrer acidente de trabalho e permanecer por mais de 15 dias afastado, seu contrato foi suspenso para percepção do benefício auxílio doença acidentário. Suspenso o contrato, o empregador suspendeu o plano de saúde do empregado, justamente quando mais o empregado dele necessita.

O empregado apresenta reclamação trabalhista e requer ao juiz que o plano seja mantido, em sede de antecipação de tutela. Para tanto, basta que demonstre a verossimilhança de suas alegações quanto à doença profissional e a necessidade do plano e a irreversibilidade do dano – caso a antecipação não seja logo concedida – fundada no fato de, não tendo condições financeiras de pagar tratamento particular, poderá vir a sofrer lesões psicológicas, físicas ou fisiológicas irreversíveis, decorrentes

³⁵RO - 10036-61.2012.5.18.0000 **Data de Julgamento:** 17/12/2013, **Relator Ministro:** Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Subseção II Especializada em Dissídios Individuais, **Data de Publicação:** DEJT19/12/2013 em que abre a possibilidade de a abusividade da transferência ser discutida em sede de antecipação de tutela.

do acidente de trabalho³⁶.

Outro caso seria, por exemplo, o empregador em via de retirar ilegalmente do empregado uma vantagem sua de natureza salarial que comprometa o final de seus vencimentos e, portanto, sua própria manutenção e/ou de sua família. Portanto, a fim de não perder a vantagem, o empregado apresenta reclamação trabalhista com pedido de antecipação de tutela para que o empregador se abstenha de reduzir seu salário. Demonstrada a verossimilhança de seu direito à vantagem e o receio de ser suprimida, aliada ao fato de que, com a supressão da vantagem, sua manutenção e/ou de sua família ficará comprometida (irreversibilidade do dano), haverá o juiz de conceder a antecipação, seja antes ou na sentença.

4. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL RECLAMAÇÃO COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

Os requisitos da petição inicial de reclamação trabalhista com antecipação de tutela ou medida liminar são os mesmos de uma reclamação comum, descritos no **§1º do art. 840, da CLT, art. 853 da CLT e art. 319 CPC/15**, que de forma simplificada são: endereçamento, qualificação das partes, uma breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, data e assinatura.

Art. 840, CLT- A reclamação poderá ser escrita ou verbal.

§ 1º - Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do Presidente da Junta, ou do juiz de direito a quem for dirigida, a qualificação do reclamante e do reclamado, uma breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante.

O detalhe é que dentro da fundamentação fática e jurídica, deverá se demonstrar a verossimilhança das alegações e a irreversibilidade do dano, previstas no art. 300, do CPC/15.

4.1. Devo abrir um tópico para cada item pedido na reclamação com antecipação de tutela ou medida liminar?

Sim. É importante (não obrigatório) que para cada tese a ser discutida na reclamação trabalhista exista um tópico correspondente, de modo a deixar a peça redigida bem organizada, o que facilitará a compreensão e correção da mesma pelo

³⁶RO - 181-04.2012.5.20.0000 **Data de Julgamento:** 10/12/2013, **Relator Ministro:** Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Subseção II Especializada em Dissídios Individuais, **Data de Publicação:** DEJT13/12/2013

examinador. Tome-se como exemplo uma reintegração no emprego. O ideal é que sejam abertos os seguintes tópicos: a) da estabilidade; b) da nulidade da dispensa; c) da antecipação de tutela ou medida liminar.

Exemplo:

I – DA ESTABILIDADE, pois deve se demonstrar que o empregado é portador de estabilidade prevista em lei, contrato ou Constituição Federal.

II – DA NULIDADE DA DISPENSA, todo empregado garantido com estabilidade, para ser despedido, necessita cometer falta grave ou que esta seja apurada mediante inquérito, logo é de extrema importância demonstrar porque a dispensa é nula;

III – DA REINTEGRAÇÃO, aqui fale da antecipação ou medida liminar e demonstre o preenchimento dos requisitos de tais medidas.

4.2. O que devo pedir numa petição de antecipação de tutela ou medida liminar?

O pedido aqui pode ser dividido em dois parágrafos básicos: no primeiro parágrafo o examinando deve pedir a concessão da antecipação de tutela antes da sentença ou da medida liminar de reintegração, por exemplo. No segundo parágrafo, o **JULGAMENTO TOTALMENTE PROCEDENTE** que vale, em média, 0,40 (quarenta décimos), com a confirmação da tutela na sentença ou da liminar da sentença e demais pedidos de praxe.

Capítulo 10

INQUÉRITO JUDICIAL PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE

1. PARA QUE SERVE O INQUÉRITO JUDICIAL PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE?

O inquérito judicial para apuração de falta grave é uma reclamação escrita, proposta exclusivamente pelo empregador contra o empregado garantido com estabilidade, nos termos dos **arts. 494 e 853 da CLT**:

ATENÇÃO!!! **GRIFAR** AS PALAVRAS DESTACADAS NA CLT:

*Art. 853, CLT - Para a instauração do inquérito para apuração de falta grave contra empregado garantido com estabilidade, o empregador apresentará reclamação por escrito à Junta ou Juízo de Direito, **dentro de 30 (trinta) dias**, contados da data da suspensão do empregado.*

Há em que certos tipos de estabilidade somente podem ser perdidas caso o empregado cometa falta grave e referida falta seja apurada mediante a apresentação de inquérito em que se verifique a procedência da acusação.

2. QUAIS CASOS DEPENDEM DE INQUÉRITO JUDICIAL?

Há seis tipos de estabilidades que só podem ser perdidas caso o empregado cometa falta grave e a falta seja apurada mediante inquérito em que se verifique a procedência da acusação: **1-** dirigente sindical e seu suplente; **2-** empregado eleito diretor de cooperativa pelo próprio empregador formada; **3-** empregado eleito, **ainda que suplente**, membro representante dos trabalhadores nas comissões de conciliação prévia; **4-** empregado nomeado membro representante dos trabalhadores no Conselho Nacional de Previdência Social; **5-** empregado estável decenal; **6-** empregado público da administração pública direta, autárquica ou fundacional.

a) dirigente sindical e seu suplente

As estabilidades do dirigente sindical e suplente estão previstas no **inc. VIII do art. 8º da CF** e **§3º do art. 543 da CLT** que dispõem basicamente que o empregado eleito para cargo de direção ou representação sindical, **ainda que suplente**, tem estabilidade no emprego desde o registro da candidatura até um ano

após o término do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

Tanto o Supremo Tribunal Federal (**súmula 197**) quanto o Tribunal Superior do Trabalho (**súmula 379**), interpretaram a expressão contida no final da redação do **inc. VIII do art. 8º da CF** e do **§3º do art. 543 da CLT** como necessidade de inquérito judicial. Assim, o simples cometimento de falta grave pelo dirigente sindical não ocasiona a perda da estabilidade. Deverá o empregador apresentar perante a Vara do Trabalho do local da prestação de serviços (**art. 651, CLT**) a ação de inquérito para apurar judicialmente a falta grave. Uma vez julgada procedente a ação, o juiz reconhece o cometimento da falta grave e o contrato poderá ser extinto por justa causa.

***Art.543, 3º, CLT** - Fica vedada a dispensa do empregado sindicalizado ou associado, a partir do momento do registro de sua candidatura a cargo de direção ou representação de entidade sindical ou de associação profissional, até 1 (um) ano após o final do seu mandato, caso seja eleito inclusive como suplente, salvo se cometer falta grave devidamente apurada nos termos desta Consolidação.*

***Art. 8º, VIII, CF/88** - e vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.*

***Súmula 197, STF** - O empregado com representação sindical só pode ser despedido mediante inquérito em que se apure falta grave.*

***Súmula 379, TST.** O dirigente sindical somente poderá ser dispensado por falta grave mediante a apuração em inquérito judicial, inteligência dos arts. 494 e 543, § 3º, da CLT.*

b) empregado eleito diretor de sociedade cooperativa

Nos termos do **art. 55 da Lei 5.764/71**, lei das cooperativas³⁷, os empregados eleitos diretores de cooperativas têm os mesmos privilégios daqueles eleitos para cargo de direção ou representação sindical:

***Art. 55, Lei 5.764/71** – Os empregados de empresas que sejam eleitos **diretores de sociedades cooperativas** pelos mesmos criadas, gozarão das garantias asseguradas aos dirigentes sindicais pelo artigo 543 da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943).*

³⁷ A chamada nova lei as cooperativas, Lei 12.690 de 19.07.2012, não revogou a lei 5.764/71, tampouco alterou a redação do art. 55 da mesma lei, apenas disciplina também as sociedades cooperativas.



O suplente do diretor de sociedade cooperativa, por falta de previsão legal, não tem qualquer estabilidade (**OJ 253, SDI-1, TST**), podendo ser dispensado a qualquer momento, inclusive, sem justa causa.

***OJ 253, SDI-1, TST** - O art. 55 da Lei 5.764/1971 assegura a garantia de emprego apenas aos empregados eleitos diretores de Cooperativas, não abrangendo os membros suplentes.*

c) empregado eleito membro representante dos trabalhadores nas comissões de conciliação prévia

Da mesma forma que a perda da estabilidade dos dirigentes sindicais está condicionada aos “termos da lei”, a dos membros das CCP’s também, de modo que se deve entender aqui, sob pena de falta de coerência, necessidade de apuração mediante inquérito judicial.

***Art. 625-B, § 1º, CLT:** É vedada a dispensa dos representantes dos empregados membros da Comissão de Conciliação Prévia, titulares e suplentes, até um ano após o final do mandato, salvo se cometerem falta grave, nos termos da lei.*

d) Empregado nomeado membro representante dos trabalhadores no Conselho Nacional de Previdência Social

A necessidade de apuração da falta grave mediante inquérito foi a mais direta neste caso, pois o **§7º do art. 3º da Lei 8.213/91** condiciona a demissão por justa causa à comprovação de falta grave através de processo judicial:

***§7º art. 3º Lei 8.213/91** – Aos membros do CNPS, enquanto representantes dos trabalhadores em atividade, titulares e suplentes, é assegurada a estabilidade no emprego, da nomeação até um ano após o término do mandato de representação, somente podendo ser demitidos por motivo de falta grave, regularmente comprovada através de processo judicial.*

e) Empregado estável decenal

Apesar de não existir mais a possibilidade de se adquirir a estabilidade decenal³⁸ prevista no **art. 492 da CLT**, aqueles que já haviam adquirido a dita estabilidade antes da promulgação da atual Constituição Federal, em 05.10.1988, mantiveram seu direito dentro da nova ordem constitucional, de modo que continuam gozando de estabilidade e somente podem ser dispensados caso

³⁸ Vide capítulo sobre estabilidade, mais precisamente sobre a estabilidade decenal.

cometam falta grave apurada mediante inquérito, nos termos do **art. 494 da CLT**.

f) Empregado público da administração pública direta, autárquica ou fundacional

O Tribunal Superior do Trabalho através da **Súmula 390, item I**, tem entendido que os empregados públicos da administração pública direta, autárquica ou fundacional gozam da estabilidade prevista no **art. 41 da CF**, de modo que após 3 anos de emprego público, somente podem ser dispensados mediante decisão judicial transitada em julgado ou processo administrativo em que lhe seja garantida a ampla defesa e o contraditório ou avaliação periódica de desempenho.

Súmula 390, I, TST - O servidor público celetista da administração direta, autárquica ou fundacional é beneficiário da estabilidade prevista no art. 41 da CF/88.

1. COMO SE PROCESSA UM INQUÉRITO JUDICIAL PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE?

Determinado empregado, dirigente sindical, e portador, da estabilidade prevista no **inc. VIII do art. 8º da CF e §3º do art. 543 da CLT**, cometeu falta grave. Nos termos do **art. 494 da CLT**, no caso de cometimento de falta grave por trabalhador estável, o empregador poderá suspender o empregado de suas funções, mas a sua despedida somente se tornará efetiva após o inquérito em que se verifique a procedência da acusação. (Súm. 403, STF)

Quando o empregado comete falta grave, o empregador não é obrigado a suspendê-lo, a suspensão é uma faculdade do empregador. Mas, uma vez suspenso, **em regra**, a suspensão só pode ser por no máximo 30 dias, nos termos do **art. 474 da CLT**.

Caso o empregador suspenda o empregado, da data da suspensão – e não do cometimento da falta grave – o empregador tem o prazo decadencial de 30 dias para apresentação de inquérito judicial para a apuração da falta grave cometida pelo empregado estável, nos termos do **art. 853 da CLT**.

Uma vez apresentado o inquérito dentro dos trinta dias contados da suspensão do empregado, excepcionalmente, o contrato de trabalho do empregado permanecerá suspenso até o julgamento do inquérito judicial pelo juiz da Vara do Trabalho, nos termos do **parágrafo único do art. 494 da CLT**.

Caso o juiz da Vara julgue o inquérito judicial procedente, reconhecendo o cometimento de falta grave pelo empregado, a sentença também declarará extinto o

contrato de trabalho por justa causa.

Caso o juiz da Vara julgue o inquérito judicial improcedente, **não** reconhecendo o cometimento de falta grave pelo empregado, a sentença determinará a imediata readmissão do empregado ao emprego, bem como o pagamento de todos os salários e demais vantagens desde a suspensão até a sentença, nos termos do **art. 495 da CLT**.

Caso o empregador desobedeça ao prazo de 30 dias previsto no art. 853 da CLT, apresentando o inquérito depois de 30 dias da data da suspensão do empregado, por ser tratar de prazo decadencial (**súmulas 403 do STF e 62 do TST**), o juiz deverá julgar extinto o feito **com** solução de mérito, nos termos do **art. 487, II do CPC/15** e determinar a imediata readmissão do empregado no emprego, bem como o pagamento de todos os salários e demais vantagens desde a suspensão até a sentença, nos termos do **art. 495 da CLT**.

2. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL DE INQUÉRITO

Os requisitos da petição inicial de Inquérito Judicial para apuração de falta grave são os mesmos de uma reclamação trabalhista e estão descritos no **§1º do art. 840, da CLT, art. 853 da CLT e art. 319 e incisos do CPC/15**, que de forma simplificada são: endereçamento, qualificação das partes, uma breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, data e assinatura.

Art. 840, CLT - A reclamação poderá ser escrita ou verbal.

§1º - Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do Presidente da Junta, ou do juiz de direito a quem for dirigida, a qualificação do reclamante e do reclamado, uma breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante.

Capítulo 11

DANO E SUA INDENIZAÇÃO

1. DANO E SUA INDENIZAÇÃO

Aquele que por ação ou omissão causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito (**art. 186 do C.C.**) e tem a obrigação de indenizar (**art. 927 do C.C.**). A indenização pelo dano encontra previsão no **art. 5º, incisos V e X da CF, arts. 223-A, 223-B, 223-C da CLT e arts. 186, 389 e 927 do C.C.** e se o dano decorre da relação de trabalho, a competência é da Justiça do Trabalho, nos termos do **art. 114, inc. VI da CF e Súmula 392 do TST³⁹**.

2. NEXO DE CAUSALIDADE

Nexo de causalidade é a **relação entre a ação ou a omissão do agente e o dano experimentado pela vítima**. Assim, deve-se demonstrar que o réu, numa ação de indenização, foi realmente o causador do dano, de modo que sua ação ou omissão prejudicou a vítima.

Assim, numa reclamação trabalhista, na fundamentação jurídica, deve-se descrever minuciosamente a conduta omissiva ou comissiva do autor e ligar tal conduta ao dano suportado pela vítima.

Por exemplo, “(...) o empregador, ao não dar manutenção devida ao veículo, este perdeu os freios numa descida, vindo a chocar-se contra um muro, fazendo com que o empregado sofresse fraturas (...)”.

Caso o acidente tenha ocorrido por fato **alheio à conduta do empregador**, como no caso de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, força maior, legítima defesa própria ou de outrem e estado de necessidade (**art. 188, inc. I do Código Civil**), **não comete o empregador qualquer ato ilícito, desaparecendo sua obrigação de indenizar**.

2.1. Dano Moral

Dano moral é o dano que abala a saúde emocional e psicológica do ofendido, após um ataque à sua honra, boa fama, reputação, sua moral ou dignidade. Por exemplo, determinado empregador chama sua empregada de burra, incompetente e incapaz em voz alta e na presença de outros empregados e clientes.

³⁹ Vide capítulo sobre competência material da Justiça do Trabalho, mais precisamente o inciso VI do art. 114 da Constituição Federal.

Não importa se a empregada é desidiosa ou zelosa, o empregador ofendeu-lhe a dignidade como pessoa e profissional fazendo-a se sentir constrangida e diminuía perante terceiros, hoje previsto na CLT, após a reforma trabalhista, nos arts. 223-A, 223-B e 223-C.

TESE DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

A reclamante tem direito à **indenização por danos morais** no valor de R\$ ____, pois sofreu assédio moral ao ter sido chamada de burra, incompetente e incapaz, apesar de todo o zelo profissional com o qual executava suas funções, causando-lhe abalos psicológicos, humilhação e constrangimento, nos termos do art. 223-A e 223-B, CLT, art. 5º, V e X, CF, art. 186 e 927, CC.

2.2. Dano Material

Dano material é prejuízo causado ao patrimônio do ofendido. Tomando-se por base o exemplo do parágrafo anterior, o abalo emocional da empregada pelas ofensas em voz alta do empregador, que ela precisou frequentar sessões com psiquiatra. O prejuízo emocional acabou lhe causando um prejuízo material, por ter que pagar pelas sessões com o psiquiatra, de modo que tais valores poderão ser ressarcidos pelo empregador através de ação de indenização por dano material.

TESE DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL

A reclamante tem direito à **indenização por danos materiais** no valor de R\$ ____, decorrente do gasto com despesas de tratamento psiquiátrico, pois o precisou fazer tratamento por culpa do empregador, uma vez que a chamou de burra, incompetente e incapaz na frente de colegas, nos termos dos arts. 949 e 950 CC.

2.3. Dano Estético

Caso o empregado sofra um acidente de trabalho ou contraia uma doença profissional que lhe altere a aparência física, fará jus a uma indenização pecuniária que lhe compense a aparência física modificada.

TESE DE INDENIZAÇÃO POR DANO ESTÉTICO

O reclamante tem direito à **indenização por danos estéticos** no valor de R\$ ____ decorrente de **deformidade física externa (aparente)**, pois (explique, dados do caso), nos termos dos arts. 949 e 950 do CC.

2.4. Dano Existencial

Dano existencial, atualmente expressamente previsto no art. 223-B da CLT, é todo e qualquer prejuízo sofrido pela vítima que possa tornar sua vida insuportável. Exemplo clássico e recorrente nas decisões do TST sobre o assunto é o pagamento de indenização por dano existencial a empregado obrigado a prestar horas extras. Após o trabalho extraordinário, chega o trabalhador muito tarde em casa, privando-o do contato com sua família e amigos, sem o direito ao lazer noturno, tornando sua vida insuportável⁴⁰.

⁴⁰DECISÕES DO TST SOBRE O ASSUNTO

Capítulo 12

DEFESA TRABALHISTA

1. INTRODUÇÃO

A defesa trabalhista tem expressa previsão no **art. 847 da CLT** e é feita oralmente, em audiência, no prazo de *vinete minutos* depois de lida a reclamação trabalhista, caso não seja dispensada a leitura. Assim, como ocorre no processo civil, a defesa trabalhista é composta de quatro respostas do réu: a contestação (**arts. 336, 337 e 341, do CPC/15**), a reconvenção (**arts. 343, do CPC/15**), a exceção de suspeição (**arts. 799, 801 e 802 da CLT**) e a exceção de incompetência relativa (**arts. 799 e 800 da CLT**).

- Contestação (**arts. 336, 337 e 341 do CPC**)
- Reconvenção (**art. 343 do CPC**)

A defesa trabalhista se divide em: defesa processual, indireta de mérito e direta de mérito.

1. CONTESTAÇÃO

Apesar de a CLT não fazer qualquer menção à contestação, mas apenas genericamente à defesa (**arts. 767, 799, §1º, 847 e 848 da CLT**), aplicam-se os **arts. 336, 337 e 341, do CPC/15** subsidiariamente ao processo do trabalho dada a omissão da CLT e a compatibilidade dos institutos.

Nos termos do **art. 336 do CPC/15**, é na contestação que o reclamado alegará toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com as quais impugna o pedido do autor. Além do mais, o **art. 341 do CPC/15** estabelece que as impugnações devem ser específicas, manifestando-se o réu, precisamente, sobre os fatos narrados na petição inicial, sob pena de aquilo que não for impugnado especificamente ou não contestado ser presumido verdadeiro, incorrendo o réu na confissão ficta ou eventualidade.

Assim, mesmo que o examinando tenha certeza de que a preliminar de inépcia da petição inicial alegada em contestação tenha o condão de extinguir o feito sem solução de mérito, ainda assim deverá, obrigatoriamente, suscitar as prejudiciais de prescrição e/ou decadência que entenda cabíveis e contestar o mérito da reclamação trabalhista, pois, na prática, o advogado alega, mas quem julga é o juiz e caso o juiz rejeite a preliminar, não havendo impugnação no mérito, há presunção de

que os fatos não impugnados são verdadeiros (eventualidade).

1.1. REQUISITOS DA PEÇA DE CONTESTAÇÃO

Apesar de nem a CLT tampouco o CPC disporem precisamente sobre os requisitos da peça de contestação, ela apresenta os seguintes requisitos: endereçamento à autoridade judiciária competente, qualificação das partes, preliminares/prejudiciais, fundamentos fáticos e jurídicos da impugnação e conclusão.

1.1.1. Endereçamento e competência funcional

O endereçamento à autoridade competente é requisito da defesa trabalhista, até mesmo porque tem por objeto a impugnação dos pedidos do autor e se conclui pedindo o acolhimento das preliminares e prejudiciais levantadas e o julgamento totalmente procedente da ação. Logo, como quem pede, pede alguma coisa a alguém, esse alguém a quem está sendo feito o pedido é a autoridade judiciária que vai apreciar a contestação.

Por exemplo, se uma reclamação trabalhista foi distribuída para a 1ª Vara do Trabalho de Olinda sob o número 0161800-23.2009.5.06.0004, a contestação a essa ação deve ser endereçada para a mesma Vara do Trabalho, ou seja, para a 1ª Vara do Trabalho de Olinda, fazendo-se menção ao número do processo, como já exigido várias vezes pela OAB/FGV.

1.1.2. Fundamentação Fática e Jurídica (Fórmula Mágica)

É a parte fundamental de qualquer peça processual, seja uma petição inicial, uma defesa ou um recurso. Mais precisamente numa contestação, que é o que nos interessa no momento, o **art. 336 do CPC/15** diz que nela o réu deverá expor as razões de fato e de direito com as quais impugna o pedido do autor. Mais uma vez utilizaremos a Fórmula Mágica.

É que ... (O que o empregado pediu de errado)

E daí? (Diga por que não tem direito e explique)

Pelo que requer ... (Faça o pedido)

Nos termos de ... (Súm, OJ, Lei)

ATENÇÃO! Note que para que sua peça seja elaborada na melhor técnica

jurídica, fundamentação fática, primeiro e, posteriormente, a fundamentação jurídica.

1.1.3. Devo abrir um tópico para impugnar cada item pedido na reclamação trabalhista?

Sim. É importante (não obrigatório) que, para cada tese a ser discutida na defesa trabalhista, exista um tópico correspondente, de modo a deixar a peça redigida bem organizada, o que facilitará a compreensão e correção da mesma pelo examinador.

EXEMPLO: caso se vá contestar pedido de pagamento de horas extras, seria interessante abrir um tópico **I – DA EXISTÊNCIA DE HORAS EXTRAS**, ou se o pedido a ser contestado é o de vínculo empregatício **II – DA EXISTÊNCIA DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO** e assim por diante.

Cada tópico deverá conter sua própria fundamentação fática e jurídica, acompanhada da menção ao dispositivo da Constituição Federal, da Consolidação das Leis do Trabalho, da legislação esparsa, das Súmulas do STF, STJ e TST, e das Orientações Jurisprudenciais do TST. O conteúdo de cada um desses tópicos deverá, obrigatoriamente, constar no pedido.

2. PRELIMINARES (art. 337 do CPC)

Por força de lei, as preliminares devem ser alegadas antes do mérito, uma vez que o **art. 337, do CPC/15** determina que compete ao réu alegar as preliminares antes de discutir o mérito. Assim, no exame de ordem, na peça profissional de contestação, caso haja preliminares estas devem ser alegadas primeiro e, depois, o mérito. Caso uma preliminar seja levantada dentro do mérito, além do erro grosseiro, existe a possibilidade banca examinadora trabalhista deixar de atribuir a pontuação equivalente.

A defesa processual prevista no **art. 337 do CPC** pode ser composta de:

Art. 337, CPC/15. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

I - inexistência ou nulidade da citação;

II - incompetência absoluta e relativa;

III - incorreção do valor da causa;

IV - inépcia da petição inicial;

V - perempção;

VI - litispendência;

VII - coisa julgada;

VIII - conexão;

IX - incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização;

X - convenção de arbitragem;

- XI - ausência de legitimidade ou de interesse processual;*
- XII - falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar;*
- XIII - indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça.*

Ao ser alegada qualquer das preliminares acima, o pedido final deve ser o acatamento da preliminar com a extinção do feito sem solução de mérito, nos termos **do art. 485 do CPC/15 e incisos**.

Art. 485, CPC/15. *O juiz não resolverá o mérito quando:*

- I - indeferir a petição inicial;*
- II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;*
- III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;*
- IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;*
- V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;*
- VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;*
- VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;*
- VIII - homologar a desistência da ação;*
- IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e*
- X - nos demais casos prescritos neste Código.*

2.1. Inexistência ou nulidade de citação (art. 337, do CPC/15)

Muito se questiona a respeito da diferença entre a citação do processo civil e a notificação do processo do trabalho. Ocorre que não existe diferença nenhuma entre ambas, pois, tanto a citação quanto a notificação significam a primeira comunicação do réu no processo, dando ciência ao mesmo de que contra ele existe uma ação.

No processo do trabalho, a notificação do reclamado ocorre por via postal, através de carta registrada ou carta com franquia ou AR (aviso de recebimento), de modo a tornar o ato processual da notificação mais rápido, atendendo ao *princípio da celeridade no processo do trabalho*. Logo, se uma reclamação trabalhista é proposta, por exemplo, na cidade de Fortaleza, mas o réu se encontra na cidade do Recife, a notificação não será feita por carta precatória, mas por via postal.

Art. 841, CLT- *Recebida e protocolada a reclamação, o escrivão ou secretário, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, remeterá a segunda via da petição, ou do termo, ao reclamado, notificando-o ao mesmo tempo, para comparecer à audiência do julgamento, que será a primeira desimpedida, depois de 5 (cinco) dias.*

§1º - *A notificação será feita em registro postal com franquia. Se o reclamado*

criar embaraços ao seu recebimento ou não for encontrado, far-se-á a notificação por edital, inserto no jornal oficial ou na que publicar o expediente forense, ou, na falta, afixado na sede da Junta ou Juízo.

§2º - O reclamante será notificado no ato da apresentação da reclamação ou na forma do parágrafo anterior.

2.1.1. Casos de nulidade de notificação:

Pelo princípio da aparência, o reclamado foi notificado. Entretanto, o reclamante não agiu com a boa-fé e lealdade processuais exigidas (**art. 77, do CPC/15**), fraudando a notificação e, por causar prejuízo à reclamada, esta deverá, na primeira oportunidade que tiver que falar nos autos (contestação), requerer a nulidade da notificação (**arts. 794 e 795 da CLT**), tornando sem efeito a revelia e a confissão ficta, caso tenham sido aplicadas.

Outro exemplo, é o caso de o processo correr sob o rito sumaríssimo e o juiz determinar a citação por edital. Aplicada a revelia e a confissão ficta, caso o juiz ainda não tenha julgado o processo, o reclamado poderá apresentar contestação a destempo⁴¹, fora da audiência, mas sempre antes da sentença, pois se o juiz já julgou o processo, a nulidade da citação somente seria possível ou em sede de recurso ordinário ou embargos à execução.

2.1.2. O que se deve pedir?

Ao se arguir a nulidade de citação em sede de preliminar, deve-se pedir seu acolhimento com a **declaração da nulidade de citação**. (**arts. 797 e 798 da CLT**).

2.2. Incompetência absoluta (art. 337 inc. II do CPC/15):

Alega-se a preliminar de incompetência absoluta quando a matéria contida na ação (reclamação trabalhista, por exemplo) não está contida nos incisos do **art. 114 da Constituição Federal**⁴². A competência absoluta não pode ser prorrogada de modo que ou a Justiça do Trabalho é ou não é competente para processar e julgar determinada ação. Caso não seja, o juiz, de ofício (**§§ 1º e 2º do art. 795 da CLT**), ou a requerimento da parte (através da preliminar de incompetência absoluta), deverá reconhecer a incompetência e determinar a extinção do feito para ele juiz e a

⁴¹ A contestação no processo do trabalho deve ser apresentada em audiência. No entanto, no caso de revelia pelo não comparecimento na audiência, tendo sido nula a notificação do reclamado e antes do juiz julgar o processo, o reclamado poderá apresentar contestação fora da audiência arguindo nulidade da citação e contestando o mérito. Caso o juiz já tenha julgado o processo, a nulidade da citação somente seria possível ou em sede de recurso ordinário ou embargos à execução.

⁴² Vide capítulo sobre Competência Material da Justiça do Trabalho.

remessa dos autos para a justiça competente.

Ao se fazer uma leitura sobre competência absoluta (material), chega-se à conclusão de que a Justiça do Trabalho é **incompetente** para processar e julgar:

Art. 114, inc. V, CF:

- a) conflitos positivos ou negativos de competência entre um Juiz do Trabalho e Juiz Comum estadual ou federal (art. 105, I, d da CF);
- b) conflitos positivos ou negativos de competência entre um Tribunal Regional do Trabalho e Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal (art. 105, I, d da CF);
- c) conflitos positivos ou negativos de competência entre um Tribunal Superior do Trabalho e Superior Tribunal de Justiça (art. 105, I, d da CF);

Art. 114, inc. VI, CF:

- a) ação acidentária proposta pelo empregado **contra o INSS** (art. 109, I da CF e súmula 15 do STJ);

Art. 114, inc. VIII, CF:

- a) execução de contribuição previdenciária decorrente de lançamento tributário originário de um auto de infração lavrado por **auditor fiscal do INSS**;
- b) execução de contribuição previdenciária do período **reconhecido em sentença**;

Art. 114, inc. IX, CF:

- a) A Justiça do Trabalho **não tem** competência criminal.

2.3. Inépcia da petição inicial (art. 337, IV do CPC):

A petição inicial está inepta quando não está apta a ser processada e, ao final, julgada. Sendo inepta, a petição inicial trabalhista será imediatamente indeferida, sem qualquer possibilidade de emenda ou retificação, nos termos da **súmula 263 do TST**. As hipóteses de inépcia são aquelas previstas no **art. 330, do CPC/15**.

Art. 330, CPC/15. A petição inicial será indeferida quando:

- I - for inepta;
 - II - a parte for manifestamente ilegítima;
 - III - o autor carecer de interesse processual;
 - IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.
- § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:
- I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;
 - II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;
 - III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;
 - IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

2.3.1. Falta pedido ou causa de pedir:

O **§1º do art. 840 da CLT** estabelece como requisitos essenciais da petição inicial trabalhista a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio e o pedido. Assim, a todo pedido feito numa inicial de Reclamação Trabalhista deve ter sua fundamentação fática, que são os motivos, as razões, as circunstâncias e os porquês de cada pedido. Caso seja pedido o pagamento de uma indenização por dano moral, na parte de fundamentação fática e jurídica deve haver a descrição detalhada de um ato ilícito praticado pelo empregador que resultou em prejuízo ao empregado.

Se não houver a descrição de qualquer ato ilícito na reclamação trabalhista, havendo apenas o simples pedido de dano moral, faltou a este a causa de pedir.

Também é possível que depois de toda uma fundamentação fática e jurídica, o autor esqueça ou deixe de fazer o pedido. Nos fatos, narrou o autor que, muito embora tenha mantido com o reclamado vínculo empregatício e trabalhado todo o ano de 2008, nunca lhe foi pago o décimo terceiro salário desse período. No entanto, ao final da petição, não houve pedido do pagamento do décimo terceiro salário de 2008. Se faltou pedido, a petição é inepta.

2.3.2. Da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão:

Em toda petição inicial, entre os fatos narrados e o pedido deve haver uma correlação ou uma relação lógica, pois exige o **art. 330, do CPC/15** que dos fatos narrados deve decorrer logicamente a conclusão. Assim, caso o empregado em sua fundamentação fática e jurídica narre circunstância em que, muito embora, tendo trabalhado todo o período com vínculo empregatício o empregador não lhe pagou o décimo terceiro de 2008 e no pedido requereu o pagamento do décimo terceiro de 2009, faltou conexão entre causa de pedir e o pedido, pelo que a reclamação trabalhista é inepta.

Ainda, se na fundamentação fática o reclamante alega que o empregador nunca reconheceu seu vínculo empregatício e não anotou sua CTPS, caso o empregado queira pedir o pagamento dos direitos e das verbas trabalhistas rescisórias e indenizatórias típicas de um empregado, deverá pedir, primeiro, o reconhecimento do vínculo empregatício. Caso não o faça, sua petição será inepta, pois pedir o pagamento de direito típico de empregado requer o reconhecimento do vínculo. Como o empregador nunca reconheceu, cabe ao empregado pedir o reconhecimento judicial, pois se não houver vínculo, como poderão ser pedidos direitos típicos de empregados? Não há lógica!

2.3.3. O pedido for juridicamente impossível:

Pedido juridicamente impossível é aquele deduzido contra a lei ou sem qualquer sustentação legal. Por exemplo, o pedido de reintegração no emprego de empregado que alega, sem ter, estabilidade ao ser despedido sem justa causa. Se não há previsão de estabilidade para a situação do empregado, não há que se falar em estabilidade e, conseqüentemente, nulidade de sua despedida. Entretanto, de acordo com a *teoria da asserção*, essa preliminar se confundiria com o próprio mérito, motivo pelo qual não poderá mais ser alegada como preliminar, mas como mérito.

2.3.4. Pedidos incompatíveis entre si:

A petição inicial também é inepta quando contiver pedidos incompatíveis entre si, como por exemplo, numa reclamação trabalhista em que se pede a reintegração no emprego e, ao mesmo tempo, a indenização do período estável. Note que, neste caso, o reclamante não está pedindo a reintegração **OU** alternativamente, não sendo possível a reintegração, a indenização do período estável, pois, se assim o fizesse, estaria agindo corretamente.

3. O QUE SE DEVE PEDIR QUANDO A PETIÇÃO FOR INEPTA?

Quando a petição inicial for inepta, deve-se pedir o indeferimento da petição inicial com conseqüente extinção do feito sem solução de mérito, nos termos do **art. 485, do CPC/15**;

3.1. Perempção (art. 337 inc. V do CPC)

Perempção é a perda do direito de reclamar na Justiça do Trabalho pelo prazo de seis meses, nos termos do **art. 731 da CLT**. No processo do trabalho, há dois casos de perempção previstos em lei: o do **art. 731 da CLT** e o do **art. 732 da CLT**.

A perempção prevista no art. 731, da CLT, está ligada aos artigos 840 e 786 e seu parágrafo único também da Consolidação. Quando o reclamante se utilizar de reclamação trabalhista verbal (**art. 840 da CLT**), ela primeiro será distribuída para só então ser reduzida a termo (**art. 786, caput, da CLT**). Uma vez distribuída, da data da distribuição, o reclamante terá o prazo de cinco dias para comparecer à secretaria da Vara do Trabalho para reduzi-la a termo. Caso não o faça dentro do prazo de 05 dias previsto no **parágrafo único do art. 786 da CLT**, incorrerá na pena de perda pelo prazo de seis meses de reclamar contra aquele empregador, com relação àquela causa de pedir e pedido. Caso ingresse com outra reclamação antes, na contestação deverá ser alegada a perempção.

O outro caso é o do **art. 732 da CLT**. Este está ligado aos **arts. 843 e 844 da CLT**. Na Justiça do Trabalho, tanto reclamante quanto reclamado deverão comparecer à audiência, **independentemente** da pessoa de seus representantes (**art. 843 da CLT**). Caso o reclamante não compareça à primeira audiência⁴³, o processo será *arquivado* (**art. 844 da CLT**), fazendo apenas *coisa julgada formal*. Caso queira, no dia seguinte poderá ingressar com a mesma reclamação trabalhista. Designada nova primeira audiência, caso não compareça a esta também, ao reclamante será aplicada a pena do **art. 731 da CLT**, ou seja, a pena de perda pelo prazo de seis meses de reclamar contra aquele empregador, com relação àquela causa de pedir e pedido.



ATENÇÃO: no caso do **art. 732 da CLT**, apenas dois arquivamentos **seguidos** pelo fato de o empregado ter faltado à primeira audiência nas duas vezes que ingressou com reclamação trabalhista (**art. 844 da CLT**) é que gera a perempção. Se o arquivamento for por outro motivo, não. Por exemplo: reclamante falta a primeira audiência, logo, arquivamento de que trata o **art. 844 da CLT**. No dia seguinte, o empregado ingressa com a mesma reclamação, mas antes da audiência atravessa petição requerendo a desistência da ação, o que é homologado pelo juiz, que determina o arquivamento da segunda reclamação. Nesse caso, não houve perempção, pois o segundo arquivamento não foi pelo motivo do **art. 844 da CLT**.

3.2. Litispendência e coisa julgada (**art. 337, VI e VII do CPC**)

Litispendência e coisa julgada são institutos muito parecidos entre si, no entanto, há detalhes que os diferenciam. Tanto a litispendência quanto a coisa julgada, para ocorrerem, dependem da existência de, pelo menos, duas ações idênticas. Nos termos dos **art. 337, §2º, do CPC/15**, uma ação é idêntica à outra quando têm as *mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido*.

Na prática diária da advocacia, é muito comum um empregado ingressar com reclamação trabalhista por intermédio de um advogado e, depois, por não estar satisfeito com seu advogado, procurar outro para ingressar com a mesma reclamação trabalhista. Muitas vezes, isso ocorre quando a primeira reclamação ainda está em curso. Outras vezes, ocorre quando a primeira reclamação já transitou em julgado e o empregado, inconformado, procura outro advogado achando que com este terá mais sorte.

⁴³ Na verdade, por lei, mesmo no procedimento ordinário, temos uma única audiência, então o não comparecimento do reclamante à audiência de julgamento (única nos termos do **art. 849 da CLT**), importaria arquivamento. No entanto, os juízes dividem as audiências em várias sessões, por isso mencionamos “primeira audiência”.

Quando há a interposição de segunda reclamação trabalhista idêntica à primeira que ainda **estava em curso**, a segunda é extinta por litispendência (**art. 337, do CPC/15**).

Quando há a interposição de segunda reclamação trabalhista idêntica à primeira, cuja **sentença já havia transitado em julgado**, a segunda é extinta por coisa julgada (**art. 337, VII do CPC/15**).



ATENÇÃO: existe a possibilidade de, no caso de duas ações, aparentemente não idênticas, a segunda ser extinta por coisa julgada. Imagine que numa determinada reclamação trabalhista sejam pedidos vínculo empregatício e verbas rescisórias e indenizatórias relativas a uma dispensa sem justa causa. Nela é feito um acordo dando ampla e geral quitação. Quando se dá ampla e geral quitação num acordo, as partes não só põe fim ao litígio, mas previnem litígios futuros oriundos da mesma relação jurídica, ou seja, havendo quitação geral, quitam-se o que foi pedido – e o que não foi – relativo àquela relação jurídica litigiosa para nada mais se poder dela reclamar (**art. 840 do CC/02**).



ATENÇÃO REDOBRADA: a litispendência e a coisa julgada podem ser parciais ou totais. Considere uma reclamação trabalhista com pedido de reconhecimento de equiparação salarial, ainda em curso. Em seguida, uma outra reclamação com as mesmas partes, em que o empregado faz o mesmo pedido de equiparação salarial e acrescenta pedido de horas extras. Aparentemente, as ações são diferentes, mas não são. O **art. 327, do CPC/15**⁴⁴ permite a cumulação de pedidos. No caso da segunda reclamação, ao invés de o empregado ingressar com uma segunda reclamação requerendo equiparação salarial e outra pedindo pagamento de horas extras, como os dois pedidos foram feitos contra o mesmo reclamado, oriundos da mesma relação de emprego, por que não os juntar num só? E isso foi feito.

Assim, uma mesma ação com dois ou mais pedidos, na verdade, poderia ser dividida em várias ações. Ou, por conexão, várias ações com as mesmas partes e a mesma causa de pedir, mas com pedidos diferentes, poderiam ser reunidas numa única ação, até por economia processual, pois em processo, cada pedido corresponde a uma ação. Logo, a primeira reclamação em que foi pedida a equiparação salarial é idêntica à parte da segunda reclamação em que também foi pedida equiparação salarial, devendo a segunda, quanto ao pedido de equiparação, ser extinta por litispendência ou coisa julgada, dependendo do caso de a primeira

⁴⁴ Vide capítulo sobre reclamação trabalhista, especialmente a parte sobre pedidos.

ação estar em curso ou já com decisão transitada em julgado.

3.3. Conexão e continência (art. 337, VIII do CPC/15):

Em que pese toda a divergência doutrinária sobre o assunto, será estabelecida aqui uma diferença entre conexão e continência, ambas preliminares de contestação.

3.3.1. Continência:

Nos termos do **art. 56, do CPC/15**, dá-se a continência entre duas ou mais ações sempre que há identidade quanto às partes e a causa de pedir, mas o objeto de uma, por ser mais amplo, abrange o das outras. Na continência, as ações têm que ter, necessariamente, as mesmas partes, mas o pedido de uma acaba englobando o pedido da outra. Tome-se como exemplo o fato de o empregado A ingressar com reclamação trabalhista contra a empresa B.

Na primeira ação, o empregado está pedindo a *nulidade de uma cláusula de seu contrato por prazo determinado*, que diz que o empregado contratado a termo ganhará menos que os empregados cujos contratos são por prazo indeterminado na mesma empresa.

Tempos depois, ingressa o mesmo empregado A contra o mesmo empregador B com reclamação trabalhista em que requer, agora, a nulidade de todo o contrato de trabalho por prazo determinado, uma vez que sua celebração não se adequou às condições previstas no **§2º do art. 443 da CLT**. Note que ao se pedir na segunda reclamação a nulidade de todo o contrato, a nulidade da cláusula contratual objeto da primeira reclamação estará implícita naquele pedido, de modo que as ações são continentes por terem as mesmas partes e a mesma causa de pedir remota (mesma relação de emprego) e a fim de se evitar decisões contraditórias, pois o mérito de uma influência no mérito da outra, devem ser julgadas juntas.

Haverá continência entre duas ações quando o pedido de uma, ao ser julgado, puder causar a perda do objeto da outra.

3.3.1.1. Qual o procedimento?

Caso as duas reclamações tenham sido distribuídas para varas distintas, por exemplo, a primeira reclamação pedindo a nulidade da cláusula foi distribuída para a 1ª Vara do Trabalho de Fortaleza e a segunda reclamação, pedindo a nulidade de todo o contrato para a 10ª Vara do Trabalho da mesma Cidade, apenas uma das varas será a competente. E qual a Vara competente? A do juízo prevento. E qual o juízo prevento? Aquele a quem foi distribuída a primeira reclamação, nos termos do **inc. IV da OJ 130, SDI-2, TST**.

Se a primeira ação distribuída foi a da nulidade da cláusula, o juízo prevento é o da 1ª Vara do Trabalho, de modo que a segunda reclamação que está na 10ª Vara será suspensa (**art. 330, do CPC/15**) e remetida para a primeira quando deverá voltar ao curso normal.

3.3.2. Conexão:

Nos termos do **art. 55, do CPC/15**, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o objeto OU a causa de pedir. Entenda-se aqui por objeto como sendo o pedido. Logo, conexas são as ações que tem o mesmo pedido OU causa de pedir. A doutrina majoritária é no sentido de que ações conexas podem ter as mesmas partes ou não, desde que lhes sejam comuns o pedido OU a causa de pedir. Em havendo conexão, o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, ordenará a reunião das ações propostas separadas, a fim de que sejam julgadas simultaneamente (**arts. 56 e 57 do CPC/15**).

A reunião das ações pode ser obrigatória - de modo a se evitar julgamentos contraditórios quando o mérito de uma ação interferir no mérito da outra - ou a reunião pode ser facultativa, que se dá no caso de se querer atender a economia e celeridade processuais.

É possível, portanto, que duas ações com partes diferentes sejam conexas. Por exemplo, em determinada reclamação que tem como partes o empregado A e o empregador B, o empregado alega que quando de sua admissão lhe foi entregue computador pelo empregador para a prestação dos respectivos serviços. No entanto, o valor do computador foi descontado de seus salários, pelo que é de propriedade do empregado. Quando de sua demissão, o empregador reteve o computador alegando ser instrumento de trabalho de propriedade da empresa. Na reclamação trabalhista, A e B reclamam a propriedade do aparelho. Ação distribuída para a 1ª Vara do Trabalho de Recife.

Ocorre que, o empregador B admitiu outro empregado, C, e entregou a ele o mesmo computador objeto do litígio do parágrafo anterior. Descontou de seus salários o valor do computador. Quando da demissão do empregado C, reteve o computador sob a mesma alegativa: era instrumento de trabalho e propriedade da empresa. O empregado C ingressa com ação contra B reclamando a propriedade do computador. Ação distribuída para a 10ª Vara do Trabalho de Recife.

No caso, os pedidos de ambas as reclamações são idênticos: a propriedade do computador, apesar de as partes serem diferentes. Caso as ações permaneçam em Varas do Trabalho distintas, é possível que haja decisões contraditórias, pois o juiz da 1ª Vara pode julgar procedente o processo em favor do empregado A e o da 10ª Vara

poderá julgar em favor do empregado C e não se saberia a quem pertenceria realmente o computador. Note que o mérito de uma ação influencia o mérito da outra e a permanência em Varas distintas poderia gerar decisões conflitantes e levar ao descrédito o Poder Judiciário, o que torna a reunião das ações, neste caso, obrigatória, podendo ser conhecida de ofício pelo juiz.

Um outro caso de conexão em que as partes são distintas se dá na *reclamatória trabalhista plúrima* prevista no **art. 842 da CLT**. No caso, sendo várias as reclamações e havendo identidade de matéria, poderão ser acumuladas num só processo, se se tratar de empregados da mesma empresa ou estabelecimento.

Imagine que empregados de determinada empresa trabalham em ambiente insalubre, mas nunca receberam o respectivo adicional. Tais empregados, em número de dez, por exemplo, apresentam cada um uma reclamação trabalhista em que pleiteiam o pagamento do adicional de insalubridade, distribuídas ou não para varas distintas. Como a perícia é obrigatória para a averiguação da insalubridade (**§2º do art. 195 da CLT**), sendo empregados da mesma empresa requerendo judicialmente insalubridade, por trabalharem no mesmo ambiente (mesma matéria), a fim de evitar a realização de dez perícias no mesmo local e para a mesma finalidade (insalubridade), um dos juízes, sabendo da existência dos demais processos, conhece a conexão e determina a reunião das ações, tendo como juízo preventivo aquele a quem foi distribuída a primeira ação (**inc. IV da OJ 130 da SDI-2 do TST**).

Neste caso, a conexão foi reconhecida, mas a reunião dos processos é facultativa, pois o mérito de uma não influenciaria no mérito das demais, de modo que apenas por uma questão de celeridade e economicidade processuais os processos foram reunidos.

3.4. Incapacidade da parte, defeito de representação e falta de autorização (art. 337, IX do CPC/15):

3.4.1. Incapacidade da parte:

A incapacidade da parte, processualmente considerada, está ligada à capacidade processual da parte, ou seja, a capacidade de a parte estar em juízo praticando sozinho atos processuais. O **art. 793 da CLT** determina que a reclamação trabalhista do menor de 18 anos será feita por seus representantes legais e, na falta destes, pela Procuradoria da Justiça do Trabalho, pelo sindicato, pelo Ministério Público estadual ou curador nomeado em juízo.

Entretanto, a problemática não é bem a idade mínima limite para a prática de atos processuais sem assistência ou representação, que é a partir dos 18 anos, mas a

idade mínima legal para que o menor de 18 seja assistido e idade máxima para que seja representado. No processo civil, as idades seriam: maior que 16 e menor que 18 anos, que seria assistido; e menor de 16 anos, representado. No processo do trabalho, a sistemática será diferente: só o representante.

A diferença de idade limite do processo civil (16 anos) para o processo do trabalho (14 anos) se dá em decorrência da impossibilidade de se aplicar a regra do Direito Civil, neste particular, ao Direito do Trabalho porque a CLT não é omissa, pois em seu **art. 402** estabelece que *se considera menor, para os efeitos desta Consolidação, o trabalhador de quatorze até dezoito anos de idade*. Apesar de a regra contida do art. 402 da CLT ser de direito material e não processual, mas no campo processual terá efeitos, pois a idade ali estabelecida foi para os efeitos de toda a Consolidação, que vai do **art. 1º até o art. 922**, englobando a parte material e processual da CLT, e não apenas para o CAPÍTULO IV – DA PROTEÇÃO DO TRABALHO DO MENOR.

Logo, caso um menor de 18 anos de idade queira ingressar com uma reclamação trabalhista, o fará assistido por seu pai ou responsável ou por qualquer das pessoas previstas no **art. 793 da CLT**.

3.4.1.1. O que se deve pedir?

Na preliminar de incapacidade da parte, ao final da argumentação, deve-se pedir a suspensão do processo para que o defeito seja sanado (**art. 76 do CPC e súmula 263 do TST**) e, caso não sanado, sua nulidade, nos termos do **art. 76, do CPC/15**, cumulado com os **arts. 794 e 795 da CLT**.

3.4.2. Defeito de representação:

O defeito de representação está ligado à capacidade postulatória prevista no **art. 791 da CLT**. Como no processo do trabalho vige o *jus postulandi*, em que tanto empregado quanto empregador poderão reclamar pessoalmente e acompanhar o processo até o final, sem assistência ou representação por advogado, sendo este final até o recurso ordinário da Vara do Trabalho para o Tribunal Regional do Trabalho (**súmula 425, TST**), não é muito comum este tipo de preliminar em uma contestação trabalhista.

No entanto, ao optar a parte pela representação ou assistência por advogado ou sindicato profissional, deverá outorgar poderes de procuração a seu representante ou assistente. Caso não o faça, este dito representante ou assistente estará irregular de representação. As **Súmulas 395 e 456 do TST e a OJ 200 da SDI-1 do TST**, trazem consigo algumas possibilidades de se alegar em sede de preliminar de

contestação:

Súmula 395, TST

Diante da existência de previsão, no mandato, fixando termo para sua juntada, o instrumento de mandato só tem validade se anexado ao processo dentro do aludido prazo;

Ocorre no caso de o outorgando estabelecer na procuração prazo para que a mesma seja juntada aos autos do processo. Caso esta data seja ultrapassada, a procuração perde sua validade e o representante está irregular de representação.

Súmula 395, TST

São válidos os atos praticados pelo substabelecido, ainda que não haja, no mandato, poderes expressos para substabelecer;

Caso a procuração vede, expressamente, o substabelecimento, caso esta cláusula seja descumprida e se substabeleça a outro advogado e este compareça à audiência, estará irregular de representação.

OJ 200 SDI-I, TST

É inválido o substabelecimento investido em mandato tácito.

Também não é possível o substabelecimento quando o mandato for tácito, acarretando também a irregularidade de representação para quem descumpra a norma:

Súmula 395, TST

*Configura-se a **irregularidade de representação** se o substabelecimento é anterior à outorga passada ao substabelecido.*

Aqui a irregularidade ocorre quando são substabelecidos poderes de um advogado para outro e aquele que substabeleceu sequer tinha procuração. O substabelecido, ao comparecer à audiência, estará irregular de representação.

SUM. 456, TST - REPRESENTAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. PROCURAÇÃO. INVALIDADE. IDENTIFICAÇÃO DO OUTORGANTE E DE SEU REPRESENTANTE. (Inseridos os itens II e III em decorrência do CPC de 2015) - Res. 211/2016, DEJT divulgado em 24, 25 e 26.08.2016

*I - É inválido o instrumento de mandato firmado em nome de pessoa jurídica que não contenha, pelo menos, o **nome do outorgante e do signatário da procuração**, pois estes dados constituem elementos que os individualizam.*

II – Verificada a irregularidade de representação da parte na instância originária, o juiz designará prazo de 5 (cinco) dias para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação, extinguirá o processo, sem resolução de mérito, se a providência couber ao reclamante, ou considerará revel o reclamado, se a providência lhe couber (art. 76, § 1º, do CPC de 2015).

*III – Caso a irregularidade de representação da parte seja constatada em fase recursal, o relator designará prazo de 5 (cinco) dias para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação, o relator **não conhecerá do recurso**, se a providência couber ao recorrente, ou determinará o **desentranhamento das contrarrazões**, se a providência couber ao recorrido (art. 76, § 2º, do CPC de 2015).*

No caso de o reclamante ser uma pessoa jurídica, como nas ações de consignação em pagamento ou inquérito judicial para apuração de falta grave, não apenas a pessoa jurídica, como seu representante legal devem estar qualificados na procuração. A ausência da qualificação ou de um ou do outro acarretará a irregularidade de representação por advogado.

3.4.2.1. O que se deve pedir?

Na preliminar de irregularidade de representação, ao final da argumentação, deve-se pedir a suspensão do processo para que o defeito seja sanado (**art. 76 do CPC e súmula 263 do TST**) e, caso não sanado, sua nulidade, nos termos do art. 76, do CPC/15, cumulado com os **arts. 794 e 795 da CLT**.

3.4.3. Falta de autorização:

A falta de autorização está ligada ao fato de que, em determinadas situações, a lei exige autorização para que uma pessoa pleiteie direito alheio em nome próprio, o que seria um caso de legitimação extraordinária ou substituição processual. No entanto, no processo do trabalho, os sindicatos e o Ministério Público do Trabalho (**arts. 127 e 129, inciso IX da Constituição Federal**), quando atuam como substitutos processuais⁴⁵, não dependem de qualquer autorização, o que torna difícil a existência dessa preliminar no processo do trabalho.

3.5. Convenção de arbitragem (art. 337, do CPC/15)

A convenção de arbitragem hoje é possível nos casos em que o empregado expressamente concorde em resolver seu litígio no Juízo Arbitral e desde que a remuneração do empregado seja superior a duas vezes o limite máximo de benefícios da Previdência Social, nos termos do art. 507-A da CLT;

Art. 507-A. *Nos contratos individuais de trabalho cuja remuneração seja superior a duas vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, poderá ser pactuada cláusula compromissória de arbitragem, desde que **por iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância expressa**, nos termos previstos na Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996.*

⁴⁵

Portanto, caso o empregado se enquadre na hipótese do art. 507-A da CLT, e tenha se comprometido a resolver qualquer litígio trabalhista perante o Juízo Arbitral, caso desrespeite a cláusula e ingresse com reclamação trabalhista, sua ação deverá ser extinta sem solução de mérito, por falta de interesse de agir.

3.6. Carência de ação

A carência de ação está ligada às condições da ação que são, nos termos do **art. 485, do CPC/15**: legitimidade das partes, possibilidade jurídica do pedido e interesse de agir. Para que o autor tenha seu direito de ação assegurado é preciso que apresente as três condições juntas. Caso falte qualquer uma delas, será carecedor de ação.

3.6.1. Legitimidade das partes:

Nos termos do **art. 17, do CPC/15** para propor ou contestar a ação é preciso ter legitimidade. Para que se tenha legitimidade para a propositura da ação, é preciso que o autor seja o titular do direito violado ou ameaçado de violação. Uma vez violado o direito ou ameaçado de violação, surge para o titular do direito lesado, o direito de ação contra aquele que promoveu a violação ou ameaça. Aquele que promoveu a violação ou ameaça deve contestar a ação contra si proposta. Assim, temos as partes legítimas de um processo.

No processo do trabalho, podemos dizer de forma grosseira, que parte legítima para propor ou contestar uma ação é quem, numa determinada relação jurídica, é empregado ou empregador ou tem responsabilidade solidária ou subsidiária. Logo, quem, numa determinada relação jurídica, não é nem empregador, nem empregado, nem tem responsabilidade solidária ou subsidiária é parte ilegítima seja para propor ou para contestar uma ação.

Os casos mais comuns – **não os únicos** – de ilegitimidade passiva ou ativa são: dono da obra (**OJ 191 do TST**), administração pública na terceirização, sucessão em grupo econômico e sócio excluído de sociedade.

a) Dono da obra (OJ 191, SDI-1, TST):

No caso do dono da obra, por falta de disposição legal, este não tem responsabilidade nem solidária, tampouco subsidiária pelos créditos trabalhistas dos empregados do empreiteiro principal ou subempreiteiro, salvo no caso de o dono da obra ser construtor ou incorporador.

Neste último caso, o dono da obra construiria a obra ou financiaria sua

construção com o intuito de lucro, ou seja, venderia ou alugaria a obra, auferindo renda ou lucros com a obra em si e, aqui, teria responsabilidade solidária⁴⁶. Quando constrói ou financia a construção para uso próprio, utilizando-a como destinatário final, não tem qualquer responsabilidade.

b) Administração pública na terceirização:

Quando a administração pública direta ou indireta terceiriza serviços na qualidade de tomador, não tem qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária pelos créditos trabalhistas dos empregados que ficaram à sua disposição, nos termos do **§ 1º do art. 71 da Lei 8.666/93, ADC nº 16 do STF e súmula 331 inciso V do TST**.

A responsabilidade da administração só se dá quando concorrem duas situações: **1)** falta de pagamento dos créditos trabalhistas por parte do empregador (empresa prestadora de serviços); **2)** falta de fiscalização por parte da administração pública na execução do contrato de prestação de serviços, principalmente no que respeita ao pagamento dos trabalhadores que ficaram à sua disposição.

Fora dessas duas possibilidades, não há que se falar em responsabilidade da administração pública.

c) Sucessão em grupo econômico:

Em se tratando de grupo econômico, a responsabilidade das empresas do grupo entre si e para com a empresa principal pelos créditos trabalhistas de seus empregados é solidária. No entanto, quando uma **empresa estranha ao grupo econômico adquire**, compra, sucede uma das empresas do grupo, **não há qualquer responsabilidade da que comprou** (sucessora) pelos créditos dos empregados das demais empresas que continuam no grupo.

No entanto, há uma **exceção**: se à época da compra, aquisição (sucessão) de uma das empresas do grupo econômico por empresa estranha ao grupo, uma das empresas pertencentes ao grupo era insolvente ou inidônea financeiramente, a empresa sucessora (a que comprou) responde solidariamente pelos créditos dos empregados do grupo, nos termos da **OJ 411 da SDI-1 do TST**.

d) Sócio excluído da sociedade:

Nos termos do **art. 1032 do Código Civil e o art. 10-A da CLT**, o sócio excluído da sociedade somente tem responsabilidade pelos débitos da sociedade até o limite de dois anos após a averbação de sua saída da sociedade. Ultrapassado o

⁴⁶...

prazo de dois anos da averbação de sua saída, não tem qualquer responsabilidade.

Caso ainda haja responsabilidade do sócio retirado, como na hipótese de não terem se passado dois anos de tal formal exclusão da sociedade, deve-se obedecer à seguinte ordem de preferência na execução, nos termos do art. 10-A da CLT:

Art. 10-A. O sócio retirante **responde subsidiariamente** pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, observada a seguinte **ordem de preferência**:

I - a empresa devedora;

II - os sócios atuais; e

III - os sócios retirantes.

Parágrafo único. O sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando ficar comprovada fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato.

3.6.1.1. O que devo pedir?

Na preliminar de ilegitimidade da parte, ao final da argumentação, deve-se pedir a extinção do feito sem solução de mérito, nos termos do **art. 485, do CPC/15**.

3.6.2. Impossibilidade jurídica do pedido

Pedido juridicamente impossível é aquele deduzido contra a lei ou sem qualquer sustentação legal, como por exemplo, o pedido de reintegração no emprego de empregado que alega, sem ter, estabilidade ao ser despedido sem justa causa. Se não há previsão de estabilidade para a situação do empregado, não há que se falar em reintegração e, conseqüentemente, nulidade de sua despedida. Entretanto, de acordo com a *teoria da asserção*, essa preliminar se confundiria com o próprio mérito, motivo pelo qual não poderia ser alegada como preliminar, mas como mérito.

Diante do fato de que, pela teoria da asserção, um pedido juridicamente impossível se confundiria com o mérito, afasta-se, em tese, sua alegação em sede de preliminar.

3.6.3. Falta de interesse de agir

O interesse de agir está ligado a duas situações: existência de uma lesão ou ameaça de lesão e adequação da lide à ação.

Só há direito de ação para alguém se o direito deste alguém tiver sido violado ou ameaçado de violação. No entanto, saber se o direito foi ou não violado,

na maioria das vezes, depende de uma maior cognição do juiz, ou seja, um maior aprofundamento do juiz na análise dos fatos que sustentam a causa, impossibilitando que aprecie a situação imediatamente. Pela asserção, ao se confundir com o mérito, pois merecedora de análise mais profunda, prejudicada estaria sua alegativa como preliminar.

A adequação da lide à ação reside no fato de que cada pedido corresponde a uma ação. Assim, se se vai pedir depósito com efeito de pagamento, não se pode pedir em reclamação trabalhista, mas em ação própria prevista em lei, qual seja, a ação de consignação em pagamento (**art. 539 e 540, do CPC/15**).

Logo, o interesse de agir está não apenas em se saber se houve ou não lesão ou ameaça de lesão, mas, em havendo a lesão ou ameaça, se utilizar a ação correta. Como o interesse requer os dois requisitos, cumulativamente, a impossibilidade de se apreciar preliminarmente apenas um deles já inviabiliza o outro, pelo que, mais uma vez pela *teoria da asserção*, a falta de interesse de agir, por, na maioria das vezes, se confundir com o mérito, deverá ser alegada como mérito e não preliminar.

3.7. Falta de caução ou de outra prestação que a lei exija como preliminar (art. 337, do CPC/15)

Não cabe no processo do trabalho.

QUADRO DE PRELIMINARES: ART. 337 DO CPC	
PRELIMINAR	O QUE PEDIR
Art. 337, inc. I CPC: inexistência ou nulidade de citação; - citação por edital em procedimento sumaríssimo; - citação por edital quando o reclamado encontra-se em local não servido pelos correios; - citação na pessoa de incapaz; - conluio entre o reclamante e quem recebeu a citação/notificação	Na contestação pedir a designação de nova audiência para apresentação de defesa, art. 796, “a” CLT. Em sede de recurso o retorno dos autos à Vara para apresentação de defesa, art. 796, “a” CLT. Em sede de embargos à execução a extinção da execução sem solução de mérito, art. 485, inc. IV CPC.

Art. 337, inc. II CPC: incompetência absoluta; - ações de servidores públicos estatutários (art. 114, inc. I CF e ADIn 3.395-6 STF); - ações de servidores públicos temporários (art. 114, inc. I CF); - ações de profissionais liberais (art. 114, inc. I CF e súmula 363 STJ); - conflito de competência entre órgãos da justiça do trabalho e órgãos da justiça comum (art. 114, inc. V CF); - contribuição previdenciária de todo o período trabalhado (súmula 368, I TST; súmula 53, STF) - ações criminais (art. 114, inc. IX CF); - ações acidente de trabalho julgadas antes da emenda 45/04 (súmula vinculante 22 STF). Art. 337, inc. II CPC: incompetência relativa; - regra geral: local da prestação de serviços (art. 651, CLT); - empregado vendedor viajante, agente comercial (art. 651, § 1º CLT); - empregado contratado no Brasil para prestar serviços em agência ou filial da empresa contratante no estrangeiro (art. 651, § 2º CLT); - empregado em atividade itinerante (art. 651, 3º CLT)	Reconhecimento da incompetência e remessa do processo para o juízo ou justiça competente art. 795 § 2º CLT.
---	--

Art. 337, inc. III CPC: incorreção do valor da causa; - procedimento sumário (Lei 5.584/70); - procedimento sumaríssimo (art. 852-A e parágrafo único CLT).	Correção do valor da causa pelo juiz art. 2º § 1º da Lei 5.584/70.
Art. 337, inc. IV CPC: inépcia da petição inicial; - falta de pedido (art. 330, inc. I CPC); - falta de causa de pedir (art. 330, inc. I CPC); - narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão (art. 330, inc. III CPC); - pedido indeterminado (art. 330, inc. II CPC); - pedidos incompatíveis entre si (art. 330, inc. IV CPC).	Extinção do feito sem solução de mérito, art. 485, inc. I CPC.
Art. 337, inc. V CPC: perempção; - reclamação não reduzida a termo no prazo; - segunda ausência injustificada à primeira audiência.	Extinção do feito sem solução de mérito, art. 485, inc. V CPC.
Art. 337, inc. VI CPC: litispendência; - ações idênticas: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, art. 337, §§ 1º, 2º, 3º e 4º CPC; - litispendência total e parcial;	Extinção do feito sem solução de mérito, art. 485, inc. V CPC.
Art. 337, inc. VII CPC: coisa julgada; - ações idênticas: mesmas partes,	Extinção do feito sem solução de mérito, art. 485, inc. V CPC.

mesma causa de pedir e mesmo pedido, art. 337, §§ 1º, 2º, 3º e 4º CPC; - coisa julgada total e parcial; - acordo judicial em que se dá ampla e geral quitação (art. 840 C.C. e OJ 132 SDI-2 TST);	
Art. 337, inc. VIII CPC: conexão (e continência); - reclamação trabalhista e ação de consignação em pagamento; - quando o mérito de uma ação tiver relação com o mérito de outra ação;	Suspensão do processo art. 313, V, “a” CPC e remessa para o juízo prevento, arts. 55, § 1º, 58 e 59 CPC e OJ 130, inc. IV SDI-2 TST.
Art. 337, inc. IX CPC: incapacidade da parte; - reclamação trabalhista de menor de 18 anos de idade (art. 793 CLT);	Suspensão do processo arts. 76 e 313, inc. I CPC e nomeação de representante ou curador art. 72, inc. I CPC.
Art. 337, inc. X CPC: convenção de arbitragem; - não é possível em dissídio individual porque os direitos individuais são indisponíveis; - só é possível em dissídio coletivo: caso o dissídio coletivo não tenha passado primeira pela tentativa de negociação, inclusive, se for o caso, negociação arbitral, o dissídio coletivo é extinto (art. 114 § 2º CF;	Extinção do feito sem solução de mérito, art. 485, inc. VII CPC.
Art. 337, inc. XI CPC: ausência de legitimidade; - dono da obra (OJ 191 SDI-1 TST e art. 455 CLT);	Extinção do feito sem solução de mérito, art. 485, inc. VI CPC.

- administração pública na terceirização (ADC 16 STF, § 1º art. 71 da Lei 8.666/93 e súmula 331 inc. V TST); - sucessão pela compra de empresa pertencente à grupo econômico (OJ 411 SDI-1 TST); - sócio excluído formalmente da sociedade há mais de dois anos (art. 1.032 C.C; art. 10-A, CLT.); - segunda concessionária por débitos anteriores à concessão dos serviços públicos (OJ 225, inc. I SDI-1, TST); Art. 337, inc. XI CPC: ausência de interesse processual; - acordo em comissão de conciliação prévia (art. 625-E CLT) - quitação passada no sindicato sem ressalva (súmula 330 TST)	
Art. 337, inc. XII CPC: falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar; - não se aplica ao processo do trabalho uma vez que como o empregado, via de regra, é pobre na forma da lei, não tem como prestar caução real ou fidejussória quando da antecipação de tutela antes da sentença, motivo pelo qual os juízes do trabalho evitam o levantamento liminar de valores pelo empregado-reclamante;	Extinção do feito sem solução de mérito, art. 485, inc. IV CPC.
Art. 337, inc. XIII CPC: indevida concessão do benefício de	Condenação do reclamante ou reclamado ao pagamento das custas

gratuidade de justiça; - benefício da justiça gratuita pode ser concedido em qualquer juízo, instância ou grau de jurisdição a requerimento da parte ou de ofício pelo juiz (art. 790 § 3º CLT);	processuais, art. 789 §§ 1º, 2º e 3º CLT.
Art. 852-B, inc. I CLT: falta de pedido líquido no rito sumaríssimo; - no procedimento sumaríssimo todo pedido deve ser certo ou determinado e indicar o valor correspondente;	Condenação do reclamante nas custas processuais, art. 852-B, inc. I, CLT e arquivamento, art. 852-B, §1º, CLT.
Art. 59, CPC: prevenção; - quando duas ou mais ações forem conexas ou continentes entre si (art. 286 inc. I CPC); - quando já tiver sido extinta ação sem solução de mérito e depois proposta ação idêntica, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda (art. 286 inc.II CPC); - quando processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles (art. 55 § 3º CPC);	Remessa do processo ao juízo prevento, arts. 58 e 59 CPC.
Art. 330, CPC: indeferimento da petição inicial; - ausência de endereçamento (art. 319, I CPC); - ausência de qualificação completa	Extinção do feito sem solução de mérito, art. 485, inc. IV CPC.

(art. 319, II CPC); - ausência de documento indispensável à propositura da ação (art. 320 CPC). - ausência de documento indispensável ao processamento do mandado de segurança (súmula 415 TST); - ausência de documento (certidão) que comprova o trânsito em julgado da decisão que se quer rescindir, decisão rescindenda (súmula 299, inc. II TST);	
--	--

PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA	
PREJUDICIAL	O QUE PEDIR
Art. 7º inc. XXIX CF: prescrição bienal; - reclamação trabalhista proposta mais de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;	Extinção do feito com solução de mérito, art. 487 inc. II CPC.
Art. 7º inc. XXIX CF: prescrição quinquenal parcial - reclamação trabalhista requerendo direitos trabalhistas anteriores a cinco anos da data da propositura da reclamação (súmula 308, inc. I TST);	Extinção do feito com solução de mérito dos pedidos anteriores a cinco anos da data da reclamação, art. 487 inc. II CPC.
Art. 7º inc. XXIX CF: prescrição quinquenal total - reclamação trabalhista proposta depois de cinco anos da data da alteração do contrato de trabalho	Extinção do feito com solução de mérito do direito oriundo da alteração contratual, art. 487 inc. II CPC.

(súmula 294 TST);	
Decadência - prazo de trinta dias para o inquérito judicial para apuração de falta grave (art. 853 CLT, súmula 403 STF e súmula 62 TST); - prazo de dois anos para propositura de ação rescisória (art. 975 CPC); - prazo de cento e vinte dias para impetração de mandado de segurança (Lei 12.016/09 art. 23);	Extinção do feito com solução de mérito pela perda do direito material envolvido na ação, art. 487 inc. II CPC.

4. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA

A vara competente para processar e julgar uma reclamação trabalhista, regra geral, é a vara do local da prestação de serviços, ainda que o contrato tenha sido firmado em outro local. O empregado se estabelece no local da prestação de serviços.

Art. 651, CLT. *A competência das Juntas de Conciliação e Julgamento é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado noutra local ou no estrangeiro.*

No entanto, temos exceções a essa regra. A primeira delas é a hipótese do empregado comercial (vendedor) que trabalha viajando. Se essa regra especial do **§1º do Art. 651 da CLT** não existisse, esse profissional cairia na hipótese do §3º desse mesmo artigo, mas existe. Logo, é competente a vara do local onde haja agência ou filial da empresa ou, não havendo, no local do domicílio do empregado ou local mais próximo.

Art. 651, CLT

§1º *Quando for parte no dissídio agente ou viajante comercial, a competência será da Junta da localidade em que a empresa tenha **agência ou filial** e a esta o empregado esteja subordinado e, na falta, será competente a Junta da localidade em que o empregado tenha domicílio ou a localidade mais próxima.*
§2º *A competência das Juntas de Conciliação e Julgamento, estabelecida neste artigo, **estende-se** aos dissídios ocorridos em agência ou filial no estrangeiro, desde que o empregado seja brasileiro e não haja convenção internacional*

dispondo em contrário.

A vara do trabalho brasileira é a competente, mas o artigo não estabeleceu qual a competência.

A exceção de incompetência é uma peça separada ou à parte da contestação e que deve ser apresentada em até cinco dias da data da notificação do reclamado, havendo suspensão do processo. Recebida a peça de exceção de incompetência relativa, o juiz abrirá vistas à parte contrária para manifestação e, em seguida, proferirá decisão. Caso acolha a exceção, determinará a remessa dos autos à Vara competente. Caso rejeite a exceção, o processo seguirá seu curso normal até a audiência prevista no art. 843 da CLT.

Atividade Itinerante é aquela que só se desenvolve, ou melhor se desenvolve, com a mudança do local da prestação de serviços. Neste caso, diferentemente do **caput do Art. 651**, o empregado não se estabelece no local da prestação de serviços.

Art. 651, CLT

§3º *Em se tratando de empregador que promova realização de atividades fora do lugar do contrato de trabalho, é assegurado ao empregado apresentar reclamação no foro da celebração do contrato ou no da prestação dos respectivos serviços.*

5. COMPENSAÇÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA

Compensar significa abater um crédito de outro crédito existente.



Atenção: a compensação ou retenção somente pode ser alegada como matéria de defesa. É o que dispõe o **Art. 767 da CLT**. A **súmula 48, do TST** traz, ainda, que a compensação somente poderá ser arguida na contestação.

É perfeitamente possível que o empregador adiante ao empregado verba salarial, sendo possível a compensação, desde que alegada na contestação.

SUM-18, TST. COMPENSAÇÃO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 *A compensação, na Justiça do Trabalho, está restrita a dívidas de natureza trabalhista.*

A compensação pode ser judicial, feita na justiça do Trabalho:

Art. 767, CLT. *A compensação, ou retenção, só poderá ser arguida como matéria de defesa.*

SUM-48, TST. COMPENSAÇÃO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 A compensação só poderá ser arguida **com a contestação**.

Ou a compensação será extrajudicial, feita fora da justiça do trabalho, no momento do pagamento das verbas rescisórias:

Art. 477, CLT

§5º Qualquer compensação no pagamento de que trata o parágrafo anterior **não poderá exceder o equivalente a um mês de remuneração do empregado**.

Só cabe compensação entre créditos trabalhistas (**Súmula 18 do TST**)

6. PRESCRIÇÃO

Definição: é uma limitação temporal ao exercício do direito de ação.

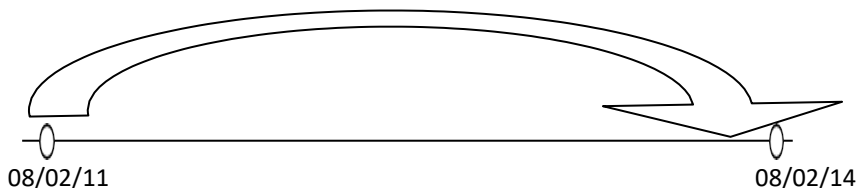
O direito de ação (*actio nata*) nasce quando você passa a ter interesse de agir, ou seja, quando há lesão ou ameaça de lesão ao seu direito.

Regra geral, existe um prazo previsto em lei para se buscar o direito violado, para se exercer o direito de ação. Trata-se do prazo prescricional. Juntamente com o direito de ação, nasce a prescrição, ou seja, o prazo para exercê-lo. Ultrapassado este, há a perda do direito de ação.

Exemplos:

1. No Direito Civil:

Evento danoso ocorre em 08/02/11. Reparação civil extracontratual (prazo prescricional de 03 anos). Prescrição em 08/02/14. Até esta data é possível ajuizar ação requerendo a reparação do dano ocorrido naquela data.



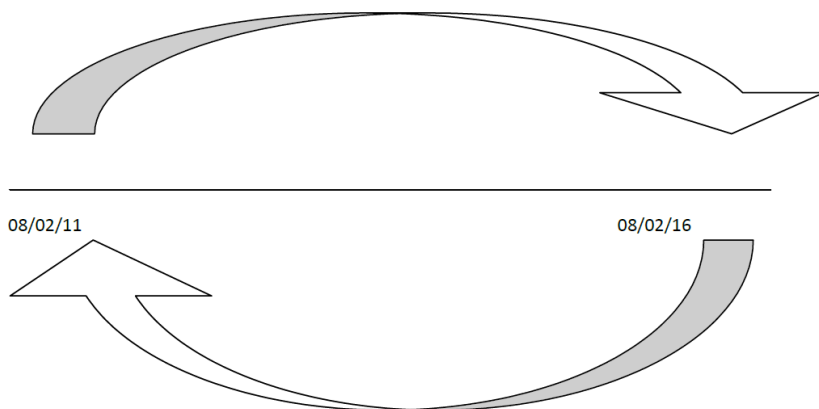
2. **No Direito do Trabalho:** temos dois prazos prescricionais (de 02 e 05 anos)

Art. 7º, CF/88

XXIX – ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;

Enquanto não houver extinção do contrato, só deve ser observada a prescrição quinquenal.

Do dia do evento danoso tem-se **05 anos** para ajuizar a ação. Inicia-se o prazo a partir do evento danoso. Da data de ajuizamento da ação, pode-se buscar até **05 anos** antes. Havendo rescisão do contrato, aí sim se observa o prazo prescricional bienal.



Evento danoso ocorre em 08/02/11. Em tese, a prescrição será em 08/02/16. Isso se não houver rescisão neste lapso temporal. Se, no entanto, houver rescisão nesse período, a prescrição se reduz para 02 anos após a extinção.

Assim, no exemplo dado, havendo rescisão em 15/04/11, é possível ajuizar a ação até 15/04/13. No entanto, neste caso, somente será possível requerer direitos que foram violados até cinco anos antes.

Logo, uma prescrição PODERÁ anular a outra, visto que, se a ação for ajuizada em 15/04/13, somente poderão ser pedidos os direitos de até 05 anos atrás.

Quanto mais tempo o reclamante demorar para ajuizar a ação, mais direitos são perdidos. Inclusive, quando se entra com a ação trabalhista, são contados 05 anos anteriores ao ajuizamento e não do término do contrato.

SUM-308, TST. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (incorporada a Orientação Jurisprudencial nº 204 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005

I. Respeitado o biênio subsequente à cessação contratual, a prescrição da ação trabalhista concerne às pretensões imediatamente **anteriores a cinco anos**, contados da **data do ajuizamento da reclamação** e, não, às anteriores ao quinquênio da data da extinção do contrato. (ex-OJ nº 204 da SBDI-1 - inserida em 08.11.2000)

II. A norma constitucional que ampliou o prazo de prescrição da ação trabalhista para 5 (cinco) anos é de aplicação imediata e não atinge pretensões já alcançadas pela prescrição bienal quando da promulgação da CF/1988. (ex-Súmula nº 308 - Res. 6/1992, DJ 05.11.1992)

III.



ATENÇÃO: Se a peça for uma reclamação, peça tudo! Se for defesa, atente para a data e peça a prescrição. Na defesa, o reclamado não projeta o aviso prévio, salvo na ação de consignação em pagamento.

OJ-83, SDI-1, TST. AVISO PRÉVIO. INDENIZADO. PRESCRIÇÃO (inserida em 28.04.1997) A prescrição começa a fluir no final da data do término do aviso prévio. Art. 487, § 1º, CLT.



O TST entende que **dano moral na relação de emprego é crédito trabalhista!** Logo, respeita os prazos prescricionais do direito do trabalho.

7. PRESCRIÇÃO QUANTO AO FGTS

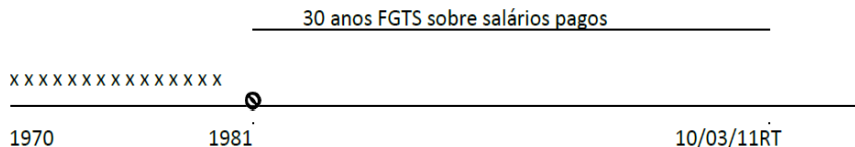
Regra geral, a prescrição do FGTS é trintenária ou trintenal, podendo ser buscados os últimos 30 anos de FGTS. Mas, como toda regra geral, há exceções, havendo casos de prescrição quinquenal e bienal.

Entretanto, a partir do dia **13.11.2014**, a prescrição passou a ser quinquenal para todos os casos. Respeitadas as ações que já estavam em curso antes de **13.11.2014**, em que se aplica a prescrição trintenal (inteligência da **súmula 362, do TST**)

Ex.: O empregado começou a trabalhar em 1960, como optante do FGTS. Trabalhou até 2010, quando se aposentou espontaneamente. O simples fato de ter se aposentando, ainda que não haja extinção do contrato, dá direito ao levantamento do FGTS. Vejamos duas situações hipotéticas:

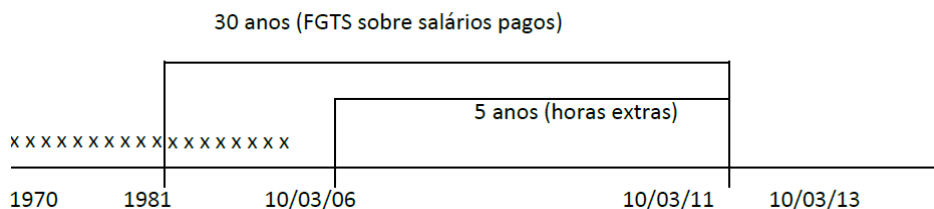
1. Durante todo o contrato de trabalho houve pagamento de salários, mas nunca

houve depósitos de FGTS.



Na Reclamação Trabalhista, pede-se somente os depósitos de FGTS sobre salários pagos. Se o reclamante ajuizar ação em 2010, recupera até 1980 e perde 10 anos de FGTS devido à prescrição trintenária.

2. Durante todo o contrato de trabalho houve pagamento de salários e prestação de horas extras, mas nunca houve pagamento de horas extras nem depósitos de FGTS.



Na Reclamação Trabalhista pede-se: **a)** depósito de FGTS sobre salários pagos dos últimos 30 anos; **b)** pagamento, integração e reflexos das horas extras. Hora extra é crédito trabalhista, logo sua prescrição é de 05 anos; **c)** depósitos de FGTS sobre as horas extras dos últimos 05 anos, tendo em vista que o fato gerador do FGTS, neste caso, são as horas extras que prescrevem em 05 anos. Conclusão: FGTS não incide sobre parcela prescrita. É a inteligência da **Súmula 206 do TST**:

SUM-206 FGTS, TST. INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS PRESCRITAS (nova redação)
- Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

A prescrição da pretensão relativa às parcelas remuneratórias alcança o respectivo recolhimento da contribuição para o FGTS.

A prescrição do FGTS, como afirmado, também é bienal:

Súmula nº 362 do TST FGTS. PRESCRIÇÃO (nova redação) - Res. 198/2015, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado em 12, 15 e 16.06.2015

I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato;

II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).

8. PRESCRIÇÃO CONTRA MENOR

Contra menor não corre prescrição. O prazo prescricional só começa a correr quando atingir a maioridade.

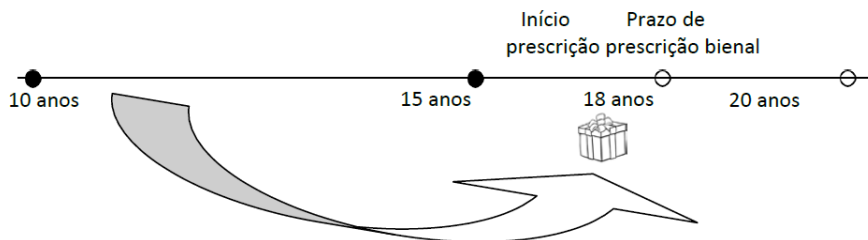
Logo, a menoridade impede a prescrição.

Art. 440, CLT. *Contra os menores de dezoito anos **não corre** nenhum prazo de prescrição.*

Para entendermos melhor, criamos a chamada “**TEORIA DO PACOTE**”:

Ex1.: Criança com 10 anos de idade começa a trabalhar (contrato nulo, não gera vínculo, mas são garantidos os direitos). Trabalhou até 15 anos de idade. Extinguindo-se o contrato de trabalho com 15 anos, a prescrição só começa a correr aos 18 anos, atingindo todos os direitos garantidos, adquiridos dos 10 aos 15 anos. Assim, o ex-empregado poderá ajuizar reclamação trabalhista até os 20 anos de idade (prescrição bienal), pedindo os créditos dos 10 aos 15 anos de idade. Logo, não há que se falar em prescrição quinquenal neste caso, pois contra menor não corre prescrição, devendo ser observada apenas, a prescrição bienal após atingida a maioridade.

Imagine que todos os direitos trabalhistas do empregado menor de idade se encontram guardados num pacote, como um presente que ele poderá vir a receber futuramente, caso busque seus direitos.



Ex2.: Empregado começou a trabalhar ainda criança, com 10 anos de idade, extinguindo-se seu contrato aos 30 anos de idade. A prescrição bienal começa a correr aos 30 anos. A partir dos 18 anos de idade, o empregado deverá observar o prazo quinquenal, que finda-se aos 23 anos, até quando poderão ser buscados os direitos dos 10 aos 18 anos.

Concluindo: Se o contrato de trabalho se extinguir enquanto o empregado ainda for menor, não há que se falar em prescrição quinquenal, mas apenas na bienal a partir da maioridade. Se o contrato se extinguir após a maioridade, além da bienal deve ser observada a prescrição quinquenal, sendo a primeira contada do término da relação de trabalho e a segunda a partir da maioridade.



9. INTERRUÇÃO DA PRESCRIÇÃO

A interrupção de qualquer prazo faz com que ele zere e recomece a contagem.

Ex.: Início do contrato de trabalho em 07/07/00. Em 07/07/10 extinguiu-se o contrato de trabalho. De 07/07/00 até 07/07/05 o empregado prestava horas extras e noturnas, sem nunca ter recebido por elas. Nesta ocasião, o empregado ingressa com sua primeira reclamação trabalhista, ainda durante o contrato de trabalho, pedindo somente horas extras, de 2000 a 2005, não havendo pedido de horas noturnas.

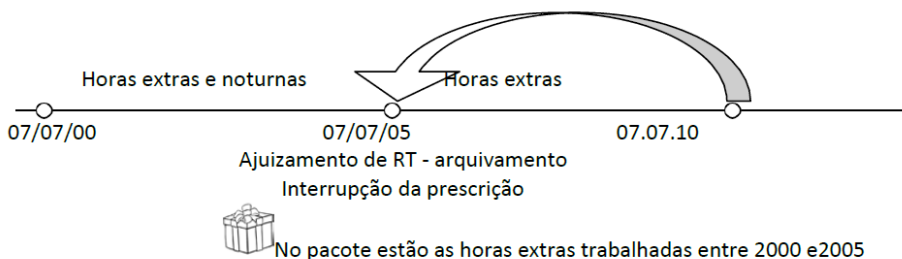
A interposição da reclamação trabalhista, ainda que arquivada, interrompe a

prescrição (seja quinquenal, seja bienal):

SUM-268, TST. A ação trabalhista, ainda que arquivada, interrompe a prescrição **somente em relação aos pedidos idênticos**.

Atenção: a interrupção da prescrição atinge somente os pedidos feitos na reclamação ajuizada.

Porém, o empregado desiste da ação, não comparecendo à audiência, arquivando-se o processo. Continua trabalhando para o mesmo empregador, desta vez, cumprindo somente horas extras, sem horas noturnas, até 2010, quando ajuíza nova reclamação trabalhista, pedindo horas extras de 2000 a 2005 (pois a prescrição foi interrompida) e horas extras de 2005 a 2010 (ainda dentro do prazo prescricional). Em relação às horas noturnas, já ocorreu a prescrição.



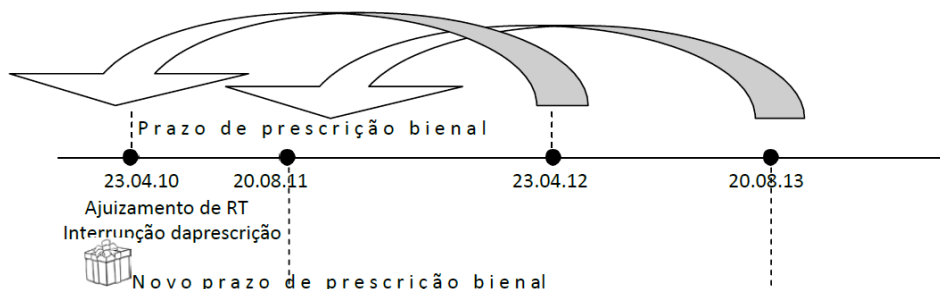
Atenção: a interrupção da prescrição só ocorre uma única vez para cada pedido.

Art. 202, CC/02. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

Se, nesse mesmo exemplo, o empregado ajuíza a ação somente em 08/07/10, volta 05 anos, não havendo que se falar em perda do direito das horas extras de 2000 a 2005, salvo se ajuizada a segunda RT após 07/07/10, pois neste caso já houve prescrição relativa à contagem do segundo prazo, após ter sido o mesmo zerado quando da interposição da primeira RT.

Extinção do contrato de trabalho em 23.04.2010 (já com a projeção do aviso prévio). O empregado pode ajuizar a reclamação até 23.04.12 (prescrição bienal). Em 28.08.11 o empregado ajuíza sua primeira reclamação trabalhista, reclamando os direitos de 2006 a 2010. Por qualquer motivo, o empregado não comparece à audiência sendo a reclamação arquivada. O ajuizamento interrompe a prescrição,

reiniciando a contagem do prazo. Logo, poderá ser ajuizada nova ação referente aos mesmos direitos (de 2006 a 2010) até 28.08.13.



Com a interrupção da prescrição, todos os direitos trabalhistas forem resguardados (imagine-os guardados no pacote!), sendo garantidos até 28.08.13, data em que ainda é possível ajuizar nova ação reclamando todos os direitos do pacote.

10. PRESCRIÇÃO TOTAL E PARCIAL

Tanto a prescrição total quanto a parcial são quinquenais, ou seja, de 05 anos.

Existem direitos que decorrem de lei e existem direitos que decorrem do contrato. Decorre de lei aquele em que a obrigação de pagar está prevista em lei (hora-extra, repouso semanal, insalubridade, periculosidade, horas noturnas, etc.). Decorrem do contrato aqueles em que a lei não obriga ao pagamento, mas apenas prevê o direito, sendo o contrato que obriga o pagamento, somente fazendo jus o empregado porque estão previstos no contrato de trabalho (por exemplo, gratificação de função).

Se o empregador não cumpre com o pagamento de direitos decorrentes de lei, a prescrição é parcial; se a falta de pagamento é de direitos decorrentes de contrato, a prescrição é total. É a inteligência da **Súmula 294 do TST**:

Súmula nº 294, TST. *Tratando-se de ação que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração do pactuado, a **prescrição é total**, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei.*

Em algo parcial não se mensura tudo, mas somente uma parte.

Se a prescrição é parcial, ao ajuizar a RT, o empregado pode reclamar os direitos dos últimos 05 anos. Logo, só alcançará uma parte dos direitos.

Se a prescrição é total, ajuizando a RT, volta-se os últimos 05 anos, ou se alcança a alteração contratual e leva tudo ou não alcança e não leva nada. É tudo ou nada, ou seja, quando o empregado volta os 05 anos para trás, ou ganha o direito todo ou não ganha nada.

10.1. Prescrição Parcial

Dois contratos de trabalho que começaram na mesma data (no ano de 2000) e se extinguíram na mesma data (em 25.10.10).

Um sujeito começou a trabalhar em 2000. Do início do contrato até 01/03/2002, ele prestou horas extras e recebeu a remuneração devida sobre essas horas extras. A partir daquela data, o empregado continuou prestando horas extras, mas o empregador deixou de fazer o devido pagamento, não o efetuando até a data da extinção do contrato, em 25/10/2010. Como o pagamento de horas extras decorre de lei, a prescrição é parcial.

Prestação e recebimento de horas extras

Prestação de horas extras sem o recebimento

Ano 2000

01.03.02

25.10.10

Se, neste caso, o empregado, diligentemente, ajuíza RT na data do término do contrato de trabalho, volta-se 05 anos e ele receberá todos os direitos relativos às horas extras prestadas e não pagas neste período, ou seja, de 25/10/2005 a 25/10/2010. Sendo assim, as horas extras de 01/03/2002 a 24/10/2005 estão prescritas.

Como se trata de pagamento devido por lei, ao não o efetuar, o empregador fere direito do empregado, gerando o seu direito de ação, que é renovado mês a mês. Daí ser a prescrição parcial, onde é possível o recebimento de parte dos direitos devidos.

Nesse caso, a prescrição é parcial, na verdade, porque a lei diz, no **Art. 59/CLT**⁴⁷ e no **Art. 7º, XVI/CF**⁴⁸, que o pagamento das horas extras é garantido por

⁴⁷ Art. 59, CLT - A duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas suplementares, em número não excedente de 2 (duas), mediante acordo escrito entre empregador e empregado, ou mediante

lei. Assim, todo mês que o empregado presta horas extras a lei lhe garante que essas horas extras sejam pagas. Se o empregador não as paga, todo mês o empregador está lesionando o direito do empregado. Então, todo mês nasce para o empregado o direito de ação. Renova-se o tempo e o direito de ação.

10.2. Prescrição Total

O empregado de uma loja, desde o início do seu contrato de trabalho, no ano de 2000, recebia comissão de 10% sobre as vendas. Em 01/03/2002, o empregador altera o contrato de trabalho e reduz a comissão para 8%. Tendo em vista que essa redução traz prejuízos ao empregado, a alteração é nula, o que é ignorado pelo empregador que procede à alteração, exigindo que os empregados assinem o contrato, dela dispondo.

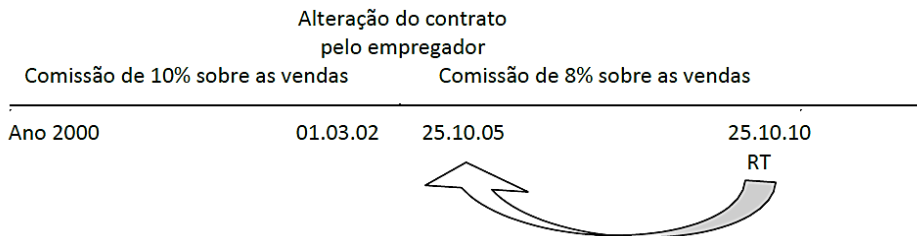
Enquanto o ato nulo no Direito Civil não prescreve, no Direito do Trabalho, prescreve. Assim, o empregado tem 05 anos a partir do ato (da alteração contratual) para buscar a nulidade dessa alteração e a diferença da redução.

Em 01/03/2002, o empregador alterou o contrato de trabalho e, ao alterar o contrato de trabalho, cometeu ato ilícito. Esse empregado só entrou com a Reclamação Trabalhista em 25/10/2010. Como o direito decorre do contrato, a prescrição é total e, se é total, quando esse empregado entrar com a ação projetando cinco anos para trás, ou ele ganha tudo ou não ganha nada. Voltando os 05 anos, volta-se à data de 25/10/2005.

Ocorre que a alteração contratual foi anterior a essa data (01/03/2002). Neste caso, o empregado não ganha o direito às diferenças pela redução da comissão, visto que o ato ilícito do empregador somente ocorreu quando da alteração contratual que não poderia ter sido feita, não havendo que se falar em renovação do direito de ação, pois o direito do empregado somente foi ferido com a alteração do contrato, em afronta à lei. Ainda neste caso, para requerer a diferença da comissão, antes é necessário requerer a anulação da alteração contratual, o que somente poderia ser feito até 01/03/07.

contrato coletivo de trabalho.

⁴⁸ Art. 7º XVI, CF - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal...



Logo, se o empregador lesionou o direito do empregado no dia 01/03/2002, nesta data nasce para o empregado o direito de ação. Nasce o direito de ação, começa a se contar o prazo de prescrição, tendo o empregado 05 anos para entrar com a ação. Nesse caso teria até o dia 01/03/2007.

Se o empregado entrar com a RT até esta data, volta 05 anos e alcança a data da alteração. Nesse caso, o juiz declara a alteração contratual nula e o empregado terá direito à diferença de 2% das comissões do período.

O direito foi violado uma única vez: quando o empregador alterou o contrato. A alteração do contrato é que foi a violação do direito. Quando o empregador violou o contrato e reduziu a comissão de 10% para 8%, fez um ato único. O direito violado foi o direito a *inalterabilidade contratual lesiva*⁴⁹.

Quando o empregador, depois da alteração contratual, passou a pagar 8%, na realidade ele não violou o contrato, pelo contrário, ele está cumprindo o contrato, está pagando de acordo com o contrato, que foi alterado e assinado pelo empregado. O ato ilícito foi o da alteração contratual. O direito de ação começa do ato ilícito. Com a reforma trabalhista, seja alteração do pactuado ou descumprimento contratual, a prescrição é total.

OJ-175, SDI-1, TST. A supressão das comissões, ou a alteração quanto à forma ou ao percentual, em prejuízo do empregado, é suscetível de operar a **prescrição total da ação**, nos termos da Súmula nº294 do TST, em virtude de cuidar-se de parcela não assegurada por preceito de lei.

SUM-275, TST. PRESCRIÇÃO. DESVIO DE FUNÇÃO E REENQUADRAMENTO (incorporada a Orientação Jurisprudencial nº 144 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005

I - Na ação que objetive corrigir desvio funcional, a prescrição só alcança as

⁴⁹**Art. 468, CLT** - Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia.

diferenças salariais vencidas no período de 5 (cinco) anos que precedeu o ajuizamento.

*II - Em se tratando de pedido de **reenquadramento**, a **prescrição** é total, contada da data do enquadramento do empregado.*

Na **súmula 275 do TST** há um caso de desvio e de reenquadramento funcional. O inciso “I” fala de *Desvio de Função*. O desvio de função é quando o contrato prevê uma função à qual corresponde um salário, e o empregado desempenha outra função que corresponde a um salário distinto. Sempre que alguém é contratado, o contrato estabelece uma função e quando se está em desvio de função, se está em flagrante descumprimento contratual. Para que um empregado passe a ocupar outra função, é preciso que se faça, obrigatoriamente, a alteração na CTPS, convidando realmente o empregado a assumir a nova função.

No desvio de função, o empregado passa a exercer função diversa da que foi contratado, sem alteração contratual, não havendo pagamento de salário correspondente. Logo, é um descumprimento contratual.

Já quando se está em descumprimento contratual, o empregado exerce a nova função para a qual foi promovido, mas continua recebendo o salário anterior, quando deveria receber o salário da nova função. Neste caso, todo mês o empregador contraria o contrato, surgindo para o empregado, mês a mês, o direito de ação. A prescrição que se renova todo mês é a prescrição parcial.

Então, desvio de função não passa de um descumprimento contratual, porque o empregador deveria ter alterado a função no contrato e não o fez.

O inciso “II” da **Súmula 275 do TST** fala de reenquadramento. Quando se fala em reenquadramento, pensa-se logo em promoção. O ato de o empregador enquadrar o empregado em outra função abaixo da ocupada anteriormente, é ato nulo, pois trata-se de uma alteração contratual prejudicial ao empregado. Nesses casos, o direito à reintegração decorre do contrato e o empregado tem 05 anos para reclamar e pedir o reenquadramento, limitado a 02 anos após a extinção do contrato de trabalho.

11. RECONVENÇÃO

A reconvenção não tem previsão no processo do trabalho, logo ela é oriunda do processo civil (**art. 343, do CPC/15**) e aplicada, subsidiariamente, ao processo do trabalho por força do **art. 769 da CLT**, uma vez que ao tornar o processo mais rápido se compatibiliza com o *princípio da celeridade*.

A reconvenção tem dupla natureza jurídica. Ao mesmo tempo que é uma

defesa do réu, é uma ação do réu contra o autor e apresentada dentro da contestação como matéria de defesa. Na verdade, é através desta última natureza da reconvenção – a de ação – que sua finalidade e cabimento serão explicados.

11.1. Para que serve uma reconvenção?

Uma reconvenção serve como um contra-ataque do réu em relação ao autor e, nos termos do **art. 343, do CPC/15**, o réu pode reconvir ao autor no mesmo processo, toda vez que a reconvenção seja conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Enquanto na reclamação trabalhista o autor acusa o réu de ter descumprido a lei ou o contrato com a consequente lesão a direito seu e, no final, requer uma sentença em que o réu seja condenado a dar, fazer, deixar de fazer ou pagar; a contestação é uma peça de defesa em que o réu se limita a impugnar os pedidos do autor (defesa de mérito: direta ou indireta) ou a atacar a relação processual autor-juíz-réu (preliminares). Já a reconvenção é o meio através do qual o réu acusa o autor de ter descumprido a lei ou o contrato com a consequente lesão a direito seu e, no final, requer uma sentença em que o réu seja condenado a dar, fazer, deixar de fazer ou pagar.

Note que o pedido feito em reconvenção muito se assemelha a uma ação, pois ambas têm basicamente a mesma finalidade: a condenação de alguém a dar, fazer, deixar de fazer ou pagar em virtude de este alguém ter descumprido a lei ou o contrato. No entanto existe, sim, diferença entre uma ação e uma reconvenção e a principal é o momento processual em que a ação e a reconvenção são apresentadas: a reconvenção tem que ser apresentada na contestação; já a ação pode ser apresentada em outro momento processual.

11.2. Reclamar ou reconvir?

Basicamente, no que respeito ao direito pleiteado não haveria qualquer diferença entre a reconvenção ou a ação, mas há diferença quanto ao ritmo imposto ao processo. É que se se optar pela reconvenção, o processo tramitará de forma muito mais rápida, pois a peça é apresentada em audiência, juntamente com a contestação, sem qualquer necessidade de distribuição, pois será processada nos mesmos autos da ação; o reconvinco – o réu da reconvenção – será notificado da mesma em audiência, sem a necessidade de notificação via postal; o juiz designa a audiência em continuação e já intima as partes no ato, inclusive o reconvinco já fica notificado para apresentar defesa à reconvenção e produzir provas, etc.

Optando-se pela ação, esta muito provavelmente será distribuída para outra vara do trabalho, onde será tombada, autuada, numerada; haverá notificação do reclamado por via postal para comparecer a audiência; se o mérito desta ação for

conexo com a ação que tramita em outra vara, uma delas será suspensa (**art. 313, do CPC/15**) e encaminhada para o juízo prevento (**arts. 57, do CPC/15 - e OJ 130, SDI-2, TST**); quando as duas ações forem reunidas será designada nova audiência, etc.

Capítulo 13

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

1. PARA QUE SERVE AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO?

A ação de consignação em pagamento é o meio processual próprio para que o devedor peça judicialmente o depósito de um valor ou coisa, com efeito de pagamento e extinga, assim, sua obrigação, quando o credor não queira ou não possa dar quitação, nos termos dos **arts. 334 e 335 do Código Civil** e **art. 539 do Código de Processo Civil de 2015**. Ação de consignação em pagamento é cabível no Processo do Trabalho por força do **art. 769 da CLT**.

***Art. 334, CC/02.** Considera-se pagamento, e **extingue a obrigação**, o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e forma legais.*

***Art. 335, CC/02.** A consignação tem lugar:*

I- se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II- se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III- se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV- se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V- se pender litígio sobre o objeto do pagamento.

Deve-se ter em mente que o devedor não tem apenas a obrigação de pagar, mas ele tem o direito de pagar. Tem o devedor o direito de cumprir fielmente a obrigação assumida, justamente para não incorrer em mora e sujeitar-se ao pagamento de multas, juros, indenizações e, se for o caso, até a inscrição de seu nome no cadastro de dívidas trabalhistas.

Conforme visto em capítulo próprio⁵⁰, o pagamento das verbas trabalhistas rescisórias e indenizatórias deve ser feito dentro do prazo previsto em lei, qual seja: até 10 dias contados a partir do término do contrato, de acordo com o **§6º do art. 477 da CLT**.

Passado o prazo para pagamento da rescisão, o empregador poderá ficar sujeito ao pagamento das multas previstas no **§ 8º do art. 477 da CLT**: **a)** uma multa

⁵⁰ Vide capítulo sobre prazo para pagamento das verbas trabalhistas rescisórias e indenizatórias, mais precisamente as alíneas “a” e “b” do §6º do art. 477 da CLT.

no valor de 160 BTN (bônus do tesouro nacional) revertida em favor da União; **b)** uma multa no valor de um salário do empregado, revertida em favor do próprio empregado.

Assim, extinguindo o empregador o contrato de trabalho e convocando o empregado para o pagamento da rescisão dentro dos prazos previstos em lei, recusando-se a receber ou não podendo receber, o empregador utilizará a ação de ação de consignação em pagamento para depósito das verbas rescisórias e indenizatórias com o fim de ver extinta sua obrigação trabalhista para com aquele empregado.

2. EM QUAIS CASOS CABE A AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO?

Os **arts. 334 e 335 do Código Civil**, aplicados subsidiariamente ao Direito do Trabalho por força do **§1º do art. 8º da CLT**, estabelecem que considera pagamento e extingue a obrigação o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos de: **a)** o credor não poder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma; **b)** o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos; **c)** o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil; **d)** ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento; **e)** pender litígio sobre o objeto do pagamento.

a) O credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma.

Nesta hipótese, por exemplo, os empregados demitidos e convocados ao recebimento das verbas dentro do prazo legal, recusam-se a dar quitação ao empregador, sob a orientação do sindicato, que alega não concordar com a demissão coletiva.



IMPORTANTE: nada impede que o empregado seja o consignante. Imagine que o empregado, ao ser demitido, procurou o empregador para devolver o celular e o computador que havia recebido como instrumento de trabalho. O empregador se recusa a receber. O empregado, para não correr o risco de ser acusado de apropriação indébita, por exemplo, requer a consignação do celular e do computador.

b) O credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos.

Neste caso, por exemplo, o empregado não comparece na data designada para o recebimento das verbas e nem justifica, nem manda procurador em seu lugar. Esta hipótese foi a prova da OAB FGV X Exame de Ordem.



IMPORTANTE: mais uma vez, nada impede que o empregado seja o consignante. Imagine que o empregado, vendedor viajante, autorizado, recebeu valores de clientes de seu empregador e procura o empregador para lhe entregar a quantia destinada. O empregador não comparece para receber na data e local designados. O empregado, para não correr o risco de ser acusado de apropriação indébita, por exemplo, requer a consignação dos valores.

c) O credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil.

Típico caso em que o empregado abandona o emprego e, apesar de convocado para retornar ao trabalho, nunca atendeu às convocações, não sabendo o empregador onde se encontra o empregado para lhe pagar as verbas.

d) Ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento.

Caso corriqueiro quando o empregado, titular dos créditos trabalhistas a serem recebidos, falece e o empregador ou não sabe quem são os herdeiros ou tem dúvidas quanto aos herdeiros, pois o empregado não os relacionou em sua CTPS ou tem duas famílias e o empregador não sabe a quem pagar.

A fim de não pagar errado, pois quem paga mal, paga duas vezes, se utiliza da ação de consignação em pagamento.

e) De haver litígio sobre o objeto do pagamento

Caso muito parecido com o anterior, só que, desta vez, por exemplo, as duas famílias do empregado estão discutindo judicialmente quem fica com as verbas. O empregador, por força do litígio sobre a titularidade das verbas devidas, consigna as mesmas em pagamento.

3. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Os requisitos da petição inicial de consignação em pagamento são os mesmos de uma petição inicial civil, previstos no **art. 319 e incisos** e **art. 539 do CPC/15**, que de forma simplificada são: endereçamento, qualificação das partes, fundamentos fáticos e jurídicos do pedido, o pedido, produção de provas, valor da causa, citação do consignado, data e assinatura.

Art. 319, CPC/15. *A petição inicial indicará:*

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

3.1. O que devo pedir numa petição de Consignação em Pagamento?

O primeiro pedido que deve ser feito numa ação de consignação em pagamento é seu **JULGAMENTO TOTALMENTE PROCEDENTE** que vale, em média, 0,40 (quarenta décimos). Deixar de fazer este pedido pode fazer com que o examinando perca a referida pontuação. Em seguida, deve-se pedir o **depósito da quantia ou coisa, com efeito de pagamento e extinção da obrigação**, nos termos dos **arts.334 e 335 do C.C.** e **art.539, do CPC/15**.

Neste caso, o examinando não precisa se preocupar em “decorar” os pedidos porque eles estão todos previstos em lei, facilitando sua realização durante a prova.

Capítulo 14

AÇÃO DE CUMPRIMENTO

1. PARA QUE SERVE UMA AÇÃO DE CUMPRIMENTO?

A ação de cumprimento é o instrumento processual próprio para que o empregado ou seu sindicato profissional requeira judicialmente o **cumprimento de uma prestação a que o empregador ficou obrigado a satisfazer**, mas que por motivos alheios à vontade do empregador ou de seu sindicato profissional, não satisfaz. A obrigação descumprida tem origem em convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo ou sentença normativa, nos termos do **art. 872, caput e parágrafo único da CLT**.

A ação de cumprimento cabe **quando houver o descumprimento de norma jurídica prevista em contratos coletivos (CCT e ACT) ou sentença normativa**. Entretanto, é de se estranhar porque, geralmente, contratos e sentenças descumpridas são executadas. Com relação ao contrato de trabalho, mesmo assinado por duas testemunhas, no Processo do Trabalho não é possível sua execução pelo simples fato de não ser o contrato individual de trabalho título executivo judicial, por não estar elencado como tal no **art. 876, caput, da CLT**.

2. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL DE AÇÃO DE CUMPRIMENTO

Os requisitos da petição inicial de ação de cumprimento são os mesmos de uma reclamação trabalhista, até porque a ação de cumprimento é uma espécie de reclamação trabalhista, de acordo com a redação do parágrafo único do art. 872 da CLT. Os requisitos estão descritos no **§1º do art. 840, da CLT** e **art. 319, CPC/15**, que de forma simplificada são: endereçamento, qualificação das partes, uma breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, data e assinatura.

Art. 840, CLT- A reclamação poderá ser escrita ou verbal.

§ 1º - Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do Presidente da Junta, ou do juiz de direito a quem for dirigida, a qualificação do reclamante e do reclamado, uma breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante.

3.1. Endereçamento e competência funcional

O endereçamento à autoridade competente é requisito da petição inicial de ação de cumprimento, até mesmo porque tem por objeto o pedido de cumprimento de cláusula prevista em convenção coletiva de trabalho, acordo

coletivo de trabalho ou sentença normativa, e quem pede, pede alguma coisa a alguém. Esse alguém a quem está sendo feito o pedido é a autoridade judiciária competente para processar e julgar a ação de cumprimento.

Nos termos do **parágrafo único do art. 872 da CLT**, a competência funcional para processar e julgar uma ação de cumprimento é da Vara do Trabalho, logo o endereçamento deve ser feito ao Juiz do Trabalho.

***Art. 872, CLT** - Celebrado o acordo, ou transitada em julgado a decisão, **seguir-se-á o seu cumprimento**, sob as penas estabelecidas neste Título.*

***Parágrafo único** - Quando os empregadores deixarem de satisfazer o pagamento de salários, na conformidade da decisão proferida, poderão os empregados ou seus sindicatos, independentes de outorga de poderes de seus associados, juntando certidão de tal decisão, apresentar reclamação à Junta ou Juízo competente, observado o processo previsto no Capítulo II deste Título, sendo vedado, porém, questionar sobre a matéria de fato e de direito já apreciada na decisão.*

3.2. Qualificação das partes

Na ação de cumprimento, o reclamante pode ser tanto o empregado quanto o sindicato dos empregados, que atuará na qualidade de substituto processual, sem necessitar de autorização dos substituídos. O reclamado é o empregador que deixar de cumprir a norma coletiva.

3.3. O que devo alegar?

O pedido feito numa ação de cumprimento deve ter fundamentação fática e jurídica que são os motivos, as razões, as circunstâncias e os porquês de cada pedido. Havendo **pedido de cumprimento** de cláusula de CCT, ACT ou sentença normativa, deve haver a descrição detalhada do descumprimento do empregador e daquilo que foi descumprido, **com a demonstração de que o ato praticado prejudicou o empregado**. Finalize com a menção ao fundamento legal.

Capítulo 15

RECURSOS NO PROCESSO TRABALHISTA

1. RECURSOS NO PROCESSO TRABALHISTA

O direito de recorrer, as decisões que são recorríveis, as hipóteses de cabimento e a própria existência de recursos estão garantidas pela norma processual comum.

Logo, só há recurso para referida decisão se houver previsão legal e, mesmo havendo recurso previsto em lei para a decisão, este se submete aos pressupostos recursais e hipóteses de cabimento específicas, criadas por lei. Se não há previsão legal de recurso para a decisão é porque não cabe recurso da decisão e esta transita em julgado. Caso a decisão contenha algum dos vícios previstos no art. 966 do CPC poderá ser declarada nula a decisão mediante ação rescisória.

1.1. Estrutura básica dos recursos

Em regra, todo recurso tem dois juízos de admissibilidade: o primeiro juízo e o segundo juízo de admissibilidade. O primeiro juízo de admissibilidade é também conhecido como juízo *a quo*, que é o juízo prolator da decisão recorrida e o juízo perante o qual o recurso será apresentado. O segundo juízo de admissibilidade é conhecido como juízo *ad quem*, que é o juízo perante o qual o recurso será processado e, ao final, julgado.

A função de cada juízo de admissibilidade é basicamente a mesma: analisar se os pressupostos intrínsecos e extrínsecos do recurso estão presentes como, por exemplo, legitimidade para recorrer, capacidade, interesse de recorrer, adequação do recurso, cabimento, tempestividade, regularidade de representação e o preparo, representado pelas custas e pelo depósito recursal.

Uma vez apresentado o recurso perante o juízo *a quo*, este analisará a presença ou não dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso. Caso entenda presentes todos os pressupostos recursais, proferirá despacho dando seguimento ou interposição ao recurso, com a intimação do recorrido para apresentar suas contrarrazões (art. 900 da CLT). Uma vez admitido na origem⁵¹, o recurso seguirá para o segundo juízo de admissibilidade no tribunal. Caso também

⁵¹Ao recurso também pode ser negado seguimento por entender o juízo *a quo* pela ausência de algum pressuposto recursal. Neste caso o recurso será trancado e da decisão que negar seguimento no primeiro juízo de admissibilidade caberá agravo de instrumento (art. 897, b, CLT) o que será estudado em capítulo específico mais adiante.

entenda presentes os pressupostos, o recurso será conhecido⁵² e enviado para o órgão específico para julgamento de mérito: caso provido, a sentença será reformada; caso improvido, a sentença será mantida.

1.2. Como se estrutura um recurso?

Como os recursos têm dois juízos de admissibilidade em instâncias diferentes, o primeiro na instância inferior e o segundo na superior, o normal é dividir o recurso em duas partes distintas: a folha de rosto, conhecida também por folha de apresentação ou interposição e as razões recursais. A folha de rosto é dirigida ao primeiro juízo de admissibilidade. As razões recursais, ao segundo juízo de admissibilidade.

A petição de folha de rosto deve conter a designação do juízo *a quo*, a indicação das partes: recorrente e recorrida, a indicação correta do recurso a ser interposto e seu dispositivo legal⁵³, indicação das custas e do depósito recursal, caso o recurso seja do empregador, o pedido de notificação da parte contrária para apresentar contrarrazões e o pedido de seguimento do recurso.

Já as razões recursais devem conter a designação do tribunal e as teses, preliminares, prejudiciais e mérito, com o pedido de conhecimento e provimento para a reforma da decisão. A folha de rosto e as razões recursais, apesar de serem petições distintas e endereças a juízos distintos, fazem parte da mesma estrutura do recurso e não devem ser apresentadas separadamente, mas em conjunto e ao mesmo tempo.

1.3. Fórmula Mágica

À semelhança do que acontece nas petições iniciais e defesa trabalhista, é nas razões recursais onde será sustentado que a decisão está errada, porque ela está errada e que deve ser reformada. É necessário, portanto, a exposição dos fundamentos fáticos e jurídicos, dos motivos pelos quais se pede a reforma do julgado:

⁵²No segundo juízo de admissibilidade também existe a hipótese de não conhecimento por entender o juízo *ad quem* pela falta de algum pressuposto processual. Neste caso o recurso não será conhecido e da decisão que negar conhecimento no segundo juízo de admissibilidade caberá agravo interno (art. 239 RITST) ou agravo de regimento (art. 235 RITST), o que será estudado em capítulo específico mais adiante.

⁵³ITEM DO EDITAL 4.2.6.1

É que ... (O que o empregado pediu de errado)

E daí? (Diga por que não tem direito e explique)

Pelo que requer ... (Faça o pedido)

Usando a Fórmula Mágica você fará com todo e qualquer pedido em Reclamação Trabalhista e, também, ao impugnar pedido em Contestações e em Recursos contra decisões, pois nestas peças é exigida a fundamentação fática e jurídica, o que será visto nos capítulos respectivos.



ATENÇÃO! Note que para que sua peça seja elaborada na melhor técnica jurídica, fundamentação fática primeiro e, posteriormente, a fundamentação jurídica.

1.4. Efeitos devolutivo e suspensivo

Os recursos no processo do trabalho são recebidos apenas em seu efeito devolutivo, não existindo, a princípio, recurso trabalhista com efeito suspensivo⁵⁴ (art. 899 da CLT).

O que significa efeito devolutivo? Efeito devolutivo é o efeito que os recursos trabalhistas têm de devolver ao Estado a matéria julgada pela decisão judicial para ser reapreciada pela instância superior. Assim, quando o direito de alguém é lesado por outrem, o ofendido recorre ao Estado através de uma ação judicial e pede que este exerça a jurisdição, ou seja, diga o direito no caso concreto. Requerido o exercício da jurisdição ao Estado, este é obrigado a julgar o processo na medida em que nenhuma lesão ou ameaça de lesão será excluída da apreciação do Poder Judiciário (art. 5º XXXV CF).

Enquanto o efeito devolutivo é regra entre os recursos, o efeito suspensivo é uma exceção. Como o próprio nome está dizendo, o efeito suspensivo conferido ao recurso acaba por suspender a eficácia da decisão. Então, uma sentença condenatória que condena alguém a dar coisa certa, fazer, deixar de fazer ou pagar, quando dela se recorre e ao recurso é conferido efeito suspensivo, a ordem judicial fica suspensa até o trânsito em julgado da decisão quando, finalmente, o condenado

⁵⁴O art. 14 da Lei 10.192/01 prevê a possibilidade de ao recurso ordinário em dissídio coletivo ser conferido efeito suspensivo pelo Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.

será executado e forçado a cumprir a sentença condenatória dando, pagando, fazendo ou deixando de fazer aquilo previsto na decisão.

Em geral, como os recursos trabalhistas não são dotados de efeito suspensivo (art. 899 da CLT), nem mesmo os recursos para o Supremo Tribunal Federal, como o recurso extraordinário (§2º art. 893 CLT), as decisões condenatórias poderão ser executadas de forma provisória e imediata⁵⁵. Caso se queira dar efeito suspensivo ao recurso, a medida cabível para tanto é a tutela cautelar em caráter antecedente⁵⁶, nos termos da súmula 414, inc. I do TST e art. 305 do CPC.

⁵⁵Sobre execução provisória, seu processamento e efeitos, vide o capítulo Execução Trabalhista.

⁵⁶Sobre tutela cautelar, vide o capítulo Tutela de Urgência.

Capítulo 16

PRESSUPOSTOS RECURSAIS

■ PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS EXTRÍNSECOS

1. PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS

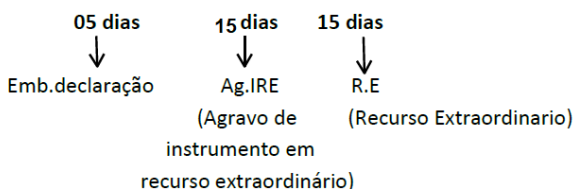
Os pressupostos recursais extrínsecos são os requisitos de admissibilidade de qualquer recurso e os três mais importantes são: tempestividade, regularidade de representação e o preparo, que corresponde às custas e ao depósito recursal.

2. TEMPESTIVIDADE

O recurso é tempestivo quando é interposto dentro do prazo do recurso que, no processo do trabalho, tem um **prazo geral e comum de 08 (oito) dias** para recorrer ou contrarrazoar qualquer recurso (art. 6º da Lei 5.584/70). Caso o recurso seja interposto depois do prazo, será tido como intempestivo. No entanto, existem três exceções à regra geral de oito dias: os embargos de declaração cujo prazo é de cinco dias (art. 897-A CLT), o agravo de instrumento para destrancar recurso extraordinário, com prazo de quinze dias (art. 328 RITST) e o recurso extraordinário, com prazo de quinze dias.

Tempestividade:

EXCEÇÃO:



Apesar de parte da doutrina questionar se os Embargos de declaração têm natureza de recurso ou de medida especial, para o TST, a natureza jurídica dos embargos de declaração é de recurso, pois esclarece que o prazo para a Fazenda Pública embargar de declaração é dobrado, ou seja, de dez dias. Ocorre que, prazo dobrado para a Fazenda Pública, é para ela recorrer (DL 779/69), daí, correto se concluir que: já que o prazo para os embargos de declaração é dobrado e prazo em dobro é para recurso, os embargos de declaração são recurso, nos termos da (OJ 192-SDI-1 TST).

3. PRORROGAÇÃO DO PRAZO RECURSAL

Existe a possibilidade de o prazo recursal ser prorrogado caso ele recaia num sábado, domingo ou feriado ou ainda em dia útil, mas que não tenha expediente forense. No entanto, deve-se ficar atento para se saber se o feriado capaz de prorrogar o prazo recursal é local ou nacional. Se for nacional o feriado ou, ainda, se se tratar de dia útil sem expediente forense, o prazo é **automaticamente prorrogado** para o primeiro dia útil seguinte.

Caso o feriado seja local, criado por lei municipal ou estadual, como o juiz somente é obrigado a conhecer lei federal – art. 376, CPC – cabe ao recorrente comprovar a existência de feriado local com o fim de prorrogar o prazo, pena de ser o recurso considerado intempestivo, nos termos da **Súmula 385 do TST**:

Grifar as palavras **destacadas** na CLT!

*Sum. 385, TST - I – Incumbe à parte o ônus de provar, quando da interposição do recurso, a existência de **feriado local** que autorize a prorrogação do prazo recursal.*

Exemplo de uma tese, desenvolvida a partir de um caso, envolvendo intempestividade recursal nos termos da Súm. 385, I do TST:

“Que ao recurso foi dado seguimento por tempestivo. Sabe-se porque interposto um dia após o prazo, pois o último dia caiu no feriado estadual. O recurso foi interposto sem a juntada de qualquer documento.”



Há intempestividade do recurso, pois não houve **comprovação do feriado estadual** para a prorrogação do prazo para o primeiro dia útil seguinte, nos termos da súmula 335, inc. I TST e art. 775 da CLT.

*II – Na hipótese de **feriado forense**, incumbirá à **autoridade** que proferir a decisão de admissibilidade certificar o expediente nos autos.*

III – Na hipótese do inciso II, admite-se a reconsideração da análise da tempestividade do recurso, mediante prova documental superveniente, em Agravo Regimental, Agravo de Instrumento ou Embargos de Declaração.

Uma prática não muito comum, mas prevista em lei, é a prolação de sentença em audiência (art. 852 CLT). Entretanto, ao invés de o magistrado na audiência única de conciliação e instrução proferir a decisão, o juiz designa uma nova data para a decisão.

Caso os advogados ou as partes sejam intimadas para comparecimento à audiência em prosseguimento à primeira para prolação da decisão, mesmo que não

compareçam a ela, o início do prazo para a interposição do recurso é o dia da audiência e a contagem, o primeiro dia útil seguinte, não podendo a parte intimada, mas que não compareceu, pretender aguardar a publicação no DJT ou ser intimada via e-mail (portal JT), até porque quando isto acontecer, o prazo para o recurso já deverá ter se esgotado, nos termos da **súmula 197 TST**:

Súm. 197, TST.** O prazo para recurso da parte que, intimada, não comparecer à audiência em prosseguimento para a **prolação da sentença conta-se de sua publicação.

Exemplo de uma tese, desenvolvida a partir de um caso, envolvendo intempestividade recursal nos termos da Súm. 197 do TST:

“Que ao recurso foi dado seguimento. Sabe-se que o recorrente, ainda em audiência, foi intimado para comparecer à próxima audiência para prolação (litura) da sentença. Na data marcada, o recorrente não compareceu, 15 dias após a audiência, foi publicada a decisão no DOJT e no terceiro dia foi protocolizado o recurso a que foi negado seguimento.”



Há intempestividade do recurso, uma vez interposto **fora do prazo de 8 dias**, pois a contagem começar a **partir da publicação da sentença em audiência**, nos termos da súmula 197 do TST.

4. REGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO

Apesar de a parte poder reclamar e se defender pessoalmente no processo do trabalho, sem a necessidade de assistência ou representação por advogado, por força do *jus postulandi* (art. 791 CLT), caso queira, poderá constituir advogado mediante procuração. Para constituir advogado faz-se necessário que a parte dê instrumento de mandato para o advogado. Quem dá o mandato (dá os poderes) é o mandante e quem recebe os poderes é o mandatário.

Por força do princípio da informalidade, que rege o processo do trabalho, o mandato ou procuração no processo do trabalho pode ser tácito ou expresso. Sendo expresso, pode ser escrito ou verbal. O mandato expresso escrito é o mais comum, pois é aquele que é elaborado no escritório do advogado, assinado pelo cliente e juntado aos autos ou com a reclamação ou com a defesa ou com o recurso.

5. MANDATO ESCRITO

O mandato escrito traz em si os poderes da cláusula *ad juditia* para o foro em geral, com o fim apenas de propor ações, interpor recursos, acompanhar o assistido

em audiência, contestar, impugnar atos etc. O mandato escrito também pode comportar os poderes especiais da cláusula **extra** para: receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação e firmar compromisso. Tais poderes têm que estar previstos expressamente na procuração, portanto, geralmente, são compatíveis apenas com a procuração escrita, pois devem constar de cláusula específica, nos termos do art. 105 do CPC.

6. MANDATO VERBAL

O mandato verbal, também conhecido como *apud acta*, tem previsão no §3º do art. 791 da CLT, na medida em que os poderes de procuração são passados pelo cliente ao advogado na própria audiência, mediante consignação do ato na ata de audiência. Então, caso o advogado compareça à audiência trabalhista com seu cliente sem procuração, o juiz, ao notar a ausência de instrumento procuratório, pode determinar a juntada do mesmo no prazo de 05 (cinco) dias. Ao invés de fazer a juntada de uma procuração escrita que, além de formal, demanda mais tempo, o advogado, com a anuência do cliente, poderá requerer que a procuração seja passada verbalmente na própria audiência, com os poderes da cláusula *ad iudicia*.

7. MANDATO TÁCITO

O mandato tácito é aquele em que não existe a presença física da procuração nos autos, nem como documento juntado e nem consignado em ata de audiência, mas decorre dos atos praticados pela parte e seu procurador em audiência. Assim, o advogado pode comparecer à audiência trabalhista com seu cliente sem procuração. Caso o juiz não note a ausência de procuração não determinará, obviamente, sua juntada aos autos. Acabada a audiência, depois de o advogado ter praticado atos processuais em nome de seu cliente na audiência trabalhista, constituído está por procuração tácita⁵⁷.

Na procuração tácita a única coisa que existe é o nome do advogado na ata do processo, demonstrando que compareceu à audiência e lá praticou atos, diferentemente do mandato *apud acta*, pois neste é reduzido a termo a verbalização da constituição de advogado pela parte. Nada impede, no entanto, que sejam requeridas ao procurador com mandato tácito, informações suficientes para facilitar

⁵⁷ “(...) A Justiça do Trabalho para evitar problemas com relação aos advogados que se fazem presentes às audiências, acompanhando reclamantes, terminou por conceder legitimidade a tal procedimento, considerando a existência do mandato tácito (...)” **Processo:** E-RR. **Número:** 21386. **Ano:** 1991. **Publicação:** DJ - 03/05/1996. **Relator:** Min. José Luís Vasconcellos.

as intimações das partes no processo, nos termos do § 2º do art. 105 do CPC.

Dada a informalidade de que se reveste o mandado tácito, este não comporta os poderes especiais da cláusula **extra**, já que tais poderes devem ser expressos no instrumento procuratório o que é incompatível com o mandato tácito (art. 105, *caput* do CPC).

8. PRAZO PARA JUNTADA DE PROCURAÇÃO

No caso de defeito ou irregularidade de representação, o juiz deverá conceder um prazo razoável de 05 (cinco) dias para o saneamento do vício, findo os quais sem o devido saneamento, extinguirá o feito sem solução de mérito (art. 76, § 2º CPC), se a providência couber ao reclamante, ou decretará a revelia ou a confissão quanto à matéria de fato, se a providência couber ao reclamado, nos termos do inciso III da **súmula 456 do TST**:

REPRESENTAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. PROCURAÇÃO. INVALIDADE. IDENTIFICAÇÃO DO OUTORGANTE E DE SEU REPRESENTANTE.

(...)

*III – Caso a irregularidade de representação da parte seja constatada em fase recursal, o relator designará **prazo de 5 (cinco) dias** para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação, o relator não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente, ou determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido (art. 76, § 2º, do CPC de 2015).*

9. PROCURAÇÃO NA FASE RECURSAL

Regularizada a representação na fase de instrução processual, com a juntada de instrumento procuratório, caso determinada a providência pelo juiz, o advogado está apto a promover a interposição de recurso. No entanto, existe a possibilidade de o advogado não cumprir a determinação de juntada da procuração ou haver a presença de um novo advogado na fase recursal.

Em todos os casos, para a interposição de recurso, a **procuração será exigida**, sob pena de inexistência do ato. No entanto, no primeiro caso, advogado cuja representação estiver irregular porque não cumpriu a determinação judicial de juntada de procuração, o advogado, notando o equívoco por si só, já que a regularização **independe** de intimação judicial, deverá regularizar sua situação no ato de interposição do recurso, sem a concessão de qualquer prazo para saneamento, é o que se vê na primeira parte do inciso I da **Súmula 383 do TST**:

RECURSO. MANDATO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. CPC DE 2015, ARTS. 104 E 76, § 2º CPC.

I – É inadmissível recurso firmado por advogado sem procuração juntada aos autos até o momento da sua interposição, salvo mandato tácito.

Na segunda hipótese, há um novo advogado atuando no processo porque, por exemplo, o antigo patrono por algum motivo não pode interpor o recurso. Neste caso, para evitar a preclusão temporal⁵⁸ o novo advogado está autorizado, excepcionalmente, a interpor recurso sem procuração (art. 104 CPC), mas deverá regularizar sua representação dentro do prazo de cinco dias, prorrogáveis por igual período mediante despacho do juiz, é o que se infere da segunda parte do inciso I da súmula 383 do TST:

RECURSO. MANDATO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. CPC DE 2015, ARTS. 104 E 76, § 2º CPC.

*I – (...) Em caráter excepcional (art. 104 do CPC de 2015), admite-se que o advogado, independentemente de intimação, exiba a procuração no prazo de 5 (cinco) dias após a interposição do recurso, prorrogável por igual período mediante despacho do juiz. Caso não a exiba, considera-se ineficaz o ato praticado e não se conhece do recurso.
(...)*

Quando o advogado estiver atuando no processo, mediante mandato tácito, a interposição de recursos sem a procuração física nos autos é garantida, já que pelo menos o nome do advogado consta na(s) ata(s) de audiência(s). Entretanto, a interposição de recurso pelo advogado detentor de mandato tácito só é válida dentro da instância trabalhista. Logo, para recursos ao STF, é necessária procuração expressa.

Outra hipótese bastante comum de irregularidade de representação é quando, apesar de a procuração já se encontrar nos autos, ela possuir vício que comprometa sua validade. Acontece, por exemplo, quando uma pessoa jurídica outorga poderes a advogado através de procuração. A pessoa jurídica pratica atos da vida civil através de seu representante legal. Deste modo, a procuração deve conter não apenas a qualificação da pessoa jurídica outorgante, mas, também, a qualificação de seu representante legal, a teor do art. 654, §1º, do Código Civil.

Neste caso, **já havendo procuração nos autos**, o relator responsável pela admissibilidade do recurso, intimará a parte através de seu advogado para que regularize a representação, no prazo de cinco dias. Caso a determinação seja descumprida, será negado seguimento ao recurso por inexistência do ato, de acordo

⁵⁸A preclusão temporal é a perda do direito de praticar determinado ato processual pela perda de prazo.

com o inciso II da Súmula 383 e incisos I e III da Súmula 456, ambas do TST:

Súmula nº 456 do TST – REPRESENTAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. PROCURAÇÃO. INVALIDADE. IDENTIFICAÇÃO DO OUTORGANTE E DE SEU REPRESENTANTE.

I - É inválido o instrumento de mandato firmado em nome de pessoa jurídica que não contenha, pelo menos, o nome do outorgante e do signatário da procuração, pois estes dados constituem elementos que os individualizam.

(...)

III – Caso a irregularidade de representação da parte seja constatada em fase recursal, o relator designará prazo de 5 (cinco) dias para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação, o relator não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente, ou determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido (art. 76, § 2º, do CPC de 2015).

“Que após a interposição do recurso, foi constatada que não havia identificação do outorgante e seu representante nos autos;”



Há **irregularidade de representação**, pois não há identificação do outorgante e de seu representante, e caso o vício não seja sanado no **prazo de cinco dias o recurso não deve ser conhecido**, nos termos das súmulas 456, I e II do TST.

Em igual caso, encontra-se o substabelecimento ocorrido em mandato tácito. O Tribunal Superior do Trabalho tem entendido que a via estreita e excepcional do mandato tácito não comporta substabelecimento, de modo que os poderes dados para o foro em geral, cláusula *ad juditia*, se exaure na pessoa do advogado outorgado, não sendo permitido o substabelecimento. Assim, caso advogado portador de mandato tácito substabeleça a outro advogado e este subscreva o recurso, haverá irregularidade de representação, a ser sanada no prazo de cinco dias da intimação, nos termos das Súmulas 383 e 456 do TST.

10. PREPARO: CUSTAS E DEPÓSITO RECURSAL

As custas têm um valor mínimo de R\$ 10,64 (dez reais e sessenta e quatro centavos), mas são calculadas da seguinte forma: se houver acordo, as custas são 2% (dois por cento) sobre o valor do acordo; se houver condenação, 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação; em qualquer outro caso em que não houver nem acordo, nem condenação, as custas serão 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, como por exemplo: processo extinto sem solução de mérito, julgamento improcedente da ação, ação declaratória julgada procedente, extinção do feito com

solução de mérito pelo reconhecimento de prescrição ou decadência, nos termos do art. 789 incisos I, II, III e IV da CLT.

Caso haja insuficiência no recolhimento das custas, deverá ser concedido pelo juiz ou relator, ao recorrente, um prazo de cinco dias para complementação. Não ocorrendo a complementação será declarado o recurso deserto, nos termos da OJ 140 SDI-1, TST.

Com a reforma trabalhista, o valor máximo para recolhimento das custas processuais é de quatro vezes o valor máximo de benefícios da Previdência Social, nos termos do art. 789, caput da CLT.

As custas devem ser **pagas no final** do processo do trabalho. Uma vez proferida a decisão e não havendo recurso, transitando em julgado a decisão, as custas devem ser recolhidas em até 48 (quarenta e oito) horas após o trânsito em julgado, sob pena de execução. Caso haja recurso, as custas devem ser recolhidas e comprovado o recolhimento dentro do prazo recursal. Note que o § 1º do art. 789 da CLT, ao utilizar a expressão “dentro do prazo recursal”, deixou claro que no prazo recursal de oito dias, por exemplo, o recurso pode ser interposto no quinto dia do prazo e as custas recolhidas e comprovado o recolhimento até o oitavo dia, nos termos da súmula 245 do TST.

As custas devem ser pagas pelo vencido (art. 789 § 1º CLT). No caso de julgamento procedente da reclamação trabalhista, pelo reclamado. No caso de julgamento improcedente, pelo reclamante, salvo se beneficiário da justiça gratuita, momento em que as custas serão dispensadas (art. 790 § 1º CLT). Havendo sucumbência recíproca⁵⁹, as custas serão pagas pelo reclamado vencido na demanda porque mesmo por mais ínfima que possa ter sido a condenação, houve condenação e as custas serão recolhidas em 2% (dois por cento) sobre a condenação.

11. DEPÓSITO RECURSAL

O depósito recursal tem natureza jurídica de **garantia do juízo**, a fim de evitar a utilização dos recursos com o único fim de atrasar o andamento processual. Assim, uma vez havendo condenação em pecúnia do reclamado, caso queira recorrer, deverá efetuar o depósito recursal, além do pagamento das custas processuais. O ideal é que o valor do depósito recursal fosse o valor da condenação. Todavia, o TST estabeleceu os valores máximos para cada depósito recursal, valores estes que são

⁵⁹Sucumbência recíproca é quando a ação é julgada parcialmente procedente significando que tanto reclamante quanto reclamado foram vencidos.

reajustados a cada ano sempre no mês de agosto. Abaixo, os valores atualizados até julho de 2024 (ATO SEGJUD.GP Nº 414/2023):

- a) Recurso ordinário: R\$ 12.665,14
- b) Recurso de revista: R\$ 25.330,28
- c) Recurso de Embargos: R\$ R\$ 25.330,28
- d) Recurso extraordinário: R\$ 25.330,28
- e) Recurso Ordinário em ação rescisória: R\$ 25.330,28
- f) Recurso de agravo de instrumento: 50% (cinquenta por cento) do valor do depósito recursal do recurso a ser destrancado.

Caso aquele condenado em pecúnia queira recorrer, o depósito recursal deverá ser realizado e comprovado dentro do prazo recursal. Note que o art. 7º da Lei 5.584/70, ao utilizar a expressão “dentro do prazo para interposição do recurso”, deixou claro que no prazo recursal de oito dias, por exemplo, o recurso pode ser interposto no quinto dia do prazo, as custas recolhidas e comprovadas no sexto e depósito recursal comprovado até o oitavo dia, nos termos da súmula 245 do TST.

A exceção é quanto ao depósito recursal do recurso de agravo de instrumento que, por força do § 7º do art. 899 da CLT, deve ser comprovado no ato de interposição do mesmo, ou seja, caso o recurso de agravo de instrumento seja interposto no quinto dia do prazo recursal, o comprovante de depósito recursal deve estar anexado ao agravo no momento de sua apresentação. Caso comprovado no sexto dia do prazo, por exemplo, ainda que dentro dos oitos dias, será o agravo de instrumento considerado deserto.

No caso do agravo de instrumento, o valor do depósito recursal equivale a 50% (cinquenta por cento) do valor do depósito recursal do recurso a ser destrancado.

À semelhança das custas processuais, o depósito recursal deve ser recolhido em seu valor exato. Caso haja insuficiência no recolhimento do depósito recursal, deverá ser concedido pelo juiz ou relator, ao recorrente, um prazo de cinco dias para complementação. Não ocorrendo a complementação, será declarado o recurso deserto, nos termos da OJ 140 SDI-1 TST.

A cada novo recurso, deverá ser feito um novo depósito recursal em sua integralidade. Mas, uma vez garantido integralmente o juízo, nenhum valor mais poderá ser exigido como depósito, pena de cerceamento de defesa, nos termos da

súmula 128 inc. I, TST.

Da redação do dispositivo, entende-se que o depósito recursal tem seus valores máximos, como visto acima. Sua finalidade não é, no entanto, impedir a interposição de recursos, mas sim evitar a interposição de recursos protelatórios, sem nenhum fundamento, de modo que se o recorrente tiver certeza de que seu direito é bom, não terá qualquer prejuízo ao recorrer e efetuar o depósito recursal, até mesmo porque, se vencedor, no final da demanda poderá levantar o valor em seu favor, mediante alvará judicial, art. 899, §1º, CLT.

12. DEPÓSITO RECURSAL E CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA

No caso de condenação solidária entre duas ou mais empresas como, por exemplo, terceirização ilícita ou empresas de grupo econômico etc., geralmente, caso as empresas condenadas solidariamente entre si queiram recorrer, o **depósito recursal feito por uma delas aproveita as demais**, salvo se aquela empresa que realizou o depósito recursal pretender sua exclusão da lide. Neste caso, a outra empresa condenada deverá realizar o depósito recursal, sob pena de deserção, Súmula 128, III, TST.

Capítulo 17

RECURSO ORDINÁRIO

1. RECURSO ORDINÁRIO

Recurso ordinário é o recurso cabível da primeira decisão que julgar o processo na instância ordinária. Vale dizer que instância pode ser dividida em: instância ordinária e extraordinária. Na instância ordinária é possível, regra geral, o exame e o reexame de fatos e provas. Já na instância extraordinária, não é possível o exame ou reexame de fatos e provas, porque a matéria discutida é unicamente de direito.

A instância ordinária trabalhista é composta pelos Juízes do Trabalho (antigas Varas do Trabalho) e os Tribunais Regionais do Trabalho. A instância extraordinária, por sua vez, pode ser dividida em Tribunal Superior do Trabalho e Supremo Tribunal Federal⁶⁰.

Instâncias Ordinárias	Instâncias Extraordinárias
Varas do Trabalho e TRT	TST e STF
É perfeitamente possível a revisão ou reexame de matéria de fato e de direito	Só cabe exame de matéria de direito

O recurso ordinário, no processo do trabalho, cabe das decisões definitivas ou terminativas dos juízes do Trabalho (varas do trabalho) e dos Tribunais Regionais do Trabalho em processos de sua competência originária:

Art. 895, CLT. Cabe **recurso ordinário** para a instância superior:

I - das decisões definitivas ou terminativas das Varas e Juízo, no prazo de 8 (oito) dias; e

II - das decisões definitivas ou terminativas dos Tribunais Regionais, em processos de sua competência originária, no prazo de 8(oito) dias, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos.

Para se entender o cabimento do recurso ordinário no processo do trabalho,

⁶⁰ Existem casos em que tanto Tribunal Superior do Trabalho quanto o Supremo Tribunal Federal serem considerados instância ordinária e apreciarem, ainda que de forma mediata, matéria de fato, como no caso das ações rescisórias de competência originária do TST e STF em que o vício apontado na decisão a ser rescindida é a prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. Apesar de se questionar na ação de forma imediata a coisa julgada, que é material de direito e de ordem pública, mas imediatamente terá que ser provado nos autos os fatos da causa. Também são instância ordinária, apesar de nestes casos a matéria ser de direito, quando forem julgados mandados de segurança, habeas corpus, habeas data e mandados de injunção de competência originária do TST e a decisão das ações for denegatória. Destas decisões, caberá caberá recurso ordinário para o STF (art. 102, II, “a” da CF).

deve-se ter em mente o que significa competência funcional originária. Competência funcional, também conhecida como competência orgânica ou de órgão, é a função que cada órgão tem para fazer determinada coisa dentro de um conjunto. Imagine a Justiça do Trabalho como um todo, como um conjunto. Por força do art. 111 da CF, esse todo, esse conjunto chamado Justiça do Trabalho é dividido em três órgãos distintos: os Juízes do Trabalho, os Tribunais Regionais do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho.

Cada órgão desses tem uma competência funcional prevista em lei, ou seja, cada um deles tem uma função específica e que só ele pode fazer. Por exemplo, somente os **Juízes do Trabalho** (Varas do Trabalho) podem processar e julgar as reclamações trabalhistas (art. 652 CLT). Já os **Tribunais Regionais do Trabalho não podem**. Tanto é verdade que se se ingressar com reclamação trabalhista diretamente no TRT, este órgão se julgará funcionalmente *incompetente*, determinando a remessa da reclamação para um dos Juízes do Trabalho (ou Varas do Trabalho). Note que a incompetência **funcional é absoluta**, não admitindo modificação e podendo ser conhecida de ofício pelo Juiz ou Tribunal.

Já os **Tribunais Regionais do Trabalho** têm competência funcional para, por exemplo, processar e julgar as ações rescisórias das sentenças dos Juízes do Trabalho transitadas em julgado (art. 678, I, c, da CLT). Logo, se se ingressar com dita ação rescisória perante um Juiz do Trabalho ou perante o Tribunal Superior do Trabalho, estes irão se declarar incompetentes funcionalmente. Já o Tribunal Superior do Trabalho tem competência funcional para processar e julgar os mandados de segurança contra atos dos ministros do próprio TST (art. 2º da Lei 7.701/88). Caso se ingresse com essa dita ação perante os Juízes do Trabalho ou perante os TRTs, eles se julgarão funcionalmente incompetentes.

Como já se notou, cada órgão de jurisdição trabalhista tem sua própria competência funcional. Esta, por sua vez, pode ser originária ou derivada. Diz-se originária quando o órgão tem competência para apreciar a ação pela primeira vez. Diz-se derivada quando o órgão tem competência para apreciar o recurso da decisão. Por exemplo: os Juízes do Trabalho têm competência funcional originária para processar e julgar as reclamações trabalhistas que visem o reconhecimento de vínculo e pagamento de verbas rescisórias e indenizatórias. Julgada a reclamação pelo Juiz do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho tem competência funcional derivada para processar e julgar o recurso ordinário da decisão do Juiz do Trabalho que julgou a reclamação (art. 895, I CLT).

Os **Tribunais Regionais do Trabalho** têm competência funcional originária para processar e julgar a ação rescisória de sentença de Juiz do Trabalho transitada

em julgado (art. 678, I, c, da CLT). Julgada a ação rescisória pelo TRT, o Tribunal Superior do Trabalho tem competência funcional derivada para processar e julgar o recurso ordinário da decisão do TRT que julgou a rescisória (art. 895, II CLT).

O **Tribunal Superior do Trabalho**, por sua vez, tem competência funcional originária para processar e julgar os mandados de segurança contra atos abusivos de ministros do próprio TST (art. 2º Lei 7.701/88). Julgado o mandado de segurança e desde que a decisão tenha sido denegatória da segurança impetrada, o Supremo Tribunal Federal terá competência funcional derivada para processar e julgar o recurso ordinário (constitucional) do acórdão do TRT que negou a segurança (art. 102, II, a da CF).

1.1. Competência originária dos órgãos de jurisdição trabalhista

São ações de competência originária dos Juízes do Trabalho: reclamação trabalhista, ação de consignação em pagamento, inquérito judicial para apuração de falta grave, ação civil pública, ação de cumprimento, ações possessórias, ações ordinárias, mandado de segurança contra ato de autoridade administrativa (art. 114 incisos IV e VII CF). Da decisão que julgar qualquer destas ações, caberá recurso ordinário para o TRT (art. 895, inciso I, da CLT).

São ações de competência originária dos Tribunais Regionais do Trabalho: mandado de segurança contra ato de Juiz do Trabalho, mandado de segurança contra ato de Desembargador do próprio TRT, ação rescisória de sentença de Juiz do Trabalho transitada em julgado, ação rescisória de acórdão do próprio TRT transitada em julgado, habeas corpus contra ato de Juiz do Trabalho, habeas data contra ato de Juiz do Trabalho e dissídio coletivo quando o dissídio envolver a área de um único TRT. Da decisão que julgar qualquer destas ações caberá recurso ordinário para o TRT (art. 895, inciso II, da CLT).

São ações de competência originária do Tribunal Superior do Trabalho: mandado de segurança contra ato de Ministro do próprio TST, ação rescisória de acórdão do próprio TST transitada em julgado, habeas corpus contra ato de Desembargador do TRT, habeas data contra ato de Desembargador do TRT e dissídio coletivo quando o dissídio envolver a área de mais de um TRT. Da decisão que julgar o mandado de segurança, o habeas corpus, o habeas data e desde que seja denegatória a decisão caberá recurso ordinário para o STF (art. 102, inciso II, alínea “a” da CF). Quanto às demais ações, os recursos respectivos serão vistos nos próximos tópicos e capítulos.

1.2. Decisões definitivas e terminativas

Sinteticamente, podemos dividir as decisões em: definitivas, terminativas e interlocutórias. As **decisões definitivas** são aquelas que julgam o mérito do processo, solucionam o mérito do processo (art. 487 CPC). Em regra, são decisões de direito material⁶¹ decidindo a existência ou não do vínculo empregatício, o direito ou não às verbas trabalhistas rescisórias ou indenizatórias, direito ou não à estabilidade etc. Desde que haja recurso previsto em lei, são recorríveis.

As **decisões terminativas** são aquelas que solucionam uma questão de direito processual. O magistrado, ao decidir a questão processual, acaba por extinguir o feito sem solução de mérito (art. 485, CPC), pois acabou por entender que o processo continha vício processual insanável, como por exemplo, algumas das preliminares previstas no art. 330 do CPC. O magistrado, ao entender inepta a petição inicial, extingue o feito sem solução de mérito e dessa decisão, desde que haja previsão legal, cabe recurso.

Por fim, existem, ainda, as **decisões interlocutórias**. Estas, à semelhança das terminativas, também decidem uma questão processual, incidental, mas ao contrário das terminativas, que acabam por extinguir o feito sem solução de mérito, o juiz da causa, ao resolver uma questão incidental, deixa o processo fluir, continuar até o termo final. Por exemplo: em audiência, o advogado da reclamada alega em contestação inépcia da petição inicial. Caso o juiz, ao decidir a questão processual (inépcia), acolha a preliminar e extinga o feito sem solução de mérito, o faz por decisão terminativa. Caso o juiz rejeite a preliminar de inépcia, o processo continua até seu desfecho e o juiz o faz mediante decisão interlocutória.

As decisões interlocutórias, todavia, são irrecorríveis de imediato, somente comportando recurso quando da sentença definitiva (§1º do art. 893 CLT). Assim, a parte interessada que se sentiu prejudicada pelo indeferimento da preliminar (reclamada), protesta em audiência (arts. 794 e 795 da CLT) para resguardar seu direito de, quando da sentença final, levantar em seu recurso ordinário, novamente, a preliminar de inépcia. Caso não proteste, ocorrerá a preclusão lógica, concordando com a decisão judicial de indeferimento da preliminar de inépcia, não mais podendo alegá-la no processo, como visto no capítulo sobre nulidades processuais.

Diante do que aqui foi visto, cabe recurso ordinário não apenas das decisões dos Juízes do Trabalho em processos de sua competência originária para o Tribunal do Trabalho, mas também dos Tribunais Regionais do Trabalho em processos de sua

⁶¹Em outros capítulos mais adiante, veremos a possibilidade de uma decisão de mérito solucionar questões de cunho processual. Por enquanto, fiquemos por aqui.

competência originária para o Tribunal Superior do Trabalho, como também pode caber recurso ordinário de processos de competência originária do Tribunal Superior do Trabalho para o Supremo Tribunal Federal (art. 102 II “a” da CF).

1.3. O que é Cerceio de Defesa? (art. 5º, LV, CF)

Para a nossa segunda fase da OAB em Direito do Trabalho, consideraremos cerceio de defesa qualquer ato praticado pelo Juiz do Trabalho ou servidor em processo judicial ou administrativo **CONTRÁRIO À LEI OU CONSTITUIÇÃO FEDERAL** que impeça, prejudique, inviabilize, dificulte o direito da parte, seja ela reclamante ou reclamada, de se defender ou provar seu direito.

Assim, uma citação nula, porque feita em desconformidade com a lei, ou inexistente, impede o direito do réu de se defender no processo. Uma decretação de revelia ou confissão ficta porque o preposto da reclamada não era empregado, sendo a reclamada microempresa ou empresa de pequeno porte ou empregadora doméstica. Quando o Juiz do Trabalho nega o pedido da parte de juntada de documento para a prova de determinado fato.

Quando o Juiz do Trabalho nega o pedido da parte de oitiva de testemunha para a prova de determinado fato. Quando o Juiz do Trabalho nega o pedido da parte para realização de perícia para a prova de determinado fato. Quando o Juiz do Trabalho nega o pedido da parte de concessão de prazo, dilação de prazo, devolução de prazo para a prática de determinado ato. Quando, enfim, a parte ou seu procurador pedem alguma coisa ao Juiz do Trabalho e ele nega e isso dificulta sua vida no processo isto é CERCEIO DE DEFESA.

O que pedir?

Em audiência, quando se protesta contra ato do Juiz que gerou cerceio de defesa, o advogado tem que pedir que o Juiz o permita praticar o ato processual tal qual por ele requerido: determinar nova citação, ouvir a testemunha, juntar o documento, realizar a perícia, devolver ou conceder ou prorrogar o prazo processual, etc.

No caso de alegação de cerceio de defesa em grau de recurso, deve-se pedir a **NULIDADE DA SENTENÇA** por CERCEIO DE DEFESA, para que o processo volte à instância de origem (Vara do Trabalho, por exemplo) e o ato possa ser praticado tal qual pelo advogado requerido: determinar nova citação, ouvir a testemunha, juntar o documento, realizar a perícia, devolver ou conceder ou prorrogar o prazo processual, etc.

Exemplos mais comuns de cerceio de defesa

- a) Em audiência trabalhista, o Juiz do Trabalho decretou a revelia e a confissão ficta da empresa PROTROMBINA-ME uma vez que ficou provado que o preposto não era seu empregado.
- b) Em audiência trabalhista, o Juiz do Trabalho decretou a revelia e a confissão ficta da empregadora doméstica DONA CHOCOTONA uma vez que ficou provado que o preposto não era seu empregado.
- c) Em audiência trabalhista, numa relação de terceirização da empresa A compareceu e contestou e a empresa B nem compareceu e tampouco contestou. O Juiz decretou sua revelia e confissão ficta.
- d) O Juiz do Trabalho julgou procedente reclamação trabalhista reconhecendo o direito do reclamante ao adicional de insalubridade/periculosidade, sem a realização de perícia.
- e) O Juiz do Trabalho indeferiu a oitiva de testemunha em procedimento sumaríssimo que não compareceu à audiência na qual deveria depor, apesar de comprovado o seu convite.
- f) O Juiz do Trabalho indeferiu a oitiva de testemunha em procedimento ordinário que não compareceu à audiência na qual deveria depor, apesar de requerido o convite da mesma em audiência pela parte interessada.
- g) O Juiz do Trabalho decretou a confissão ficta da reclamante depois que não compareceu à audiência em prosseguimento na qual deveria depor, sem que o juiz houvesse cominado a pena de confissão.

Quando não é Cerceio de Defesa

Nunca se esqueça que a negativa do juiz de deixar a parte produzir determinado tipo de prova somente é cerceio de defesa se a decisão dele, juiz, estiver contra a Lei, Constituição Federal, súmula ou OJ. Assim, caso a decisão que negou o pedido do advogado ou parte estiver em conformidade com a lei ou jurisprudência, não poderá ser considerada cerceio de defesa.

Qual a tese jurídica?

- a) Reclamada alega cerceio de defesa pela citação por edital depois de comprovado nos autos que não foi citada por carta registrada, por retirar a numeração do prédio, de modo que os ARs eram devolvidos como “endereço não encontrado”.

- b) Em audiência trabalhista, o Juiz do Trabalho decretou a revelia e a confissão ficta da empresa TROMBOPLASTINA S.A., uma vez que ficou provado que o preposto não era seu empregado.
- c) O Juiz do Trabalho indeferiu juntada de documento depois de acabada a fase de instrução processual, tendo ficado provado nos autos que o advogado não havia juntado porque esqueceu.
- d) O Juiz do Trabalho decretou a confissão ficta da reclamada, depois que não compareceu à audiência em prosseguimento na qual deveria depor, tendo o juiz cominado a pena de confissão.

A DISTRIBUIÇÃO E IMPUGNAÇÃO DO ÔNUS DA PROVA NO PROCESSO DO TRABALHO

Ônus da prova no Processo do Trabalho é o encargo de alguém, reclamante ou reclamado, ter que provar determinado fato. Se provar o fato, ganha a pretensão. Se não provar o fato, perde a pretensão. O ônus da prova pode ser do autor ou do réu, tanto é verdade que o art. 818, incisos I e II da CLT estabelecem, respectivamente, que ao autor cabe a prova dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu, os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

O ônus da prova no Processo do Trabalho é distribuído em relação a cada pedido feito na petição inicial, depois de contestada a ação. Assim, para cada pedido feito e após a contestação pelo reclamado, o juiz deverá estabelecer os pontos controvertidos e distribuir o ônus de provar cada fato relativo a cada pedido entre reclamante e reclamado.

Assim, se o ônus de provar determinado fato (pedido) é do autor, o reclamado poderá entrar mudo e sair calado da audiência, pois caso o autor não prove o fato, este terá o pedido julgado improcedente, ainda que o reclamado não produza qualquer contraprova. O oposto é verdadeiro: se o ônus de provar determinado fato (pedido) é do réu, o reclamante poderá entrar mudo e sair calado da audiência, pois caso o reclamado não prove o fato, o autor terá o pedido julgado procedente ainda que o reclamante não produza qualquer prova.

A distribuição do Ônus da Prova

A distribuição do ônus da prova se faz com obediência às seguintes regras que são postas em ordem decrescente de importância, do maior para o menor:

- 1) Quem tem obrigação legal de ter o documento, tem que provar;
- 2) O comum, o ordinário se presume; o especial, o extraordinário se prova;
- 3) Quem alega fato novo, tem que provar.

■ Regra 1:

Se alguém tem que ter o documento ou por obrigação legal ou convencional, esta pessoa, seja ela autora ou ré, terá que provar, com a apresentação do documento em audiência, a existência ou não do direito. Por exemplo: por mais que o empregado ingresse com reclamação trabalhista contra o empregador, afirmando que já está há três meses trabalhando sem receber salários, neste caso o ônus da prova não é do autor que tem que provar os fatos constitutivos do seu direito, mas do réu, que tem que juntar os recibos de pagamento de salários e provar que os pagou e que, portanto, o autor não tem mais direito ao pagamento dos mesmos.

Mas por que o ônus é do reclamado? Por que o parágrafo único do art. 464 da CLT estabelece que o empregador pagará os salários do empregado contra-recibo assinado pelo empregado. Assim, por força de lei, o empregador deve ter o comprovante e provar o fato extintivo do direito do autor.

■ Regra 2:

Tudo o que for normal, comum, ordinário é presumido ser ou existir no Direito, se presume e o que é anormal, incomum, extraordinário, tem que ser provado. Por exemplo: o comum e normal é o empregado trabalhar oito horas por dia, até porque é a jornada máxima normal estabelecida no inc. XIII do art. 7º da CF. Quando o empregado ingressa com reclamação trabalhista contra o empregador alegando a prestação de horas extras (extraordinárias) ele está alegando o incomum, o extraordinário, pois está afirmando possuir jornada maior que a estabelecida em lei. Assim, tem o reclamante o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e, caso não prove, terá julgado improcedente seu pedido.

■ **Regra 3:**

Quem alega fato novo acaba por reconhecer o fato e negar o direito, o que é diferente da defesa direta de mérito. E o que é a defesa direta de mérito? É quando o réu nega completa e totalmente o fato ou fundo de direito. Por exemplo: o empregado ingressa com reclamação trabalhista, alegando ter trabalhado durante dois anos para o reclamado, preenchendo os requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, com o pedido de reconhecimento de vínculo e direitos daí decorrentes. O empregador, reclamado, ao contestar a reclamação trabalhista nega totalmente o fato, ou seja, nega a prestação de serviços, dizendo que aquele reclamante nunca trabalhara para si e que, portanto, nunca poderia ser ou ter sido seu empregado. O reclamado não alegou nenhum fato novo, apenas negou de forma direta o direito, fazendo com que o ônus da prova recaísse sobre o reclamante, que teria que provar os fatos constitutivos (prestação de serviços e vínculo empregatício) de seu direito.

Note que no exemplo acima, o reclamado negou totalmente o fato, pois não reconheceu nem a prestação de serviços (fundo ou base de direito) e nem o vínculo. No entanto, no caso de o reclamante ingressar com reclamação trabalhista alegando ter trabalhado durante dois anos para o reclamado, preenchendo os requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, com o pedido de reconhecimento de vínculo e direitos daí decorrentes e o empregador, reclamado, ao contestar a reclamação trabalhista reconhecer a prestação de serviços, mas afirmar que o trabalhador era autônomo ou eventual ou estagiário ou voluntário ou avulso, acabou por alegar fato novo e atrair para si o ônus da prova, tendo agora, o reclamado, que provar o fato impeditivo do direito do reclamante.

Conflito de regras

Existe a possibilidade de as três regras brigarem ou concorrerem entre si, ou seja, com relação a determinado fato, a regra 1 possa entrar em confronto com a regra 2. Tome-se como exemplo o empregado que ingressa com reclamação alegando a prestação de horas extras contra empresa que possui mais de vinte empregados.

Nesse caso, a regra 1 entra aparentemente em conflito com a regra 2, pois quando o empregado alega a prestação de horas extras, acaba por alegar o extraordinário e ter que provar o trabalho acima da jornada normal. Por outro lado, o empregador ao ter mais de vinte empregados, tem obrigação, por lei, de ter o controle de ponto de todos os seus empregados (art. 74, §2º da CLT) e quem tem obrigação, legal ou convencional, de ter o documento tem que provar.

E aí, como sair dessa? Nesse caso cabe o inciso I do art. 818 da CLT ou o inciso

II?

É o caso o inciso II do art. 818 da CLT, sendo do empregador o ônus de provar a inexistência de horas extras. Quando duas ou mais regras entrarem em aparente conflito entre si, a regra 1 prevalecerá sobre a 2 que prevalecerá sobre a 3. Assim, a obrigação legal de ter o documento prevalece sobre o comum, que se presume e o extraordinário se prova, de modo que caberá ao empregador provar a inexistência das horas extras, isto é, algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Aplicação no recurso ordinário

A questão da distribuição do ônus da prova no Processo do Trabalho tanto poderá cair nas questões quanto na peça profissional, principalmente se a peça for um recurso, como o ordinário ou o de revista, por exemplo:

- a) Empregado ingressa com reclamação trabalhista alegando a prestação de 2 horas extras por dia por trabalhar das 08h-12h e das 14h-20h de segunda a sexta-feira e aos sábados, das 8h-12h, em empresa com 15 empregados. Designada audiência de instrução, as testemunhas do reclamante não souberam explicar de forma satisfatória a jornada do autor e o reclamado dispensou a oitiva de suas testemunhas. O juiz, na sentença, reconheceu a prestação de horas extras e condenou o empregador ao pagamento de duas horas extras diárias, pelo fato de não ter juntado os cartões de ponto e comprovado a inexistência de horas extras. Como advogado da empresa, recorra.
- b) Empregado ingressa com reclamação trabalhista alegando a prestação de 2 horas extras por dia por trabalhar das 08h-12h e das 14h-20h de segunda a sexta-feira e aos sábados, das 8h-12h, em empresa com 21 empregados. Designada audiência de instrução, as testemunhas do reclamante não souberam explicar de forma satisfatória a jornada do autor e o reclamado dispensou a oitiva de suas testemunhas. O juiz na sentença, não reconheceu a prestação de horas extras e deixou de condenar o empregador ao pagamento de duas horas extras diárias, pelo fato de que as testemunhas do reclamante não produziram prova robusta e cabal da prestação do trabalho extra. Sabe-se que o empregador não juntou os cartões de ponto. Como advogado do empregado, recorra.
- c) Empregado ingressa com reclamação trabalhista requerendo o pagamento do valor relativo ao vales transporte não concedidos na vigência do contrato de trabalho. Contestada a ação, o empregador argumenta que o empregado não

fazia jus ao vale porque morava próximo ao local de trabalho. Designada audiência de instrução e julgamento, nem empregado e nem empregador apresentaram testemunhas e nem juntaram qualquer tipo de documento. Na sentença o juiz julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que cabia ao empregado a prova dos fatos constitutivos do seu direito.

- d) Empregado ingressa com reclamação trabalhista requerendo equiparação salarial, apontando como paradigma, empregado da mesma empresa cujo padrão salarial é mais elevado que o do reclamante, muito embora ambos exercessem a mesma função e na mesma localidade. O empregador, na contestação, afirmou que a diferença salarial se dá em virtude de que a perfeição técnica do paradigma é bastante superior à do reclamante. Designada audiência de instrução, compareceram as partes, mas deixaram de apresentar testemunhas e documentos. Na sentença o juiz julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que cabia ao empregado a prova dos fatos constitutivos do seu direito.
- e) Empregado ingressa com reclamação trabalhista requerendo a nulidade da dispensa com justa causa e o reconhecimento da dispensa sem justa causa. O empregador, na contestação, alega que o empregado cometeu falta grave ao subtrair objeto pessoal de outro colega de trabalho durante o expediente. Designada audiência de instrução, compareceram as partes, mas deixaram de apresentar testemunhas e documentos. Na sentença o juiz julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que cabia ao empregado a prova dos fatos constitutivos do seu direito.

Capítulo 18

RECURSO ADESIVO

Recurso adesivo é aquele utilizado pela parte quando perde o prazo para o recurso principal, desde que a parte adversa tenha também interposto seu recurso. É aquele interposto no prazo para resposta ao recurso interposto pela outra parte, e que fica “adesivo” (dependente, colado) ao primeiro recurso (interposto pela parte contrária), motivo pelo qual, se o recurso principal não for admitido ou se a outra parte dele desistir, o recurso adesivo também se extinguirá.

Perfeitamente cabível no Processo do Trabalho por força da aplicação subsidiária do **art. 997, do CPC, a súmula 283, TST**, esclarece que caberá recurso adesivo em recurso ordinário, recurso de revista, embargos de divergência e agravo de petição. O recurso adesivo é interposto dentro do prazo das contrarrazões ao recurso principal da parte adversa.

ATENÇÃO!!! **GRIFAR** AS PALAVRAS DESTACADAS NA CLT:

Art. 997. *Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.*

§ 1º Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro.

§ 2º O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:

I - será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder;

II - será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial;

III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível.

Súmula nº 283 do TST. *O recurso adesivo é compatível com o processo do trabalho e cabe, no prazo de 8 (oito) dias, nas hipóteses de interposição de recurso ordinário, de agravo de petição, de revista e de embargos, sendo desnecessário que a matéria nele veiculada esteja relacionada com a do recurso interposto pela parte contrária.*

Capítulo 19

RECURSO DE REVISTA

1. RECURSO DE REVISTA

De acordo com a lei, cabe recurso de revista, para a turma do Tribunal Superior do Trabalho, das decisões proferidas em recurso ordinário, em dissídio individual pelos Tribunais Regionais do Trabalho. Da simples leitura do *caput* do art. 896 da CLT tiramos três informações importantes: um, que o recurso de revista é o recurso cabível das decisões dos TRTs em recurso ordinário. Logo, só cabe recurso de revista caso o TRT julgue um recurso ordinário. Se o TRT julgar qualquer outra coisa, como um agravo de instrumento (súmula 218, TST) ou mandado de segurança ou ação rescisória⁶², por exemplo, não cabe recurso de revista, posto que só cabe recurso de revista das decisões dos TRTs em recurso ordinário⁶³.

Art. 896, CLT. Cabe Recurso de Revista para Turma do Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas em grau de recurso ordinário, em dissídio individual, pelos Tribunais Regionais do Trabalho, quando (...).

O recurso de revista é de competência funcional derivada das oito turmas do TST. Assim, **não tem competência funcional** derivada para julgar recurso de revista a Seção de Dissídios Individuais, quer a 1 ou a 2 ou a Plena ou a Transitória, tampouco tem competência para processar e julgar recurso de revista o pleno do Tribunal Superior do Trabalho.

Três, que só cabe recurso de revista de dissídios individuais, não cabendo recurso de revista de dissídios coletivos. Assim, das decisões dos TRTs em dissídios coletivos de sua competência funcional originária, cabe recurso ordinário para o TST, nos termos do inciso II do art. 895 da CLT.

1.1. Hipótese de cabimento: alínea “a” do art. 896 da CLT

Para se entender as hipóteses de cabimento do recurso de revista quanto à alínea “a” do art. 896 da CLT “(...) *derem ao mesmo dispositivo de lei federal*”

⁶²Do mandado de segurança e da ação rescisória cabe recurso ordinário para o TST (art. 895, inc. II, do TST). Do agravo de instrumento não cabe nenhum recurso porque não há previsão legal, salvo afronta à CF, momento em que caberá recurso extraordinário direto para o STF (art. 102, inc. III, “a” da CF).

⁶³Excepcionalmente, no processo de execução, existe a possibilidade do recurso de revista contra decisão do TRT em agravo de petição e somente quando houver ofensa direta e literal à Constituição Federal, nos termos do § 2º do art. 896 da CLT. Assim, a regra permanece a mesma: recurso de revista só das decisões dos TRTs em recurso ordinário, no processo de conhecimento.

interpretação diversa da que lhe houver dado outro Tribunal Regional do Trabalho, no seu Pleno ou Turma, ou a Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, ou contrariarem súmula de jurisprudência uniforme dessa Corte ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal;” é preciso que se tenha em mente que um mesmo dispositivo de lei federal pode ser interpretado de forma diferente por dois ou mais TRTs, por exemplo.

Tem que se ter em mente que um juiz nunca aplicará a lei; um promotor nunca defenderá a aplicação da lei; um advogado nunca pedirá a aplicação da lei. O que eles fazem, na verdade, é cada um aplicar, defender e pedir a aplicação de suas próprias interpretações da lei. Assim, é perfeitamente possível que um mesmo dispositivo de lei federal seja interpretado por dois ou mais TRTs de forma diferentes.

Tome-se como exemplo o art. 133 inc. II da CLT, dispositivo de lei federal que estabelece que *“não terá direito a férias o empregado que, no curso do período aquisitivo (...) inc. I - permanecer em gozo de licença, com percepção de salários, por mais de 30 (trinta) dias;”*. Exemplificativamente, o Tribunal Regional do Trabalho da 27ª Região,⁶⁴ ao julgar um recurso ordinário em que se questionava a perda do direito às férias de empregado por ter permanecido mais de trinta dias de licença remunerada, aplicou, ao julgar o caso, não o inciso II do art. 133 da CLT, mas sua interpretação, decidindo no acórdão que o empregado perde o direito às férias, mas não perde o terço constitucional.

O advogado do empregador, inconformado com a decisão, querendo retirar qualquer direito do empregado às férias ou ao terço constitucional, que seja, faz aprofundada pesquisa e encontra uma decisão de outro tribunal, no caso, do Tribunal Regional do Trabalho da 36ª Região⁶⁵ que, ao julgar um recurso ordinário em caso idêntico ao seu em que se questionou também a perda do direito às férias de empregado que permaneceu mais de trinta dias de licença remunerada, aplicou interpretação do inc. II do art. 133 da CLT diversa do TRT da 27ª Região, na medida em que decidiu no acórdão que o empregado perde não apenas o direito às férias, mas, inclusive, perde o terço constitucional, pois quem perde o principal perde o acessório⁶⁶.

Uma vez encontrada a divergência de interpretação, por exemplo, entre dois

⁶⁴Tribunal Regional fictício.

⁶⁵Tribunal Regional fictício.

⁶⁶Por incrível que possa parecer, existe mesmo essa controvérsia entre alguns tribunais regionais sobre o inc. II do art. 133 da CLT. Pessoalmente, ficamos com a segunda tese.

TRTs distintos, obrigatoriamente⁶⁷, sobre o mesmo dispositivo de lei federal, preenchida está a hipótese de cabimento do recurso de revista. Demonstrada a divergência nos termos da súmula 337 do TST e § 1º-A incisos I, II e III do art. 896 da CLT, passa-se em seguida a sustentar nas razões do recurso de revista que a decisão do TRT da 27ª Região está errada, e porque está errada e que deve ser reformada.

No entanto, a divergência apta a ensejar o seguimento e o conhecimento do recurso de revista não é apenas aquela entre dois tribunais regionais distintos. A lei abriu a possibilidade de a divergência jurisprudencial sobre a interpretação de um mesmo dispositivo de lei federal ser demonstrada entre dois TRTs **ou** entre o TRT e a Seção de Dissídios Individuais do TST **ou** entre o TRT e uma OJ do TST **ou** entre o TRT e uma súmula do TST **ou** entre o TRT e uma súmula vinculante do STF, nos termos do art. 896, “a” da CLT.

1.2. Divergência entre dois TRTs

A divergência entre dois TRTs sobre a interpretação de um mesmo dispositivo de lei federal é a mais comum. Note-se que a alínea “a” do art. 896 da CLT exige que a divergência jurisprudencial seja entre dois tribunais regionais diferentes, não se admitindo a divergência, por exemplo, entre duas turmas do mesmo Tribunal Regional do Trabalho, nos termos da OJ 111 da SDI-1 do TST:

***SDI-1 OJ-111.** Não é servível ao conhecimento de recurso de revista aresto oriundo de mesmo Tribunal Regional do Trabalho, salvo se o recurso houver sido interposto anteriormente vigência da Lei nº 9.756/1998.*

Assim, a divergência pode ser entre as decisões do TRT 7ª Região, Ceará, e do TRT 6ª Região, Pernambuco, porque seriam decisões oriundas de TRTs distintos. O art. 678 da CLT permite que os Tribunais se dividam em turmas. Então, um tribunal regional composto por oito desembargadores, pode ser dividido em duas turmas, cada uma com três desembargadores porque, em regra, o Presidente do Tribunal e seu Vice não compõem as Turmas, compondo, entretanto, o Tribunal Pleno.

1.3. Divergência entre TRT e SDI do TST

Existe a possibilidade de a divergência apta a ensejar o conhecimento do

⁶⁷SDI-1 OJ-111 RECURSO DE REVISTA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ARESTO ORIUNDO DO MESMO TRIBUNAL REGIONAL. LEI Nº 9.756/1998. INSERVÍVEL AO CONHECIMENTO (nova redação) - DJ 20.04.2005. Não é servível ao conhecimento de recurso de revista aresto oriundo de mesmo Tribunal Regional do Trabalho, salvo se o recurso houver sido interposto anteriormente vigência da Lei nº 9.756/1998.

recurso de revista seja entre um TRT, no seu pleno ou turma, e a Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho. A única dificuldade aqui é entender que a SDI não se confunde com suas orientações jurisprudenciais. Pode-se dizer, inclusive, que toda OJ vem da SDI, mas nem tudo que vem da SDI é OJ.

A Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, criada pela Lei 7.701/88, tem como finalidade uniformizar o entendimento do TST sobre determinado assunto. Isto ocorre porque o TST é composto por 27 (vinte e sete) ministros divididos em 8 (oito) turmas, com três ministros por turma já que o Presidente do Tribunal, seu Vice e o Corregedor estão fora das turmas. Ocorre que cada ministro vota com base em seu livre convencimento, daí a composição das turmas ser preferencialmente ímpar, a fim de evitar empate nas decisões dos recursos de competência das turmas.

No entanto, cada turma pode ter seu próprio entendimento sobre a interpretação de determinado dispositivo de lei federal ou aplicação de dispositivo da Constituição Federal e que pode ser entendimento totalmente diverso das demais turmas do TST. Por exemplo, antigamente, antes de o entendimento ser pacificado no TST, sua primeira turma entendia que o empregado estável arbitrariamente despedido sem justa causa e que só deixava para entrar com reclamação trabalhista requerendo sua reintegração ou indenização substitutiva após o fim do período estável, não tinha direito nem à reintegração e nem à indenização do período estável, pois ao deixar para exercer seu direito de ação somente depois de acabado o período estável, o fez de forma abusiva, visto que sua inércia era vista como renúncia à própria garantia de emprego.

No entanto, a quinta turma do TST, ao julgar um recurso de revista em idêntica situação - empregado estável arbitrariamente despedido sem justa causa e que só deixava para entrar com reclamação trabalhista requerendo sua reintegração ou indenização substitutiva após o fim do período estável – entendeu que o empregado tem direito, sim, à indenização substitutiva, pois seu direito de ação está limitado apenas ao prazo prescricional de dois anos após a extinção do contrato de trabalho, não se caracterizando qualquer abuso de direito.

A divergência de entendimento sobre o mesmo assunto é crucial para a oxigenação e atualização do Direito, mas não é razoável, tampouco seguro, que um tribunal superior tenha entendimentos tão diferentes sobre o mesmo tema. Daí, a parte que deseje a reforma da decisão, poderá demonstrar a divergência de entendimento entre as turmas do TST sobre o mesmo assunto, interpondo para a SDI um recurso chamado de Embargos ou Embargos ao TST ou ainda Embargos de Divergência, previsto no inciso II do art. 894 da CLT, e que serão estudados no

próximo capítulo.

Quando a SDI julgar o recurso de Embargos e optar fundamentadamente por um dos entendimentos ou ainda por um terceiro⁶⁸, esta decisão refletirá naquele momento e enquanto não for substituído o entendimento dominante do Tribunal Superior do Trabalho não sumulado e ainda não pacificado por orientação jurisprudencial. É esta decisão que será a divergência apontada para o conhecimento e prosseguimento do recurso de revista.

1.4. Divergência entre TRT e Orientação Jurisprudencial do TST

Apesar de não prevista em lei, o TST vem admitindo como divergência ensejadora da admissibilidade do recurso de revista indicação de orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho, nos termos da OJ 219, SDI-1:

RECURSO DE REVISTA OU DE EMBARGOS FUNDAMENTADO EM ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO TST. É válida, para efeito de conhecimento do recurso de revista ou de embargos, a invocação de Orientação Jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho, desde que, das razões recursais, conste o seu número ou conteúdo.

A proposta de edição de orientação jurisprudencial parte da Comissão de Jurisprudência do TST e é necessário que o entendimento repetido da SDI esteja dentro de uma dessas situações⁶⁹:

I – dez acórdãos da Subseção respectiva reveladores da unanimidade sobre a tese;

OU

II – vinte acórdãos da Subseção respectiva prolatados por maioria de dois terços de seus integrantes.

Imagine que o TRT da 32ª Região⁷⁰, ao julgar um recurso ordinário, reformou sentença de Juiz do Trabalho para declarar nula perícia que classificou determinado ambiente como insalubre, porque feita por engenheiro do trabalho. No caso, aplicou sua interpretação do art. 195, *caput*, da CLT, na medida em que entendeu que a

⁶⁸Atualmente a controvérsia está pacificada através da OJ 399, SDI-1 do TST: ESTABILIDADE PROVISÓRIA. AÇÃO TRABALHISTA AJUIZADA APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE GARANTIA NO EMPREGO. ABUSO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. O ajuizamento de ação trabalhista após decorrido o período de garantia de emprego não configura abuso do exercício do direito de ação, pois este está submetido apenas ao prazo prescricional inscrito no art. 7º, XXIX, da CF/1988, sendo devida a indenização desde a dispensa até a data do término do período estável.

⁶⁹Art. 171 do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho (RITST)

⁷⁰Tribunal fictício

regra contida no dispositivo estabelece uma obrigatoriedade de que a averiguação de insalubridade seja feita por médico do trabalho e da periculosidade, por engenheiro do trabalho.

A parte prejudicada, a fim de interpor recurso de revista da decisão, faz pesquisa e encontra a OJ 165 da SDI-1 do TST, que esclarece que o art. 195 da CLT não faz qualquer distinção entre o médico e o engenheiro para efeito de caracterização e classificação da insalubridade e periculosidade. De posse do entendimento, demonstra a divergência entre o TRT da 32ª Região e a orientação jurisprudencial 165 da seção de dissídios individuais e preenche o requisito de admissibilidade do recurso, para logo após expor suas razões de direito pelas quais a decisão merece ser reformada.

1.5. Divergência entre TRT e súmula do TST

Outra divergência ensejadora de recurso de revista é aquela entre o TRT e uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho. A proposta para edição de súmula depende do requerimento de 10 (dez) ministros do TST e encaminhada a proposta à Comissão de Jurisprudência, após a decisão sobre cujo conteúdo se quer sumular se repita da seguinte forma⁷¹:

I – três acórdãos da Subseção Especializada em Dissídios Individuais, reveladores de unanimidade sobre a tese, desde que presentes aos julgamentos pelo menos 2/3 (dois terços) dos membros efetivos do órgão;

OU

II – cinco acórdãos da Subseção Especializada em Dissídios Individuais, prolatados por maioria simples, desde que presentes aos julgamentos pelo menos 2/3 (dois terços) dos membros efetivos do órgão;

OU

III – quinze acórdãos de cinco Turmas do Tribunal, sendo três de cada, prolatado s por unanimidade;

OU

IV – dois acórdãos de cada uma das Turmas do Tribunal, prolatados por maioria simples;

E

V – os acórdãos catalogados para fim de edição de Súmula deverão ser de relatores diversos, proferidos em sessões distintas.

⁷¹Artigo 165 do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho (RITST).

Em acórdão proferido pelo TRT da 27ª Região, o acórdão garantiu honorários advocatícios a advogado particular, ao entender que a assistência judiciária prevista nos §§1º e 2º do art. 14 da Lei 5.584/70, não afasta o deferimento da verba honorária do advogado particular na Justiça do Trabalho, prevista no art. 85 do CPC. O empregador, inconformado com a decisão, resolve recorrer de revista e aponta como divergência, aquela prevista no inciso I da súmula 219 do TST, segundo a qual honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho, somente se o empregado estiver assistido por advogado do sindicato de sua categoria profissional.

Demonstrada a divergência entre o TRT da 27ª Região e o inciso I da súmula 219 do TST, preenchido está o requisito de admissibilidade do recurso de revista, passando-se agora à exposição das razões de direito pelas quais a decisão merece ser reformada.

1.6. Divergência entre TRT e súmula vinculante do STF

Inovação trazida pela Lei 13.015/14 é a possibilidade de cabimento de recurso de revista quando houver divergência entre uma decisão de TRT e uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal

1.8. Hipótese de cabimento: alínea “c” do art. 896 da CLT

Cabe recurso de revista não apenas de divergência de interpretação de um mesmo dispositivo de lei federal entre dois TRTs **ou** entre o TRT e a Seção de Dissídios Individuais do TST **ou** entre o TRT e uma OJ do TST **ou** entre o TRT e uma súmula do TST **ou** entre o TRT e uma súmula vinculante do TST, nos termos do art. 896 alínea “a” da CLT, mas também cabe recurso de revista quando um Tribunal Regional do Trabalho, ao julgar um recurso ordinário em dissídio individual, proferir decisão com violação literal de disposição de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição Federal.

A título de exemplo, o art. 146, *caput* da CLT estabelece que seja qual for o motivo da demissão, o empregado fará jus à remuneração de férias simples ou em dobro, cujo direito tenha adquirido:

***Art. 146.** Na cessação do contrato de trabalho, qualquer que seja a sua causa, será devida ao empregado a remuneração simples ou em dobro, conforme o caso, correspondente ao período de férias cujo direito tenha adquirido.*

Determinado TRT, ao julgar um recurso ordinário, profere o seguinte acórdão:

“vistos, etc. (...) negado ao empregado o direito à remuneração de férias simples, uma vez que cometeu falta grave e a falta grave cometida consubstanciou-se em crime hediondo, capaz, inclusive, de afastar o direito adquirido às férias”. Note que na decisão, coincidentemente, o acórdão violou não apenas uma lei federal (art. 146, CLT), ao negar férias vencidas a empregado que cometeu falta grave, muito embora a lei esclareça que qualquer que seja o motivo da demissão, o empregado não perde o direito, mas também afrontou à Constituição Federal em seu art. 5º inciso XXXVI, na medida em que não respeitou o direito adquirido às férias.

Assim, da decisão do TRT em julgar o recurso ordinário pela violação direta de lei federal, caberá recurso de revista para a turma do TST. Pela afronta à Constituição Federal, também caberá recurso de revista e, não, recurso extraordinário, nos termos da alínea “c” do art. 896 da CLT.

Em se tratando de recurso de revista no procedimento sumaríssimo, somente será admitido recurso de revista por contrariedade à súmula de jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho ou a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal e por violação direta da Constituição Federal, nos termos do § 9º do art. 896 da CLT.

1.9. TRANSCENDÊNCIA

Art.896-A - O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica.

§ 1º São indicadores de transcendência, entre outros:

I - econômica, o elevado valor da causa;

II - política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal;

III - social, a postulação, por reclamante-recorrente, de direito social constitucionalmente assegurado;

IV - jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista.

§ 2º Poderá o relator, monocraticamente, denegar seguimento ao recurso de revista que não demonstrar transcendência, cabendo agravo desta decisão para o colegiado.

§ 3º Em relação ao recurso que o relator considerou não ter transcendência, o recorrente poderá realizar sustentação oral sobre a questão da transcendência, durante cinco minutos em sessão.

§ 4º Mantido o voto do relator quanto à não transcendência do recurso, será lavrado acórdão com fundamentação sucinta, que constituirá decisão irrecorrível no âmbito do tribunal.

§ 5º É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da

matéria.

§ 6º O juízo de admissibilidade do recurso de revista exercido pela Presidência dos Tribunais Regionais do Trabalho limita-se à análise dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos do apelo, não abrangendo o critério da transcendência das questões nele veiculadas.

Capítulo 20

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA

Quando a prova fala somente em EMBARGOS, está falando de *embargos de divergência*. Se ela quiser se referir aos embargos de declaração ou aos embargos de execução, ela dirá especificamente. Genericamente, EMBARGOS serão os de divergência.

De acordo com o **Art. 894, da CLT**, cabem embargos de divergência da Turma para a SDI, das decisões das Turmas que divergirem entre si, entre a Turma e a SDI, entre a Turma e a OJ, e entre a Turma e a Súmula.

ATENÇÃO!!! **GRIFAR** AS PALAVRAS DESTACADAS NA CLT:

Art. 894, CLT. *No Tribunal Superior do Trabalho cabem embargos, no prazo de 8 (oito) dias:*

*I – de **decisão não unânime** de julgamento que:*

a) conciliar, julgar ou homologar conciliação em dissídios coletivos que excedam a competência territorial dos Tribunais Regionais do Trabalho e estender ou rever as sentenças normativas do Tribunal Superior do Trabalho, nos casos previstos em lei; e (alínea “b”) Vetado)

II – das decisões das Turmas que divergirem entre si, ou das decisões proferidas pela Seção de Dissídios Individuais, salvo se a decisão recorrida estiver em consonância com súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal.

Por isso foi dito que nem tudo que se origina na SDI é OJ. As OJ's são criadas após repetidas decisões da SDI. Quando há entendimento da SDI, os entendimentos das Turmas não o superam, mas ao contrário, devem observá-lo.

Capítulo 21

RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL

O recurso ordinário constitucional, capitulado no art. 1.027, do CPC, somente é apreciado no STF ou STJ, tendo esta denominação porque permite o exame de matéria de fato e de direito, além de não ter limitação da matéria alegada, podendo ser invocado nos Tribunais Superiores.

O **ROC** é interposto para o **STF**, no prazo de 15 dias, contados da intimação do acórdão que **DENEGOU** o mandado de segurança, o mandado de injunção ou o habeas data, interpostos nos tribunais superiores enquanto única instância competente para processar tais ações, em observância à sua competência originária.

O ROC é interposto para o **STJ** quando **DENEGADO** o mandado de segurança, decidido em única instância nos Tribunais Regionais Federais ou nos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal. A competência originária dos Tribunais, nestes casos, deve ser observada nas Constituições Estaduais.

Se a medida é concessiva, cabe recurso extraordinário ou especial.

O efeito é devolutivo, podendo ser dado efeito suspensivo pelo relator.

O juízo de admissibilidade é feito no juízo “a quo”, conforme **arts. 1027 e 1028 do CPC**. Deve-se observar, para o seu julgamento, o Regimento Interno do STF ou STJ quanto a preparo e procedimento.

ATENÇÃO!!! GRIFAR AS PALAVRAS DESTACADAS NA CLT:

***Art. 1027, CPC.** Serão julgados em recurso ordinário:*

*I - pelo **Supremo Tribunal Federal**, os mandados de segurança, os habeas data e os mandados de injunção decididos em única instância pelos Tribunais superiores, quando denegatória a decisão;*

***Art. 1028, CPC.** Ao recurso mencionado no art. 1.027, inciso II, alínea “b”, aplicam-se, quanto aos requisitos de admissibilidade e ao procedimento, as disposições relativas à apelação e o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.*

ATENÇÃO:

***Art. 102, CF.** Compete ao **Supremo Tribunal Federal**, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:*

II - julgar, em recurso ordinário:

a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;

Para interpor Recurso Extraordinário é necessário provar a existência de repercussão geral. **Art. 102, §3º/CF**

Lei 11.418/06, Art. 2º, §3º

Sempre haverá repercussão geral quando a decisão for contrária à Súmula do STF.

ATENÇÃO!!! **GRIFAR** AS PALAVRAS DESTACADAS NA CLT:

***Art.102, §3º, CF/88:** No recurso extraordinário o recorrente deverá **demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso**, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços dos seus membros.*

***Art. 2º, Lei 11.418/06:** A Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 543-A e 543-B:*

***Art. 1.035, CPC/15.** O Supremo Tribunal Federal, em **decisão irrecorrível, não conhecerá** do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada **não tiver repercussão geral**, nos termos deste artigo.*

§ 1º Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.

§ 2º O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal.

§ 3º Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que:

*I - **contrarie** súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal;*

*II - tenha sido proferido **em julgamento de casos repetitivos**;*

*III - tenha **reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal**, nos termos do art. 97 da Constituição Federal.*

§ 4º O relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

§ 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.

§ 6º O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem, que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se sobre esse requerimento.

§ 7º Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6º caberá agravo, nos termos do art. 1.042.

*§ 7º Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6º ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá **agravo interno**.*

§ 8º Negada a repercussão geral, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobrestados na origem que versem sobre matéria idêntica.

§ 9º O recurso que tiver a repercussão geral reconhecida deverá ser julgado no prazo de 1 (um) ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus.

§ 10. Não ocorrendo o julgamento no prazo de 1 (um) ano a contar do reconhecimento da repercussão geral, cessa, em todo o território nacional, a suspensão dos processos, que retomarão seu curso normal.

§ 11. A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão.

■ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Por força do **Art. 93, IX, CF/88**, o Juiz é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos do processo. Ocorre que, na prática, muitos erros ocorrem, sendo prolatadas sentenças omissas, contraditórias ou obscuras que, por este motivo, são nulas.

Art. 93, CF/88

IX – Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

A **omissão** ocorre quando o Juiz deixa de se manifestar sobre algum ponto do processo, sobre algum pedido formulado.

A **contradição** ocorre quando o juiz conclui algo e decide diferente do que concluiu.

A **obscuridade** ocorre quando há pontos obscuros, ou seja, pontos na decisão de difícil compreensão.

A omissão, a contradição e a obscuridade são sanadas com os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, previstos no **Art. 897-A da CLT**, que devem ser opostos no prazo de cinco dias, a contar da intimação ou publicação da decisão.

Embargos de declaração **INTERROMPEM** o prazo recursal (**Art. 1.026, do CPC**) - aplicado ao processo do trabalho por força do **Art. 769/CLT**).

A interrupção ocorre independente de os embargos terem sido opostos pelo reclamante ou pelo reclamado.

Para oposição dos **ED não é necessário o depósito recursal, nem são**

devidas custas.

Quando os embargos de declaração forem opostos para suprir omissão, terão *efeitos modificativos*, que também são chamados de *efeitos infringentes*. Sempre que os embargos tiverem tais efeitos, obrigatoriamente o juiz deverá conceder prazo às partes para manifestação:

OJ n. 142, SDI-1, TST. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO MODIFICATIVO. VISTA À PARTE CONTRÁRIA. (inserido o item II à redação) – Res. 178/2012, DEJT divulgado em 13, 14 e 15.02.2012

I - É **passível de nulidade** decisão que acolhe embargos de declaração com efeito modificativo sem que seja concedida oportunidade de manifestação prévia à parte contrária.

II - Em decorrência do efeito devolutivo amplo conferido ao recurso ordinário, o item I não se aplica às hipóteses em que não se concede vista à parte contrária para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos contra sentença. Embargos de declaração para sanar contradição também possuem sempre efeitos modificativos.

Capítulo 22

AÇÕES POSSESSÓRIAS

1. PARA QUE SERVE UMA AÇÃO POSSESSÓRIA?

A ação possessória é o instrumento processual próprio para que se garanta a posse de determinado bem imóvel depois de o legítimo possuidor ter sido esbulhado, turbado ou ameaçado em sua posse. As ações possessórias típicas podem ser divididas em três, nos termos dos **arts. 927 e 932 do Código Civil**:

- a) Ação de reintegração de posse;
- b) Ação de manutenção de posse;
- c) Interdito proibitório.

A ação de **reintegração de posse** é a ação cabível quando há esbulho, ou seja, a perda da posse por parte do possuidor. Neste caso a posse foi perdida e o possuidor esbulhado a quer de volta, requerendo sua reintegração na posse, voltando a ser o possuidor do bem imóvel esbulhado.

A ação de **manutenção de posse** serve para evitar a perda da posse quando alguém está tentando retirar a posse do possuidor. Não conseguiu ainda, mas está turbando, perturbando a posse de alguém. O possuidor, no entanto, não precisa esperar a perda (esbulho) da posse para agir. Desde já poderá manejar ação de manutenção de posse a fim de se ver mantido na posse, evitando a sua perda.

Por fim, o **interdito proibitório** serve para interromper as ações de pessoas que estejam ameaçando a posse de outrem. Não houve nem perda (esbulho), nem turbação, mas alguém está, apenas, ameaçando tirar a posse do possuidor e esta ação visa cessar tais ameaças.

2. QUANDO CABEM AS AÇÕES POSSESSÓRIAS?

No Processo do Trabalho tais ações cabem por força do **inciso II do art. 114 da CF/88** que estabelece como competência da Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas ao exercício (em regra, abusivo) do direito de greve.

Assim, por exemplo, caso os grevistas com os ânimos inflamados pelo

sindicato de sua categoria profissional invadam a empresa a fim de forçarem o empregador a acatarem suas exigências, o empregador esbulhado da posse de sua empresa poderá manejar a ação de reintegração de posse, nos termos do **art. 560, do CPC/15**.

Caso os grevistas não tenham invadido ainda, mas estejam tentando invadir, turbando a posse do empregador de sua empresa com a escalada frustradas dos muros, tentativa frustrada de arrombamento dos portões da empresa, o empregador a fim de acabar com as tentativas e se manter na posse, manejará a ação de manutenção de posse, nos termos do **art. 560, do CPC/15**.

Por último, os grevistas nem invadiram e nem estão tentando invadir, mas estão ameaçando invadir caso as exigências dos grevistas não sejam cumpridas, o empregador com justo receio de vir a perder a posse, poderá se utilizar da ação de interdito proibitório a fim de parar as ameaças, nos termos do **art. 567, do CPC/15**.

O Supremo Tribunal Federal, através de sua **Súmula vinculante 25**, pacificou entendimento no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada.

3. REQUISITOS DA PETIÇÃO DE AÇÃO POSSESSÓRIA

Os requisitos da petição inicial de ação de uma ação possessória, eminentemente civil, mas cabível no processo do trabalho, são aqueles do **art. 319** e incisos e ainda **arts. 560 e 567 todos do CPC/15**:

Além desses requisitos, o **art. 561, do CPC/15** ainda esclarece que caberá ao autor provar: **I** – sua posse; **II** – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; **III** – a data da turbação ou do esbulho; **IV** – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse na ação de reintegração.



ATENÇÃO: nos casos ações de reintegração, manutenção de posse e interdito proibitório, a petição inicial deverá conter obrigatoriamente o pedido de cominação ao réu de determinada pena pecuniária, caso este continue as ameaças, nos termos do **art. 567 do CPC/15**.

3.1. Qualificação das partes

Na petição de ação possessória, ambas as partes devem ser qualificadas. A qualificação deve ser a prevista no **art. 319, CPC/15**, que dispõe que qualificar é identificar reclamante e reclamado através dos nomes, prenomes, estado civil, profissão e domicílio e residência. Qualquer outra informação é desnecessária⁷².

Nas ações possessórias, o autor é, em regra, o empregador ou terceiro esbulhado, turbado ou ameaçado. O reclamado pode ser tanto o sindicato que determinou a turbação, esbulho ou ameaça, quanto os trabalhadores, caso não sejam organizados em sindicatos. Na verdade, as partes dependerão muito da questão a ser elaborada.

3.2. O que devo alegar?

Saber o que alegar é a parte fundamental em qualquer peça processual. Numa petição inicial, todo pedido tem uma causa de pedir que lhe é correspondente sob pena de inépcia da petição **art.330, do CPC/15**.

As ações de reintegração, manutenção de posse e interdito proibitório devem conter necessariamente os requisitos previstos no **art. 561, do CPC/15** de modo que na petição inicial devem ser demonstradas:

I – a posse do autor: na petição inicial deve ser dito que o autor detém a posse (no caso de manutenção) ou que detinha a posse (no caso de reintegração) do bem imóvel. **Ex.:** “(...) que o autor era o possuidor do imóvel **tal** situado no endereço **tal** até que o réu o invadiu e lhe tomou a posse (...)”, ou ainda, “(...) que o autor é o possuidor do imóvel **tal** situado no endereço **tal**, mas o réu está tentando invadir (...)”, ou ainda, “(...) que o autor é o possuidor do imóvel **tal** situado no endereço **tal**, mas o réu está **ameaçando** sua posse(...)”;

II – a turbação, esbulho ou ameaça praticados pelo réu: devem ser narrados os atos praticados pelo réu de esbulho ou turbação. **Ex.:** “(...) que o réu invadiu o imóvel após a derrubada dos portões da empresa, lá se instalando e detendo a posse da mesma (...)”, ou ainda, “(...) que o réu está tentando invadir a empresa através da escalada de seus muros e derrubada dos portões (...)”, ou ainda, “(...) que o réu está ameaçando lhe tomar a posse da empresa através da escalada de seus muros e derrubada dos portões(...)”;

⁷² Vide espelhos de prova de todos os exames de ordem unificados OAB/FGV que podem ser obtidos em <http://oab.fgv.br>

III – a data da turbacão ou do esbulho ou ameacaa: “(...) que o réu esbulhou o autor da posse no dia **tal e tal** (...)”, ou ainda, “(...) que o réu está turbando sua posse no dia **tal e tal** (...)”; ou ainda, “(...) que o réu está **ameacando** turbar ou esbulhar sua posse no dia **tal e tal**(...)”;

IV – a continuacão da posse, embora turbada ou ameacada, na açao de manutencão ou interdito; a perda da posse na açao de reintegracão: aqui deve ser dito que o autor ainda está na posse ou que já a perdeu. **Ex.:** “(...) que apesar da tentativa de invasão da empresa, o autor ainda continua na posse da mesma (...)”, ou ainda, “(...) que apesar da **ameaca** de invasão da empresa, o autor ainda continua na posse da mesma (...)” ou ainda, “(...) que após a invasão da empresa o autor perdeu a posse da mesma(...)”.

Termine com a mençao dos fundamentos legais.

3.3. Tem liminar?

Sim, deve-se pedir a reintegracão, manutencão ou o mandado proibitorio em sede de liminar ou antecipacão de tutela, pois não é razoável que o réu espere o demorado curso normal do processo para ter sua posse de volta ou que cessem as turbacões ou ameacas. Quem está privado de sua posse a quer imediatamente. Assim, o **art. 562, do CPC/15** prevê expressamente a possibilidade de concessão de liminar pelo juiz mediante requerimento da parte interessada.

Deve-se demonstrar, em todo caso, a verossimilhança das alegaçoes e a irreversibilidade do dano caso o autor continue privado de sua posse ou sofrendo turbacão ou ameaca, nos termos do **art. 311, do CPC/15**.

3.4. Devo abrir um tópico para cada item pedido na açao possessória?

Sim. É importante (não obrigatório) que para cada tese a ser discutida na açao possessória exista um tópico correspondente, de modo a deixar a peça redigida bem organizada, o que facilitará a compreensao e correçao da mesma pelo examinador. As açoes possessórias, por serem açoes muito simples, praticamente com tese única, o ideal é que seja aberto o seguinte tópico: da turbacão ou do esbulho ou da ameaca.

Exemplo: **I – DO ESBULHO**. Nele, alegue que empregador detinha a posse da empresa, mas os empregados no dia 22.06.2014 escalaram os muros e derrubaram os portões, ocupando as dependências da empresa, esbulhando o empregador de sua posse.

Note que neste exemplo foram utilizados, de forma simplificada, todos os requisitos do **art. 561, do CPC/15**.

3.5. O que devo pedir numa ação possessória?

O primeiro pedido a ser feito numa ação possessória é seu **JULGAMENTO TOTALMENTE PROCEDENTE** que vale, em média, 0,40 (quarenta décimos). Deixar de fazer este pedido faz com que o examinando perca a referida pontuação. Em seguida, deve-se pedir:

- a) **Na ação de reintegração de posse:** a reintegração do autor na posse do imóvel (**art. 560 do CPC/15**);
- b) **Na ação de manutenção de posse:** a manutenção do autor na posse do imóvel (**art. 560 do CPC/15**);
- c) **No interdito proibitório:** que o juiz expeça mandado proibitório contra o réu para que cessem as ameaças de turbação ou esbulho, bem como seja cominada ao réu uma pena pecuniária no valor de R\$____, caso descumpra a decisão (**art. 567 do CPC/15**).

4. DEVO PEDIR OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA?

Não, pois aqui, em regra, o esbulhado, turbado ou ameaçado em sua posse é o empregador e portanto, sem qualquer presunção de pobreza, a não ser que a proposta (enunciado) da questão assim o diga.

Capítulo 23

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Todo recurso passa pelos juízos de admissibilidades, onde são analisados os pressupostos intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Em ambos os juízos, são analisados os pressupostos intrínsecos e extrínsecos.

Quando a parte ganha o recurso, diz-se que *houve provimento* ao recurso (recurso provido, sentença reformada); se a parte perde, diz-se que *não houve provimento* ao recurso (recurso improvido, decisão mantida).

1º Juízo de Admissibilidade: <i>a quo</i>	2º Juízo de Admissibilidade: <i>ad quem</i>
Decisão interlocutória da qual, em regra, não cabe recurso.	
Seguimento	✓ Conhecimento ✓ Confirmação da presença dos requisitos.
Não seguimento (ou decisão de trancamento ou decisão de não admissão ou decisão que negou interposição)	✓ Não conhecimento

Da decisão que dá seguimento ao recurso, não cabe recurso, exceto embargos de declaração, conforme **art. 897-A, CLT**.

Da decisão do primeiro juízo de admissibilidade que nega seguimento ao recurso, cabe agravo de instrumento (**art. 897, CLT**)

O agravo de instrumento, no processo do trabalho, somente tem a finalidade de **destrancar recurso**.

ATENÇÃO!!! **GRIFAR** AS PALAVRAS **DESTACADAS** NA CLT:

Art. 897, CLT. Cabe agravo, no prazo de oito dias:

b) de instrumento, dos despachos que denegarem a interposição de recursos.

Das decisões do relator que dão conhecimento ao recurso não cabe recurso.

Das decisões do relator que negam conhecimento ao recurso cabe **AGRAVO DE REGIMENTO (arts. 235 e 239/RI-TST)**:

Art. 235, REGIMENTO INTERNO DO TST. *Cabe agravo regimental, no prazo de oito dias, para o Órgão Especial, Seções Especializadas e Turmas, observada a competência dos respectivos órgãos, nas seguintes hipóteses:*

*I- do despacho do Presidente do Tribunal que **denegar seguimento aos embargos infringentes**;*

*II- do despacho do Presidente do Tribunal que **suspender** execução de liminares ou de decisão concessiva de mandado de segurança;*

III- do despacho do Presidente do Tribunal que conceder ou negar suspensão da execução de liminar, antecipação de tutela ou da sentença em cautelar;

IV- do despacho do Presidente do Tribunal concessivo de liminar em mandado de segurança ou em ação cautelar;

V - do despacho do Presidente do Tribunal proferido em pedido de efeito suspensivo;

VI - das decisões e despachos proferidos pelo Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho;

VII- do despacho do Relator que negar prosseguimento a recurso, ressalvada a hipótese do Art. 239, VIII - do despacho do Relator que indeferir inicial de ação de competência originária do Tribunal; e

*IX - do despacho ou da decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma, do Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho ou Relator que **causar prejuízo ao direito da parte**, ressalvados aqueles contra os quais haja recursos próprios previstos na legislação ou neste Regimento.*

Art. 239, REGIMENTO INTERNO DO TST. *Caberá agravo ao órgão colegiado competente para o julgamento do respectivo recurso, no prazo de oito dias, a contar da publicação no órgão oficial:*

I - da decisão do Relator, tomada com base no § 5.º do art. 896 da CLT;

II - da decisão do Relator, dando ou negando provimento ou negando seguimento a recurso, nos termos do art. 557 e § 1.º-A do CPC.

Exemplos: decisão que nega requerimento de realização de perícia é decisão interlocutória, não cabendo, em regra, recurso. Mas, em se tratando de ato de autoridade contra direito líquido e certo, cabe MS. (*Atenção! MS é ação e não recurso!*) Já no Tribunal, o relator nega a liminar no MS. Trata-se de mais uma decisão interlocutória. Neste caso, de decisão interlocutória que nega (indefere) liminar, cabe agravo.

Em relação ao MS, a **súmula 418 do TST** diz que o juiz não é obrigado a conceder liminar, não cabendo direito líquido e certo, logo, não sendo possível a interposição de MS.

SUM-418, TST. *A concessão de liminar ou a homologação de acordo constituem faculdade do juiz, **inexistindo direito líquido e certo tutelável pela via do mandado de segurança.***

No entanto, se o juiz conceder a liminar quando não há direito líquido e certo a ser protegido, caberá MS contra o ato do juiz que concedê-la:

OJ-64, SDI-2, TST. *Não fere direito líquido e certo a concessão de tutela antecipada para reintegração de empregado protegido por estabilidade provisória decorrente de lei ou norma coletiva.*

Se, no caso da OJ acima, fizermos o raciocínio contrário, veremos que se o empregado NÃO tem direito à estabilidade e, ainda assim, o juiz conceder a liminar pela reintegração, haverá ferimento ao direito líquido e certo do empregador, que tem a faculdade de rescindir o contrato de trabalho.

Art. 897, CLT

§5º *Sob pena de não conhecimento, as partes promoverão a formação do instrumento do agravo de modo a possibilitar, caso provido, o imediato julgamento do recurso denegado, instruindo a petição de interposição:*

I – obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada, da certidão da respectiva intimação, das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado, da petição inicial, da contestação, da decisão originária, da comprovação do depósito recursal e do recolhimento das custas;

II – facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis ao deslinde da matéria de mérito controvertida.

O valor do depósito recursal do agravo de instrumento, hoje, é o valor de 50% do valor do depósito do recurso que se pretende destrancar.

Art. 899, CLT

§7º *No ato de interposição do agravo de instrumento, o depósito recursal corresponderá a **50% (cinquenta por cento) do valor do depósito** do recurso ao qual se pretende destrancar (acrescentado pela Lei 12.275/10).*

Capítulo 24

EXECUÇÃO

Para que serviria a sentença se não tivéssemos a execução? Se não houvesse procedimento no sentido de forçar o devedor a pagar, a sentença não serviria para nada.

Temos dois tipos de execução: a definitiva e a provisória.

A execução definitiva, de acordo com o **art. 876 da CLT**, é aquela que parte de uma decisão transitada em julgado. Já a execução provisória é aquela que parte de uma decisão ainda não transitada em julgado.

A execução provisória existe para dar mais celeridade ao processo, pois havendo recursos, o processo sobe fisicamente, podendo ser o mesmo adiantado na horizontal, ou seja, podendo ser dada continuidade a ele enquanto os recursos são decididos.

Os recursos trabalhistas, em regra, não detêm efeito suspensivo (**art. 899, CLT**). É por isso que se permite a execução provisória. No entanto, a execução provisória só alcança os atos constritivos. Logo, em regra, a execução provisória não permite os atos expropriatórios, que somente serão realizados na execução definitiva.

A execução provisória deve ser feita enquanto o processo ainda está em curso. Havendo recurso, fisicamente o processo sobe para instância superior, devendo ser feita a chamada **extração de carta de sentença**, a fim de tornar possível a continuidade da execução provisória.

A petição de extração de carta de sentença é endereçada ao Juiz da Vara, requerendo que, tendo em vista que o recurso não tem efeito suspensivo, seja dado início à execução provisória, devendo ser juntados três documentos, quais sejam: cópia da sentença, cópia das procurações dos advogados e certidão do Tribunal informando que o recurso não foi recebido no efeito suspensivo.

ATENÇÃO!!! **GRIFAR** AS PALAVRAS **DESTACADAS** NA CLT:

Art. 522, CPC. O cumprimento provisório da sentença será requerido por petição dirigida ao juízo competente.

Parágrafo único. Não sendo eletrônicos os autos, a petição será acompanhada de cópias das seguintes peças do processo, cuja autenticidade poderá ser certificada pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal:

I - decisão exequenda;

II - certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo;

III - procurações outorgadas pelas partes;

IV - decisão de habilitação, se for o caso;

V - facultativamente, outras peças processuais consideradas necessárias para demonstrar a existência do crédito.

De acordo com o **Art. 876 da CLT**, o título executivo de uma execução provisória é uma decisão não transitada em julgado. Já os títulos executivos da execução definitiva são: decisão transitada em julgado, sentença homologatória de acordo descumprido, TAC (termos de ajustamento de conduta) e acordo não cumprido assumidos em CCP (comissão de conciliação prévia)

Art. 876, CLT. *As decisões passadas em julgado ou das quais não tenha havido recurso com efeito suspensivo; os acordos, quando não cumpridos; os termos de ajuste de conduta firmados perante o Ministério Público do Trabalho e os termos de conciliação firmados perante as Comissões de Conciliação Prévia serão executados pela forma estabelecida neste Capítulo.*

Parágrafo único. *A Justiça do Trabalho executará, de ofício, as contribuições sociais previstas na alínea a do inciso I e no inciso II do caput do art. 195 da Constituição Federal, e seus acréscimos legais, relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e dos acordos que homologar.*

A sentença é líquida quando o juiz define o valor da condenação. Nela, o título executivo está pronto para ser executado, exigido.

A sentença ilíquida é aquela em que o valor estipulado é geral, global, sem dados numéricos específicos. Nesses casos, a sentença deve ser liquidada, podendo ser a liquidação por cálculo, arbitramento ou artigo, em conformidade com o **art. 879 da CLT**:

Art. 879, CLT. *Sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á, previamente, a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos.*

§ 1º-A. A liquidação abrangerá, também, o cálculo das contribuições previdenciárias devidas.

§ 1º-B. As partes deverão ser previamente intimadas para a apresentação do cálculo de liquidação, inclusive da contribuição previdenciária incidente

Uma vez elaborados os cálculos, tem-se a chamada *conta de liquidação*, que são os cálculos elaborados para se chegar aos valores de cada parcela da condenação.

Elaborada a conta e tornada líquida, o juiz DEVERÁ abrir prazo de 08 dias comuns para as partes se manifestarem a respeito dos cálculos. Se o fizer e as partes

não se manifestarem, dar-se-á a preclusão e não poderá ser haver questionamento dos cálculos em embargos de execução. Se, no entanto, o juiz homologar a conta sem abrir prazo às partes, pode a parte impugnar os cálculos nos embargos.

Art. 879, §2º, CLT. *Elaborada a conta e tornada líquida, o Juiz abrirá às partes prazo comum de oito dias para impugnação fundamentada com a indicação dos itens e valores objeto da discordância, sob pena de preclusão.*

O prazo para manifestação da União, diferente do que ocorre para as partes, é obrigatório:

Art. 879, §3º, CLT. *Elaborada a conta pela parte ou pelos órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho, o juiz procederá à intimação da União para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.*

A liquidação, por mais absurda que seja a decisão, deverá ser feita nos seus exatos termos.

Art. 879, §1º, CLT. *Na liquidação, não se poderá modificar, ou inovar, a sentença liquidanda, nem discutir matéria pertinente à causa principal.*

Homologada a liquidação da sentença, ter-se-á um título executivo líquido, certo e exigível. Nesse momento, inicia-se o processo de execução, com a expedição do *mandado de execução*, conforme **art. 880, CLT**.

O mandado de execução conterá:

1. Cópia da decisão
2. Citação do devedor
3. Intimação para pagar em 48h
4. Nomeação de bens em 48h
5. Penhora de tantos bens quantos bastem para a garantia do juízo.

Art. 880, CLT. *Requerida a execução, o juiz ou presidente do tribunal mandará expedir mandado de citação do executado, a fim de que cumpra a decisão ou o acordo no prazo, pelo modo e sob as cominações estabelecidas ou, quando se tratar de pagamento em dinheiro, inclusive de contribuições sociais devidas à União, para que o faça em 48 (quarenta e oito) horas ou garanta a execução, sob pena de penhora.*

§1º *O mandado de citação deverá conter a decisão exequenda ou o termo de acordo não cumprido.*

§2º A citação será feita pelos oficiais de justiça.

§3º Se o executado, procurado por duas vezes no espaço de quarenta e oito horas, não for encontrado, far-se-á citação por edital, publicado no jornal oficial ou, na falta deste, afixado na sede da Junta ou Juízo, durante cinco dias.

No **art. 882 da CLT** é estabelecido que a nomeação de bens à penhora deve observar a ordem preferencial dos bens indicados conforme **art. 835 do CPC**:

Art. 882, CLT. *O executado que não pagar a importância reclamada poderá garantir a execução mediante **depósito da quantia correspondente**, atualizada e acrescida das despesas processuais, apresentação de seguro-garantia judicial ou nomeação de bens à penhora, observada a ordem preferencial estabelecida no art. 835 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil.*

Art. 835. *A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:*

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.



Cuidado! Tanto na execução definitiva quanto na provisória o executado é obrigado a obedecer à ordem do **art. 835 do CPC**. Assim, se forem nomeados bens outros que não dinheiro em espécie ou carta de fiança bancária, o juiz poderá ignorar a nomeação e determinar o bloqueio na conta bancária do executado. Dessa decisão não cabe mandado de segurança.

É a inteligência da **súmula 417, I TST**:

SUM-417, TST. MANDADO DE SEGURANÇA. PENHORA EM DINHEIRO

I - Não fere direito líquido e certo do impetrante o ato judicial que determina penhora em dinheiro do executado para garantir crédito exequendo, pois é prioritária e obedece à gradação prevista no art. 835 do CPC de 2015 (art. 655 do CPC de 1973).

Se no prazo estipulado de 48h. o executado não pagou nem nomeou bens a penhora, o oficial de justiça prosseguirá à penhora compulsória, devendo observar o

art. 833, CPC/15:

Art. 833. São impenhoráveis:

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

VI - o seguro de vida;

VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;

XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.

Pergunta: Salários podem ser penhorados?

OJ-SDI2-153, TST. Ofende direito líquido e certo decisão que determina o bloqueio de numerário existente em conta salário, para satisfação de crédito trabalhista, ainda que seja limitado a determinado percentual dos valores recebidos ou a valor revertido para fundo de aplicação ou poupança, visto que o art. 649, IV, do CPC contém norma imperativa que não admite interpretação ampliativa, sendo a exceção prevista no art. 649, § 2º, do CPC espécie e não gênero de crédito de natureza alimentícia, não englobando o crédito trabalhista.

Resposta: Não. E da decisão cabe MS.

Contados da penhora o executado tem 05 dias para interpor embargos à execução. Se o executado for a Fazenda Pública, o prazo é de 30 dias, contados do

mandado de citação, pois da Fazenda não é possível penhorar bens. Tal prazo é para embargos de execução (ação do devedor) ou para impugnação da liquidação (ação do credor).

Art. 884, CLT. Garantida a execução ou penhorados os bens, terá o executado cinco dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exequente para a impugnação.

Nos embargos à execução pode ser alegado:

Art. 884, CLT.

§1º A matéria de defesa será restrita às alegações de cumprimento da decisão ou do acordo, quitação ou prescrição da dívida.

Da decisão que julgar os embargos cabe **agravo de petição** no prazo de 05 dias para o TRT. Julgado o agravo de petição, a regra é que no processo de execução, NÃO cabe recurso de revista, salvo em se tratando de matéria constitucional, ou seja, se houver afronta à CF.

Art. 896, CLT

§2º Das decisões proferidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho ou por suas Turmas, em execução de sentença, inclusive em processo incidente de embargos de terceiro, não caberá Recurso de Revista, salvo na hipótese de **ofensa direta e literal de norma de Constituição Federal**.

SUM-266, TST. A admissibilidade do recurso de revista interposto de acórdão proferido em **agravo de petição**, na liquidação de sentença ou em processo incidente na execução, inclusive os embargos de terceiro, depende de **demonstração inequívoca de violência direta à Constituição Federal**.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Com a reforma trabalhista, a prescrição intercorrente está prevista no art. 11-A da CLT e trata-se da prescrição que ocorre no curso do processo de execução quando o credor não movimenta o processo por mais de **02 anos** contados a partir do momento em que o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução.

A prescrição intercorrente pode ser conhecida de ofício ou a requerimento da parte, em qualquer grau de jurisdição, nos termos do §2º do art. 11-A da CLT.

EXECUÇÃO DEFINITIVA

- decisão judicial transitada em julgado
- sentença homologatória de acordo descumprida
- termo de ajustamento de conduta (TAC)
- acordo em comissão de conciliação prévia (CCP)
- Promovida pelas partes (art. 878 da CLT)
- de ofício pelo juiz ou pelo presidente do Tribunal só quando não tiver representado por advogado.

EXECUÇÃO PROVISÓRIA

- decisão NÃO transitada em julgado (Não tem expropriação, só vai até a penhora)
- Art. 899, *caput* da CLT
- Arts. 521 e 522 do CPC
- Art. 893, §2º da CLT

Embargos à execução

Sentença

Agravo de petição

Art. 897, 'a' da CLT

Acórdão

Recurso de Revista

Art. 896, p.2º, CLT

Acórdão

Ação do credor

O credor não precisa garantir o juízo, porém, só pode fazer a impugnação se o devedor garantir o juízo

Recurso Extraordinário

Art. 102, III, 'a' da CF

- cálculos (Regras aritméticas) OU
- arbitramento (Perito) OU
- artigos (SEMPRE acompanhada da expressão PROVA DO FATO NOVO)

Encontrar valores.

Não discute mérito.

Liquidação

Art. 879, §1º-B da CLT

vem acompanhada da expressão PROVA DO FATO NOVO

Regras: oficial de justiça

Procurado 2x em 48h = edital

- citação do devedor

- cópia da decisão

- intimação para pagar em 48h (art. 881 da CLT)

- nomeação de bens à penhora em 48h (art. 835 do CPC e Sum. 417 do TST)

- penhora forçada (Penhora de tantos bens quantos bastem para a garantia do juízo) (art. 833 do CPC)

NÃO PRECISA GARANTIR O JUÍZO:

- Entidades filantrópicas
- Fazenda Pública
- Empresas em recuperação judicial
- Empresas falidas

Art. 884, §6º da CLT
Sum. 86 do TST

Conta de liquidação

Discriminado parcelas e valores

Intimação

Juiz é obrigado a abrir prazo

Partes

Credor

Devedor

08 dias (prazo comum)

Obrigatório

Art. 879, §2º da CLT

União

Obrigatório

Art. 879, §3º da CLT

Sentença homologatória de cálculos

Mandado de execução

Execução começa aqui. Antes é fase de liquidação!

Art. 880 da CLT

IRRECORSÍVEL

Sum. 298, IV do TST

Sum. 399, II do TST

Pode Ação Rescisória

Prazo de 5 dias, com exceção da Fazenda Pública que é de 30 dias e começa a partir da citação

